

DIGESTO

BIENES

MANUAL DE ESTUDIO · NIVEL EXAMEN DE GRADO

Elaborado por **Laura Schultz Solano**

Texto refundido a partir de los apuntes de Cristián Boetsch Gillet, jurisprudencia seleccionada y comparaciones doctrinales · Borrador en construcción, pendiente de revisión

Índice

A. Conceptos generales y clasificaciones de los bienes

1. Introducción
2. Cosa y bien
3. Regulación
4. Bienes corporales e incorporeales
 - a. Concepto
 - b. Críticas a esta clasificación
 - c. Importancia y aplicación práctica de esta clasificación
 - d. Bienes incorporeales
 - e. Bienes corporales
5. Bienes muebles e inmuebles
 - a. Conceptos generales
 - b. Importancia de la clasificación
 - c. Bienes (corporales) muebles
 - d. Bienes (corporales) inmuebles
 - e. Bienes incorporeales (derechos) muebles e inmuebles
6. Bienes consumibles y no consumibles
 - a. Clases de consumibilidad
 - b. Bienes deteriorables y corruptibles
7. Bienes fungibles y no fungibles
 - a. Concepto y fungibilidad objetiva y subjetiva
 - b. Consumibilidad, fungibilidad y cosas genéricas
 - c. Importancia de esta clasificación
8. Bienes principales y accesorios
 - a. Factores para determinar lo principal y lo accesorio
 - b. Importancia de la clasificación
9. Bienes divisibles e indivisibles
 - a. Divisibilidad de los derechos
10. Bienes singulares y bienes universales
 - a. Las universalidades
11. Bienes presentes y futuros
12. Bienes comerciables e in comerciables

- a. Clasificación de los bienes inmerciables

- 13. Bienes apropiables e inapropiables

- a. Bienes apropiados e inapropiados
- b. Bienes susceptibles e insusceptibles de apropiación por particulares

- 14. Bienes privados y públicos (o nacionales)

- a. Bienes nacionales de uso público
- b. Bienes fiscales

- B. El dominio

- 1. Consideraciones preliminares

- 2. Concepto legal del dominio

- 3. Bases constitucionales del dominio

- 4. Caracteres

- a. Real
 - b. Absoluto
 - c. Abuso del derecho
 - d. Exclusivo
 - e. Perpetuo
 - f. Abstracto
 - g. Elástico

- 5. Facultades (o atributos)

- a. Facultad de uso
 - b. Facultad de goce
 - c. Facultad de disposición

- 6. Estipulaciones limitativas de la facultad de disposición ("cláusulas de no enajenar")

- a. Argumentos a favor de la validez
 - b. Argumentos en contra de la validez
 - c. Posición intermedia y jurisprudencia
 - d. Contenido y efectos de la cláusula

- 7. Clasificaciones del derecho de propiedad

- 8. Aspectos pasivos del derecho de propiedad

- a. Las obligaciones reales
 - b. Las cargas reales
 - c. Responsabilidad por la propiedad

9. La extinción del dominio

- a. Modos de extinción absolutos
- b. Modos de extinción relativos

C. La copropiedad

1. Terminología

2. Naturaleza jurídica

- a. Doctrina romana
- b. Doctrina germánica

3. La comunidad en el Código Civil chileno

- a. Naturaleza jurídica de la comunidad
- b. Regulación

4. Fuentes de la indivisión

5. Clases de indivisión

- a. Según el objeto sobre el que recae
- b. Según su origen
- c. Según su duración

6. La cuota

7. Administración de la comunidad

- a. Administración sin acuerdo ni administrador designado
- b. Administración por medio de un administrador proindiviso

8. La coposesión

9. La copropiedad inmobiliaria

10. Extinción de la comunidad

D. Los modos de adquirir: aspectos generales y la ocupación

1. Sistemas de adquisición del dominio

- a. Sistema de la dualidad título-modo
- b. Sistema consensual
- c. Sistema del Código Civil chileno

2. Reserva legal y enumeración

3. Clasificaciones

- a. Originarios y derivativos
- b. A título universal y a título singular
- c. Por acto entre vivos y por causa de muerte

d. A título gratuito y a título oneroso

4. **Ámbito de aplicación**
5. **Se puede adquirir por un solo modo**
6. **La exigencia del título en todos los modos de adquirir**
7. **Concepto de la ocupación**
8. **Elementos**
9. **Requisitos**
10. **Reglas particulares**
 - a. **Ocupación de cosas animadas**
 - b. **Ocupación de cosas inanimadas**
 - c. **Especies muebles al parecer perdidas y especies náufragas**

E. **La accesión**

1. **Concepto**
2. **Clases de accesión**
3. **Naturaleza jurídica**
4. **Accesión discreta o de frutos**
 - a. **Concepto**
 - b. **Frutos y productos**
 - c. **Clases de frutos**
 - d. **El dominio de los frutos**
5. **Accesión continua**
 - a. **Accesión de inmueble a inmueble**
 - b. **Accesión de mueble a mueble**
 - c. **Accesión de mueble a inmueble**

F. **La tradición: descripción general, requisitos y efectos**

1. **Concepto**
2. **Caracteres**
 - a. **Es un modo de adquirir derivativo**
 - b. **Es una convención**
 - c. **Es consecuencia de un título**
 - d. **Por regla general, es un modo de adquirir a título singular**
 - e. **Sirve de justo título para prescribir**
3. **Aplicación**
4. **Entrega y tradición**

5. Presencia de dos personas: tradente y adquirente
 - a. Facultad y capacidad de las partes
 - b. Tradición y pago
 6. Consentimiento de ambas partes
 - a. Aspectos generales
 - b. Reglas sobre el error
 - c. Tradición por representantes
 - d. Consentimiento en las ventas forzadas
 7. Título traslativo de dominio
 - a. Concepto
 - b. El título debe ser válido
 - c. El conflicto teórico con la noción de contrato real
 8. Entrega
 9. Efectos de la tradición, cuando el tradente es dueño de la cosa que entrega
 10. Efectos de la tradición, cuando el tradente no es dueño pero tiene otros derechos
 11. Efectos de la tradición, cuando el tradente no es dueño
 12. Efectos particulares
 - a. Retroactividad
 - b. Época para exigir la tradición
 - c. Tradición sujeta a modalidades
- G. La tradición de derechos reales sobre muebles
1. Aspectos generales
 2. Tradición real
 3. Tradición de muebles conforme al art. 684
 - a. Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente (art. 684 N° 1)
 - b. Mostrándosela (art. 684 N° 2)
 - c. Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar en que esté guardada la cosa (art. 684 N° 3)
 - d. Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido (art. 684 N° 4)
 - e. Tradición por breve mano (art. 684 N° 5, primera parte)
 - f. Constituto posesorio (art. 684 N° 5, segunda parte)
 - g. Otras formas de tradición ficta
 4. Principio que rige las diversas tradiciones fictas
 5. Prueba de la tradición

6. Tradición de muebles por anticipación

7. Taxatividad de las formas fictas

8. Valor comparativo

9. Tradición de muebles registrables

H. La tradición de derechos reales sobre inmuebles: el sistema registral

1. Introducción

2. Aspectos generales de los sistemas registrales

a. Fundamentos del sistema registral

b. Tipos de registros

3. El sistema registral chileno

a. El Registro Conservatorio de Bienes Raíces

b. Principios en los que se funda el sistema registral chileno

c. Títulos que deben inscribirse y títulos que pueden inscribirse

d. Modo de proceder a las inscripciones, su forma y solemnidad

e. Obligación de inscribir y causales de negativa

f. Plazo para inscribir

g. Inscripción de inmuebles que no han sido antes inscritos

h. Inscripción de títulos anteriores a la vigencia del Reglamento

i. Confección y contenido de las inscripciones

j. Subinscripciones

k. Cancelaciones

l. Reinscripciones

m. Sanción por defectos de la inscripción

n. Saneamiento de títulos

o. Problemas del sistema registral chileno

4. Tradición de derechos reales sobre inmuebles

5. Tradición de cuotas

a. Cuota en cosa singular

b. Cuota en cosa universal

6. Inscripciones a que da lugar la sucesión por causa de muerte

a. El art. 688 del Código Civil

b. Sanción por infracción al art. 688 del Código Civil

7. La inscripción en la prescripción

I. La tradición del derecho real de herencia y de los derechos personales

1. Momento a partir del cual es posible realizar la tradición de la herencia
2. Forma de efectuar la tradición del derecho de herencia
3. Forma de efectuar la tradición del derecho a un legado
4. El art. 688 y la tradición de los derechos de herencia y legado
 - a. En cuanto a la herencia
 - b. En cuanto al legado
5. Tradición de créditos personales
6. Tradición de derechos litigiosos

J. La posesión: aspectos generales

1. Introducción
2. Definición y elementos
3. Naturaleza jurídica
4. La posesión en su relación con el dominio
5. Mera tenencia
6. Ventajas de la posesión
7. Cosas susceptibles de posesión
8. Cosas no susceptibles de posesión
9. ¿Pueden poseerse los derechos personales?

K. Clases de posesión

1. Generalidades
2. Posesión regular
 - a. Concepto
 - b. Primer elemento: el justo título
 - c. Segundo elemento: la buena fe
 - d. Tercer elemento: la tradición
 - e. Ventajas de la posesión regular
3. Posesión irregular
 - a. Concepto
 - b. Paralelo entre la posesión regular e irregular
4. Posesiones viciosas
 - a. Clases
 - b. Utilidad de la posesión viciosa

L. La mera tenencia; transmisibilidad, agregación e interversión de la posesión

1. La mera tenencia

- a. Concepto
 - b. Fuentes de la mera tenencia
 - c. Características
 2. ¿Es la posesión transmisible y/o transferible?
 - a. En cuanto a la transmisión
 - b. En cuanto a la transferencia
 3. Agregación de la posesión
 - a. Concepto
 - b. Posesiones contiguas
 4. La interversión de la posesión
 - a. Concepto
 - b. Mutación de la mera tenencia en posesión
 - c. Transformación del poseedor en mero tenedor
- M. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión de bienes muebles
1. Observaciones generales
 - a. Capacidad para adquirir la posesión
 - b. Adquisición de la posesión por intermedio de otro
 2. Principio básico de la adquisición de la posesión
 3. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión de bienes muebles
 - a. Adquisición
 - b. Conservación
 - c. Pérdida
- N. La posesión inscrita: aspectos generales y régimen de los inmuebles no inscritos
1. Aspectos generales
 - a. La posesión de inmuebles en el Mensaje del Código Civil
 - b. Diferencias con la posesión de bienes muebles
 - c. Problemas que presenta la materia
 - d. Doctrinas antagónicas sobre la posesión de los inmuebles
 - e. Jurisprudencia
 2. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión de inmuebles no inscritos
 - a. Adquisición
 - b. Conservación y pérdida
- O. Adquisición, conservación y pérdida de la posesión de inmuebles inscritos

1. Adquisición

a. Tradición

2. Conservación y pérdida

- a. Por voluntad de las partes
- b. Por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho
- c. Cancelación por una nueva inscripción desconectada de la anterior: el art. 730
- d. Por decreto judicial

P. Prueba de la posesión

- 1. Prueba de la posesión de los muebles
- 2. Prueba de la posesión de los inmuebles

Q. La prescripción adquisitiva: nociones generales, fundamento, características y reglas comunes

- 1. Nociones generales
- 2. Fundamento de la prescripción
- 3. Características de la prescripción adquisitiva
 - a. Es un modo de adquirir originario
 - b. Permite adquirir el dominio de toda clase de bienes que puedan poseerse
 - c. Es un modo de adquirir a título singular
 - d. Es un modo de adquirir a título gratuito y por acto entre vivos
- 4. Reglas comunes a toda prescripción
 - a. Debe ser alegada
 - b. No puede renunciarse anticipadamente
 - c. Las reglas son iguales para todas las personas

R. Elementos de la prescripción adquisitiva: cosa susceptible de prescripción y la posesión

- 1. Primer elemento: cosa susceptible de prescripción
 - a. Regla general
 - b. Excepciones: cosas no susceptibles de ser adquiridas por prescripción
 - c. ¿Puede haber posesión sin prescripción?
 - d. Prescripción entre comuneros

2. Segundo elemento: la posesión

S. Tercer elemento de la prescripción adquisitiva: el transcurso del tiempo

- 1. Adquisición por prescripción del derecho real de dominio
 - a. Prescripción adquisitiva ordinaria
 - b. Prescripción adquisitiva extraordinaria

c. Adquisición por prescripción de los otros derechos reales

T. Interrupción, suspensión y efectos de la prescripción adquisitiva

1. Cuarto elemento: la prescripción no debe encontrarse interrumpida

- a. Conceptos generales
- b. Interrupción natural
- c. Interrupción civil

2. Quinto elemento: la prescripción no debe encontrarse suspendida

- a. Concepto y fundamento
- b. Aspectos generales
- c. Causales de suspensión
- d. Suspensión entre cónyuges

3. Prescripción contra título inscrito

4. La adquisición del dominio por la prescripción

5. Efecto liberatorio de la prescripción

6. La función de la sentencia en materia de prescripción

U. La sucesión por causa de muerte como modo de adquirir

- 1. Ideas generales
- 2. Apertura de la sucesión y delación de las asignaciones
- 3. El derecho de herencia

V. La propiedad fiduciaria

- 1. Definición y origen
- 2. Constitución del fideicomiso
- 3. Elementos
 - a. Una cosa susceptible de darse en fideicomiso
 - b. Concurrencia de tres personas
 - c. Existencia de una condición
- 4. Efectos del fideicomiso
 - a. Derechos y obligaciones del fiduciario
 - b. Derechos y obligaciones del fideicomisario

5. Extinción del fideicomiso

W. El usufructo, el uso y la habitación

- 1. Concepto
- 2. Características

- a. Es un derecho real
- b. Es un derecho real sobre cosa ajena
- c. Confiere la mera tenencia de la cosa fructuaria
- d. Es temporal
- e. Es intransmisible por causa de muerte
- f. En principio, es divisible

3. Elementos

- a. Bien susceptible de usufructo
- b. Concurrencia de tres sujetos
- c. El plazo

4. Constitución

- a. Por ley
- b. Por voluntad del propietario
- c. Por prescripción
- d. Por sentencia judicial

5. Efectos

- a. Derechos del usufructuario
- b. Obligaciones del usufructuario
- c. Derechos del nudo propietario
- d. Obligaciones del nudo propietario

6. Extinción

7. El uso y la habitación

- a. Concepto
- b. Principales aspectos

X. Las servidumbres

1. Concepto

2. Elementos

- a. Dos predios de distinto dueño
- b. Un gravamen

3. Características

4. Clasificación

- a. Según su origen
- b. Según sus señales de existencia
- c. Según su ejercicio

d. Según su objeto o carácter

5. Ejercicio del derecho de servidumbre

6. Clases de servidumbres según su origen

a. Servidumbres naturales

b. Servidumbres legales

c. Servidumbres voluntarias

7. Derechos y obligaciones de los dueños de los predios

8. Extinción de las servidumbres

9. Excurso: el derecho real de conservación

Y. Las acciones protectoras: formas de protección y acción reivindicatoria

1. Diversas formas de protección

a. Medidas generales de protección del dominio

b. Medidas de protección en el derecho privado

2. Concepto de la acción reivindicatoria

3. Requisitos

a. Que se trate de una cosa susceptible de reivindicarse

b. Que el reivindicante sea dueño de la cosa

c. Que el reivindicante esté privado de su posesión de la cosa

4. Contra quién se dirige la acción

a. Contra el actual poseedor

b. Contra el poseedor que dejó de poseer

c. Contra el injusto detentador

5. Extinción por prescripción

6. Medidas precautorias

7. Prestaciones mutuas

a. Prestaciones del poseedor vencido al reivindicante

b. Prestaciones del reivindicante al poseedor vencido

c. Liquidación de las prestaciones

d. Derecho legal de retención

Z. Las acciones posesorias

1. Aspectos generales

a. Concepto

b. Características

- c. Diferencias con la acción reivindicatoria
 - d. Requisitos
 - e. Prueba
- 2. Análisis particular de las diversas acciones posesorias
 - a. Querella de amparo
 - b. Querella de restitución
 - c. Querella de restablecimiento
 - d. Otras acciones

A. CONCEPTOS GENERALES Y CLASIFICACIONES DE LOS BIENES

1. INTRODUCCIÓN

El Derecho de Bienes (también denominado *Derecho de Cosas* y/o *Derechos Reales*) tiene por objeto el estudio de las normas jurídicas que regulan a los objetos: determinar su concepto, clasificarlos según su naturaleza material y otros factores, analizar el poder que se puede tener sobre ellos, establecer los modos de lograr esa potestad y decidir la protección que a ese poder adquirido se confiere.

Conviene distinguir el campo del Derecho de Bienes del Derecho de Obligaciones. Mientras el Derecho de Obligaciones regula el intercambio de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de los individuos, la materia jurídica de los derechos reales, primero, fija o radica los bienes en el patrimonio de cada individuo, y segundo, determina los poderes o facultades que el sujeto tiene sobre ellos.

2. COSA Y BIEN

En doctrina se discute el sentido y alcance de los conceptos de cosa y bien, cuestión que no resuelve el Código Civil. Buena parte de la doctrina estima que, jurídicamente, cosa es todo lo que forma parte del mundo exterior y sensible (cosas materiales), y también todo aquello que, sin representación exterior ni percepción por los sentidos, sí puede percibirse con la inteligencia (cosas inmateriales). Así, **ROZAS** señala que *cosa es todo lo que es relevante o tomado en cuenta por la ley y que pueda ser objeto de relaciones jurídicas*.

Las características de la noción jurídica de cosa serían: (a) debe ser extraña al sujeto, pues la cosa se contrapone a la persona, como objeto se contrapone a sujeto; (b) debe tener relevancia jurídica, esto es, posibilidad de ser objeto de relaciones jurídicas; (c) la noción de cosa es independiente de la de apropiabilidad por un sujeto, por ejemplo los metales de una mina inexplorada; y (d) las cosas pueden ser presentes o futuras.

Parte de la doctrina asocia el concepto de bien a aquellas cosas que presentan un interés o utilidad para un sujeto. **ALESSANDRI** señala que la etimología de la palabra bienes delata el carácter útil de las cosas que el Derecho considera: proviene del adjetivo latino *bonus*, que a su vez deriva del verbo *beare*, hacer feliz. Aunque las cosas propias no dan la felicidad, contribuyen al bienestar del hombre por la utilidad moral o material que de ellas puede obtenerse. El Código no define lo que es bien, sino que se limita en el **art. 565** a señalar en qué consiste.

Para algunos autores la relación entre cosa y bien es de género a especie; para otros, la noción de cosa es objetiva y la de bien es subjetiva. En todo caso, la distinción tiene utilidad, pues permite explicar la coexistencia de varios derechos subjetivos en una misma cosa (un mismo predio, cosa,

puede ser objeto de diversos derechos reales, bienes, con distintas utilidades: dominio, usufructo, servidumbres, hipotecas, etc.).

NO CONFUNDIR

Cosa vs. bien

Atendido que nuestro ordenamiento jurídico emplea indistintamente estos conceptos, así se hará en este manual, salvo que se indique lo contrario. La distinción es doctrinal, no legal: el Código no la formula expresamente.

3. REGULACIÓN

Siendo el centro de la materia el derecho de propiedad, la regulación base se encuentra en la Constitución Política, en particular en el **artículo 19 N°s 21 a 25** (destacándose los N°s 23 y 24). El principal conjunto de normas legales se encuentra en el Libro II del Código Civil, denominado *De los Bienes, y de su Dominio, Posesión, Uso y Goce*. También regulan la materia otras normas del mismo Código y de leyes y reglamentos especiales.

4. BIENES CORPORALES E INCORPORALES

4.1. Concepto

Esta clasificación está expresamente reconocida en el Código Civil, que abre el Libro II con el **art. 565**: *los bienes consisten en cosas corporales o incorporeales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas con los sentidos, como una casa, un libro. Incorporeales las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres activas.*

Esta disposición se complementa con el **art. 576**, que establece que las cosas incorporeales son derechos reales o personales, y con el **art. 583**, que señala que sobre las cosas incorporeales hay también una especie de propiedad: así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo. La clasificación también está reconocida en el **art. 19 N° 24** de la Constitución.

4.2. Críticas a esta clasificación

La doctrina suele indicar que esta clasificación consagra la llamada *cosificación de los derechos*: el entendimiento de que un derecho está en el mismo plano que una cosa corporal cualquiera, lo que para muchos es un error. La doctrina extranjera objeta que las cosas corporales son objeto de derechos (relación vertical), de modo que no sería procedente pretender luego que estos, a su vez, son cosas junto a los primeros (relación horizontal), lo que además posibilita derechos sobre derechos.

Muchos autores estiman que entre los derechos considerados cosas no puede incluirse el derecho de propiedad, pues este se identifica tradicionalmente con la cosa en que se ejerce; considerarlo cosa crearía una cadena infinita de derechos sobre derechos (se tiene propiedad sobre un automóvil, sobre ese derecho se tiene a la vez propiedad, y así sucesivamente). Esta crítica es atendible, pero el Código sí reconoce la *propiedad sobre el derecho de propiedad*, pues el **art. 577** menciona entre los derechos reales, cosas incorpóreas conforme al **art. 576**, el de dominio o propiedad.

4.3. Importancia y aplicación práctica de esta clasificación

Para muchos autores, la ley atiende a la naturaleza corporal o incorpórea de los bienes para dictar las normas sobre los modos de adquirir las diversas clases de bienes y la manera de disponer de ellos. En Chile, desde los años sesenta, esta clasificación ha tenido gran aplicación práctica en dos ámbitos:

a. Protección de derechos ante agresiones legislativas cometidas mediante retroactividad.

Si una ley dispone que se aplicará incluso a situaciones ya producidas (como efectivamente ocurrió en Chile, cuando una nueva ley extendió la duración mínima de los arrendamientos de predios rústicos aplicándose a los contratos vigentes) y se detecta que vulnera un derecho ya adquirido de un particular, se sostiene que la ley priva de la propiedad de ese derecho y que, por no reunir los requisitos que la Constitución exige para expropiar, es inconstitucional.

b. Protección de derechos ante agresiones de la autoridad o de particulares, mediante actos administrativos o materiales ilegales o arbitrarios.

Cuando el derecho afectado no está directamente protegido por el recurso de protección (**art. 20** de la Constitución), como ocurre con el derecho a la educación del **art. 19 N° 10**, se plantea que en todo caso el afectado es dueño de ese derecho y que, al agredírsele, se agrede su derecho de propiedad, que sí está protegido por ese recurso.

DATO DE GRADO

¿Por qué importa la cosificación de los derechos en un examen?

Porque explica la llamada "propietarización" de los derechos: en Chile se recurre de protección invocando el derecho de propiedad sobre otros derechos (a la educación, a una pensión, a un crédito) precisamente porque el **art. 583** permite hablar de propiedad sobre cosas incorpóreas. Conviene tener a mano este mecanismo argumental, aunque doctrinalmente se le critique.

4.4. Bienes incorporeales

Si bien el **art. 576** dispone que las cosas incorporeales son derechos reales o personales, también existen otras cosas no perceptibles por los sentidos (y por tanto incorporeales) distintas de derechos, que igualmente tienen regulación y protección, como el espacio aéreo, las energías o las obras del ingenio. Este apartado se centra en los derechos reales y personales, por ser los que reciben mayor atención en el Código Civil.

a) Los derechos reales

Por definición legal, los derechos reales son aquellos que se tienen sobre una cosa sin respecto a determinada persona (**art. 577**).

(i) Concepto.

Se concibe como una relación persona-cosa, inmediata, absoluta: un derecho en la cosa (*ius in re*). Puede entenderse como un poder o señorío que tiene un sujeto sobre una cosa. Cuando ese poder es completo y total se está ante el derecho real máximo, el dominio; pero puede ser parcial, incompleto, como en los demás derechos reales (usufructo, prenda, hipoteca). El titular es una persona, pero puede ser también varias, como en la copropiedad.

(ii) Elementos del derecho real.

La doctrina suele indicar que los derechos reales están compuestos por dos elementos: el sujeto activo o titular del derecho, que tiene el poder de aprovecharse de la cosa en forma total o parcial; y la cosa objeto del derecho, que puede ser corporal o incorporeal y que debe ser siempre determinada, porque, como decía **PLANIOL**, el derecho real tiene por objeto garantizar el hecho de la posesión, necesariamente concreto. Para este mismo autor existiría un tercer elemento: un sujeto pasivo, que sería "todo el mundo" (obligación pasivamente universal), cuya obligación consistiría en abstenerse de perturbar el ejercicio del derecho.

(iii) Clases.

El contenido de los distintos derechos reales conduce a agruparlos en derechos reales de goce y de garantía. Los de goce permiten la utilización directa de la cosa (uso, percepción de frutos): el más completo es el dominio, y junto a él están el usufructo, el uso o las servidumbres. Los de garantía, como la prenda y la hipoteca, permiten utilizar la cosa indirectamente por su valor de cambio, con la facultad de lograr su enajenación para obtener con el producto una prestación incumplida. También puede distinguirse, por un lado, el dominio y, por otro, los demás derechos reales, llamados derechos reales en cosa ajena o derechos reales limitados.

(iv) Reserva legal en la creación de derechos reales.

A diferencia de los derechos personales, que son infinitos en número, los derechos reales, por su contenido absoluto y directo sobre las cosas, solo los puede establecer la ley. Nuestro Código los

enumera en el **art. 577** inc. 2º: el dominio, el de herencia, el de usufructo, el de uso, el de habitación, las servidumbres activas, la prenda y la hipoteca. Esta enumeración no es taxativa: otros textos legales establecen otros derechos reales, como el censo (**art. 579**), el derecho real de aprovechamiento de aguas del Código de Aguas, la concesión minera del Código de Minería, el derecho real de conservación de la Ley N° 20.930, y el derecho del copropietario sobre los bienes comunes en la propiedad horizontal de la Ley N° 21.442.

La doctrina chilena, en general, no acepta que los particulares puedan crear derechos reales distintos de los establecidos por la ley, atendido el carácter de orden público de las normas sobre organización de la propiedad. Esto no se opone a que la voluntad de los particulares sea, por regla general, lo que origina los derechos reales concretos: para que se configure un usufructo será necesario que un sujeto se lo conceda a otro en un convenio o testamento, pero el usufructo, como figura jurídica, ya está diseñado en la ley.

b) Los derechos personales

(i) Concepto.

Por definición legal, los derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas (**art. 578**). Las nociones de derecho personal (o crédito) y obligación son correlativas: se habla de derecho personal o de obligación según la relación entre los sujetos se mire desde el punto de vista del acreedor o del deudor.

(ii) Elementos del derecho personal.

Los elementos de la obligación son: los sujetos, activo (acreedor) y pasivo (deudor); el objeto del crédito, esto es, la prestación a que se obliga el deudor, que consiste en un comportamiento positivo o negativo, lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer (**art. 1438**); y un vínculo jurídico, que es lo que diferencia la obligación de otros deberes, como los morales.

(iii) Carácter ilimitado de los derechos personales.

A diferencia de los derechos reales, y en base al principio de la autonomía de la voluntad, los derechos personales son ilimitados, pues pueden originarse libremente en la voluntad de los contratantes, sin perjuicio del respeto a la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Por ende, hay tantos derechos personales como relaciones jurídicas puedan crearse.

c) Paralelo entre los derechos reales y personales

La doctrina tradicional contraponen los derechos reales a los personales, destacando las siguientes diferencias:

Criterio	Derechos reales	Derechos personales
Relación con la cosa	Relación directa de persona a cosa (<i>jure in re</i>)	Relación entre dos sujetos determinados: acreedor y deudor (<i>jure ad rem</i>)
Contenido	Poder jurídico inmediato y directo sobre la cosa	El acreedor solo obtiene el beneficio mediante un acto del deudor
Forma de adquirir	Título más modo de adquirir (ej. contrato más tradición)	Basta el título: de la sola celebración del contrato nacen y se incorporan al patrimonio
Carácter absoluto o relativo	Absolutos: acción persecutoria y restitutoria ejercitable frente a terceros	Relativos: solo se pueden exigir del deudor
Contravención	Pueden ser violados por cualquiera	Solo pueden ser violados por el deudor
Acciones	Nacen acciones reales, para perseguir la cosa de manos de quien la tenga	Nacen acciones personales, para reclamar al deudor el cumplimiento de la prestación
Origen y número	Solo los crea la ley (<i>numerus clausus</i>)	Los crean las partes sin más límite que la ley, el orden público o la moral (<i>numerus apertus</i>)
Fuentes	Nacen de los modos de adquirir	Nacen de las fuentes de las obligaciones: el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley (arts. 1437, 2284 y 2314)
Duración	Perpetuos, o al menos de prolongada duración	Usualmente de breve existencia, pues el acreedor espera obtener cuanto antes el pago de lo debido
Posesión y prescripción	Se poseen y se adquieren por prescripción, salvo los casos que la ley exceptúa	Se discute si pueden poseerse y, por tanto, si es posible ganar por prescripción un derecho personal

Si la obligación consiste en dar una cosa y esta es transferida por el deudor a un tercero, el acreedor no puede pedir al tercero la restitución de la cosa debida: deberá ejercer otra clase de acciones contra el deudor (indemnización de perjuicios, nulidad absoluta, acción pauliana, etc.), precisamente porque su derecho es personal y no real.

d) Las acciones

Luego de definir el derecho real y el derecho personal, el Código declara que de ellos nacen, respectivamente, las acciones reales y las acciones personales (parte final de los **arts. 577 y 578**). Desde el punto de vista del Derecho Civil, la acción es el derecho que se hace valer en juicio para obtener que sea reconocido, satisfecho o respetado.

Desde el punto de vista del Derecho Procesal, el término acción tiene al menos tres acepciones: como sinónimo de derecho (el demandante carece de acción); como sinónimo de pretensión de tener un derecho válido (la acción es fundada o infundada); y como la facultad de provocar la actividad jurisdiccional, el poder jurídico de todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la satisfacción de una pretensión.

La acción real tutela un derecho real y puede interponerse contra cualquier persona que no lo hubiese respetado. La acción personal tutela un derecho personal y solo puede ejercerse contra la persona (deudor) que hubiese contraído la obligación correlativa.

4.5. Bienes corporales

El **art. 565** indica que los bienes corporales son los que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, como una casa o un libro. El **art. 566** establece que las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles, clasificación que se analiza en el apartado siguiente. El **art. 580** aplica también esta clasificación a los derechos y acciones, según sea la cosa en que han de ejercerse (derechos reales) o que se debe (derechos personales), y el **art. 581** agrega que los hechos que se deben se reputan muebles.

5. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5.1. Conceptos generales

Esta clasificación se funda en la fijeza: la posibilidad o imposibilidad de las cosas de trasladarse de un lugar a otro, sea por fuerza propia o por una fuerza externa. Sin embargo, la ley admite que una cosa mueble por naturaleza sea considerada inmueble y, a la inversa, que una cosa inmueble se reputa mueble para constituir un derecho sobre ella en favor de terceros.

Aunque el **art. 566** señala que las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles, esta clasificación es aplicable tanto a los bienes corporales como a los incorpóreos (**art. 580**). Nacida en el Derecho Romano, se transformó en una de las clasificaciones fundamentales de los bienes: la naturaleza y el rol económico distinto de unos y otros imponen diversidad de normas en muchas materias. Hasta el desarrollo industrial, los inmuebles fueron el bien económico por excelencia, lo que explica su especial protección en las codificaciones decimonónicas; hoy la producción industrial ha generado muchos bienes muebles cuyo valor puede superar el de los inmuebles.

5.2. Importancia de la clasificación

Son numerosas las disposiciones que distinguen entre bienes muebles e inmuebles, la mayoría de ellas en protección de estos últimos. Entre las más relevantes:

a. Compraventa.

La de bienes raíces es solemne, requiere escritura pública para perfeccionarse, mientras que la de muebles es simplemente consensual (**art. 1801**).

b. Tradición.

La de inmuebles se efectúa por la inscripción del título en el Registro del Conservador de Bienes Raíces (**art. 686**); la de muebles, por la entrega material o simbólica (**art. 684**).

c. Prescripción adquisitiva ordinaria.

Para adquirir el dominio de inmuebles se exige poseerlos por un plazo mayor que el exigido para los muebles (**art. 2508**).

d. Sucesión por causa de muerte.

Para que los herederos puedan disponer de los inmuebles transmitidos, deben cumplirse ciertas diligencias que no se exigen respecto de los muebles (**art. 688**).

e. Sociedad conyugal.

Los inmuebles aportados o adquiridos a título gratuito durante el matrimonio pertenecen al haber del respectivo cónyuge; los muebles aportados o adquiridos a cualquier título ingresan al haber social (**arts. 1725 y siguientes**).

f. Lesión enorme.

La acción rescisoria por lesión enorme procede solo en la venta o permuta de inmuebles (**art. 1891**).

g. Enajenación de bienes de incapaces.

La del hijo o pupilo debe cumplir formalidades especiales, previo decreto judicial, y en el caso del pupilo, además, pública subasta (**arts. 254, 393 y 394**).

h. Cauciones reales.

Se distinguen dos instituciones distintas según la garantía sea mueble o inmueble: la prenda y la hipoteca, respectivamente (**arts. 2384 y 2407**).

i. Competencia de los tribunales.

Es distinta según sea mueble o inmueble la acción intentada (**arts. 135 y 138** del Código Orgánico de Tribunales).

5.3. Bienes (corporales) muebles

Los define el **art. 567**: son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas, como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que solo se muevan

por una fuerza externa, como las cosas inanimadas.

a) Clasificación

(i) Muebles por naturaleza.

Son las cosas muebles propiamente tales, a las que se refiere la definición del **art. 567**, que a su vez se dividen en semovientes (se trasladan moviéndose por sí mismas, como los animales) y cosas inanimadas (solo se mueven por una fuerza externa).

(ii) Muebles por anticipación.

Los consagra el **art. 571**: los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera y fruto de los árboles, o los animales de un vivar, se reputan muebles aun antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre esos productos o cosas a favor de otra persona que el dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera. Al reputarse muebles, se les aplican todas las normas de estos cuando se trata de constituir derechos a favor de terceros (de ahí, por ejemplo, el **art. 1801** inc. 3°).

EJEMPLO

Un mueble por anticipación

El dueño de un fundo vende a un tercero, antes de la cosecha, toda la madera de un bosque que crece en su predio. Aunque los árboles siguen adheridos al suelo (y por tanto son inmuebles por naturaleza mientras no se corten), para el efecto de constituir el derecho del comprador sobre esa madera, se reputan muebles desde ya.

b) Reglas de interpretación relativas a los bienes muebles

Atendido que a la palabra mueble se le puede dar un sentido diverso, el Código establece, en forma dispersa, ciertas reglas de interpretación. El **art. 574** inc. 1° dispone que cuando por la ley o el hombre se usa la expresión bienes muebles sin otra calificación, se comprende en ella todo lo que se entiende por cosas muebles según el **art. 567**, esto es, los muebles por naturaleza. El inciso 2° agrega que en los muebles de una casa no se comprende el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas o artísticas, los libros o sus estantes, las medallas, las armas, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, la ropa de vestir y de cama, los carruajes o caballerías o sus arreos, los granos, caldos, mercancías, ni en general otras cosas que las que forman el ajuar de una casa.

Por su parte, el **art. 1121** inc. 1° indica que si se lega una casa con sus muebles o con todo lo que se encuentre en ella, no se entienden comprendidas las cosas enumeradas en el inciso 2° del **art. 574**, sino solo las que forman el ajuar de la casa y se encuentran en ella. En síntesis: el término

mueble, sin calificativo, se refiere a los muebles por naturaleza; y los muebles de una casa son los que forman su ajuar.

5.4. Bienes (corporales) inmuebles

Los define el **art. 568**: inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos. Debido a que el legislador considera jurídicamente inmuebles ciertos bienes que naturalmente no lo son, se distingue entre inmuebles por naturaleza, por adherencia y por destinación.

a) Inmuebles por naturaleza

Son las cosas que no pueden trasladarse de un lugar a otro sin que se altere su sustancia (tierras, minas, etc.). En rigor, el suelo, el subsuelo y las minas son las únicas cosas cuya movilización no se concibe atendiendo a su propio ser. La palabra "casa" alude en general a todo edificio en que se puede vivir o morar; "heredad" es una porción de terreno cultivado perteneciente a un mismo dueño, con lo que se designa a los predios rústicos; y "finca" se refiere tanto a predios urbanos como rústicos, aunque en su acepción natural alude más bien a los últimos.

Diversas leyes especiales han definido, de modo no uniforme, los conceptos de inmueble rústico e inmueble urbano (la derogada Ley N° 16.640 sobre Reforma Agraria, el Decreto Ley 3.516 sobre División de Predios Rústicos, la Ley N° 18.101 sobre Arrendamiento de Predios Urbanos, el Decreto Ley 993 sobre Arrendamiento de Predios Rústicos). Esta distinción importa, entre otras cosas, porque las reglas sobre cabida de los predios solo se aplican a la venta de predios rústicos (**art. 1831** y siguientes); porque predios urbanos y rústicos tienen normas de arrendamiento distintas (Ley 18.101 y DL 993, respectivamente); y porque la subdivisión de un predio urbano y la de uno rústico siguen procedimientos y autoridades distintas.

Importa, además, porque el arrendamiento de los predios urbanos y rústicos de la sociedad conyugal o de la mujer requiere de su autorización si se exceden los plazos de los **arts. 1749, 1754 y 1756**, y porque similar autorización se exige para el arrendamiento de los bienes del hijo sujeto a patria potestad (**arts. 255 y 407**).

b) Inmuebles por adherencia

Del **art. 568** se desprende que son ciertos bienes que, siendo muebles, se reputan inmuebles por estar adheridos permanentemente a un inmueble, como los árboles. El **art. 569** agrega, como ejemplo, los árboles y las plantas que adhieren al suelo por sus raíces, siempre que no se encuentren en macetas que puedan transportarse de un lugar a otro.

Los productos de la tierra y los frutos de los árboles, mientras permanecen adheridos a su fuente de origen, son inmuebles, pues forman con ella un solo todo; separados permanentemente, son muebles, y se reputan muebles aun antes de su separación para constituir derechos sobre ellos en favor

de terceros (muebles por anticipación). La jurisprudencia ha resuelto que deben reputarse inmuebles por adherencia los durmientes, rieles y demás obras de un ferrocarril, los puentes, alcantarillados y terraplenes, y también las líneas telegráficas, por estar permanentemente adheridas al suelo.

Para que un bien se califique de inmueble por adherencia se requiere, copulativamente: que la cosa adhiera a un bien inmueble por naturaleza o a otro inmueble por adherencia; y que la cosa adhiera de forma permanente, esto es, con una incorporación estable, íntima y fija, y no una mera adherencia exterior. Permanencia no es lo mismo que perpetuidad: por eso son inmuebles por adherencia las construcciones levantadas para una exposición, aunque deban demolerse luego de cierto tiempo.

c) Inmuebles por destinación

El **art. 570** dispone que se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, aunque puedan separarse sin detrimento. Son, entonces, ciertos bienes muebles que la ley reputa inmuebles por estar permanentemente destinados al uso, cultivo o beneficio de un inmueble (no del propietario del inmueble): las losas de un pavimento, los tubos de las cañerías, los utensilios de labranza o minería, o los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio de una finca.

Los inmuebles por destinación conservan su naturaleza mueble y difieren de los inmuebles por adherencia en que su inmovilización es solo ficticia y jurídica: el motivo de la ficción es evitar el menoscabo de separar bienes que para su mejor aprovechamiento requieren de otros elementos complementarios. Celebrado un acto jurídico sobre un inmueble sin especificar la suerte de esos objetos, se entienden incluidos, salvo que la voluntad de las partes los excluya.

Elementos de los inmuebles por destinación

Deben reunirse copulativamente tres requisitos: que la cosa mueble se haya colocado en un inmueble; que haya sido colocada en interés del inmueble mismo, esto es, para su uso, cultivo o beneficio; y que la destinación tenga carácter permanente, lo que no es lo mismo que perpetuidad, como lo comprueba que el **art. 570** mencione los "abonos" existentes en la finca, que dejan de existir por su empleo.

Cesación de la calidad de inmueble por destinación

Conforme al **art. 573**, los inmuebles por destinación no dejan de serlo por su separación momentánea del inmueble al que acceden, pero desde que se separan con el objeto de darles un destino diferente, dejan de ser inmuebles. En armonía con ello, el **art. 2420** establece que la hipoteca afecta a los muebles que por accesión pertenecen al inmueble según el **art. 570**, pero el gravamen deja de afectarlos desde que esos inmuebles por destinación pasan a pertenecer a terceros, reconociéndose el derecho del deudor para enajenarlos.

5.5. Bienes incorporeales (derechos) muebles e inmuebles

El **art. 580** indica que los derechos reales y personales pueden ser muebles o inmuebles: cuando dispone que los derechos se reputan bienes muebles o inmuebles según lo sea la cosa en que han de ejercerse, se refiere a los derechos reales, que se ejercen "en" las cosas; cuando expresa que se reputan muebles o inmuebles según sea la cosa "que se debe", alude a los derechos personales, porque en virtud de ellos se deben las cosas.

Hay derechos reales que siempre son inmuebles, como las servidumbres activas, la hipoteca, el derecho de habitación y el censo; el derecho real de prenda, en cambio, es siempre mueble. El derecho real de usufructo y el de uso podrán ser muebles o inmuebles, según la naturaleza de la cosa corporal sobre la que recaen.

Tratándose de derechos personales, en las obligaciones de dar, si el objeto corporal que el acreedor puede exigir al deudor es mueble, el derecho personal también lo será; si es inmueble, el derecho personal será inmueble. En las obligaciones de hacer y de no hacer, los derechos personales se reputan muebles (**art. 581**).

Se discute qué naturaleza tiene el derecho real de herencia frente a esta clasificación: para algunos será mueble o inmueble según los bienes que compongan la herencia; para otros, por ser esta una universalidad jurídica sin regulación especial, se le aplica la regla general y se estima de naturaleza mueble.

6. BIENES CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES

Por su naturaleza, esta clasificación solo es aplicable a los bienes muebles. Está contenida, en forma confusa, en el **art. 575** (que se refiere a las cosas fungibles e infungibles), lo que para algunos autores confunde consumibilidad con fungibilidad. Mientras lo consumible es aquello que, usándolo conforme a su destino, se destruye, lo fungible es aquello que tiene igual poder liberatorio.

6.1. Clases de consumibilidad

La doctrina distingue entre consumibilidad objetiva y subjetiva. Son objetivamente consumibles los bienes que, por sus propias características, se destruyen ya natural, ya civilmente, por el primer uso: naturalmente, si desaparecen físicamente o sufren una alteración substancial (un alimento); civilmente, si el uso implica enajenar el bien (las monedas). Son objetivamente no consumibles los que, por sus características, no se destruyen ni natural ni civilmente por el primer uso, como una mesa o un automóvil.

Son subjetivamente consumibles los bienes que, atendido el destino que tienen para su actual titular, su primer uso importa enajenarlos o destruirlos (un automóvil usado para rodar una escena en que será arrojado a un precipicio). Son subjetivamente no consumibles los que, atendido ese des-

tino, su primer uso no importa enajenarlos (monedas que forman una colección numismática, o estampillas de una colección filatélica).

EJEMPLO

Consumibilidad objetiva y subjetiva combinadas

Los libros de una librería son subjetivamente consumibles para el librero (su destino es venderlos), pero no son objetivamente consumibles (leerlos no los destruye). A la inversa, una botella de licor es objetivamente consumible, pero, destinada a una exposición o muestra, es subjetivamente no consumible. Los alimentos de un almacén, en cambio, son consumibles desde ambos puntos de vista.

6.2. Bienes deteriorables y corruptibles

El carácter de no consumible de un bien no se opone al paulatino deterioro ocasionado por el uso. Algunos autores configuran una categoría especial, la de los bienes deteriorables o gradualmente consumibles, intermedia entre consumibles y no consumibles, aunque en rigor se trata siempre de cosas no consumibles, pues no se destruyen objetivamente por el primer uso sino de forma gradual. Dentro de los bienes consumibles hay, a su vez, una categoría especial de bienes corruptibles, que deben consumirse en breve tiempo porque rápidamente pierden su aptitud para el consumo, como algunas frutas o medicamentos (**art. 488** del Código Civil y **art. 483** del Código de Procedimiento Civil).

7. BIENES FUNGIBLES Y NO FUNGIBLES

7.1. Concepto y fungibilidad objetiva y subjetiva

En general puede decirse que son fungibles las cosas que, por presentar entre sí una igualdad de hecho, se les considera de igual poder liberatorio; en otros términos, las que pertenecen a un mismo género y se encuentran en el mismo estado, y que por ende son sustituibles. Desde un punto de vista objetivo, la fungibilidad es precisamente esto. Se ha propuesto también, sin ser aceptada unánimemente, una acepción subjetiva: dos o más cosas serían subjetivamente fungibles cuando el interesado les atribuye igual poder liberatorio (como en la dación en pago, las obligaciones alternativas o la compensación convencional). Así, cosas objetivamente fungibles pueden no serlo subjetivamente, sobre todo cuando media el poder de afección, como un reloj corriente que, por ser un recuerdo familiar, es no fungible para su actual propietario.

7.2. Consumibilidad, fungibilidad y cosas genéricas

Generalmente las cosas consumibles son también fungibles, como la mayoría de los alimentos, pero ambos caracteres no van necesariamente unidos: hay bienes consumibles no fungibles (una bebida exclusiva y cuidadosamente preparada) y bienes fungibles no consumibles objetivamente (los libros de una misma edición, las reproducciones de una obra de arte). Solo puede afirmarse que ambos caracteres a menudo concurren, pero son independientes.

El criterio de las cosas genéricas y el de las fungibles también es distinto: en las genéricas se atiende a la determinación de las cosas; en las fungibles, a la similitud o disimilitud entre dos o más cosas, a las que se les confiere o no idéntico poder liberatorio. No puede sostenerse, por tanto, que las cosas fungibles sean necesariamente genéricas y las no fungibles, cuerpos ciertos: una pistola de cierto calibre es una cosa genérica y fungible, pero la misma pistola identificada por su número de serie es un cuerpo cierto y, a la vez, fungible.

7.3. Importancia de esta clasificación

Esta clasificación reviste importancia, entre otras, en dos materias: el mutuo recae en cosas fungibles (**art. 2196**), mientras que el comodato, por regla general, recae en cosas no fungibles; y la compensación legal solo es posible entre dos deudas que tienen por objeto cosas fungibles (**art. 1656 N° 1**).

8. BIENES PRINCIPALES Y ACCESORIOS

Bienes principales son los que tienen existencia independiente, sin necesidad de otros, como el suelo. Bienes accesorios son los que están subordinados a otros sin los cuales no pueden subsistir, como los árboles. El Código no formula esta clasificación, pero la reconoce implícitamente en numerosas disposiciones (**arts. 587, 1122, 1127 y 1830**). Se aplica no solo a los bienes corporales, sino también a los incorporeales: la servidumbre es accesoria del dominio sobre el predio en que se ejerce, y la hipoteca es accesoria del crédito que garantiza.

8.1. Factores para determinar lo principal y lo accesorio

a. Subsistencia.

Se considera principal la cosa que puede subsistir por sí misma, y accesoria la que necesita de otra. El suelo es siempre cosa principal respecto de una casa, aunque valga menos que esta, pues el edificio no se concibe sin suelo donde adherirse (**art. 668**). Un crédito existe por sí mismo, pero no la hipoteca que lo cauciona.

b. Finalidad.

Es accesoria la cosa destinada al uso, cultivo, beneficio, adorno o complemento de otra, como la vaina respecto de un sable.

c. Valor.

En la adjunción, si de las dos cosas unidas una es de mucho más valor que la otra, la primera es la principal (**art. 659**).

d. Volumen.

Cuando no pueden aplicarse los criterios de mayor estimación y finalidad, en la adjunción se mira como principal la de mayor volumen (**art. 661**).

8.2. Importancia de la clasificación

La clasificación es importante porque rige el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal: traspasado un derecho sobre una cosa principal, se traspasa el derecho sobre las accesorias, y extinguido el primero, se extingue el segundo. Adquiere especial relevancia a propósito de la accesión como modo de adquirir el dominio, en la cual, en los diversos casos que trata el Código, el dominio de lo accesorio accede al dominio de lo principal.

9. BIENES DIVISIBLES E INDIVISIBLES

Desde un punto de vista físico, todas las cosas corporales son divisibles, pues en último término todas pueden fraccionarse, aunque ello suponga su destrucción. Desde un punto de vista jurídico, en cambio, hay dos conceptos de divisibilidad: uno material y otro intelectual.

a. Divisibilidad material.

Son jurídica y materialmente divisibles los bienes que pueden fraccionarse sin destruirse en su estado normal ni perder notoriamente su valor al considerar las partes en conjunto. Un líquido es divisible; un animal es indivisible, porque al fraccionarlo se destruye en su estado normal; un diamante normalmente es indivisible, porque al fraccionarlo disminuye apreciablemente su valor.

b. Divisibilidad intelectual.

Son jurídica e intelectualmente divisibles las cosas que pueden fraccionarse en partes ideales o imaginarias, aunque no puedan serlo materialmente. Desde este punto de vista todos los bienes, corporales e incorporeales, son divisibles. Los bienes incorporeales (derechos), al no tener consistencia física, solo son intelectualmente divisibles, y hay ciertos derechos que la ley declara indivisibles ni siquiera intelectualmente, como la servidumbre (**arts. 1524, 826 y 827**).

9.1. Divisibilidad de los derechos

Los derechos personales son divisibles o indivisibles según lo sea la obligación que es su contrapartida: la obligación de construir una casa o de conceder una servidumbre es indivisible, y asimismo el derecho correlativo; la obligación de pagar una suma de dinero es divisible, y asimismo el derecho (**art. 1524**). En cuanto a los derechos reales, algunos son indivisibles conforme al derecho positivo, como los de servidumbre (**arts. 826 y 827**), prenda (**art. 2405**) e hipoteca (**art. 2408**).

El derecho real de dominio, en cambio, es típicamente divisible desde un doble punto de vista: primero, admite desmembraciones, siendo la más usual aquella en que el propietario mantiene la nuda propiedad y confiere a un tercero las facultades de uso y goce, dando origen al usufructo; y segundo, sobre un mismo objeto varias personas pueden ejercer el derecho de dominio a la vez, dando origen a la copropiedad o comunidad.

10. BIENES SINGULARES Y BIENES UNIVERSALES

Son bienes singulares los que constituyen una unidad, natural o artificial. Son bienes universales las agrupaciones de bienes singulares que no tienen entre sí una conexión física, pero que forman un todo funcional y están relacionados por un vínculo determinado.

10.1. Las universalidades

Se suele distinguir entre universalidades de hecho (*universitas facti*) y universalidades de derecho o jurídicas (*universitas juris*).

a) Universalidades de hecho

Suelen definirse como un conjunto de bienes que, sin perder su individualidad, forman un todo al estar unidos por un vínculo de igual destino, generalmente económico. Aunque tradicionalmente se indicaba que solo podían estar compuestas por muebles, hoy la doctrina admite que también pueden estar compuestas por inmuebles. Presentan las siguientes notas: los bienes que la componen pueden ser de la misma naturaleza (colecciones, como los libros de una biblioteca) o de naturaleza diferente (explotaciones, como el establecimiento de comercio); mantienen su propia individualidad, función y valor, por lo que las meras partes de un bien singular no constituyen universalidad de hecho; el vínculo que las une es de un común destino o finalidad, generalmente económico; y comprenden solo elementos activos, no pasivos o deudas.

b) Universalidades de derecho

Están constituidas por un conjunto de bienes y relaciones jurídicas activas y pasivas consideradas jurídicamente como formando un todo indivisible. Contienen tanto elementos pasivos como activos, existiendo una correlación funcional entre ellos, de modo que el activo responde del pasivo existente o eventual; y funciona en ellas, como norma general, el principio de la subrogación real,

por el cual los bienes que ingresan a la universalidad a costa de otros que salen pasan a ocupar la posición jurídica de estos. En el derecho chileno, la universalidad jurídica típica es la herencia; la doctrina agrega, discutiblemente, otras como la sociedad conyugal, el patrimonio del fallido o el patrimonio reservado de la mujer casada.

c) Diferencias entre ambas universalidades

Mientras la unidad de la universalidad de hecho es configurada por el hombre, en la de derecho es impuesta por la ley. Las de hecho solo comprenden activo; las de derecho, activo y pasivo. Las de hecho, por regla general, no tienen regulación jurídica especial; las de derecho sí la tienen. Nuestro derecho positivo no reglamenta las universalidades como categoría general, pero el Código supone la clasificación: los **arts. 1317 y 1340** distinguen bienes singulares y universales, el **art. 951** se refiere a la herencia como universalidad de derecho, y el **art. 788** implica un caso de universalidad de hecho.

11. BIENES PRESENTES Y FUTUROS

Atendiendo a la existencia real de los bienes al momento de crearse una relación jurídica, se clasifican en presentes y futuros. Es una clasificación puramente jurídica, porque en la realidad solo son bienes los llamados presentes. Son bienes presentes los que, a un momento determinado, tienen existencia real; son futuros los que a esa época no existen y solo se espera que existan. El Código no formula expresamente esta clasificación, pero la reconoce en diversas disposiciones, como los **arts. 1461 y 1813**, a propósito del objeto de un acto jurídico o de una compraventa, respectivamente.

12. BIENES COMERCIALES E INCOMERCIALES

Los bienes se clasifican en comerciables e in comerciables según puedan o no ser objeto de relaciones jurídicas por los particulares. Son comerciables los que pueden ser objeto de relaciones jurídicas privadas, de manera que sobre ellos puede recaer un derecho real o constituirse un derecho personal (**arts. 1461 y 2498**): son susceptibles de propiedad o posesión privada, y la mayoría de las cosas lo son. Son in comerciables los que no pueden ser objeto de relaciones jurídicas por los particulares, no susceptibles de propiedad o posesión privada. La clasificación es importante porque el objeto de los actos jurídicos debe ser comerciable (**art. 1461**), habiendo objeto ilícito en la enajenación de bienes no comerciables (**art. 1464 N° 1**).

NO CONFUNDIR**Bienes inmerciables vs. bienes inalienables o personalísimos**

Los bienes inalienables o personalísimos son plenamente comerciables, en cuanto son susceptibles de propiedad y posesión privada, pero tienen la particularidad de que no pueden transferirse ni transmitirse a otras personas. Es el caso de los derechos reales de uso y habitación (**art. 819**). No debe confundirse esta categoría con la de los bienes inmerciables propiamente tales.

12.1. Clasificación de los bienes inmerciables**a. Inmerciables en razón de su naturaleza.**

Como la alta mar o el aire: son las llamadas por el **art. 585** "cosas comunes a todos los hombres", las únicas que en rigor no son objeto de relaciones jurídicas en general y a las que puede aplicarse la expresión de cosas fuera del comercio humano.

b. Inmerciables en razón de su destino.

Bienes que, siendo naturalmente comerciables, se han sustraído del comercio jurídico para dedicarlos a un fin público, como las plazas, calles y demás bienes nacionales de uso público (**art. 589**). Pueden ser objeto de ciertas relaciones jurídicas de carácter público, como las concesiones que otorga la autoridad, por lo que solo desde el punto de vista del derecho privado son inmerciables.

En cuanto a las cosas consagradas al culto divino, el Código se remite, en el **art. 586**, al Derecho Canónico; el **art. 587** deja en claro que estos bienes son comerciables.

13. BIENES APROPIABLES E INAPROPIABLES

Relacionada con la clasificación anterior, pero atendiendo exclusivamente al dominio, se clasifican en apropiables e inapropiables según sean o no susceptibles de propiedad, pública o privada. Pueden entenderse como inapropiables las cosas comunes a todos los hombres, antes calificadas de absolutamente inmerciables.

13.1. Bienes apropiados e inapropiados

Apropiados son los susceptibles de apropiación y que actualmente poseen un dueño. Inapropiados son los susceptibles de apropiación que actualmente carecen de dueño: pueden no haber tenido nunca propietario (*res nullius*) o haberlo tenido y haber sido abandonados con intención de desprenderse del dominio (*res derelictae*). En el Derecho chileno la existencia de bienes inapropiados (llamados "mostrencos" si son muebles y "vacantes" si son inmuebles) queda limitada a los mue-

bles: el **art. 590** establece que son bienes del Estado todas las tierras situadas dentro de los límites territoriales que carecen de otro dueño.

Existen disposiciones legales que establecen cuándo un bien adquiere la calidad de abandonado y, por tanto, de *res derelictae*. Es lo que ocurre con el **art. 42** de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, que dispone que se entenderán abandonadas en favor del proveedor las especies que le sean entregadas en reparación, cuando no sean retiradas en el plazo de un año contado desde la fecha en que se haya otorgado y suscrito el correspondiente documento de recepción del trabajo.

13.2. Bienes susceptibles e insusceptibles de apropiación por particulares

La organización social ha impuesto siempre la necesidad de que ciertos bienes, por su naturaleza susceptibles de apropiación, no queden entregados al dominio de particulares, sino que pertenezcan a toda la comunidad para la satisfacción de necesidades generales, como los caminos y calles. El **art. 19 N° 23** de la Constitución garantiza a todas las personas la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto los que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o los que deban pertenecer a la Nación toda y la ley así lo declare, sin perjuicio de otras normas constitucionales (el Estado es dueño de las minas, las aguas no se pueden apropiar libremente, etc.).

En Chile se acostumbra denominar a los bienes de dominio de los particulares "bienes privados" o "particulares", y a los de la Nación toda, "bienes nacionales", subdistinguiéndose entre "bienes nacionales de uso público" y "bienes del Estado" o "fiscales".

14. BIENES PRIVADOS Y PÚBLICOS (O NACIONALES)

Bienes privados son los que pertenecen a los particulares. Bienes públicos o nacionales son, conforme al **art. 589**, aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda, subdistinguiéndose entre bienes nacionales de uso público (o bienes públicos) y bienes del Estado (o bienes fiscales).

14.1. Bienes nacionales de uso público

Son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda y su uso, a todos los habitantes (**art. 589**): plazas, calles, puentes, caminos, mar adyacente. Su tuición está encargada a distintas autoridades según su naturaleza (Ministerio de Obras Públicas, Fuerzas Armadas, Ministerio de Bienes Nacionales, municipalidades, etc.).

(i) Características.

Su uso pertenece a todos los habitantes del país. Aunque el Código no lo expresa, están fuera del comercio por su propio destino, por lo que son imprescriptibles e inalienables. Sin perjuicio de ello, la autoridad puede otorgar a particulares permisos y concesiones sobre algunos de estos bie-

nes, o más usualmente sobre partes de ellos, para destinarlos a fines específicos de los que también se beneficie la comunidad: así, el **art. 599** exige permiso especial de la autoridad competente para construir obras sobre calles, plazas, puentes, playas y demás lugares de propiedad nacional, y el **art. 602** aclara que quien obtiene ese permiso solo adquiere el uso y goce de las obras construidas, no la propiedad del suelo.

(ii) Desafectación.

El Estado puede desprenderse del dominio de un bien nacional de uso público, pero solo en virtud de una ley que declare su desafectación, esto es, su sustracción al dominio público y a su condición y destino de bien nacional de uso público.

a) Dominio público marítimo

El **art. 593** define el mar territorial como el mar adyacente hasta la distancia de 12 millas marinas medidas desde las respectivas líneas de base, y es de dominio nacional. Define también la zona contigua, que se extiende hasta las 24 millas marinas, en la que el Estado ejerce jurisdicción para prevenir y sancionar infracciones a sus leyes aduaneras, fiscales, de inmigración o sanitarias. Las aguas interiores del Estado son las situadas en el interior de las líneas de base del mar territorial. El **art. 596** define la zona económica exclusiva, que se extiende hasta las 200 millas contadas desde esas mismas líneas de base. Otras disposiciones atinentes son los **arts. 585, 594, 604, 612, 613 y 614**, además de la Ley de Navegación, la Ley Orgánica de la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante, y la Ley General de Pesca y Acuicultura.

b) Dominio público terrestre

Comprende todos los bienes nacionales de uso público situados en la superficie del territorio del Estado (**arts. 589 y 592**). La administración de los bienes nacionales de uso público situados en cada comuna corresponde al municipio respectivo, sin perjuicio de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas.

c) Dominio público fluvial y lacustre

Comprende todas las aguas del territorio nacional: conforme al **art. 595**, todas las aguas son bienes nacionales de uso público. El **art. 19 N° 24** inciso final de la Constitución establece que los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos conforme a la ley, otorgan a sus titulares la propiedad sobre ellos.

d) Dominio público aéreo

El propietario de un predio es dueño del espacio existente sobre su inmueble, lo que significa que tiene derecho a ocuparlo con construcciones o plantaciones, con las limitaciones que imponga la ley (la Ley General de Urbanismo y Construcciones o las normas municipales). Cuando se afirma

que el Estado tiene soberanía sobre el espacio ubicado sobre su territorio, se quiere indicar que está facultado para regular su utilización, materia de la que se ocupa el Código Aeronáutico.

14.2. Bienes fiscales

El Estado, ente de Derecho Público, puede ser sujeto o titular de derechos privados. Los bienes fiscales constituyen el patrimonio privado del Estado, y le pertenecen en cuanto sujeto de relaciones patrimoniales privadas, para lo cual es llamado "Fisco". Con el **art. 589** puede decirse que son los bienes nacionales cuyo uso no pertenece a la nación toda. Teóricamente su régimen jurídico es el Derecho Privado, aunque siempre se han dictado leyes especiales que reglamentan su adquisición, administración y disposición (actualmente el Decreto Ley 1.939 y los **arts. 19 N° 21 y 60 N° 10** de la Constitución), de modo que las normas de Derecho Privado común solo tienen valor supletorio.

El Ministerio de Bienes Nacionales es el órgano que principalmente administra los bienes fiscales, aunque todos los ministerios y reparticiones públicas poseen bienes fiscales bajo la tuición del servicio correspondiente. Entre los bienes fiscales pueden mencionarse los afectos al funcionamiento de los servicios públicos, las herencias en que sucede el Fisco como heredero intestado (herencias yacentes que se transforman en vacantes, **art. 995**), las nuevas islas que se forman en el mar territorial o en ríos y lagos navegables por buques de más de 100 toneladas (**art. 597**), la captura bélica (**art. 640**), y las tierras que, ubicadas dentro del territorio nacional, carecen de otro dueño (**art. 590**).

DATO DE GRADO

El art. 590 como presunción de dominio fiscal

Se estima que el **art. 590** establece una verdadera presunción de dominio a favor del Fisco respecto de las tierras sin otro dueño dentro del territorio nacional, de manera que quien le dispute un inmueble debe acreditar dominio, aunque tenga posesión. Conviene recordar este punto al analizar conflictos de tierras sin antecedentes registrales claros.

B. EL DOMINIO

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En doctrina, atendida la naturaleza y trascendencia del derecho de propiedad, no existe unanimidad acerca de sus concepciones fundamentales: su concepto, sus modalidades, las clases de bienes susceptibles de propiedad privada, las facultades que confiere y las restricciones que debe soportar el propietario motivan controversias interminables, en las que los postulados jurídicos se confunden con los económicos, sociológicos y políticos.

La reglamentación fundamental del dominio se encuentra en el **art. 19 N°s 21 a 25** de la Constitución, que sienta sus bases estructurales. En el Código Civil, el tema se regula en el Libro II (**arts. 582** y siguientes), que determina qué se entiende por propiedad, los modos de adquirirla, sus restricciones por la existencia de derechos reales limitados y su protección. Adicionalmente, diversas leyes regulan ciertas clases de propiedad, transformando, restringiendo o protegiendo el dominio desde otras perspectivas.

2. CONCEPTO LEGAL DEL DOMINIO

El **art. 582** inc. 1° dispone que *el dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno*. El **art. 583** agrega que sobre las cosas incorpóreas hay también una especie de propiedad.

Para el Código, "propiedad" y "dominio" son sinónimos. Sin embargo, algunos autores aplican la expresión dominio solo al derecho real que recae sobre cosas materiales, y reservan el término propiedad, más genérico, para todo género de derechos susceptibles de apreciación pecuniaria (una herencia, un crédito). Para otros, no hay diferencia de extensión o contenido entre ambos términos, sino de punto de vista: el dominio sería de carácter subjetivo (el poder del sujeto) y la propiedad, de sentido objetivo (la pertenencia de la cosa al sujeto).

La definición legal es de carácter analítico: concibe el dominio como un conjunto de facultades o prerrogativas identificables y de cierta autonomía, y por tanto enumera, con un criterio cuantitativo, las facultades que confiere al propietario. Esta concepción se opone a la sintética, que concibe el dominio, desde un punto de vista cualitativo, como un señorío monolítico o poder pleno sobre el objeto, con prescindencia de sus facultades identificables.

La definición legal de dominio tiene cuatro componentes: la calificación de derecho, con la calificación derivada de real; la consignación de los atributos de uso (implícito en el goce), goce y disposición, con la amplitud de la arbitrariedad; las restricciones genéricas inmediatas, la ley y el derecho ajeno; y un campo de aplicación, las cosas corporales, ampliado luego (**art. 583**) a las cosas incorpóreas, aunque respecto de estas se hable de una "especie" de propiedad.

3. BASES CONSTITUCIONALES DEL DOMINIO

Aunque el estudio detenido de la regulación constitucional de la propiedad corresponde al curso de Derecho Constitucional, conviene fijar sus aspectos elementales. La Constitución no define qué es la propiedad, pero en los **arts. 19 N°s 21 a 25** (que regulan el llamado orden público económico) consagra principios relativos a su función social, su protección, sus atributos esenciales y ciertas restricciones.

El **art. 19 N° 23** regula el derecho a la propiedad o libre apropiabilidad de los bienes; el **art. 19 N° 24** asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporeales; y estas garantías se refuerzan con el **art. 19 N° 26**, que asegura que los preceptos legales que regulen, complementen o limiten las garantías constitucionales no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.

(i) Garantía.

La Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporeales. Al aludir a "las diversas especies" de propiedad se pretende abarcar tanto la reglamentada en el Código Civil como la normada en leyes especiales, por ejemplo la propiedad indígena.

(ii) Protección y reserva legal.

La protección del dominio está dada, en primer término, por el aseguramiento del derecho de propiedad, que consagra una reserva legal para establecer los modos de adquirir el dominio y para imponer restricciones, obligaciones y privaciones. Se reafirma con el **art. 19 N° 26**, que prohíbe afectar el dominio en su contenido esencial, y el dominio está además incluido, por el **art. 20**, entre los derechos fundamentales protegidos por el recurso de protección.

(iii) Función social.

Solo la ley puede establecer las limitaciones y obligaciones que deriven de la función social de la propiedad, la que comprende cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad pública, la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental.

(iv) Regulación de la expropiación.

La privación de la propiedad, o expropiación, está detenidamente regulada en el **art. 19 N° 24**. Nadie puede ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación, por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador. El expropiado puede siempre reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios, y tiene siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado: a falta de

acuerdo, debe pagarse en dinero efectivo y al contado, y el Fisco no puede tomar posesión material del bien mientras no se pague el total de la indemnización.

4. CARACTERES

La doctrina le asigna a la propiedad el carácter de derecho real, absoluto, exclusivo, perpetuo, abstracto y elástico.

4.1. Real

El dominio es el derecho real por excelencia: se ejerce sobre una cosa sin respecto a determinada persona (**arts. 577 y 582**).

4.2. Absoluto

Confiere al titular la posibilidad de ejercer sobre el objeto las más amplias facultades, de manera soberana e independiente. El Código, siguiendo las codificaciones de su época, establece este carácter absoluto al permitir al dueño gozar y disponer de la cosa arbitrariamente, no siendo contra la ley o el derecho ajeno.

DATO DE GRADO

¿Es criticable la palabra "arbitrariamente" del art. 582?

Por el término "arbitrariedad" que incluye la definición legal, esta ha sido calificada de clásica, criticándosele por dar cuenta de un poder absoluto, individualista y desprovisto de preocupación social. Sin embargo, la misma definición agrega que esa arbitrariedad encuentra su límite en la ley y el derecho ajeno, lo que morigera cualquier eventual abuso y coordina la norma con la regulación constitucional de la función social de la propiedad.

4.3. Abuso del derecho

La doctrina del abuso del derecho se pregunta si una persona puede incurrir en responsabilidad al ejercer un derecho propio cuando, con ello, lesiona un interés ajeno que no está protegido por otro derecho. Se distingue así de la colisión de derechos, que supone el choque entre dos derechos de igual jerarquía, resuelto generalmente por criterios que fija el propio legislador, como el de la utilidad del **art. 56** del Código de Aguas para la apertura de pozos que privan de agua a un predio vecino.

Son requisitos del abuso del derecho: que se ejerza un derecho, a lo menos con apariencia de legalidad; que el daño recaiga sobre un interés no protegido por otro derecho; y que ese daño no repor-

te ninguna utilidad a quien lo ejerce, siendo por ello inmoral o antisocial. El Código no contiene una norma que trate sistemáticamente la institución, y en el derecho comparado se proponen dos soluciones.

La primera aplica las reglas de la responsabilidad extracontractual, exigiendo dolo o culpa (**art. 2314** y siguientes), solución criticada porque estos elementos subjetivos no son propios del abuso del derecho, cuyo verdadero test es si el acto se ajusta a la utilidad económica y social que el ordenamiento le reconoce al derecho ejercido. La segunda construye una teoría autónoma del abuso del derecho, independiente de la responsabilidad extracontractual, que examina objetivamente el comportamiento del titular y su conformidad con los fines económicos y sociales de su derecho, criticada a su vez por la imprecisión del criterio, que puede derivar en arbitrariedad judicial.

Comprobado el abuso, la sanción es la indemnización de los perjuicios causados, con fundamento en el **art. 2314**, y la cesación del acto abusivo.

EJEMPLO

Un propietario construye un muro de diez metros de altura invocando razones de seguridad, cuando bastaban cinco. El exceso no le reporta ninguna utilidad adicional y solo priva de luz al vecino: es un caso clásico de abuso del derecho de dominio, que da lugar a indemnización y a la orden de reducir el muro.

4.4. Exclusivo

El dominio se radica en un solo titular: no puede haber dos o más propietarios independientes uno del otro sobre la misma cosa, con iguales poderes sobre ella. La demarcación y el cerramiento son manifestaciones de esta exclusividad (**arts. 842 a 846, 876, 878 y 942**). La comunidad no constituye excepción a esta característica, porque hay un solo dominio (no dos independientes) y cada comunero tiene una parte del derecho, no el total; tampoco la desnaturaliza que existan sobre la cosa otros derechos reales junto al dominio, pues estos solo limitan la libertad de acción del propietario.

Una importante forma de concreción de la exclusividad es la llamada facultad de excluir: el poder del dueño para impedir a los demás el uso y goce de la cosa, comprendiendo intromisiones tanto jurídicas como materiales. Se reconocen, con todo, ciertas excepciones a esta facultad:

(i) El derecho de uso inocuo o inocente.

Es el que se tiene sobre la cosa propiedad de otro para obtener un provecho sin causar al dueño perjuicio alguno, o causándolo en medida insignificante.

(ii) El derecho de acceso forzoso (o coactivo).

Es el que se reconoce al dueño o administrador de una cosa para entrar transitoriamente a una propiedad ajena a ejecutar algún acto relativo a la utilización de aquel objeto, por ejemplo para recoger frutos caídos en el predio vecino o para reparar un muro (**arts. 620 y 943**).

(iii) El principio del mal menor.

Cualquier persona puede aprovecharse de una cosa ajena para salvar otra cosa o un bien jurídico de mayor valor que el daño que pueda causar. El Código lo rechaza en el comodato: el **art. 2178** hace responder al comodatario aun del caso fortuito cuando, en la alternativa de salvar de un accidente la cosa prestada o la suya, ha preferido deliberadamente la suya. Sí lo reconoce, en cambio, el **art. 36** de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria.

Estas excepciones son concreciones de la función social del dominio, y por su entidad requieren de un criterio prudente y firme control.

4.5. Perpetuo

El dominio sobre una cosa persiste mientras subsiste la cosa misma, y por ende no se extingue por el solo transcurso del tiempo o por el no ejercicio del derecho; por lo mismo, su acción protectora, la reivindicatoria, tampoco se extingue por el solo transcurso del tiempo. El titular puede perder el derecho y la acción cuando un tercero posee la cosa y llega a ganarla por prescripción, conforme al **art. 2517**: toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho.

4.6. Abstracto

El poder del titular es independiente de las facultades concretas que integran su contenido: aunque se extraiga alguna, incluso esencial, el dominio permanece sin desnaturalizarse. Así ocurre en el usufructo, donde el nudo propietario se desprende de las facultades de uso y goce en favor del usufructuario, pero conserva íntegramente su calidad de dueño.

4.7. Elástico

El poder del dueño tiene la virtud de contraerse y expandirse. Al concurrir sobre la cosa otros derechos reales de inferior jerarquía, el dominio se contrae, para expandirse de inmediato y sin necesidad de un nuevo acto cuando ese derecho que lo comprimía cesa: así, extinguido el usufructo, el nudo propietario recupera de pleno derecho las facultades de uso y goce, sin que sea necesaria una restitución formal.

5. FACULTADES (O ATRIBUTOS)

La concepción clásica, desde el Derecho Romano, asigna al propietario tres facultades fundamentales: uso (*jus utendi*), goce (*jus fruendi*) y disposición (*jus abutendi*) del objeto de su dominio.

5.1. Facultad de uso

Significa que el propietario puede utilizar o servirse de la cosa conforme a su naturaleza (habitar la casa, vestir el traje). El Código, como su modelo francés, no menciona separadamente este atributo, lo que ha llevado a la doctrina a entender que lo incluye en la facultad de goce; así aparece en las definiciones de usufructo (**art. 764**) y arrendamiento (**art. 1915**), y con más evidencia aún en la definición del derecho real de uso (**art. 811**).

5.2. Facultad de goce

Significa que el dueño puede beneficiarse y hacerse dueño de los frutos y productos de la cosa. Aunque el **art. 643** los llama a todos "productos", la doctrina siempre ha distinguido los frutos de los productos: los frutos son los que la cosa da periódicamente, ayudada o no de la industria humana y sin detrimento de la cosa fructuaria; el producto carece de periodicidad y disminuye la cosa (**art. 537**). No resulta muy justificado, con todo, recurrir a la accesión, como lo hace el Código (**arts. 643** y siguientes), para conferir al propietario los frutos y productos de su cosa: le pertenecen, más bien, por la facultad de goce.

5.3. Facultad de disposición

Deriva del carácter absoluto del dominio: significa que el dueño puede disponer de la cosa según su voluntad y arbitrariamente, no siendo contra la ley o el derecho ajeno. Tiene dos manifestaciones: por una parte, el dueño puede disponer materialmente de la cosa, modificándola o destruyéndola; por otra, puede disponer jurídicamente de ella, celebrando negociaciones con terceros, gravándola con prendas, hipotecas u otras limitaciones y, en fin, enajenándola.

6. ESTIPULACIONES LIMITATIVAS DE LA FACULTAD DE DISPOSICIÓN ("CLÁUSULAS DE NO ENAJENAR")

Son las convenciones por las que el propietario de un objeto se obliga a no disponer de él, sea material o jurídicamente. La estipulación de no disponer materialmente (por ejemplo, para preservar un bien artístico o histórico) no presenta mayores dificultades, aunque es de rara ocurrencia. La estipulación de no disponer jurídicamente, usualmente llamada "cláusula de no enajenar", es de habitual aplicación pero ha sido objeto de arduo debate doctrinal.

El Código, en ciertos casos, prohíbe la cláusula de no enajenar (**arts. 1126, 1964, 2031 y 2415**) y en otros la permite (**arts. 751, 793 y 1432**), sin que exista una norma que en términos expresos y

generales resuelva la discusión.

6.1. Argumentos a favor de la validez

Se ha sostenido la validez de estas cláusulas en base a los siguientes argumentos: no hay una prohibición expresa de carácter general respecto de estos pactos, y en Derecho privado se puede hacer todo lo que no está expresamente prohibido por la ley; que la ley prohíba expresamente la cláusula en ciertos casos hace suponer que, por lo general, es posible convenirla; si el propietario puede desprenderse del uso, goce y disposición enajenando la cosa, con mayor razón podría desprenderse solo de esta última facultad; y el Reglamento del Registro del Conservador de Bienes Raíces permite inscribir todo impedimento o prohibición referente a inmuebles, sea convencional, legal o judicial, que embarace o limite de cualquier modo el libre ejercicio del derecho de enajenar (**art. 53 N° 3** del Reglamento).

6.2. Argumentos en contra de la validez

En contra, se afirma que estas cláusulas son nulas por las siguientes razones:

a. Atentarían contra la libre circulación de la riqueza.

La proscripción de trabas de tipo feudal es uno de los principios fundamentales del Código y del Mensaje: la facultad de enajenar sería de orden público y, por ende, no derogable por los particulares.

b. Su permiso expreso en casos puntuales confirmaría la regla contraria.

Que la ley permita la cláusula en determinados casos haría concluir que, en general, no se tiene por válida.

c. El art. 1810 solo permite prohibir enajenar a la ley.

Dispone que pueden venderse todas las cosas cuya enajenación no esté prohibida por ley.

d. El art. 53 del Reglamento del Conservador es solo una norma reglamentaria.

No podría dársele eficacia en lo que no se acomode a la ley que rechaza estas cláusulas, sin perjuicio de que se ha sostenido que, al haberse dictado en virtud de una disposición del Código (**art. 695**), tendría fuerza de ley.

En esta posición, las cláusulas voluntarias de no enajenar adolecerían de nulidad absoluta por falta o ilicitud del objeto (**arts. 10, 1461, 1466 y 1682**).

6.3. Posición intermedia y jurisprudencia

Hay quienes aceptan la validez de estas cláusulas en términos relativos: si se establecen por un tiempo no prolongado y existiendo alguna justificación. Se señala como importante el **art. 1126**,

que dispone que si se lega una cosa con calidad de no enajenarla, y la enajenación no compromete ningún derecho de tercero, la cláusula de no enajenar se tiene por no escrita. Interpretada a contrario sensu y con aplicación general, esta norma permitiría concluir que, si existe una debida justificación, como el que esté comprometido el derecho de un tercero, la cláusula de no enajenar vale. La jurisprudencia parece aceptar la validez de la estipulación por tiempo determinado y prudente, y con justificado motivo, aunque en alguna ocasión también la ha rechazado.

6.4. Contenido y efectos de la cláusula

En cuanto a su contenido, se trata de una obligación de no hacer (no celebrar acto enajenativo). Supuesta su validez, si el deudor la infringe enajenando el bien, es aplicable el **art. 1555**. Por ello se ha señalado que la cláusula implica una verdadera condición resolutoria, que se cumple cuando el obligado a no enajenar, enajena; respecto del tercero adquirente, sus efectos le alcanzarán o no conforme a los **arts. 1490 y 1491**.

7. CLASIFICACIONES DEL DERECHO DE PROPIEDAD

(i) Según su titularidad.

La propiedad puede ser individual, asociativa o colectiva, según el propietario sea un particular, un grupo de individuos (generalmente organizado como persona jurídica, como una cooperativa) o el Estado.

(ii) Según la naturaleza del objeto.

Puede ser propiedad civil o común, agraria, urbana, intelectual, minera, horizontal, etc.

(iii) Según la integridad de facultades.

Puede haber propiedad plena, provista de los atributos de uso, goce y disposición, o propiedad nuda, que contiene solo el derecho de disposición jurídica del objeto, perteneciendo a otro las facultades de uso y goce, configurándose en este un derecho de usufructo (**art. 582** inc. 2º).

(iv) Según su duración.

Se distingue entre propiedad absoluta, no sometida a duración o término, y propiedad fiduciaria, sometida al evento de traspasarse a otro si se cumple una condición (**art. 733**).

8. ASPECTOS PASIVOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD

8.1. Las obligaciones reales

Las obligaciones reales, también llamadas *propter rem*, son las que incumben al propietario o al poseedor de una cosa por el solo hecho de serlo. Presentan dos particularidades: el deudor se determina atendiendo a quién es propietario o poseedor de la cosa, de ahí su nombre (en razón o por causa de la cosa); y la obligación se traspasa al sucesor particular en forma automática, sin que sea necesaria ninguna estipulación especial de transferencia. Por seguir a la cosa y gravar a los adquirentes sucesivos, desvinculando por lo general al enajenante, la obligación real es una especie de obligación "ambulatoria".

EJEMPLO

Disposiciones que consagran obligaciones propter rem

El **art. 858**, que establece la obligación de contribuir, a prorrata de los derechos de cada uno, en las expensas de construcción, conservación y reparación del cerramiento; el **art. 859**, sobre los árboles medianeros; el **art. 942**, en relación con las acciones posesorias especiales; y el **art. 1962**, sobre la obligación de respetar el contrato de arrendamiento.

8.2. Las cargas reales

Son gravámenes que, con carácter periódico o intermitente pero en todo caso reiterado, nacen de la ley o de un contrato y pesan sobre quien es dueño o poseedor de una cosa, precisamente por tal razón. Pueden consistir en entregar cualquier cosa (productos de un predio, dinero) o en realizar prestaciones de naturaleza personal: las contribuciones o impuesto territorial sobre bienes raíces, los derechos de pavimentación, el censo o canon que debe pagar el censuario (**art. 2032**), o la obligación de pagar los gastos comunes que tiene el dueño de un departamento.

NO CONFUNDIR

Obligaciones reales vs. cargas reales

Ambas gravan a quien es dueño o poseedor de una cosa por el solo hecho de serlo, pero las obligaciones reales son, por regla general, de ejecución única (nacen y se extinguen con un hecho puntual, como reparar un cerramiento), mientras que las cargas reales tienen carácter periódico o intermitente y reiterado, como los gastos comunes o el impuesto territorial.

8.3. Responsabilidad por la propiedad

Aparte de las obligaciones reales, la ley impone una responsabilidad específica al propietario de una cosa, a lo menos en dos casos: la responsabilidad del dueño de un animal (**arts. 2326 y 2327**) y la responsabilidad del dueño de un edificio (**arts. 2323 inc. 1º y 934**), aunque si la víctima es un vecino, la responsabilidad solo procede si el daño se produce después de notificada la querrela de obra ruinosa. Si el daño proviene de un vicio de construcción, la responsabilidad recae sobre el empresario o arquitecto que se encargó de ella (**art. 2324** en relación con la regla 3ª del **art. 2003**). Se trata de casos de responsabilidad extracontractual, específicamente de presunciones de culpabilidad por el hecho de las cosas.

9. LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO

El Código no contiene una regulación sistemática de la materia, y la doctrina nacional no le ha dedicado mucha atención. El dominio puede extinguirse por varias causas, distinguiéndose entre modos absolutos, con los que desaparece el derecho (si posteriormente la cosa llega a adquirirse por un nuevo titular, la adquisición es originaria), y modos relativos, con los que solo cambia de titular, produciéndose un traspaso.

9.1. Modos de extinción absolutos

Los hay con y sin voluntad del dueño:

(i) La destrucción de la cosa.

Puede ser voluntaria o involuntaria. Jurídicamente, la destrucción importa cuando la cosa pierde su función o rol económico; si se destruye parcialmente, o quedan restos de ella, se entiende que el titular sigue siendo dueño, pero de la cosa reducida o transformada.

(ii) La recuperación de la libertad de los animales cautivos o domesticados.

Puede ser voluntaria o involuntaria. Existen reglas especiales en el título de la ocupación (**arts. 608, 619, 620 y 621**).

(iii) Las especies al parecer perdidas.

Sin voluntad del dueño: encontrada la cosa, se subasta, y el subastador adquiere el dominio originariamente (**arts. 632, 633, 637 y 642**).

(iv) La in comerciabilidad sobreviviente.

Sin voluntad del dueño: la hipótesis más corriente tiene lugar cuando una cosa pasa a ser un bien nacional de uso público, generalmente por la vía de una expropiación.

(v) El abandono.

Por definición es voluntario, y es admisible conforme a los **arts. 12 y 624**. Tratándose de inmuebles, el Fisco adquiere el dominio originariamente y de pleno derecho por el modo de adquirir ley (**art. 590**); tratándose de muebles, el eventual adquirente posterior adquiere el dominio, asimismo, originariamente, por ocupación.

9.2. Modos de extinción relativos

También se distingue entre la transferencia voluntaria y la que se produce con prescindencia de la voluntad del titular. En la transferencia voluntaria se incluye la tradición, con todos los títulos traslativos que le sirven de antecedente. En la no voluntaria se incluyen habitualmente diversas formas de accesión, la expropiación y la prescripción, aunque respecto de esta última es discutible que exista propiamente una "transferencia".

C. LA COPROPIEDAD

1. TERMINOLOGÍA

Tanto en la ley como en la doctrina se emplean indistintamente varios conceptos relacionados con la materia: indivisión, comunidad, condominio y copropiedad. El primero, "indivisión", parece ser el más comprensivo y puede utilizarse para referirse a los otros; "condominio" y "copropiedad" se tienen generalmente como sinónimos.

Algunos autores denominan "comunidad" a la indivisión sobre una universalidad jurídica, como la herencia, y "copropiedad" o "condominio" a la que recae sobre especies o cuerpos ciertos.

Otros entienden que "comunidad" es el género indivisión de cualquier derecho que pertenece a dos o más sujetos y que se ejerce sobre un mismo objeto (comunidad de propiedad, de usufructo, de servidumbre, etc.), y que "copropiedad" o "condominio" es la especie indivisión del derecho de dominio: hay comunidad cuando dos o más sujetos tienen un derecho de idéntica naturaleza jurídica sobre la totalidad de un mismo objeto (lo característico es que los derechos de los comuneros sean análogos, por eso no hay comunidad entre el nudo propietario y el usufructuario aunque sus derechos recaigan sobre la misma cosa), y hay copropiedad o condominio cuando dos o más sujetos tienen el dominio sobre la totalidad de un mismo objeto.

2. NATURALEZA JURÍDICA

Dos grandes concepciones se han elaborado para explicar la naturaleza de la comunidad, y ambas han inspirado las diferentes reglamentaciones.

2.1. Doctrina romana

Considera la comunidad una modalidad del dominio, en la cual cada comunero tiene una cuota parte en la cosa común y, además, derecho a la cosa en su totalidad. Cada comunero tiene una cuota abstracta o ideal, puesto que la cosa no se halla dividida materialmente, y es dueño exclusivo de esa fracción intelectual, pudiendo ejercitar derechos sobre ella como tal. Considerada la cosa en concreto y en su totalidad, todos tienen derecho a ella, pero el derecho de cada uno está limitado por el concurso de los demás, de modo que ninguno puede ejecutar actos materiales o jurídicos sobre ella sin el consentimiento de todos los otros. Esta doctrina, individualista, estima a la comunidad nada más que como una modalidad del dominio.

Se le critica por sus contradicciones conceptuales: es contradictorio concebir un dominio exclusivo y a la vez plural, con poderes que se extenderían a la totalidad de la cosa, cuando uno de los caracteres del dominio es precisamente ser exclusivo. Además, el derecho de propiedad permite obtener del bien el máximo de utilidades, usarlo, gozarlo y disponer de él arbitrariamente, características que no se dan en la copropiedad, donde el derecho de cada comunero está limitado por el de los

demás. A esta crítica jurídica se agrega una económica: la copropiedad romanista, al ser esencialmente individualista, permite a cada cual disponer de su cuota y, a la vez, entabrar la utilización de la cosa por los demás, disminuyendo con ambas facultades la productividad de los bienes comunes.

2.2. Doctrina germánica

Abandona la noción de propiedad exclusiva y hace predominar el derecho del grupo por sobre el del individuo. Según esta concepción, la comunidad es una propiedad colectiva, llamada también "de manos juntas" o "en mano común" (*gesammte hand*), en que el objeto pertenece a todos los comuneros considerados colectivamente, como un solo titular. No se tienen derechos sobre cuota: todos tienen un derecho de goce sobre el objeto, cualitativamente igual pero parcial, limitado por el derecho de los demás, al punto de llegar a negarse a los comuneros incluso la acción para pedir la partición de la cosa común.

3. LA COMUNIDAD EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO

3.1. Naturaleza jurídica de la comunidad

La doctrina nacional estima que el Código chileno adopta fundamentalmente la doctrina romana, conclusión a la que se llega por los antecedentes de su elaboración y por el contenido de varios preceptos que reconocen la noción de cuota y permiten al comunero celebrar respecto de ella diversos actos sin el consentimiento de los otros, siendo la noción de cuota, precisamente, el rasgo distintivo de la concepción romana.

3.2. Regulación

A diferencia de algunos precedentes legislativos, el Código chileno dedica un título especial a la comunidad, tratándola como cuasicontrato y regulándola, en consecuencia, en el libro de las obligaciones (**arts. 2304** y siguientes, inspirados directamente en las enseñanzas de **POTHIER**) y no en el de los bienes, como ocurre en otras codificaciones. Hay, además, numerosas disposiciones sobre la materia diseminadas por el Código, y deben tenerse presentes las reglas sobre partición de bienes hereditarios (**arts. 1317** y siguientes), que tienen aplicación general en virtud de disposiciones expresas (**arts. 1776, 2115 y 2313**).

El legislador no favorece el estado de indivisión, porque constituye fuente permanente de discordia entre los comuneros en el aprovechamiento de la cosa común, inhibe las posibilidades de inversiones y mejoras por la incertidumbre sobre la suerte definitiva del objeto, e impide la libre circulación de esos bienes. En el mismo sentido, el Código dispone que la partición de la cosa común "podrá siempre pedirse" (**art. 1317**), de donde se deriva que la acción de partición es imprescriptible.

4. FUENTES DE LA INDIVISIÓN

La comunidad puede tener por causa un hecho, un contrato o la ley.

a. Un hecho.

El más frecuente es la muerte del causante, que origina la comunidad hereditaria cuando hay dos o más herederos.

b. Un contrato.

La indivisión nace de un contrato si dos o más personas adquieren en común una cosa por cualquier título de dominio seguido de la tradición, o si el dueño exclusivo de un bien se desprende de una cuota de su dominio cediéndosela a una o más personas.

c. La ley.

Entre los casos de indivisión que tienen por fuente un texto legal pueden citarse los bienes afectos al uso común en los edificios o conjuntos habitacionales acogidos a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, la medianería y las servidumbres.

5. CLASES DE INDIVISIÓN

5.1. Según el objeto sobre el que recae

Conforme a este criterio, puede haber comunidad sobre una universalidad o sobre una cosa singular. Es la única clasificación que reconoce el Código (**arts. 1317 y 2304**), pero ha dado lugar a intensos debates doctrinales.

a) En cuanto a la clase de universalidades sobre las que puede haber comunidad

Hay quienes entienden que puede haber comunidad tanto en universalidades de hecho como en universalidades de derecho o jurídicas, siendo la herencia el ejemplo de estas últimas que menciona el **art. 2306**; discutiblemente se agrega la comunidad que queda al disolverse la sociedad conyugal o una sociedad civil o comercial, y en general cada vez que la comunidad recae sobre un patrimonio o masa de bienes con activo y pasivo propios.

En contrario se ha sostenido que, siendo un rasgo distintivo de las universalidades jurídicas el tener un pasivo, en Chile no puede haber comunidad sobre universalidades jurídicas, porque en virtud de los **arts. 1354 y 2306**, habiendo dos o más comuneros, el pasivo está siempre, por el solo ministerio de la ley, dividido entre los copartícipes.

b) En cuanto a los efectos de la adjudicación

La generalidad de la doctrina nacional afirma que el Código chileno siguió la noción romana de la comunidad, conforme a la cual, en la partición de la comunidad, se asigna a la adjudicación un efecto atributivo. La comunidad puede terminar por varias causales conforme al **art. 2312**; una es la partición, que puede efectuarse por acuerdo entre los comuneros, por juez partidor o por decisión del causante cuando la comunidad es de origen hereditario. La partición es el conjunto de actos tendientes a distribuir los bienes comunes entre los comuneros en proporción a sus cuotas; la adjudicación es el acto por el cual el comunero recibe un bien determinado de la comunidad en pago de su cuota.

Conferir efecto atributivo a la adjudicación significa que, cuando a un comunero se le adjudica un bien, es dueño de ese objeto desde el día de la adjudicación: esta constituye título traslativo de dominio y, al entregársele la cosa, se configura una enajenación (la adjudicación "atribuye dominio"). Se opone al efecto declarativo, por el cual se considera que el adjudicatario es dueño del objeto desde el día en que se originó la comunidad y, recíprocamente, que nunca tuvo derechos en los demás bienes adjudicados a otros comuneros (la adjudicación "declara" un dominio ya existente), de modo que no es título traslativo ni constituye enajenación.

EJEMPLO

Por qué importa la opción entre efecto atributivo y declarativo

Uno de los comuneros, sin acuerdo de los otros, constituye un usufructo sobre un bien de la comunidad, y después ese bien le es adjudicado precisamente a él. Con el efecto atributivo, el usufructo fue constituido por quien no era dueño, porque solo lo es desde la partición. Con el efecto declarativo, lo constituyó el dueño, porque lo es desde que se originó la comunidad.

NO CONFUNDIR

Chile se apartó aquí de la concepción romana

Aunque la doctrina nacional entiende que el Código chileno sigue, en general, la concepción romana de la comunidad, en materia de efectos de la adjudicación se apartó de ella y consagró el efecto declarativo (**art. 1344**; el **art. 718** establece el mismo efecto para la posesión).

c) En cuanto a la comunicación entre la cuota y el bien común

Cuando la comunidad recae sobre una universalidad surge un problema de relevante alcance práctico: si existe o no comunicación entre la cuota y los bienes que integran la universalidad. La concepción romana indica que sí están comunicados, en dos sentidos: la cuota en la universalidad se aplica o imprime en cada uno de los bienes que la integran (si hay un automóvil, una casa y un fundo, cada comunero tiene una cuota en cada uno de ellos), y la naturaleza de los bienes queda

impresa en la cuota, de modo que si en la comunidad hay solo muebles la cuota es mueble, si solo hay inmuebles es inmueble, y si hay de ambas clases, es mixta.

El Código chileno no expresó alternativa sobre este punto. La doctrina nacional dominante, aunque admite que el Código se inspira en la concepción romana, estima que en esto no la siguió: no se produce comunicación de la cuota a los distintos bienes, y el derecho de cada comunero recae sobre el todo común abstractamente considerado, no sobre las cosas o partes materiales de él. Si A y B son los únicos herederos de una persona que dejó un fundo y una casa, cada heredero es dueño de la mitad de la herencia, pero no de la mitad del fundo ni de la mitad de la casa.

Se dan como argumentos de esta conclusión: el **art. 1909**, por el que el cedente del derecho de herencia no responde de la existencia de bienes determinados sino solo de su calidad de heredero, lo que se justifica porque su derecho recae únicamente sobre la universalidad; el **art. 686**, que ordena inscribir el dominio y otros derechos reales sobre inmuebles pero no menciona al derecho real de herencia, precisamente porque, al recaer sobre una abstracción, no es inmueble ni mueble; y el efecto declarativo de la adjudicación (**arts. 718 y 1344**), opuesto al efecto atributivo romano, que también sería contrario a la comunicación.

Si no se produce la comunicación, la cuota escapa a la clasificación de los bienes en muebles e inmuebles, con importantes consecuencias: si se enajena la cuota, su tradición no requiere inscripción conservatoria (reservada para inmuebles), bastando cualquiera de las formas de tradición de los muebles del **art. 684**; y si el indivisario es incapaz, no se requieren las formalidades habilitantes prescritas para enajenar bienes raíces suyos. Si la comunidad recae sobre una cosa singular, en cambio, no hay duda de que la cuota de cada uno se radica en el único objeto de la comunidad y participa de su carácter (**art. 580**): si es un inmueble, la tradición de la cuota requerirá inscripción, y su enajenación por un incapaz necesitará de las formalidades habilitantes correspondientes.

5.2. Según su origen

La comunidad puede derivar de un hecho (como la comunidad hereditaria, que nace con la muerte del causante), de la voluntad del titular (dos o más personas adquieren en común un bien, o un propietario enajena una cuota) o de la ley (medianería, servidumbres, propiedad horizontal).

5.3. Según su duración

Pueden ser temporales o perpetuas. Las temporales, por regla general indeterminadas en el tiempo, pueden tener duración determinada en virtud del llamado "pacto de indivisión", que por la adversidad legal a la comunidad está sujeto a limitaciones (**art. 1317**): a falta de pacto, la regla es que la partición puede pedirse en cualquier tiempo. Las perpetuas las establece la ley, aunque en el fondo derivan más bien de la naturaleza misma de las cosas, como la comunidad en la propiedad horizontal o la medianería.

6. LA CUOTA

Con la concepción romana, en nuestros textos los derechos y obligaciones de los comuneros en la cosa común se precisan a través de la noción de cuota o cuota parte: es la porción ideal, determinada o determinable, que cada comunero tiene en el objeto de la comunidad. Las cuotas pueden ser iguales o desiguales; a falta de prueba en contrario se entienden iguales (**arts. 1098 y 2307**), y se expresan generalmente en fracciones o porcentajes.

El comunero puede vender o ceder libremente su cuota, por acto entre vivos (**arts. 1320 y 1812**) o por causa de muerte (**art. 1110**); puede reivindicarla (**art. 892**); puede hipotecarla (**art. 2417**); y puede ser embargada (**art. 524** del Código de Procedimiento Civil), sin perjuicio de los actos materiales que los comuneros pueden ejecutar en la cosa común (**arts. 2305 y 2081**), pudiendo cualquiera pedir el cese del goce gratuito que de la cosa común haga otro comunero.

7. ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD

Las escasas normas legales que regulan la comunidad no contienen una reglamentación explícita y general sobre su administración (con la excepción de la copropiedad inmobiliaria, que tiene reglamentación especial), por lo que esta es una de las materias que mayor controversia práctica genera la indivisión, agravada por la falta de claridad de las normas del Código Civil y del Código de Procedimiento Civil en diversos aspectos. Conviene distinguir dos situaciones: la administración de la comunidad sin acuerdo entre los comuneros ni administrador designado, y la designación judicial de un administrador proindiviso.

7.1. Administración sin acuerdo ni administrador designado

La doctrina y jurisprudencia entienden que a esta materia se refiere, implícitamente, el **art. 2305**, en cuanto dispone que el derecho de cada comunero sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social, remitiéndose de forma bastante unánime al **art. 2081**, contenido en las normas sobre la sociedad colectiva civil.

a) Debate sobre el mandato tácito y recíproco entre comuneros

Se discute si, a falta de convención, existe entre los comuneros un mandato recíproco que habilite a cualquiera de ellos para realizar actos de administración sobre la cosa común. Es relevante determinarlo, porque de existir el mandato, los actos de un comunero obligan a los demás aunque no hayan reportado utilidad a la comunidad; de no haberlo, el comunero que actúa lo hace como agente oficioso y, conforme al **art. 2290**, solo obliga al resto en la medida en que el acto hubiere sido útil.

La doctrina que afirma la existencia del mandato tácito y recíproco se sustenta en que el **art. 2305** se remitiría ampliamente al **art. 2081**, incluido su inciso primero, que dispone que, no habiéndose conferido la administración a uno o más de los socios, se entiende que cada uno ha recibido de los

otros el poder de administrar. De existir este mandato, cada comunero quedaría investido de las potestades que señala el **art. 2078**: cuidar de la conservación, reparación y mejora de los bienes comunes, sin poder empeñarlos, hipotecarlos ni alterar su forma, salvo que actúe como agente oficioso en alteraciones urgentes que no dieron tiempo para consultar a los demás comuneros.

Otros autores nacionales, como **SOMARRIVA** y **CLARO SOLAR**, estiman que el mandato tácito y recíproco no opera en la comunidad, porque la sociedad y la comunidad tienen diversa naturaleza (la primera nace de un acto voluntario con *affectio societatis*, ausente en la comunidad, donde los comuneros muchas veces ni siquiera se conocen), porque la remisión del **art. 2305** al **art. 2081** se circunscribe al derecho de los comuneros en la cosa común y no a su administración, y porque el **art. 2307**, al hacer responsable solo al comunero que contrajo una deuda en pro de la comunidad, evidenciaría que no existe representación recíproca.

DATO DE GRADO

¿Existe mandato tácito y recíproco entre comuneros?

La jurisprudencia ha aceptado por mucho tiempo la aplicación del mandato tácito y recíproco a la comunidad, pero actualmente hay fallos en sentidos distintos. Conviene tener presentes ambas posiciones y sus argumentos, porque de la respuesta depende si los actos de administración de un comunero, adoptados sin consultar a los demás, los obligan o no.

b) Prohibición de hacer innovaciones en los inmuebles comunes

Aun aceptando que en las comunidades opera el mandato tácito y recíproco, rige la prohibición del **art. 2081 N° 4**: ninguno de los socios puede hacer innovaciones en los inmuebles que dependan de la sociedad sin el consentimiento de los otros. La innovación se entiende como una modificación que cambia el destino de la cosa, como transformar una casa habitación en almacenes comerciales, o destinar a plantación de arboledas un campo de siembra de cereales; hay autores que dan un sentido aún más amplio a la palabra, entendiendo que también la hay cuando cambia significativamente la estructura o el valor de la cosa.

Sobre la construcción que un comunero hace en el terreno común, **SOMARRIVA**, siguiendo a la doctrina francesa, afirma que si los demás comuneros consideran inútiles las obras, pueden exigir el restablecimiento de las cosas al estado primitivo y la demolición, y que si prefieren conservarlas, el comunero constructor podría entablar una acción de reembolso para evitar un enriquecimiento sin causa. Parece más ajustado a nuestro ordenamiento entender que la demolición no es viable, porque el derecho a solicitarla es de carácter excepcional y ninguno de esos casos se refiere a la comunidad, y que lo edificado en el inmueble común pasa a formar parte de la comunidad a prorrata de la cuota de los comuneros, aplicando el principio del **art. 699**, que da al dueño del terreno el derecho a hacer suyo lo edificado por otro sin su conocimiento, previo pago de las indemnizaciones correspondientes.

c) Derecho a veto (ius prohibendi).

Existe consenso doctrinal y jurisprudencial en que a las comunidades se aplica el derecho a veto o *ius prohibendi* del **art. 2081 N° 1**: cualquier socio puede oponerse a los actos administrativos de otro mientras esté pendiente su ejecución o no hayan producido efectos legales. Cada comunero, cualquiera sea su porcentaje en la comunidad, puede oponerse a que en la cosa común se ejecuten actos jurídicos o materiales. El *ius prohibendi* reconoce, con todo, ciertas mitigaciones:

a. En cuanto a la oportunidad.

Solo puede invocarse mientras esté pendiente la ejecución del acto o este no haya producido efectos legales; producidos los efectos, al comunero afectado solo le cabe demandar indemnización de perjuicios.

b. Los actos de conservación.

Escapan al veto, por estar destinados a evitar detrimentos en la cosa común y mantener su valor y utilidad (**art. 2081 N° 3**).

c. Las acciones judiciales de protección de la cosa común.

También escaparían del requisito de unanimidad, como las que ponen término a una turbación de la posesión o interrumpen una prescripción adquisitiva, por tratarse de una especie de medida conservativa.

En conclusión, sin pacto de administración ni administrador proindiviso, resulta necesaria la unanimidad de los comuneros para administrar sin entorpecimiento la cosa común, con las mitigaciones señaladas.

7.2. Administración por medio de un administrador proindiviso

Atendidos los problemas prácticos que se derivan de exigir unanimidad para la administración, el Código de Procedimiento Civil, a propósito del juicio de partición (**arts. 645** y siguientes), reguló la posibilidad de designar un administrador proindiviso, exigiendo para ello mayoría y no unanimidad.

a) Oportunidad y tribunal competente

Aunque las normas sobre el administrador proindiviso están en el título del juicio de partición, la designación puede solicitarse sin necesidad de que exista tal juicio, cualquiera sea el estado en que se encuentren los bienes comunes y el origen o clase de comunidad. El **art. 653** del Código de Procedimiento Civil dispone que, de no haber juicio de partición, el asunto debe conocerlo la justicia ordinaria a falta de acuerdo entre los comuneros; se discute si es competente el juez del lugar donde está ubicado el inmueble (**arts. 135 y 137** del Código Orgánico de Tribunales) o el del domicilio del comunero citado (**art. 134** del mismo Código), porque la designación de administrador no

busca "reclamar" un inmueble. Iniciado el juicio de partición, el árbitro partidor pasa a tener competencia sobre estas materias.

b) Poderes y mayorías requeridas

Para la designación se cita a todos los interesados a un comparendo, que se celebra con solo los que concurran, aplicándose el **art. 654** inc. 1º del Código de Procedimiento Civil: de no estar todos presentes, solo pueden acordarse las medidas del artículo por mayoría absoluta de los concurrentes que represente al menos la mitad de los derechos de la comunidad, o por resolución del tribunal a falta de mayoría. La jurisprudencia exige que los representantes de los comuneros cuenten con poder especial para designar al administrador y fijarle facultades.

La ley exige, en definitiva, una "doble mayoría": de los concurrentes y de los derechos representados, lo que genera dificultades prácticas cuando solo hay dos comuneros. La jurisprudencia mayoritaria entiende, además, que aun cuando concurran todos los interesados al comparendo, los acuerdos pueden adoptarse por mayoría y no requieren unanimidad.

c) Designación del administrador y sus facultades

Conforme al **art. 654** del Código de Procedimiento Civil, por mayoría pueden adoptarse acuerdos sobre el nombramiento de uno o más administradores, la fijación de sus salarios, atribuciones y deberes, la determinación del giro que deba darse a los bienes comunes y el máximo de gastos permitidos, y la fijación de las épocas en que deba rendirse cuenta a los interesados. Resulta indispensable que, junto con la designación, se establezcan detalladamente sus facultades, pues el administrador tiene la calidad jurídica de mandatario de los comuneros y se le aplican los **arts. 2131, 2134 y 2160**: solo los actos que ejecute dentro de los límites del mandato obligan a la comunidad.

8. LA COPOSESIÓN

La coposesión es a la posesión, en los hechos, lo que la copropiedad es a la propiedad, en el Derecho: tiene lugar cuando dos o más personas detentan con ánimo de dueño, poseen, un mismo objeto. El Código la admite en a lo menos dos normas: el **art. 687**, sobre la inscripción del acto de partición relativo a inmuebles que antes se poseían proindiviso, y el **art. 718**, que entiende que cada partícipe de una cosa poseída proindiviso ha poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere durante todo el tiempo que duró la indivisión.

Siguiendo los principios posesorios, el ánimo de dueño debe inspirar a todos los coposeedores, aunque algunos no detentan materialmente la cosa poseída en común: basta con que uno de ellos la posea a nombre de los otros. Al igual que la posesión, la coposesión puede o no ir acompañada del dominio; cuando no lo está, adquiere especial importancia, pues con ella se puede adquirir el dominio por prescripción. Se ha discutido si entre los comuneros coposeedores puede haber prescripción, materia que se estudia a propósito de la prescripción adquisitiva.

9. LA COPROPIEDAD INMOBILIARIA

Las exigencias del desarrollo urbano, la escasez del suelo y la necesidad de limitar la excesiva extensión de las ciudades han originado la construcción de edificaciones de altura, cuya propiedad se reparte entre distintos titulares que utilizan partes de ella con exclusividad. La copropiedad inmobiliaria, también llamada "propiedad horizontal", es un régimen en el cual se es titular del dominio exclusivo sobre determinada unidad de un edificio o sector del suelo, y codueño de modo permanente y en principio irrenunciable de los elementos comunes indispensables a la existencia y disfrute de aquella. En Chile, el cuerpo legal fundamental es la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria (D.O. de 16 de diciembre de 1997), cuyo **art. 48** derogó la antigua Ley N° 6.071 sobre Propiedad Horizontal.

Una síntesis de esta reglamentación:

- a. Los diversos pisos de un edificio y los diversos departamentos de un piso pueden pertenecer a distintos propietarios, régimen posible incluso en construcciones de un solo piso.
- b. Cada propietario es dueño exclusivo de su piso o departamento y comunero de los bienes comunes.
- c. Son bienes comunes los necesarios para la existencia, seguridad y conservación del edificio y los que permiten el uso y goce de la propiedad exclusiva (el terreno, los muros exteriores y soportantes, etc.).
- d. El derecho del comunero sobre los bienes comunes es proporcional al valor de su piso o departamento, y en la misma proporción debe contribuir a los gastos, salvo acuerdo distinto.
- e. Los derechos sobre los bienes comunes son inseparables del dominio, uso y goce del respectivo piso o departamento, de modo que cualquier negociación sobre estos alcanza a aquellos.
- f. Se puede hipotecar o gravar libremente el piso o departamento, sin consentimiento de los demás copropietarios.
- g. Existen normas sobre administración del edificio y relaciones de vecindad.

En cuanto a su fin, rige la indivisibilidad perpetua: mientras exista el edificio, ninguno de los copropietarios puede pedir la división del suelo ni de los demás bienes comunes.

10. EXTINCIÓN DE LA COMUNIDAD

El **art. 2312** señala las causales de extinción: la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona, la destrucción de la cosa común, y la división del haber común. El **art. 1317** autoriza a los comuneros a solicitar la partición en cualquier momento, es decir, nadie está obligado a permanecer en la indivisión, de ahí que la acción de partición sea imprescriptible.

Hay, con todo, casos excepcionales en que no puede hacerse uso de este derecho: cuando se ha pactado la indivisión por un plazo que no puede exceder de 5 años, sin perjuicio de renovarlo si consienten todos los comuneros; y los casos de indivisión forzada, como la copropiedad inmobiliaria, las tumbas o mausoleos, los señalados en los **arts. 1728 y 1729** a propósito de la sociedad conyugal, o la propiedad fiduciaria mientras penda la condición.

D. LOS MODOS DE ADQUIRIR: ASPECTOS GENERALES Y LA OCUPACIÓN

1. SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DEL DOMINIO

Para la transferencia de bienes por acto entre vivos se han configurado diversos sistemas, entre los que destacan el de la dualidad título-modo y el sistema consensual.

1.1. Sistema de la dualidad título-modo

Con precedentes del Derecho Romano, en muchas legislaciones, entre ellas la nuestra, para la transferencia del dominio y demás derechos reales se exige la concurrencia de dos elementos jurídicos: un título y un modo de adquirir. Título es el hecho o acto jurídico que sirve de antecedente para la adquisición del dominio; modo de adquirir es el hecho o acto jurídico que produce efectivamente la adquisición. Con el solo título no se adquiere el dominio de las cosas: de él nace solamente un derecho personal, el de exigir que posteriormente se transfiera el dominio mediante el correspondiente modo de adquirir.

EJEMPLO

Título y modo en la compraventa

Perfeccionado el contrato de compraventa, el comprador aún no es dueño de la cosa comprada, ni el vendedor la ha hecho ajena: con el contrato (título) el vendedor solo se ha obligado a transferirla al comprador. El dominio se transfiere después, cuando el vendedor efectúa al comprador la entrega o tradición (modo) de la cosa vendida.

1.2. Sistema consensual

Frente al sistema de la dualidad, existe el sistema consensual o del efecto real del contrato, en cuya virtud el solo título es suficiente para producir la transferencia del dominio, sin necesidad de recurrir al modo. El Código Civil francés sigue esta tendencia: la propiedad se transfiere y adquiere por el solo efecto del contrato, y la tradición pierde su calidad de modo de adquirir, representando solo la ejecución de la obligación del vendedor de poner la cosa a disposición del comprador.

1.3. Sistema del Código Civil chileno

Nuestro Código adoptó el sistema romano del título y modo, o del efecto personal del contrato. El Mensaje, a propósito de la transferencia del dominio de inmuebles por tradición, expresa que la transferencia y transmisión de dominio y la constitución de todo derecho real, salvo las servidumbres, exige una tradición, y que mientras esta no se verifica, un contrato puede ser perfecto y pro-

ducir obligaciones entre las partes, pero no transfiere el dominio ni tiene respecto de terceros existencia alguna.

Configuran el sistema, fundamentalmente, el **art. 588** (que enumera los modos de adquirir), y los **arts. 670 y 675**, que disponen que la tradición es un modo de adquirir el dominio y que, para que valga, se requiere un título traslativo de dominio, como el de venta, permuta o donación. Debe advertirse, con todo, que este sistema no se da con absoluta pureza en el Derecho chileno, pues hay casos en que se le da un efecto real al contrato.

2. RESERVA LEGAL Y ENUMERACIÓN

Conforme al **art. 19 N° 24** de la Constitución, solo la ley puede establecer los modos de adquirir el dominio. El **art. 588** del Código enumera los siguientes: la tradición, la ocupación, la accesión, la sucesión por causa de muerte y la prescripción. A ellos debe agregarse la propia ley, que en ciertos casos opera como modo de adquirir: por ejemplo, el usufructo legal (más propiamente, derecho real de goce) del padre o madre sobre los bienes del hijo no emancipado (**art. 810**), la atribución de dominio que el **art. 626** hace al dueño del terreno sobre el tesoro encontrado en su propiedad, o la ley de expropiación, que la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que sirve de título y modo de adquirir el bien expropiado.

3. CLASIFICACIONES

3.1. Originarios y derivativos

El modo es originario si permite adquirir la propiedad independientemente del derecho de un antecesor, como ocurre en la ocupación, la accesión y la prescripción. Es derivativo si por él se adquiere el dominio traspasado de otro titular que por ello es el antecesor, como la tradición y la sucesión por causa de muerte. La distinción importa para determinar el alcance del derecho del adquirente: si el modo es originario, basta examinar el hecho que lo configura y la cosa sobre que recae; si es derivativo, es preciso examinar además los derechos que tenía el antecesor, pues nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Así, si el tradente no era dueño de la cosa, el adquirente no adquiere el dominio (**art. 682**), e igualmente si la cosa estaba gravada, el adquirente la recibe con esas limitaciones.

3.2. A título universal y a título singular

Se clasifican según se puedan adquirir con ellos universalidades jurídicas o bienes determinados. La ocupación y la accesión permiten adquirir solo bienes específicos: son modos a título singular. Por la sucesión por causa de muerte pueden adquirirse tanto bienes determinados (legados de especie o cuerpo cierto) como universalidades (herencias). La tradición y la prescripción son generalmente modos a título singular, pero excepcionalmente lo son también a título universal, cuando un

heredero transfiere su derecho de herencia o cuando un heredero aparente llega a adquirir por prescripción la herencia de que está en posesión.

3.3. Por acto entre vivos y por causa de muerte

Según presuponga o no la muerte del titular del derecho para que el modo opere. La clasificación existe precisamente por la sucesión por causa de muerte, que se configura a la muerte del causante; todos los demás modos son por acto entre vivos.

3.4. A título gratuito y a título oneroso

Según signifiquen o no una contraprestación pecuniaria para el adquirente. Son a título gratuito la ocupación, la accesión, la prescripción y la sucesión por causa de muerte. La tradición puede revestir uno u otro carácter según el título que le sirve de antecedente: gratuito si es una donación, oneroso si es una compraventa.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Los modos de adquirir también sirven para adquirir otros derechos reales y aun derechos personales. La tradición y la sucesión por causa de muerte sirven para adquirir cualquier derecho real o personal. Dentro de los derechos reales, la ocupación y la accesión se aplican solo al dominio; la prescripción, en cambio, sirve para adquirir todos los derechos reales, menos las servidumbres discontinuas e inaparentes.

Por la ocupación pueden adquirirse las cosas corporales muebles, ya que los inmuebles que carecen de dueño pasan al Estado (**art. 590**). La accesión tiene un campo más extenso, pues permite adquirir cosas muebles e inmuebles. Por la prescripción se extiende aún más la posibilidad de adquisición: además de las cosas corporales, muebles o inmuebles, pueden adquirirse las cosas incorpóreas, indiscutiblemente los derechos reales, salvo las servidumbres discontinuas e inaparentes (**art. 882**); se discute si los derechos personales serían susceptibles de adquirirse por prescripción adquisitiva.

La tradición permite adquirir todas las cosas corporales, muebles e inmuebles, y todas las incorpóreas, sean derechos reales o personales, salvo excepcionalmente los derechos personalísimos, por ser inalienables cuando el tradente es su titular (aunque sí pueden adquirirse por tradición cuando se constituye el derecho real de uso o de habitación, esto es, al momento de nacer el derecho real). Por la sucesión por causa de muerte pueden adquirirse las cosas corporales e incorpóreas y también las universalidades jurídicas, esto es, todo el patrimonio transmisible de una persona, salvo los derechos intransmisibles, como los del comodatario o el usufructo, que se extinguen con la muerte de su titular. Excepcionalmente, es posible adquirir universalidades jurídicas por tradición y por prescripción tratándose del derecho de herencia.

5. SE PUEDE ADQUIRIR POR UN SOLO MODO

No es posible adquirir un bien por dos o más modos: la aplicación de uno de ellos hace innecesario otro, así como no se puede hacer lo ya hecho, tampoco se puede adquirir lo ya adquirido. La jurisprudencia ha declarado reiteradamente que, si bien se puede poseer una cosa por varios títulos, el dominio se adquiere por uno solo, de manera que basta un modo de adquirir y no pueden concurrir varios respecto de unos mismos bienes: para adquirir las cosas heredadas o legadas es suficiente la sucesión por causa de muerte, sin que la tradición sea necesaria.

6. LA EXIGENCIA DEL TÍTULO EN TODOS LOS MODOS DE ADQUIRIR

En doctrina se debate si es necesaria la concurrencia de un título en todos los modos de adquirir o solo en algunos. Es claro, por disponerlo expresamente el **art. 675**, que la tradición requiere un título traslativo de dominio. Respecto de los demás modos, algunos autores sostienen que también se exige título, atendidos el **art. 703**, que llama a la ocupación, accesión y prescripción "títulos constitutivos de dominio", y el **art. 951** y siguientes, que para la sucesión por causa de muerte identifican como título el testamento o la ley; en estos tres modos, el título se confundiría con el modo.

Otros entienden que el título solo se exige para la tradición, como lo dispone expresa y excepcionalmente el **art. 675**, cuestión ratificada por el párrafo del Mensaje que alude exclusivamente a ella. Cuando el **art. 703** menciona los títulos constitutivos y califica de tales a la ocupación, accesión y prescripción, no se estaría refiriendo al dominio sino a la posesión: serían allí títulos para poseer, cuando por falta de requisitos u otras circunstancias no funcionan como modos de adquirir. De rechazarse esta distinción, se llegaría a la incongruencia de que quien empieza a poseer sería ya dueño.

Se agrega que existen incluso casos en los que la tradición se verifica precisamente por la celebración de un contrato, confundiéndose título y modo: el más evidente es el de las tradiciones fictas de bienes muebles del **art. 684 N° 5**, llamadas "brevi manu" y "constituto posesorio", en que la tradición se verifica por la venta, donación u otro título de enajenación, o por el mero contrato.

7. CONCEPTO DE LA OCUPACIÓN

La ocupación es un modo de adquirir el dominio de las cosas corporales muebles que no pertenecen a nadie, mediante la aprehensión material de ellas acompañada de la intención de adquirirlas, siempre que esa adquisición no esté prohibida por las leyes patrias ni por el Derecho Internacional. Se encuentra regulada en los **arts. 606 a 642**.

8. ELEMENTOS

Del concepto pueden observarse dos elementos: la aprehensión material y la intención de adquirir el dominio. Ambos, físico y psíquico, deben concurrir copulativamente, de ahí que quienes carecen de voluntad, como los dementes y los infantes, no puedan adquirir por este modo (del **art. 723** inc. 2º se podría desprender que los impúberes que ya dejaron de ser infantes sí serían hábiles para adquirir por ocupación).

9. REQUISITOS

(i) Que la cosa aprehendida carezca de dueño.

Son las llamadas *res nullius*: pueden ser cosas que nunca han tenido propietario (los animales bravíos) o que dejaron de tenerlo (los animales domesticados que recobran su libertad natural), y también las abandonadas por su dueño al primer ocupante, llamadas *res derelictae* (el ejemplo clásico son las monedas que se arrojan a la multitud). Como se requiere una cosa sin dueño, y en virtud del **art. 590**, este modo de adquirir solo se aplica en Chile a los bienes muebles: si la aprehensión con ánimo de adquirir recae sobre una cosa que tiene dueño, no opera la ocupación, aunque permite al ocupante entrar en posesión de la cosa y, eventualmente, adquirir el dominio después de un tiempo por prescripción.

(ii) Que la adquisición no esté prohibida por las leyes o el Derecho Internacional.

Los animales que según las leyes chilenas pueden adquirirse por caza o pesca no pueden serlo en la época en que las ordenanzas respectivas prohíban esas actividades sobre determinadas especies (**art. 622**). En el ámbito del Derecho Internacional se prohíbe, por ejemplo, el pillaje: la apropiación individual que hace un soldado o particular, y no el Estado enemigo, de los bienes de propiedad particular de los vencidos.

(iii) Aprehensión material de la cosa con intención de adquirirla.

Dentro de este requisito se distinguen la aprehensión material (elemento físico o de hecho) y el ánimo de adquirir el dominio (elemento intencional). La aprehensión puede ser real, cuando efectivamente el individuo toma la cosa, o presunta, cuando sin haber aprehensión material efectiva, el individuo ejecuta actos que ponen de manifiesto su intención de adquirirla, como el cazador que hiere a su presa de manera que no pueda escapar y va tras su búsqueda. Ambos elementos deben concurrir copulativamente: la aprehensión material no puede faltar, porque todo modo de adquirir es un hecho, y tampoco puede faltar el ánimo, razón por la cual los dementes y los infantes no pueden adquirir por ocupación.

10. REGLAS PARTICULARES

El Código da un variado conjunto de reglas para especies de distinta naturaleza susceptibles de adquirirse por ocupación.

10.1. Ocupación de cosas animadas

Opera a través de la caza y la pesca. El **art. 608** clasifica las cosas animadas en animales bravíos o salvajes, domésticos o domesticados; de él se concluye que solo pueden adquirirse por caza o pesca los animales bravíos y los domesticados que, saliendo de la dependencia del hombre, vuelven a su condición de animales bravíos (**arts. 619 a 623**).

En materia de caza, se puede cazar en tierras propias; no se puede cazar en tierras ajenas salvo con permiso del dueño o salvo que no estén cercadas, plantadas o cultivadas, y ni aun en ese caso si el dueño prohibió expresamente la caza y notificó la prohibición; y si se caza en tierras ajenas sin el permiso requerido, lo cazado queda para el dueño del terreno y el cazador debe indemnizarle los perjuicios (**arts. 609 y 610**).

La pesca se rige, además de los **arts. 611 a 616**, por la Ley General de Pesca y Acuicultura (Ley N° 18.892), que somete a sus disposiciones toda actividad pesquera extractiva, de acuicultura e investigación. Los pescadores están autorizados para un uso limitado de las playas de mar y de las tierras contiguas a ella hasta 8 metros, sin tocar construcciones ni atravesar cercas, arboledas o siembras (**arts. 612 a 614**); en ríos y lagos de uso público (**art. 597**), un DFL de 1931 permite ocupar las riberas hasta 5 metros.

Se entiende que el cazador o pescador se apodera del animal bravío y lo hace suyo desde que lo hiere gravemente, de modo que no le sea fácil escapar y siga persiguiéndolo, o desde que el animal cae en sus trampas o redes armadas en lugar donde sea lícito cazar o pescar (**art. 617**); y un cazador o pescador no puede perseguir un animal que ya perseguía otro, pudiendo este último reclamarlo como suyo si el primero se apodera de él (**art. 618**).

10.2. Ocupación de cosas inanimadas

a) Invención o hallazgo

Es una especie de ocupación por la cual quien encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio apoderándose de ella (**art. 624**). El nombre viene del latín *invenire*, hallar, y no alude a inventar algo. Requiere que se trate de cosas inanimadas, que sean *res nullius* o *res derelictae*, y que quien encuentre la cosa se apodere de ella, pues de lo contrario no se revela la intención de adquirir el dominio.

Por esta forma de ocupación se adquiere el dominio de cosas que no presentan señales de dominio anterior, como las que arroja el mar; una cosa con señales de dominio anterior no se considera *res nullius*, sino especie al parecer perdida, y no puede adquirirse por invención. El **art. 624** inc. 3°

asimila a las cosas sin dueño las *res derelictae*, siempre que sea manifiesta la intención del dueño de renunciar a su dominio, porque las renunciaciones no se presumen; de ahí la presunción simplemente legal del inciso final del **art. 624** respecto de las cosas que se arrojan al mar para alijar la nave.

b) El descubrimiento de un tesoro

Es, en verdad, una especie de invención o hallazgo. El **art. 625** inc. 2º llama tesoro a la moneda o joyas, u otros efectos preciosos, que elaborados por el hombre han estado largo tiempo sepultados o escondidos sin que haya memoria ni indicio de su dueño. Se requiere que se trate de una cosa mueble, de monedas, joyas u otros objetos preciosos, elaborados por el hombre, que hayan estado sepultados o escondidos durante largo tiempo, y que no haya memoria o indicio del dueño.

El dominio del tesoro se adquiere por el solo hecho del descubrimiento, aunque el descubridor no se apodere de él: la ley exige solo una aprehensión presunta. Para saber a quién pertenece hay que distinguir:

(i) Lo descubre el propietario del suelo.

A él pertenece la totalidad, mitad a título de propietario y mitad a título de descubridor, adquiriéndolo no por accesión sino por ocupación (**art. 626** inc. 3º; no basta ser usufructuario, **art. 786**).

(ii) Lo descubre un tercero en suelo ajeno.

Si el hallazgo fue fortuito o resultado de pesquisas autorizadas por el dueño, el tesoro se divide en partes iguales entre el descubridor y el dueño del suelo; si las pesquisas se hicieron contra la voluntad del dueño o sin su anuencia, todo el tesoro pertenece a este último.

Quien quiera cavar en suelo ajeno buscando especies que asegure pertenecerle debe señalar el paraje, dar competente seguridad de que probará su derecho y de que abonará todo perjuicio al dueño (**art. 627**); si no prueba su derecho, las especies se consideran bienes perdidos o tesoro encontrado en suelo ajeno según los antecedentes, y en este último caso se dividen en partes iguales entre el denunciador y el dueño del suelo, previa deducción de las costas (**art. 628**).

c) La captura bélica

Es el despojo de los bienes del vencido en provecho del vencedor: se llama botín a la captura de cosas muebles en la guerra terrestre, y presa a la de naves y mercaderías en el mar. Los bienes adquiridos por captura bélica pertenecen al Estado (**art. 640**); los particulares no pueden adquirir por esta vía el dominio de bienes de naciones enemigas, neutrales ni aliadas.

Hoy la guerra es de Estado a Estado, y el Derecho Internacional (Cuarta Convención de La Haya, **art. 46**) ordena respetar también la propiedad particular, de modo que en la guerra terrestre solo pueden capturarse las propiedades del Estado enemigo. Esta inviolabilidad no rige para la guerra marítima, donde los beligerantes pueden confiscar como presas naves mercantes y mercaderías

enemigas e incluso neutrales, derecho que hoy solo ejercen los Estados a través de buques de guerra, tras la abolición del corso marítimo por la Declaración Naval de París de 1856.

Las presas hechas por bandidos, piratas o insurgentes no dan dominio, y cualquiera puede "represarlas" para ponerlas a disposición de su dueño, teniendo derecho a que este les abone el precio de salvamento (**art. 641**); si no aparece el dueño a reclamarlas, se procede como con las cosas perdidas, pero los represadores conservan sobre las especies no reclamadas dentro de un mes los mismos derechos que si las hubieran apresado en guerra de nación a nación (**art. 642**).

10.3. Especies muebles al parecer perdidas y especies náufragas

En principio no pueden ser objeto de ocupación, porque no son *res nullius* ni *res derelictae*. Pero como su dueño no se conoce y puede no presentarse a reclamarlas, la ley permite que, tras las diligencias necesarias para averiguarlo, si no se presenta o no hace valer sus derechos, estas cosas se adquieran en la forma que ella indica.

NO CONFUNDIR

Especies al parecer perdidas vs. *res derelictae*

Las *res derelictae* son cosas que su dueño abandonó voluntariamente para que las hiciera suyas el primer ocupante. Las especies perdidas, en cambio, son cosas respecto de las cuales su propietario no ha manifestado en forma alguna la intención de desprenderse del dominio: su separación es involuntaria.

Los **arts. 629 a 639** reglamentan la materia: publicados los avisos correspondientes, si no se presenta el dueño a reclamar las especies, estas se subastan y el producto se reparte en partes iguales entre quien las encontró y la municipalidad respectiva, tratándose de especies al parecer perdidas, o entre quien las encontró y el hospital de la zona, tratándose de especies náufragas. Estas normas están además complementadas por disposiciones especiales de Derecho Administrativo, como el DL 3.063 sobre Rentas Municipales (**art. 43**), que fija en un mes, contado desde que las especies llegaron a poder de la municipalidad, el plazo para reclamarlas, y obliga a la municipalidad a entregar al dueño que reclame dentro de los 6 meses siguientes al remate el valor obtenido en él, menos los gastos.

E. LA ACCESIÓN

1. CONCEPTO

Conforme al **art. 643**, la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a ella.

2. CLASES DE ACCESIÓN

(i) Accesión discreta.

Llamada también "por producción" o "accesión de frutos": deriva del mismo cuerpo o "cosa madre" por medio del nacimiento o producción, y se manifiesta en la generación de productos y frutos.

(ii) Accesión continua.

Llamada también "por unión" o accesión propiamente tal: resulta de la agregación de dos o más cosas diferentes que, luego de unirse, forman un todo indivisible. Puede ser mobiliaria o inmobiliaria según se realice en beneficio de cosa mueble o inmueble, y natural o artificial según se deba a la fuerza de la naturaleza o a la industria humana; algunos agregan la accesión mixta, la que procede de ambas conjuntamente, como la plantación o la siembra.

3. NATURALEZA JURÍDICA

Se discute si la accesión es verdaderamente un modo de adquirir que crea una relación jurídica nueva, o si se trata de una simple facultad o extensión del dominio que nada nuevo crea, sino que prolonga la misma relación jurídica de propiedad. Se han formulado tres teorías.

a. Toda accesión es un modo de adquirir.

Nuestro Código sigue este punto de vista en el **art. 643**, al hablar de "lo que ella produce" (accesión discreta) y "lo que se junta a ella" (accesión continua).

b. Toda accesión es una simple facultad o extensión del dominio.

Tratándose de la accesión discreta, el dominio preexistente sobre la cosa madre se amplía a los frutos que produce. Tratándose de la continua, aunque hace adquirir una propiedad nueva, predomina el aspecto extensivo, porque quien adquiere la cosa por accesión la adquiere como consecuencia del dominio que tenía sobre otra, porque la cosa accesorio pierde su individualidad al unirse con la principal, y porque su adquisición no depende de un nuevo título, sino del mismo título de propiedad de la cosa principal.

c. Solución ecléctica.

Solo la accesión continua sería un verdadero modo de adquirir; la discreta sería una simple facultad del dominio, el ejercicio de la facultad de goce, que habilita al dueño de una cosa para apropiarse los productos y frutos que ella genera, sin que sea necesario invocar un título y modo de adquirir nuevo. En la accesión propiamente tal una cosa pierde su existencia identificándose con otra, y en la discreta ocurre lo contrario: el producto o fruto adquiere existencia propia al separarse de la cosa madre.

La doctrina mayoritaria objeta la inclusión de la accesión entre los modos de adquirir porque, a diferencia de ellos, no atiende a la voluntad del adquirente, y porque la accesión de frutos ya está comprendida en la facultad de goce del propietario.

4. ACCESIÓN DISCRETA O DE FRUTOS

4.1. Concepto

Llamada también "accesión por producción": en virtud de ella, el dueño de una cosa lo es también de lo que la cosa produce.

4.2. Frutos y productos

Se entiende por fruto lo que una cosa da periódicamente y sin detrimento de su sustancia (las flores y frutos de los árboles); es producto lo que una cosa da sin periodicidad o con detrimento de su estructura (las piedras de una cantera). El **art. 643** confunde ambos términos, haciéndolos sinónimos, pero otras disposiciones distinguen los dos conceptos en el sentido descrito (**arts. 537 y 784**). Las características comunes de frutos y productos son su accesoriedad y utilidad, y las diferenciadoras, la periodicidad y el alterar o disminuir sensiblemente la sustancia de la cosa principal.

La distinción no tiene importancia respecto del dueño, pues su dominio siempre abarca unos y otros; sí la tiene cuando se trata de constituir derechos en favor de terceros distintos del dueño de la cosa principal, pues por regla general solo se cede el derecho a gozar de los frutos, como en el usufructo o respecto de los guardadores (**arts. 526, 527 y 537**).

4.3. Clases de frutos

Como indica el **art. 643**, los frutos pueden ser naturales o civiles.

a) Frutos naturales

Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana (**art. 644**). El precepto comprende tanto los propiamente tales, que la cosa da espontáneamente, como los "frutos industriales", producidos con ayuda de la industria humana (el vino, algunos aceites). En

cuanto a su estado, el **art. 645** distingue frutos pendientes, mientras adhieren a la cosa que los produce; percibidos, los que han sido separados de ella; y consumidos, cuando se han consumido materialmente o enajenado. Esta clasificación no tiene importancia respecto del propietario, pero sí respecto de terceros, porque estos solo se hacen dueños de los frutos mediante la percepción (**art. 781**, en el usufructo).

b) Frutos civiles

El fruto civil es la utilidad equivalente que el dueño de una cosa obtiene al conceder a un tercero su uso y goce. El Código no lo define, y se limita a dar ejemplos (**art. 647**), el más típico de los cuales es la renta de arrendamiento; también menciona el interés de capitales exigibles. En cuanto a su estado, se llaman pendientes mientras se deben, y percibidos desde que se cobran.

4.4. El dominio de los frutos

Conforme al **art. 646**, aplicable también a los frutos civiles por el **art. 648**, los frutos pertenecen al dueño de la cosa que los produce por el solo hecho de su producción. Hay casos, sin embargo, en que pertenecen a un tercero, sea por disposición expresa de la ley (los usufructos legales, el poseedor de buena fe que hace suyos los frutos) o en virtud de un hecho voluntario del propietario (el arrendamiento, el usufructo convencional, la anticresis, **art. 2435**), aunque en tales casos el dueño no deja de percibir frutos, civiles, por la contraprestación que recibe.

5. ACCESIÓN CONTINUA

Es la accesión propiamente tal: la unión permanente de dos o más cosas originariamente separadas que pasan a formar un todo indivisible, obra de la naturaleza o del hombre. Puede ser de tres clases: accesión de inmueble a inmueble o natural, accesión de mueble a inmueble o industrial, y accesión de mueble a mueble.

5.1. Accesión de inmueble a inmueble

Regulada en los **arts. 649 a 656**, agrupa sus distintas clases bajo el nombre de "accesiones del suelo".

a) Aluvión

El terreno de aluvión se forma por los sedimentos que el agua va depositando, alejándose poco a poco de su primitiva ribera. El **art. 649** lo define como el aumento que recibe la ribera del mar, de un río o de un lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas; el retiro debe ser, además, definitivo, pues el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas forma parte de la ribera o del cauce y no accede a las heredades contiguas (**art. 650** inc. 2°).

El terreno de aluvión pertenece a los propietarios riberaños, como compensación por el riesgo de ser colindantes con el agua (**art. 650** inc. 1°); excepcionalmente, en los puertos habilitados, pertenece al Estado. Para determinar los límites de la parte que accede a cada heredad, se prolongan las respectivas líneas de demarcación directamente hasta el agua; si estas líneas se cortan antes de llegar a ella, el triángulo formado por ellas y el borde del agua accede a las dos heredades laterales, dividiéndose por una línea recta trazada desde el punto de intersección hasta el agua (**art. 651**).

b) Avulsión

Se llama avulsión el acrecimiento de un predio por la acción de una avenida u otra fuerza natural violenta, que transporta una porción del suelo de un predio al fundo de otra persona. A diferencia del aluvión, hay aquí un terreno perfectamente determinado y de dueño conocido: este conserva su dominio sobre la porción arrancada para el solo efecto de llevársela, pero si no la reclama dentro del año siguiente, la hace suya el dueño del sitio a que fue transportada (**art. 652**).

NO CONFUNDIR

Aluvión vs. avulsión

En el aluvión el retiro de las aguas es lento, imperceptible y definitivo, y no hay un terreno identificable ni un dueño conocido de él: por eso accede directamente a los propietarios riberaños. En la avulsión, en cambio, una fuerza natural violenta transporta de una vez una porción de suelo perfectamente determinada, cuyo dueño se conoce, y que este puede recuperar dentro de un año antes de que acceda al predio de destino.

Se refiere el **art. 653** a la inundación de un predio: si el terreno es restituido por las aguas dentro de los 5 años siguientes, vuelve al dominio de su antiguo dueño (si este solo era poseedor, se suspende durante ese lapso el cómputo del plazo para prescribir, **art. 2502 N° 1**); si pasan los 5 años sin que las aguas se retiren, el dueño pierde su dominio en forma definitiva, y si el terreno queda al descubierto con posterioridad, se aplican las reglas del aluvión (**art. 651**).

c) Mutación del álveo o cambio de cauce de un río

"Álveo" significa madre del río, el cauce original. Se distinguen tres hipótesis: si el río varía su curso, cargándose a una de las riberas y dejando la otra definitivamente en seco, la parte descubierta accede a los propietarios riberaños, como en el aluvión (**art. 654** inc. 1°); si el río varía enteramente de cauce, se traza una línea longitudinal que divida el cauce abandonado en dos partes iguales, accediendo cada una a las heredades contiguas dentro de sus respectivas líneas de demarcación (**art. 654** inc. 2°); y si el río se divide en dos brazos que no vuelven a juntarse, se aplican las reglas anteriores (**art. 655**). En los dos primeros casos, los propietarios riberaños tienen derecho a hacer las obras necesarias para volver el río a su antiguo cauce, con permiso de la autoridad competente.

d) Formación de nueva isla

Se requiere que la isla se forme en ríos o lagos no navegables por buques de más de 100 toneladas (**art. 597**) y con carácter definitivo (**art. 656** regla 1ª). Formada la nueva isla, se distinguen tres situaciones:

(i) Se forma por abrirse el río en dos brazos que luego vuelven a juntarse.

No se altera el dominio anterior de los terrenos comprendidos en ella, aunque el lecho que quede en seco a consecuencia de su formación accede a las heredades contiguas como en el aluvión (**art. 656** regla 2ª).

(ii) Se forma en el lecho del río.

Accede a las heredades de la ribera más cercana, si toda ella queda dentro del espacio entre esa ribera y una línea imaginaria que divida el cauce en dos porciones iguales, o se reparte entre las heredades de ambas riberas si la línea imaginaria toca la isla (**art. 656** regla 3ª).

(iii) Se forma en un lago.

Sin que ninguna heredad esté a la distancia requerida para participar de ella, se discute si pertenece en comunidad a los propietarios riberaños o al Estado por aplicación del **art. 590**, posición esta última que parece más acertada.

5.2. Accesión de mueble a mueble

Se origina cuando se unen dos cosas muebles pertenecientes a distintos dueños. El Código la regula en los **arts. 657 a 667**, resolviendo el problema principal (a quién pertenece la cosa resultante) con el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, para lo cual da criterios de determinación: el valor, venal o de afección, la función, y el volumen.

a) Adjunción

Es una especie de accesión que se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que pueden separarse y subsistir cada una después de separada, como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra (**art. 657**). Requiere la unión de cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños, que conserven su propia fisonomía al separarse, y ausencia de conocimiento de la unión por ambos o alguno de los dueños.

El dominio corresponde al dueño de la cosa principal, quien debe pagar el valor de la accesoria a su dueño (**art. 658**). Para determinar cuál es la principal: si una de las cosas es de mucho más estimación (por regla general, el valor venal, salvo que la cosa tenga para su dueño un gran valor de afección) se mira como principal (**art. 659**); si no hay tanta diferencia, será accesoria la que sirva para el uso, ornato o complemento de la otra (**art. 660**); y si no puede aplicarse ninguna de esas reglas, se mira como principal la de mayor volumen (**art. 661**), correspondiendo al juez fallar con-

forme a la equidad si ambas tienen el mismo volumen (**art. 170 N° 5** del Código de Procedimiento Civil).

b) Especificación

Es la creación o producción de una cosa nueva empleando materia ajena sin el consentimiento del propietario (**art. 662** inc. 1°). Requiere la mano de obra o industria humana, la materia ajena, y la producción de una nueva especie: no hay especificación si solo se destruye una cosa para gozar del producto resultante (quien quema leña para calentarse, aunque obtenga carbón, no especifica, pero sí especifica quien la quema para producir carbón).

El Código la trata expresamente como una especie de accesión, en cuanto supondría la unión de dos cosas, la materia ajena y el trabajo propio; otros autores discrepan, porque la accesión requiere la unión de dos cosas de diferentes dueños y en la especificación solo hay una cosa, la materia ajena, transformada por un trabajo que no es en sí mismo una "cosa" apropiable, razón por la cual códigos modernos como el suizo o el italiano la tratan como un modo de adquirir independiente.

No habiendo conocimiento por una de las partes ni mala fe por la otra, el dueño de la materia se hace dueño de la obra pagando la hechura (**art. 662** inc. 2°), solución que refleja el criterio del Código napoleónico de mirar el trabajo humano como un valor de inferior jerarquía, opuesto al de las legislaciones contemporáneas, que en principio atribuyen la propiedad de la nueva especie al artífice. Excepcionalmente, el artífice se hace dueño de la obra cuando esta vale mucho más que la materia primitiva, como al pintar un lienzo ajeno o esculpir una estatua en mármol ajeno, debiendo indemnizar los perjuicios al dueño de la materia (**art. 662** inc. 3°). Si la materia es en parte ajena y en parte propia de quien hizo la obra, y las partes no pueden separarse sin inconveniente, habrá comunidad sobre la obra, aunque no con iguales derechos (**art. 662** inc. 4°).

c) Mezcla

Es la unión de dos o más cuerpos, sólidos o líquidos, que se confunden en el conjunto dejando de ser distintos y reconocibles, como la mezcla de dos vinos de cepas distintas. Esto la diferencia de la adjunción, en la que las cosas continúan distintas y reconocibles, y de la especificación, que supone una sola sustancia transformada por el trabajo humano.

No habiendo conocimiento del hecho por una de las partes ni mala fe por la otra, la mezcla pertenece en común a los dueños de las cosas mezcladas, a prorrata del valor de la materia de cada uno (**art. 663** inc. 1°); en rigor, aquí no hay accesión ni cambio de dominio. Sí la hay si el valor de la materia de uno de ellos fuere considerablemente superior: en tal caso su dueño puede reclamar la cosa producida por la mezcla, pagando el precio de la materia restante (**art. 663** inc. 2°).

d) Reglas comunes a las tres especies de accesión de mueble a mueble

a. Derecho de restitución.

El **art. 665** da al dueño de la materia usada sin su conocimiento, que tenga derecho a la propiedad de la cosa en que fue empleada, el derecho a pedir en su lugar la restitución de otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud, o su valor en dinero (para algunos, más que accesión, hay aquí compraventa).

b. Derecho a pedir la separación de la cosa.

El **art. 664** concede al dueño de una de las materias unidas, que no sea fácil de reemplazar y pueda separarse sin deterioro de lo demás, el derecho a pedir su separación y entrega a costa de quien hizo uso de ella sin su conocimiento (tampoco hay aquí propiamente accesión, sino reivindicación).

c. Presunción de consentimiento.

El **art. 666** presume que quien tuvo conocimiento del uso de su materia por otro consintió en ello, y solo tiene derecho a su valor.

d. Consecuencia del error sin justa causa y de la mala fe.

El **art. 667** hace responder a quien usó materia ajena sin conocimiento del dueño y sin justa causa de error, con la pérdida de lo suyo y el pago de los perjuicios, sin perjuicio de la acción criminal si procedió a sabiendas, salvo que el valor de la obra excediere notablemente al de la materia.

5.3. Accesión de mueble a inmueble

a) Conceptos generales y presupuestos

Llamada también accesión industrial (**arts. 668 y 669**), comprende las modalidades de edificación y de plantación o siembra, sometidas a las mismas reglas, y opera cuando se construye, planta o siembra con materiales o semillas de persona distinta del dueño del suelo. Incorporados definitivamente los materiales al suelo, o arraigadas las semillas, sin que exista pacto o vínculo contractual entre los participantes, el Código aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, considerando siempre el suelo como el elemento principal: el dueño del predio adquiere por accesión lo edificado, plantado o sembrado, sin perjuicio de las normas para indemnizar a quien nada adquirirá, relacionadas con las prestaciones mutuas de la reivindicación (**art. 669**).

Se requiere, primero, que no exista vínculo contractual entre el dueño del suelo y el propietario de los materiales, plantas o semillas, exigiéndose ignorancia por una de las partes: si media un contrato, como un arrendamiento con mejoras a beneficio del arrendador, o un usufructo, no hay accesión sino tradición u otro modo de adquirir. Y segundo, que los materiales, plantas o semillas se hayan incorporado en forma definitiva al suelo (**art. 668** inc. final): mientras los materiales no se incorporen a la construcción, o las plantas no arraiguen, no hay accesión y su propietario puede reclamarlos.

b) Efectos e indemnizaciones

Producida la incorporación o el arraigo, se aplica la regla de que lo accesorio accede a lo principal, considerándose siempre principal el suelo, cualquiera sea su valor o el de los materiales, y sea quien sea quien costó la obra.

Para evitar el enriquecimiento sin causa se distinguen dos casos. Si se edifica, planta o siembra con materiales ajenos en suelo propio, y el dueño de los materiales no tenía conocimiento del uso que se hacía de ellos, el propietario del inmueble adquiere en todo caso lo edificado, plantado o sembrado, variando solo su responsabilidad frente al dueño de los materiales:

(i) Justa causa de error.

Debe pagar el justo precio o restituir otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud (**art. 668 1º**).

(ii) Sin justa causa de error.

Debe, además, indemnizar los perjuicios.

(iii) A sabiendas.

Queda sujeto además a eventual responsabilidad penal.

Si el dueño de los materiales tuvo conocimiento del uso que de ellos se hacía (**art. 668 2º** parte final), el propietario del suelo solo debe pagar el justo precio o restituir otro tanto, entendiéndose que hay aquí, más que accesión, una verdadera compraventa o tradición, por existir consentimiento de las partes.

Si se edifica, planta o siembra con materiales propios en suelo ajeno, y el dueño del suelo no tuvo conocimiento, este tiene un derecho alternativo (**art. 669**):

(i) Hacer suyo lo edificado, plantado o sembrado.

Pagando al dueño de los materiales las indemnizaciones prescritas para los poseedores de buena o mala fe en las reglas de las prestaciones mutuas (**arts. 904** y siguientes): mejoras necesarias y útiles si de buena fe, solo las necesarias si de mala fe, nunca las voluptuarias. La buena o mala fe se determina al tiempo en que las obras fueron ejecutadas (**art. 913**).

(ii) Obligar a quien edificó, plantó o sembró a pagarle.

A quien edificó o plantó, a comprarle el terreno pagándole su justo precio con intereses legales por el tiempo que lo tuvo en su poder (una verdadera compraventa forzada); a quien sembró, a pagarle una suma equivalente a la renta de arrendamiento que habría obtenido.

Si el dueño del suelo tuvo conocimiento de lo que se hacía, está obligado a pagar la edificación, plantación o sementera (**art. 669 2º**), entendiéndose también aquí que hay tradición y no accesión,

por mediar consentimiento.

El Código no contempla el caso de edificar, plantar o sembrar con materiales ajenos en suelo ajeno; se ha sostenido que corresponde aplicar por analogía las reglas anteriores.

DATO DE GRADO

¿Cuándo hay accesión y cuándo hay tradición?

La trampa recurrente en esta materia es tratar como accesión casos en que en realidad hubo consentimiento entre las partes. Cada vez que el dueño de los materiales, plantas o semillas tuvo conocimiento del uso que de ellos se hacía, o que existe un vínculo contractual entre el dueño del suelo y el propietario de lo incorporado, la doctrina entiende que no hay accesión, sino una verdadera compraventa o tradición, porque la accesión, como modo de adquirir, presupone precisamente la ausencia de acuerdo entre las partes.

F. LA TRADICIÓN: DESCRIPCIÓN GENERAL, REQUISITOS Y EFECTOS

1. CONCEPTO

Con antecedentes en el Derecho Romano, desarrollados en la Edad Media, el Código chileno establece como principio para la transferencia de bienes la dualidad título y modo de adquirir, sistema que se observa con particular claridad, y para algunos es el único caso en que verdaderamente tiene lugar, en la aplicación del modo tradición. El **art. 670** inc. 1º la define como un modo de adquirir el dominio de las cosas que consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Las reglas se contienen en los **arts. 670 a 699**, sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces para la tradición de inmuebles, de los **arts. 1901** y siguientes para la de derechos personales, y del Código de Comercio para la de créditos mercantiles.

2. CARACTERES

2.1. Es un modo de adquirir derivativo

El adquirente deriva su dominio de otro sujeto, el tradente, a diferencia de la ocupación y la accesión. Siendo derivativo, este modo no transfiere al adquirente más derechos que los que tenía el tradente: si este no era dueño de la cosa tradida, tampoco lo será quien la recibe (nadie puede transferir más derechos que los que tiene).

2.2. Es una convención

De la definición se desprende su carácter convencional: acuerdo de voluntades que produce consecuencias jurídicas. Con ella no se crean obligaciones, lo que la haría un contrato, sino que se extinguen las contraídas en el título que la antecede. El vendedor, el donante o el aportante en sociedad no transfieren en el respectivo contrato la cosa vendida, donada o aportada, sino que se obligan a transferirla; al efectuar la tradición, con ese acto voluntario y convencional, extinguen (pagan) su obligación.

2.3. Es consecuencia de un título

Frecuentemente se dice que la tradición puede ser a título gratuito u oneroso; más propiamente, es el título del que es consecuencia el que tiene ese carácter: si el antecedente es una donación, será a título gratuito, y si es una compraventa, a título oneroso.

2.4. Por regla general, es un modo de adquirir a título singular

Excepcionalmente lo es a título universal, en el caso de la tradición del derecho de herencia, con dos precisiones: no se transfiere el patrimonio del tradente, sino el del causante, de modo que tratándose del patrimonio del propio tradente la tradición jamás es a título universal; y hay tradición del derecho de herencia cuando el heredero, ya fallecido el causante, cede su derecho, pero el traspaso de los bienes del difunto al heredero opera por la sucesión por causa de muerte, no por la tradición. En nuestro Derecho, por regla general, no se aceptan los contratos que conducen al traspaso de universalidades (**arts. 1811 y 2056**), de ahí la inaplicabilidad de la tradición en esos casos; cuando la ley sí permite esa negociación, como en la herencia o cuota hereditaria, la tradición recobra aplicación, y solo se discute cómo debe efectuarse.

2.5. Sirve de justo título para prescribir

Cuando el tradente no es dueño de la cosa que entrega, la tradición no opera como modo de adquirir, pero sirve de justo título para que el adquirente gane después la cosa por prescripción.

3. APLICACIÓN

Su vigencia en la vida jurídica es intensa: la aplicación diaria del contrato de compraventa trae como consecuencia directa la tradición de los objetos vendidos, en cumplimiento del contrato. Mediante este modo se pueden adquirir tanto el dominio como los demás derechos reales (**art. 670 inc. 2º**) y los derechos personales (**art. 699**), con excepción de los personalísimos cuando el tradente sea su titular, por ser inalienables; en este sentido, la ocupación y la accesión son modos de aplicación más limitada. Puede además utilizarse, no como modo de adquirir el dominio, sino como requisito para poseer una cosa: cuando el tradente no es el verdadero dueño, el adquirente no adquiere el dominio, pero la tradición le sirve para poseerla y llegar a adquirirla por prescripción.

4. ENTREGA Y TRADICIÓN

El elemento central que da consistencia a la tradición es la entrega del objeto tradido, pero pueden darse situaciones de entrega material de una cosa sin que se configure la tradición. Cuando la entrega se efectúa con intención de transferir el dominio u otro derecho real, hay tradición; esa intención se manifiesta también en el título que la antecede, llamado "título traslativo de dominio" (la compraventa, el aporte a una sociedad, la donación). Si lo pactado es un arrendamiento o un préstamo de uso, la entrega se efectúa sin esa intención, y el título mismo, llamado "título de mera tenencia", revela que la entrega solo confiere a quien recibe la mera tenencia de la cosa.

NO CONFUNDIR**Entrega vs. tradición**

En la tradición existe, de parte del tradente y del adquirente, la intención de transferir y adquirir el dominio, intención ausente en la simple entrega, aunque el acto material sea el mismo tratándose de bienes muebles. Esa intención se manifiesta en el título traslativo de dominio que antecede a la tradición; en la entrega propiamente tal hay, en cambio, un título de mera tenencia. Y mientras la tradición hace adquirir el dominio o la posesión, la entrega propiamente tal solo confiere la mera tenencia, que por regla general no habilita para adquirir por prescripción.

Pese a esta distinción, el Código no siempre emplea los términos con ese rigor: a veces los trata como sinónimos (**art. 1824**, "entrega o tradición"), otras usa "entrega" siendo más preciso "tradición" (**art. 2196**), otras usa "tradición" siendo más preciso "entrega" (**art. 2174** inc. 2º), y en otras se ajusta a las acepciones expuestas (**arts. 2212 y 2174** inc. 1º).

5. PRESENCIA DE DOS PERSONAS: TRADENTE Y ADQUIRENTE

Siendo una convención, la tradición requiere de dos partes (**art. 671**).

5.1. Facultad y capacidad de las partes

a) El tradente

Debe ser plenamente capaz. Aunque el **art. 670** parece exigir al tradente solo "facultad" para transferir y al adquirente "capacidad" para adquirir, no debe entenderse que al primero no se le exige capacidad: siendo una convención, si el tradente es incapaz, se aplica la sanción ordinaria para los actos de los incapaces, según la clase de incapacidad. La exigencia de "facultad" apunta, además, al poder de disposición: si el tradente es un representante legal que entrega un bien del representado, debe cumplir las formalidades habilitantes correspondientes, sin las cuales carece de poder para enajenar libremente.

El tradente debe ser también dueño de la cosa que transfiere. Si no lo es, transfiere los derechos que sobre ella tenía al momento de la tradición, conforme al principio de que nadie puede transferir más derechos que los que tiene (*nemo plus iuris dat quam ipse habet*), consagrado en el **art. 682**: si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa entregada por él o a su nombre, no se adquieren por la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre ella, pero si el tradente adquiere después el dominio, se entiende que este se transfirió desde el momento de la tradición.

b) El adquirente

Buena parte de la doctrina estima que también debe ser plenamente capaz, por estar celebrando un acto jurídico, con la sanción ordinaria en caso de incapacidad. Otros autores distinguen, exigiendo al tradente capacidad de ejercicio y bastando en el adquirente la capacidad de goce; otros sostienen que al adquirente se le exige capacidad de administración y al tradente, de disposición, lo que se corroboraría con las normas sobre el pago: el **art. 1575** inc. 2º, del que se desprendería que la capacidad del tradente es la de libre disposición de sus bienes, y el **art. 1578 N° 1**, que anula el pago hecho a quien no tiene la libre administración de sus bienes, salvo en el caso del **art. 1688**.

5.2. Tradición y pago

Generalmente la tradición constituye un verdadero pago, pues el tradente la efectúa porque se obligó a ello en un título precedente, lo que lleva a relacionar sus normas con las del pago (**arts. 1568** y siguientes, en especial los **arts. 1575 y 1578 N° 1**). El **art. 1575** dispone que si paga quien no es dueño de la cosa pagada, el pago no es válido; y aunque la tradición hecha por quien no es dueño es válida en cuanto tal (solo que no transfiere el dominio), sí puede ser nula en cuanto pago, permitiendo al acreedor pedir la nulidad del pago, restituir lo recibido y continuar demandando la prestación debida.

6. CONSENTIMIENTO DE AMBAS PARTES

6.1. Aspectos generales

Siendo la tradición un acto jurídico bilateral, el consentimiento, conforme al **art. 670**, debe implicar la intención determinada de ambas partes de transferir y adquirir, respectivamente, el dominio. Esta intención supone, ante todo, que la tradición tenga como antecedente un título traslativo de dominio, pues solo en estos surge la obligación de efectuar una tradición que transfiera el dominio; jamás podría presumirse si la entrega se funda en un título de mera tenencia.

El **art. 672** exige que la tradición sea hecha voluntariamente por el tradente o su representante, y el **art. 673**, que cuente con el consentimiento del adquirente o su representante; ambos disponen que la tradición inicialmente inválida por falta de esa voluntad se valida retroactivamente por la ratificación de quien tiene facultad de enajenar o de adquirir. Aunque los preceptos hablan de validez e invalidez, lo que sugeriría nulidad absoluta insaneable, el hecho de admitir su saneamiento por ratificación hace pensar que la sanción a la falta de voluntad es más bien la inoponibilidad del acto.

6.2. Reglas sobre el error

El consentimiento debe estar exento de vicios (**art. 1452**); el Código establece reglas especiales para el error, que puede recaer en la cosa tradida, en la persona o en el título.

a) Error en la cosa tradida

El **art. 676** exige, para la validez de la tradición, que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse. El error recae aquí en la tradición misma, no en el título: se entregó o recibió una cosa creyéndose que se entregaba o recibía una distinta. La disposición armoniza con el **art. 1453**, sobre el error esencial, que recae en la naturaleza del acto o en la identidad de la cosa específica, respecto del cual se discute en doctrina si la sanción es la inexistencia, la nulidad absoluta o la relativa.

b) Error en la persona

El mismo **art. 676** exige que no se padezca error en cuanto a la persona a quien se hace la entrega, ni en cuanto al título. Es una excepción a los principios generales, según los cuales el error sobre la persona no vicia el consentimiento salvo que ella sea el motivo determinante del acto: aquí el error en la persona siempre anula la tradición, porque esta es el cumplimiento de la obligación que nace del contrato, y el pago debe hacerse siempre al acreedor, so pena de nulidad o ineficacia para extinguir la obligación (**art. 1576**); más propiamente, habría aquí pago de lo no debido, susceptible de repetición. Si el error no recae en la persona sino solo en su nombre, la tradición es válida (**arts. 676** inc. 2º, 1057 y 1455).

c) Error en el título

El **art. 677** invalida la tradición cuando una sola de las partes supone un título traslativo de dominio, como cuando una tiene el ánimo de entregar a título de comodato y la otra el de recibir a título de donación, o cuando ambas suponen títulos traslativos de dominio pero diferentes, como si una supone mutuo y la otra donación.

EJEMPLO

Las dos formas de error en el título

Pedro entrega su automóvil a Juan creyendo que se lo presta (comodato), mientras Juan cree que Pedro se lo está regalando (donación): ambos suponen un título traslativo, pero de naturaleza distinta a la que el otro entiende, y la tradición es inválida. Distinto es el caso en que Pedro entrega el automóvil creyendo que lo presta, y Juan cree que se lo prestan también, pero por comodato precario en vez de comodato ordinario: aquí ninguno de los dos supone un título traslativo de dominio, y por tanto no hay ni siquiera tradición que invalidar, sino una simple entrega.

d) Error de los mandatarios

El **art. 678** dispone que el error sufrido por mandatarios o representantes legales también invalida la tradición, norma que resulta redundante considerando la regla general del **art. 1448**.

6.3. Tradición por representantes

Como es regla general en Derecho Civil (**art. 1448**), la tradición también puede efectuarse a través de representantes, legales o voluntarios, lo que confirman expresamente los **arts. 671, 672, 673, 674 y 678**. Especial interés reviste el **art. 671**: pueden entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o representantes legales; en las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente, y el juez su representante legal; y la tradición hecha por o a un mandatario debidamente autorizado se entiende hecha por o a su mandante.

6.4. Consentimiento en las ventas forzadas

En las ejecuciones judiciales para el pago de deudas, si el acreedor embarga y remata bienes del deudor, surge la duda sobre la legalidad de la tradición por la que el subastador adquiere lo rematado, ya que el deudor propietario está lejos de consentir en ella. Para esta situación, el **art. 671** inc. 3º dispone que en esas ventas forzadas el juez es el representante legal de la persona cuyo dominio se transfiere, y otorga el consentimiento en su nombre, siempre que se trate propiamente de ventas forzadas y no de las que se hacen "por el ministerio de la justicia" sin ser forzadas (como la venta de bienes de ciertos incapaces, **art. 394**), casos en que rigen las reglas generales.

DATO DE GRADO

¿Cómo se explica la falta de consentimiento del deudor en la venta forzada?

El **art. 671** soluciona el problema práctico (quién otorga el consentimiento), pero no explica del todo por qué el deudor, que se opone manifiestamente, queda igualmente obligado. Una explicación recurre a la teoría de la representación modalidad de los actos jurídicos, según la cual no es la voluntad del representado la que contrata, sino la del representante. Otra recurre al derecho de prenda general de los acreedores (**art. 2465**): al contraer una obligación, el deudor sabe que ha de responder de ella con todos sus bienes, presentes y futuros, y estaría consintiendo de antemano en una eventual enajenación forzada. Esta segunda explicación, sostenida por **CLARO SOLAR**, funciona bien para obligaciones contractuales, pero es insuficiente para las que provienen de un hecho ilícito.

7. TÍTULO TRASLATIVO DE DOMINIO

7.1. Concepto

El **art. 675** dispone que para que valga la tradición se requiere un título traslativo de dominio, como el de venta, permuta o donación. Como de los contratos solo nacen derechos personales, y solo con el modo de adquirir se adquieren los derechos reales, puede decirse, desde el punto de

vista del modo, que la tradición requiere de un título traslativo precedente, lo que lleva a la doctrina nacional a considerar al título como la causa de la tradición.

La expresión "título" se usa en dos acepciones: una jurídica, el acto jurídico que sirve de antecedente a la adquisición del dominio, y otra material, el documento que da constancia de ese acto; en materia de tradición, el Código emplea la primera. Entre los títulos traslativos de aplicación más frecuente están la compraventa, la permuta, la donación, el aporte en propiedad a una sociedad, la novación y, discutiblemente, la dación en pago.

7.2. El título debe ser válido

Para que la tradición produzca su efecto normal de transferir el dominio, debe tener como antecedente un título válido (**art. 675**). En términos teóricos, la tradición efectuada sin título, o con título nulo, podría calificarse como nula (si se la concibe como un acto causado, cuya suerte depende de la del título) o como válida (si se la concibe como un acto abstracto, independiente del título). El texto del **art. 675** consagra la tradición, en cuanto modo de adquirir el dominio, como un acto causado: si el título falta o es nulo, la tradición es nula en cuanto mecanismo traslativo.

Pero esa nulidad no alcanza al efecto posesorio de la tradición. Varios argumentos apoyan esta conclusión: la parte final del **art. 675** apunta al traslado del dominio, sin referirse a la posesión; el **art. 704** considera títulos injustos para poseer, pero títulos al fin, al nulo (Nº 3) y al aparente (Nº 4), de modo que quien recibió por un título nulo tiene posesión, aunque irregular, pudiendo llegar al dominio por prescripción extraordinaria; y el Código admite la ocupación como título para poseer, lo que equivale a admitir la posesión sin título, de modo que no sería coherente negar la posesión a quien tiene un título, aunque nulo.

En suma, si tras la tradición se descubre que no había título o que era nulo, no se transfiere el dominio, pero el adquirente sí habrá entrado en posesión; el dueño podrá pedir la restitución mediante la acción del **art. 1687** y, ante terceros, reivindicar, mientras el poseedor no logre prescribir.

7.3. El conflicto teórico con la noción de contrato real

La técnica del contrato real ocasiona un conflicto con este sistema: como estos contratos se perfeccionan por la entrega de la cosa (**art. 1443**), y en algunos, como el mutuo, esa entrega es tradición porque transfiere el dominio de lo entregado (**art. 2197**), surge la duda de cuál es el título de esa tradición, si antes de la entrega no hay contrato. Las dos alternativas, entender que hay una tradición sin título o que título y modo se confunden y nacen simultáneamente, resultan igualmente insatisfactorias.

8. ENTREGA

Más que un requisito autónomo, la entrega es el elemento sustantivo de la tradición, alrededor del cual han de cumplirse las demás exigencias anotadas.

9. EFECTOS DE LA TRADICIÓN, CUANDO EL TRADENTE ES DUEÑO DE LA COSA QUE ENTREGA

Se produce el efecto normal y propio de la tradición: transferir el dominio del tradente al adquirente (**arts. 670, 671 y 1575**). Si el tradente tenía la cosa sometida a gravámenes reales, el adquirente la adquiere con las mismas cargas, siguiendo siempre el principio de que nadie puede transferir más derechos que los que tiene.

Además, la tradición deja al adquirente en posesión de la cosa, porque ambas partes tienen la intención de que quede como dueño, y al quedar con la cosa a su disposición reúne los elementos de la posesión del **art. 700**. Excepcionalmente, mediante las tradiciones simbólicas (**art. 684**), puede darse el caso de que el adquirente tenga el ánimo de dueño pero no llegue a tener la cosa a su disposición, faltándole entonces el elemento tenencia y, por tanto, la posesión. Este efecto posesorio se produce sea que el tradente fuera dueño, poseedor o mero tenedor: incluso el que recibe de un mero tenedor queda en posesión (**art. 730**), de modo que el primer efecto de la tradición es siempre dejar al adquirente en posesión, y solo produce el efecto de transferir el dominio cuando el tradente era dueño.

10. EFECTOS DE LA TRADICIÓN, CUANDO EL TRADENTE NO ES DUEÑO PERO TIENE OTROS DERECHOS

Si el tradente carecía del dominio pero tenía sobre la cosa otro u otros derechos transferibles, como un usufructo, los transfiere con la tradición (**art. 682**, que impropiamente habla de derechos "transmisibles" en vez de "transferibles"). El adquirente queda entonces como poseedor no dueño de la cosa, y como dueño y poseedor de esos otros derechos reales que sí tenía el tradente, solución de calidad discutible porque incrusta en su patrimonio derechos que quizás no quiso adquirir.

11. EFECTOS DE LA TRADICIÓN, CUANDO EL TRADENTE NO ES DUEÑO

El adquirente no adquiere dominio alguno, pero la tradición cumple otra función: le confiere posesión de la cosa, poniéndolo en vías de ganar el dominio por prescripción (**art. 683**). El precepto no convierte a la tradición en título para poseer, pues esta es siempre consecuencia de un título: el rol de la tradición aquí es poner en posesión al que recibe la cosa, sirviéndose del mismo título (por ejemplo, la compraventa) que se examina también al estudiar la posesión.

12. EFECTOS PARTICULARES

12.1. Retroactividad

Si el tradente que no era dueño de la cosa adquiere después su dominio, la transferencia al adquirente se entiende operar desde el instante de la tradición (**art. 682** inc. 2º, en relación con el **art. 1819**). La regla es prácticamente conveniente, aunque genera, en estricta lógica, una suerte de superposición de dominios durante el período intermedio, entre el primitivo dueño (que no había perdido su dominio hasta que el tradente lo adquirió) y el adquirente (a quien la retroactividad hace dueño desde la tradición).

12.2. Época para exigir la tradición

Para determinar desde cuándo puede exigirse la tradición de lo debido, hay que recurrir al título respectivo: si somete la entrega a una condición o a un plazo suspensivo, habrá que esperar su cumplimiento; si nada dice, será exigible desde que el título se perfeccione (**art. 681**). Si, exigible ya la tradición, se notifica al obligado una resolución judicial que ordena retención, embargo o prohibición de celebrar actos y contratos sobre lo debido, este debe abstenerse de efectuarla, bajo los efectos de los **arts. 1578 N° 2 y 1464 N°s 3 y 4**.

12.3. Tradición sujeta a modalidades

Los efectos de la tradición pueden someterse a modalidades, según lo permite el **art. 680**, cuyas particularidades habrá que buscar en el título respectivo.

(i) Condición suspensiva.

Es el caso de la llamada "cláusula de reserva de dominio", el pacto por el cual el tradente mantiene el dominio de la cosa tradida hasta el cumplimiento de una condición o plazo. La regla general es que puede acordarse válidamente en cualquier título traslativo; pero un caso especial resulta controvertido: el **art. 680** inc. 2º la permite expresamente cuando se pacta bajo la condición de que se pague el precio, referida a la compraventa, mientras el **art. 1874**, regulando precisamente la compraventa, dispone que esa cláusula no produce otro efecto que poder demandar el cumplimiento o la resolución del contrato, sin reserva efectiva de dominio.

DATO DE GRADO**¿Prevalece el art. 680 o el art. 1874 en la cláusula de reserva de dominio?**

La doctrina nacional ha sostenido en forma prácticamente unánime que debe prevalecer el **art. 1874** por sobre el **art. 680**, invocando el principio de especialidad y razones de utilidad práctica (riesgo para el comprador frente a actos de disposición del vendedor, suficiencia de la acción resolutoria de los **arts. 1489, 1490 y 1491**). Sin embargo, **CAPRILE** defiende la tesis contraria: la historia fidedigna de la ley muestra que la controversia sobre los efectos de la reserva de dominio en la compraventa se planteó precisamente a propósito del **art. 680**, y la reserva de dominio, como modalidad que afecta a la tradición, tendría mayor utilidad práctica como garantía, sobre todo frente a la quiebra del comprador, donde el vendedor podría reivindicar la cosa sin verse afectado por las limitaciones de la acción resolutoria.

(ii) Condición resolutoria.

El **art. 680** dispone que la tradición puede transferir el dominio bajo condición resolutoria, con tal que se exprese. Se ha discutido si esto exige que la condición resolutoria tácita del **art. 1489** deba pactarse expresamente para afectar la tradición, pero la duda pierde relevancia práctica: si se incumple una obligación del título y, por el **art. 1489**, se obtiene por sentencia la resolución del contrato, la tradición queda igualmente sin efecto, pues debe restituirse lo recibido en virtud del título resuelto.

(iii) Plazo.

Puede pactarse un plazo suspensivo, caso en que la tradición ya efectuada comienza a producir sus efectos desde que llega el día convenido (una tradición anticipada, análoga a la cláusula de reserva de dominio), o un plazo extintivo, en que llegado el día se extingue el dominio del adquirente, configurándose típicamente un usufructo o un fideicomiso.

G. LA TRADICIÓN DE DERECHOS REALES SOBRE MUEBLES

1. ASPECTOS GENERALES

Reglamentan esta materia los **arts. 684 y 685** del Código Civil, además de algunas normas del Código de Comercio y de textos especiales, como la legislación sobre almacenes generales de depósito. Para tratarla, es necesario distinguir entre tradición real y tradición ficta o simbólica (ambos términos se emplean aquí como sinónimos, aunque hay quienes les asignan diferencias).

2. TRADICIÓN REAL

Es la expresión natural o auténtica de la tradición, con la cual se cumplen las justificaciones de publicidad y posesión propias de este modo de adquirir. Se efectúa por una entrega real, o como la llama la doctrina antigua, tradición "de mano a mano": la cosa tradida es materialmente entregada por el *tradens* al *accipiens*, cumpliéndose los demás requisitos ya indicados. Por su naturaleza, esta forma solo es aplicable a las cosas que por su volumen y peso permiten la entrega material de una persona a otra. El Código no la menciona directa o claramente, pero desde la definición del modo no cabe duda de que es su primera forma. Una parte de la doctrina considera también como tradición real la de los N°s 1, 2 y hasta 3 del **art. 684**; entre nosotros, **BARROS ERRÁZURIZ** niega esta calificación, entendiendo que todas las formas del **art. 684** son fictas.

3. TRADICIÓN DE MUEBLES CONFORME AL ART. 684

La tradición de los derechos reales sobre una cosa corporal mueble debe hacerla el tradente entregando la cosa al adquirente por alguno de los medios que señala el **art. 684**.

3.1. Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente (art. 684 N° 1)

Corresponde a lo que los romanos conocían como tradición real: el obligado a la tradición de una cosa que se encuentra delante de ambas partes permite que el adquirente la coja o asa materialmente, quedando la cosa en su poder. Se exige la presencia simultánea de tradente y adquirente, la presencia de la cosa a la vista y alcance de ambos, y la aprehensión de ella por el adquirente sin oposición del tradente. La tradición se entiende verificada cuando el adquirente aprehende la cosa con la intención de hacerla suya; el solo hecho de que el tradente permita la aprehensión, aunque revele su intención de transferir el dominio, no basta si el adquirente no recibe materialmente la cosa.

Se ha discutido qué ocurre si quien tiene derecho a exigir la tradición se niega a tomar la cosa que se le ha permitido aprehender. La tesis que parece jurídicamente más correcta es que, en tal caso, no ha operado la entrega y la obligación de hacer la tradición sigue vigente, porque no puede exis-

tir el acto jurídico "entrega" sin la aceptación de la cosa por el adquirente, y porque la tradición es un pago efectivo que supone que una parte entrega voluntariamente y la otra recibe también voluntariamente: si el acreedor se niega a recibir, el deudor deberá recurrir al pago por consignación (**arts. 1598** y siguientes) para extinguir su obligación.

3.2. Mostrándosela (art. 684 N° 2).

Los romanos la conocían como *longa manu* (tradición de larga mano), por suponerse que el adquirente la aprehende ficticiamente extendiendo sobre ella una larga mano suya; también se la llamaba *occulis et affectu* (por los ojos y la intención). Consiste en que el obligado a la tradición pone la cosa a la vista de la otra parte, con la intención de que quede a su disposición, lo que el adquirente acepta. Según **POTHIER**, esta forma se aplicaba también a los bienes raíces: los ojos de aquel a quien se muestra la cosa hacen la función de sus pies y de sus manos.

Para **VIAL**, es difícil estimar cumplida la obligación de hacer la tradición de una cosa mueble por el solo hecho de que el deudor la ponga a la vista del acreedor, aunque este la acepte: lo razonable es estimarla cumplida una vez que la cosa se encuentre materialmente en poder del adquirente, porque la tradición que se hace en virtud de un título traslativo debe permitir adquirir, a lo menos, la posesión, y esta supone el corpus, la tenencia de la cosa.

Frente a la posible interpretación de que el **art. 684 N° 2** reproduce, sin más, un medio del Derecho Romano y que basta con mostrar la cosa para adquirir posesión aunque no exista tenencia material, **VIAL** plantea dos reparos: el **art. 684** no regula la forma en que se adquiere posesión, sino los medios por los que el tradente exterioriza su intención de transferir el dominio, de modo que mostrar la cosa revela esa intención pero no constituye por sí sola la entrega, la que solo se entiende verificada cuando el adquirente entra en posesión material de ella; y admitir lo contrario contradiría los principios generales de la posesión de los muebles, que exigen tenencia, no la mera exhibición.

NO CONFUNDIR

"Mostrándosela" (N° 2) no es una tradición ficta como la del N° 5

Si se estimara que el solo hecho de mostrar la cosa configura tradición y hace adquirir posesión, se estaría reconociendo una tradición ficta similar a la del **art. 684 N° 5**. Pero esa interpretación tropieza con que el propio Código reserva expresamente la categoría de tradición ficta al N° 5, lo que revela que el N° 2 debe contemplar algo distinto: una simple manifestación de la intención de transferir, que solo se perfecciona en entrega cuando el adquirente efectivamente toma la cosa bajo su poder.

3.3. Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar en que esté guardada la cosa (art. 684 N° 3).

Para algunos autores es la forma de tradición simbólica por excelencia, en que las llaves constituyen el símbolo de la entrega; otros entienden que es una forma de tradición real, al permitir la toma inmediata de posesión. El Código no exige que el almacén o cofre esté a la vista de las partes, pero la entrega de las llaves debe ser real. Según **VIAL**, la entrega y recepción de las llaves transfiere el dominio aunque no se haya entregado materialmente la cosa guardada, porque las llaves representan o simbolizan la cosa, y con su recepción esta se incorpora al poder de dominación del adquirente: el corpus posesorio se da desde que el adquirente recibe las llaves, aunque materialmente detente solo estas y no la cosa misma.

3.4. Encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido (art. 684 N° 4).

Es otra figura considerada por el Derecho Romano como tradición simbólica: el tradente se encarga de poner la cosa a disposición del adquirente en el lugar convenido, por ejemplo, dejándola en el domicilio del comprador dentro de cierto plazo. Se discute si la tradición se entiende verificada por el solo compromiso, o solo cuando efectivamente se cumple el encargo.

La doctrina nacional, con **PEÑAILILLO**, se inclina por entender simbólicamente verificada la tradición desde que se conviene el encargo, sin esperar su cumplimiento: el Proyecto de 1853 exigía que el encargo se cumpliera, exigencia luego eliminada, lo que revelaría que el legislador la consideró innecesaria; se trataría de un verdadero mandato por el que el tradente queda como mero tenedor.

CLARO SOLAR y **VIAL** sostienen lo contrario: la tradición solo se verifica cuando efectivamente se pone la cosa a disposición del adquirente, porque el **art. 684** no regula la forma de la entrega sino los medios de exteriorizar la intención de transferir, y el mero compromiso no constituye, ni de lejos, la entrega y recepción que la tradición requiere; la eliminación de la exigencia del Proyecto de 1853 se explicaría, para estos autores, porque el cumplimiento del encargo ya estaba implícito en la disposición, no porque se hubiera vuelto innecesario.

3.5. Tradición por breve mano (art. 684 N° 5, primera parte)

Se refiere a la venta, donación u otro título de enajenación conferido a quien tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario u otro título no traslativo de dominio. Es la llamada tradición *brevi manu*: según **CLARO SOLAR**, consiste en suponer que quien tenía la cosa como mero tenedor, por el hecho de adquirir sobre ella un título traslativo de dominio, ha recibido la cosa misma, como si se le hubiese entregado corporalmente, suprimiéndose así el acto de restitución de la tenencia al propietario para que este, inmediatamente, se la entregara de vuelta al adquirente que ya la tenía en su poder.

EJEMPLO**Tradición brevi manu**

Una persona tiene una cosa en calidad de comodatario (mero tenedor) y después se la compra a su dueño. No es necesario que este le haga materialmente una nueva tradición, porque el comprador ya tiene la cosa en su poder: lo que cambia es la relación jurídica sobre ella, que pasa de mera tenencia (derivada del comodato) a dominio y posesión, por efecto de la tradición que finge la ley.

3.6. Constituto posesorio (art. 684 N° 5, segunda parte)

Es la forma inversa de la anterior: el dueño de una cosa mueble celebra respecto de ella un contrato traslativo de dominio, como una compraventa, estipulándose en el mismo contrato que el dueño se constituye usufructuario, comodatario o arrendatario, es decir, que conserva la cosa en su poder, pero ya no a título de dueño, sino de mero tenedor. En estricto rigor el vendedor debería hacer la tradición material al comprador, quien inmediatamente debería devolvérsela en calidad de arrendamiento u otro título, lo que es evidentemente innecesario: por eso la ley finge una tradición que en el hecho no se efectúa, y que habilita al comprador para adquirir el dominio y la posesión, dándose a su respecto el corpus posesorio porque el tradente, que conserva la cosa, la tiene a nombre y en lugar del adquirente.

3.7. Otras formas de tradición ficta

A los casos del **art. 684** deben agregarse otras formas diseminadas en la legislación. El **art. 148** del Código de Comercio dispone, para la compraventa mercantil, que el envío de las mercaderías hecho por el vendedor al domicilio del comprador o a cualquier otro lugar convenido importa la tradición efectiva de ellas, siempre que el envío se haya efectuado con ánimo de transferir la propiedad; el **art. 149** del mismo Código considera entrega, entre otros hechos, la transmisión de la factura o la fijación de la marca del comprador. Hay, además, ciertos bienes muebles cuya forma de tradición es discutida, como las naves (Libro III del Código de Comercio y Ley de Navegación) y las aeronaves (Código Aeronáutico).

4. PRINCIPIO QUE RIGE LAS DIVERSAS TRADICIONES FICTAS

En todas las formas de tradición ficta del **art. 684** hay una idea permanente: aun sin realizarse la entrega real y material, el adquirente queda en posibilidad de disponer inmediatamente de la cosa tradida como poseedor. Aun cuando la cosa quede materialmente en poder del tradente, como en el constituto posesorio, este queda solo como mero tenedor, y si el adquirente no puede disponer materialmente de ella, jurídicamente ya dispuso, en el acto mismo, al aceptar que quedara en poder del tradente.

5. PRUEBA DE LA TRADICIÓN

Dada la importancia de demostrar que se efectuó la tradición de un objeto, y que este hecho no exige formas documentadas, conviene dejar constancia escrita de su realización, por ejemplo en el mismo título. Además, el **art. 702** inc. final consagra una presunción: la posesión de una cosa a ciencia y paciencia de quien se obligó a entregarla hace presumir la tradición, a menos que esta haya debido efectuarse por inscripción del título.

6. TRADICIÓN DE MUEBLES POR ANTICIPACIÓN

El **art. 685** inc. 1º establece la regla general: cuando con permiso del dueño de un predio se toman en él piedras, frutos pendientes u otras cosas que forman parte del predio, la tradición se verifica en el momento de la separación de esos objetos. Esta disposición se relaciona con el **art. 571**, que reputa muebles, aun antes de su separación, los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, para constituir un derecho sobre ellos a otra persona que el dueño. No hay conflicto entre ambas normas, porque tratan materias distintas: el **art. 571** califica de muebles ciertos bienes (los muebles por anticipación), y el **art. 685** inc. 1º establece la forma de efectuar su tradición, que es real, exigiendo que la separación se efectúe con permiso del dueño, en lo que radica precisamente la voluntad del tradente.

Se ha discutido si la tradición de estos bienes puede efectuarse, además de la forma real del **art. 685**, por alguna de las formas fictas del **art. 684**; como no se viola ninguna norma, la conveniencia práctica aconseja la respuesta afirmativa. El **art. 685** inc. 2º agrega una regla de acceso a la propiedad ajena: quien tenga derecho a los frutos de una sementera, viña o plantío puede entrar a cogerlos, fijándose el día y hora de común acuerdo con el dueño. Así, la tradición de un bosque puede efectuarse ya por alguna de las formas del **art. 684** (un solo acto, como mostrarlo, efectúa la tradición del conjunto de árboles), ya por la del **art. 685** inc. 1º (la tradición se va efectuando árbol por árbol, conforme se cortan).

7. TAXATIVIDAD DE LAS FORMAS FICTAS

Se discute si la tradición ficta puede efectuarse por formas distintas de las señaladas en el **art. 684**, aparte de los casos en que leyes especiales disponen otras formas. Autores como **CLARO SOLAR** no ven inconvenientes, y la jurisprudencia nacional ha fallado en igual sentido. Otros, como **PESCIO**, niegan esa posibilidad: estas formas fictas son creaciones de la ley, siempre excepcionales, y desde el punto de vista posesorio, el Código dispone que la posesión se adquiere por la aprehensión material o legal (**art. 723**), no pudiendo hablarse de aprehensión "legal" donde la ley no la establece; se hace notar, además, el carácter perentorio y limitativo de los términos con que el **art. 684** introduce su enumeración.

8. VALOR COMPARATIVO

Se discute el igual o diferente valor que debe atribuirse a la tradición real y a la ficta cuando entran en conflicto. Puede ocurrir que un tradente efectúe una tradición ficta y luego una real de la misma cosa a diferentes personas.

EJEMPLO

Conflicto entre tradición ficta y tradición real

X vende a Y un mueble, acordándose que X lo conservará en su poder como arrendatario (constituto posesorio); posteriormente X lo vende nuevamente a Z, a quien esta vez le efectúa la tradición real.

Entre nosotros, el **art. 1817** soluciona el problema para la compraventa: el comprador que primero haya entrado en posesión de la cosa será preferido. Como la posesión se adquiere al cambiar el ánimo, aun con la tradición ficta, en el ejemplo Y, el primer adquirente, sería el preferido, quedando Z solo con una acción de indemnización. Como el precepto no distingue, se sostiene que debe preferirse al primero aunque su tradición haya sido ficta, asignando a ambas formas igual valor.

Autores extranjeros, en cambio, atribuyen en la colisión mayor valor a la tradición real, por un principio protector del tercero: la tradición ficta, al efectuarse por actos representativos, no da noticia a los terceros del cambio de situación de la cosa, mientras que la tradición real sí es advertible por ellos. El problema puede presentarse con más dudas en contratos distintos de la compraventa, en que no se dispone ni siquiera del **art. 1817**.

9. TRADICIÓN DE MUEBLES REGISTRABLES

Buena parte de las legislaciones, entre ellas la nuestra, someten a un sistema de registro, en condiciones similares a los inmuebles, ciertos bienes muebles que por necesidades de organización y control del tráfico así lo requieren, como las naves, las aeronaves o los vehículos motorizados terrestres. En casos de textos insuficientes, se ha discutido si la inscripción registral desempeña o no la función de tradición.

Tratándose de vehículos motorizados terrestres, la legislación especial somete la constitución, transmisión, transferencia y gravámenes de su dominio a las normas del Derecho común para los bienes muebles: el título respectivo no está sometido a formas especiales y la tradición se rige por el **art. 684**. Existe, sin perjuicio de ello, un Registro de Vehículos Motorizados llevado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, en el que se inscriben el vehículo, su propietario y las variaciones de dominio; estas inscripciones no son requisito de los respectivos actos, pero se presume propietario a quien figure inscrito, salvo prueba en contrario, conforme a los **arts. 33** y siguientes de la Ley del Tránsito (Ley N° 18.290) y al Reglamento del Registro de Vehículos Motorizados.

H. LA TRADICIÓN DE DERECHOS REALES SOBRE INMUEBLES: EL SISTEMA REGISTRAL

1. INTRODUCCIÓN

Con la dictación del Código se estableció, para organizar la propiedad territorial, un sistema para los derechos sobre inmuebles basado en un registro. El Mensaje explica que el arbitrio más sencillo para poner a la vista de todos el estado de las fortunas territoriales era hacer obligatoria la inscripción de todas las enajenaciones de bienes raíces, exceptuadas las servidumbres prediales.

DATO DE GRADO

El Mensaje del Código Civil sobre el Registro Conservatorio

La transferencia y transmisión de dominio, la constitución de todo derecho real, exceptuadas las servidumbres, exige una tradición; y la única forma de tradición que para esos actos corresponde es la inscripción en el Registro Conservatorio. Mientras esta no se verifica, un contrato puede ser perfecto, puede producir obligaciones y derechos entre las partes, pero no transfiere el dominio, no transfiere ningún derecho real, ni tiene respecto de terceros existencia alguna. La inscripción es la que da la posesión real efectiva; y mientras ella no se ha cancelado, el que no ha inscrito su título, no posee: es un mero tenedor. Como el Registro Conservatorio está abierto a todos, no puede haber posesión más pública, más solemne, más indisputable, que la inscripción.

El **art. 686** dispone que la tradición del dominio de los bienes raíces se efectúa por la inscripción del título en el Registro del Conservador, y de la misma manera la de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces, los de habitación o censo y el de hipoteca; la tradición de las minas se rige por el Código de Minería. Relacionando esta norma con otros textos, la tradición del dominio y otros derechos reales sobre inmuebles se efectúa por inscripción (**art. 686**), con excepción de la servidumbre, que se efectúa por escritura pública (**art. 698**), salvo la servidumbre de alcantarillado en predios urbanos, que vuelve a la regla de la inscripción. La forma de efectuar la tradición del derecho real de herencia, en cambio, es discutida.

Considerando las diversas disposiciones del Código y de leyes especiales, la inscripción en nuestro registro inmobiliario cumple varias funciones: constituye la tradición del dominio y de otros derechos reales inmuebles; conforma la historia de las mutaciones, gravámenes y restricciones de la titularidad de los inmuebles; les confiere publicidad; constituye, para un importante sector de la doctrina, requisito, prueba y garantía de la posesión de inmuebles, la llamada "teoría de la posesión inscrita"; y, discutiblemente, constituye solemnidad de ciertos actos sobre inmuebles, como el usufructo por acto entre vivos (**art. 767**), el uso (**art. 812**), el fideicomiso (**art. 735**), el censo (**art. 2027**), la hipoteca (**art. 2409**) y la donación irrevocable (**art. 1400**).

2. ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS REGISTRALES

2.1. Fundamentos del sistema registral

En el Derecho Romano, y aun en el antiguo Derecho Español vigente en Chile antes del Código, la tradición del dominio de los inmuebles se efectuaba por alguna de las formas simbólicas ya vistas para los muebles. Para facilitar la circulación del dominio inmueble, evitar la clandestinidad y desarrollar el crédito territorial, fue imponiéndose en las legislaciones más avanzadas la publicidad de la constitución, transferencia y transmisión de los derechos reales sobre inmuebles. Con la dictación del Código se estableció entre nosotros, como es norma en la organización moderna de la propiedad territorial, un sistema de transferencia de los derechos sobre inmuebles basado en un Registro, que otorga publicidad a sus mutaciones jurídicas, facilita la circulación de la propiedad y el crédito con garantía territorial.

2.2. Tipos de registros

En teoría existen alternativas en varias cuestiones fundamentales para la construcción de un Registro Territorial.

a) Folio real vs. folio personal

El registro o folio real se lleva por predios: cada uno se matricula con un número de orden y le corresponde una hoja especial que constituye su registro, permitiendo conocer de un vistazo todas sus mutaciones y gravámenes. El registro o folio personal se organiza tomando como pauta los nombres de las personas a quienes afecta cada anotación: para conocer la historia de un predio, obliga a encontrar el nombre de todos sus propietarios anteriores y revisar largos índices. Este último es el sistema que opera en Chile.

b) Registro de transcripciones vs. registro de inscripciones

Bajo el sistema de las transcripciones, lo que se registra es una copia íntegra de los títulos presentados. Bajo el sistema de las inscripciones, en cambio, lo que consta en el registro es un extracto o resumen del título. En Chile rige el sistema de las inscripciones.

c) Sistemas con legalidad registral vs. sistemas sin legalidad registral

Se entiende por legalidad registral el carácter de seguridad absoluta, eventualmente con garantía del Estado, de que los titulares de derechos incorporados al Registro efectivamente lo son: implica garantizar la validez y eficacia de los actos que motivaron la inclusión del inmueble a nombre de determinada persona, de modo que si el contrato que originó la inscripción resulta nulo, esa nulidad generalmente no altera la situación registral, y la reparación al perjudicado se hace por compensación de dinero. Dar legalidad a un Registro exige un riguroso examen de los antecedentes jurídicos del primer solicitante y de las características materiales del inmueble.

Entre los sistemas de mayor renombre están el prusiano o alemán y el Acta Torrens, vigente en Australia, en el que la inscripción también es prueba del dominio: el Estado examina los antecedentes y el plano presentados por el propietario y, si están conformes, efectúa la inscripción, redactando dos certificados idénticos, uno para el propietario y otro para el Registro.

En Chile, **BELLO** no estableció conscientemente un sistema en que la inscripción garantizara la propiedad, sino solo la posesión, para evitar los problemas de implementar una legalidad registral que hubiera exigido providencias compulsivas y juicios costosos y de larga duración. La aspiración del sistema, expresada en el Mensaje, es que algún día inscripción, posesión y propiedad sean términos idénticos; esa época aún no ha llegado.

3. EL SISTEMA REGISTRAL CHILENO

3.1. El Registro Conservatorio de Bienes Raíces

Las normas legales fundamentales están contenidas en los **arts. 686** y siguientes del Código, y en virtud de lo prescrito en el **art. 695**, en el Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, de 24 de junio de 1857, que consigna básicamente su organización y funcionamiento.

a) El Conservador de Bienes Raíces

El registro funciona como una oficina en cada comuna, a cargo de un funcionario llamado Conservador de Bienes Raíces, auxiliar de la administración de justicia y ministro de fe pública (**arts. 446** y siguientes del Código Orgánico de Tribunales); en Santiago está a cargo de tres funcionarios, y en la mayoría de las comunas el notario es, a la vez, el Conservador. El Conservador no tiene atribuciones para examinar la validez y eficacia de los títulos ni la correspondencia entre las declaraciones sobre los predios y sus características reales, por lo que el Estado no garantiza esa congruencia ni la calidad de auténtico propietario de quien aparece como dueño en la inscripción.

Sí tiene responsabilidad por negligencia, dolo o abuso en el desempeño de sus funciones (**arts. 96 a 98**): civil, conforme a las reglas generales (**arts. 2314** y siguientes); funcionaria, según el Código Orgánico de Tribunales (**art. 530** y siguientes); y penal, según las normas sobre delitos funcionarios. No percibe sueldo fiscal, sino derechos arancelarios que cobra a los interesados.

b) Libros fundamentales

Los libros fundamentales son el Repertorio, el Registro y el Índice General; el Registro es el que constituye propiamente el sistema, siendo los otros dos su complemento. Leyes posteriores han entregado al Conservador el mantenimiento de otros registros, como el de Comercio, el de Prenda Agraria o el de Prenda Industrial.

El Repertorio

Es el libro de ingreso de la oficina (**arts. 21** y siguientes del Reglamento): en él se anotan todos los títulos que se presentan al Conservador, por orden cronológico de llegada, cualquiera sea su naturaleza, y al igual que el Registro es de periodicidad anual.

El Registro

Está integrado por tres registros particulares: el Registro de Propiedad, en el que se inscriben las traslaciones de dominio (transferencias, transmisiones y adquisiciones por prescripción); el Registro de Hipotecas y Gravámenes, en el que se inscriben las hipotecas, censos, derechos de usufructo, uso y habitación, fideicomisos, servidumbres y gravámenes semejantes; y el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, en el que se inscriben las interdicciones, prohibiciones de enajenar e impedimentos del **art. 53 N° 3**. Todos son anuales, y en cada uno se inscriben también las respectivas cancelaciones y subinscripciones (**art. 33**). Cada registro parcial contiene un índice alfabético de los otorgantes (**art. 41**), de especial importancia práctica.

El Índice General

Junto con los índices de cada registro parcial, permite el funcionamiento del sistema, ubicando las inscripciones y permitiendo reconstruir la historia de los inmuebles. Se construye por orden alfabético de los otorgantes, a medida que se practican las inscripciones en los tres registros (**art. 43**), y es igualmente anual.

c) Publicidad

El Registro es público, y el Conservador está obligado a dar las copias y certificados que se le soliciten (**arts. 49, 50 y 51**). Entre los certificados más frecuentes están los de "dominio vigente", en que se deja constancia de que un inmueble está inscrito a nombre de determinada persona; los de "gravámenes", que dan cuenta de cargas como hipotecas o usufructos; y los de "prohibiciones", que dan cuenta de impedimentos al libre ejercicio del derecho de enajenar, como embargos. El examen del Registro se retrotrae en el tiempo hasta el plazo de la prescripción extraordinaria, que consolida la situación registrada sin que puedan afectarla defectos anteriores.

3.2. Principios en los que se funda el sistema registral chileno

Siguiendo la exposición de **HERNÁNDEZ y PEÑA**, pueden identificarse los siguientes principios.

a) Principio de tracto sucesivo

Cada inscripción relativa a un inmueble va concatenada a la anterior, lo que permite revisar el historial del bien raíz como una cadena de eslabones sucesivos, con la excepción de la primera inscripción, que no tiene una que la anteceda. Se consagra en el **art. 692** del Código y en el **art. 80**

del Reglamento: siempre que se transfiera un derecho antes inscrito, se debe mencionar la inscripción precedente en la nueva.

b) Principio de rogación

El Conservador practica una inscripción o anotación solo a petición de parte, no pudiendo hacerlo de oficio, conforme al **art. 690** del Código y a los **arts. 60 y 61** del Reglamento. La jurisprudencia ha resuelto que el procedimiento registral solo puede ponerse en marcha a instancia de parte, y que solo pueden practicarse los asientos solicitados. Solo excepcionalmente el Conservador puede actuar de oficio, para rectificaciones de forma o anotaciones de simple referencia (**arts. 88 y 92** del Reglamento), este último con la prohibición expresa de cancelar inscripciones de oficio.

c) Principio de prioridad

Consagrado en los **arts. 14, 17 y 66** del Reglamento, consiste en priorizar la inscripción requerida con anterioridad frente a la solicitada en momento posterior. Como señala **PEÑAILILLO**: primero en el tiempo, primero en el derecho.

d) Principio de inscripción

Conforme al **art. 686**, la tradición del dominio de los inmuebles y de los demás derechos que allí se señalan se efectúa mediante la inscripción, y conforme al **art. 724**, también la posesión se adquiere mediante ella. La inscripción no tiene en nuestro ordenamiento un carácter declarativo, pero tampoco llega a ser constitutiva: en cuanto única forma de efectuar la tradición, lo que prueba y garantiza es la posesión (cuestión discutida, como se dirá), sin que exista obligación de realizarla.

e) Principio de publicidad

Consiste en el acceso libre a la información del Registro y en la posibilidad de requerir las certificaciones pertinentes, lo que da sostén tanto a las relaciones entre quienes negocian sobre inmuebles como a la protección de la confianza razonable de terceros. El Reglamento lo consagra ampliamente en sus **arts. 49, 50 y 51**.

f) Principio de fe pública registral

Consiste en tener por verdaderos los datos contenidos en el Registro, de modo que los errores u omisiones posteriormente descubiertos no serían oponibles a los terceros de buena fe que, amparados en la seguridad de esa información, contratan con quien aparece legitimado para disponer del derecho. Este principio no está consagrado expresamente en nuestro ordenamiento, lo que provoca críticas doctrinales sobre su verdadero alcance práctico.

3.3. Títulos que deben inscribirse y títulos que pueden inscribirse

a) Títulos que deben inscribirse

El **art. 52** del Reglamento enumera estos títulos, que deben complementarse con varias normas del Código y de leyes especiales:

a. Los títulos traslativos de dominio de bienes raíces y los de los derechos de usufructo, uso, habitación, censo e hipoteca constituidos en inmuebles.

Aunque el precepto pareciera aludir a títulos traslativos de uso y habitación, estos derechos son personalísimos (**art. 819**) y, por ende, intransferibles e intransmisibles.

b. La sentencia ejecutoriada que declare la prescripción adquisitiva del dominio sobre un inmueble o de los derechos anteriores.

En relación con los **arts. 689 y 2513**.

c. La constitución de fideicomisos relativos a inmuebles.

d. La constitución de usufructos sobre inmuebles por acto entre vivos.

e. La constitución del uso y habitación sobre inmuebles por acto entre vivos.

f. La constitución, división, reducción y redención del censo.

g. La constitución de censo vitalicio.

h. La constitución de la hipoteca.

i. La renuncia de cualquiera de los derechos anteriores.

j. Los decretos de interdicción provisoria y definitiva.

k. Los decretos que rehabilitan al disipador y al demente.

l. Los decretos que confieren la posesión definitiva de los bienes del desaparecido.

m. Los decretos que conceden el beneficio de separación de bienes (art. 1385).

b) Títulos que pueden inscribirse

El **art. 53** menciona estos títulos, también complementado por otras normas del Código y de leyes especiales:

a. Toda condición suspensiva o resolutoria del dominio de inmuebles.

b. Toda condición suspensiva o resolutoria de otros derechos reales constituidos sobre inmuebles.

c. Todo gravamen impuesto sobre un inmueble, distinto de los del art. 52, como las servidumbres.

d. El arrendamiento en el caso del art. 1962.

e. Cualquier otro acto o contrato cuya inscripción sea permitida por la ley.

f. Todo impedimento o prohibición referente a inmuebles, sea convencional, legal o judicial, que embarace o limite el libre ejercicio del derecho de enajenar.

El Código de Procedimiento Civil modificó el N° 3 del **art. 53** respecto de las prohibiciones judiciales, haciendo obligatoria, para afectar a terceros, la inscripción de la prohibición decretada por el juez de celebrar actos o contratos sobre bienes raíces (**art. 297** inc. 1°), y del embargo que recae sobre bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos, expresión que los autores y la jurisprudencia entienden en sentido amplio, comprensivo de otras medidas que aseguren el resultado del juicio (**art. 453** inc. 1°).

En cuanto a las prohibiciones convencionales, si recaen sobre inmuebles pueden inscribirse (**art. 53 N° 3**). Inscrita la prohibición, se discute qué debe hacer el Conservador si el obligado a no enajenar, infringiendo su obligación, enajena y pide que se inscriba ese título. Se ha sostenido que debe negarse, por el **art. 13** del Reglamento, al ser un caso de inscripción "legalmente inadmisibles", pues la coherencia del Registro impide un título que contradice una prohibición ya inscrita.

También se ha sostenido que debe inscribir, porque la validez de la cláusula de no enajenar es discutida, y aun admitiéndola, genera solo una obligación de no hacer cuya infracción no corresponde controlar al Conservador, cuyo principio general es inscribir los títulos que se le presenten, salvo excepciones que deben interpretarse restrictivamente. La jurisprudencia parece inclinarse por esta segunda alternativa.

3.4. Modo de proceder a las inscripciones, su forma y solemnidad

Estas materias están reguladas principalmente en los Títulos VI y VII del Reglamento, **arts. 54** y siguientes.

a) Comuna en que debe efectuarse

Es la de la ubicación del predio (**arts. 54** del Reglamento, **687** del Código y **659** del Código de Procedimiento Civil); si el inmueble está en dos o más comunas, debe inscribirse en todas ellas. La inscripción en una comuna que no corresponde es inútil, aplicándose el **art. 696**: los títulos no dan ni transfieren la posesión efectiva mientras la inscripción no se efectúe como se ordena.

b) Quién puede pedir la inscripción

Conforme al **art. 60**, los interesados pueden pedirla por sí, por personeros o por representantes legales. El **art. 61** agrega que si la inscripción es para transferir el dominio u otro derecho real del **art. 52 N° 1**, el apoderado o representante debe presentar el título de su mandato o representación; en las demás basta la copia auténtica del título en virtud del cual se pide la inscripción.

c) Documentos con que se requiere la inscripción: minutas

Se solicita exhibiendo copia auténtica del título o del decreto judicial (**arts. 690** del Código y **57** del Reglamento); aunque no lo dice expresamente, solo se admite la inscripción de instrumentos públicos, no de documentos privados. El **art. 57** agrega que se exhibirán también los demás documentos necesarios, sean públicos o privados, dando lugar a las llamadas minutas: instrumentos privados suscritos por los interesados, cuya función es suplir o explicar designaciones defectuosas o insuficientes de los títulos, sin que en caso alguno puedan considerarse una nueva inscripción o un nuevo título (**art. 82** del Reglamento).

d) Anotación en el Repertorio

Es la constancia de la presentación y recepción de un título para su inscripción, efectuada por estricto orden de presentación, con las menciones del **art. 24** (**arts. 65 y 66**). El Conservador no examina la legalidad de los títulos, y en ningún caso deja de anotar en el Repertorio el título presentado, salvo desistimiento del requirente (**arts. 15 y 67**). Si tras la anotación se niega a inscribir, el Reglamento señala el procedimiento a seguir (**arts. 14** inc. final, 25, 18, 19 y 20).

La anotación en el Repertorio es presuntiva y caduca a los dos meses si no se convierte en inscripción, salvo que la imposibilidad de inscribir se deba a una prohibición judicial. Convertida en inscripción, esta surte efectos desde la fecha de la anotación, operando retroactivamente (**art. 17**). Mientras está pendiente subsanar el defecto de un título, pueden efectuarse otras anotaciones incompatibles sobre el mismo inmueble; en la práctica, se hace la segunda anotación, pero no se inscribe hasta que caduque la primera. Cualquier interesado puede solicitar un "certificado de repertorio", que da cuenta de las anotaciones existentes respecto de un inmueble (**art. 69**), relevante por el efecto retroactivo de las inscripciones a la fecha de la anotación.

3.5. Obligación de inscribir y causales de negativa

La regla general es que el Conservador está obligado a inscribir los títulos que se le presenten, sin retardo (**arts. 12, 13, 14, 25 y 70**). Excepcionalmente puede negarse, por alguna de las causales de los **arts. 13 y 14**, estampando el motivo en el título y dejando constancia en el Repertorio. El perjudicado puede reclamar ante el juez de primera instancia (**arts. 18 a 20**), quien resuelve tras pedir informe al Conservador; si rechaza la solicitud, cabe apelación, y para algunos, casación en el fondo contra el fallo de la Corte, atendido que el Reglamento constituye jurídicamente un Decreto con Fuerza de Ley.

a) La causal genérica del art. 13

El Conservador puede rehusar inscribir si la inscripción es "en algún sentido legalmente inadmisibles", término objetado por su imprecisión. Los ejemplos que da el Reglamento (copia no auténtica, inmueble fuera del departamento, falta de aviso del **art. 58**, vicio que anule absolutamente el título, o falta de designaciones legales) apuntan principalmente a defectos de forma, salvo el penúlti-

mo ("vicio o defecto que lo anule absolutamente"), sobre cuyo alcance formal o sustancial se discute. En todo caso, esta causal presenta dos límites: debe tratarse de un defecto que provoque nulidad absoluta, y debe ser "visible en el título", esto es, perceptible con su solo examen, sin necesidad de confrontarlo con otros antecedentes (equivalente a la causal del **art. 1683** para que el juez declare de oficio la nulidad absoluta).

b) Las causales específicas del art. 14

Son dos, bien determinadas: cuando, inscrito un predio por una compraventa, se solicita una nueva inscripción en favor de otra persona invocando un título de compraventa distinto emanado del mismo vendedor; y cuando un fundo es vendido por quien, según el Registro, no es su dueño o actual poseedor.

En conjunto, las atribuciones de control del Conservador son limitadas y se circunscriben principalmente a las formas de los títulos, careciendo por regla general de control sobre el fondo de los actos, labor que recae en el juez. El sistema carece, por ello, de legalidad registral, lo que le resta seguridad y permite litigios frecuentes.

3.6. Plazo para inscribir

El Reglamento no trata expresamente desde cuándo y hasta cuándo puede inscribirse. Pueden enunciarse dos principios: como la inscripción es consecuencia del título, es este el que debe examinarse para determinar el plazo; y esa indagación debe orientarse a su eficacia en el tiempo en que se pretende inscribir, de modo que, por ejemplo, una compraventa de inmueble puede inscribirse desde que sea exigible la obligación de efectuar la tradición, lo que generalmente ocurre desde que se perfecciona el contrato.

3.7. Inscripción de inmuebles que no han sido antes inscritos

Se establece un procedimiento especial, la "inscripción por avisos", regulado en el **art. 693** del Código y el **art. 58** del Reglamento, para dar publicidad a la inscripción que se pretende. Exige dar noticia a terceros mediante tres avisos publicados en un diario de la comuna, o en su defecto de la capital de provincia o de región, y fijar un cartel durante 15 días en la oficina del Conservador, con las designaciones de quienes transfieren y de los linderos y nombre de la propiedad. El Conservador protocoliza el cartel y certifica el cumplimiento de estos requisitos; la inscripción no puede efectuarse antes de 30 días desde el otorgamiento del certificado.

Se discute la sanción por incumplir estas formalidades: para algunos, la nulidad absoluta; para otros, la inoponibilidad al tercero perjudicado. Estas formalidades se exigen para la transferencia del dominio por acto entre vivos o la constitución y transferencia de otros derechos reales sobre inmuebles no inscritos, pero no para una primera inscripción basada en otros antecedentes, como la sentencia que declara la prescripción adquisitiva o las inscripciones originadas en la sucesión por causa de muerte.

3.8. Inscripción de títulos anteriores a la vigencia del Reglamento

El **art. 101** del Reglamento permite inscribir estos títulos con la sola presentación del título, si lo hubiere; si faltare, la inscripción se hace cumpliendo las prescripciones del **art. 58**. Las firmas de las partes no son necesarias en ninguno de los dos casos, y las designaciones omitidas se suplen por minutas firmadas por los interesados, en concordancia con los **arts. 39 y 85**.

3.9. Confección y contenido de las inscripciones

Su confección se regula en los **arts. 73 y 75 a 77** del Reglamento. En cuanto al contenido, la inscripción es un extracto o resumen del título, cuyas menciones precisas señalan el Código y el Reglamento según la naturaleza del título (**arts. 690** y siguientes del Código y **78** y siguientes del Reglamento). Para mantener el encadenamiento de las inscripciones se exige, cuando procede, mencionar la inscripción precedente (**arts. 692** del Código y **80** del Reglamento), práctica que se complementa con una nota de referencia en la inscripción anterior hacia la posterior.

Ante la ausencia de menciones en el título, el **art. 82** del Reglamento distingue: la falta absoluta se suple con escritura pública, y los defectos o insuficiencias, con minutas. Dos menciones merecen comentario especial: los linderos (**arts. 78 N° 4 y 81 N° 3**) y los datos de la inscripción precedente (**art. 80**). Si faltan, procede la negativa del Conservador por la causal del **art. 13**, debiendo el interesado suplir el defecto con escritura pública complementaria o minuta, según el caso; nada impide, en todo caso, que se celebren simultáneamente dos o más compraventas sobre un mismo predio en una misma escritura, caso en el cual el Conservador practica inscripciones sucesivas.

3.10. Subinscripciones

Los errores, omisiones u otras modificaciones necesarias una vez practicada la inscripción se salvan a su margen derecho, mediante las llamadas subinscripciones: anotaciones escritas al margen, en la forma y para los fines que señala el Reglamento (**arts. 88, 89 y 91**).

3.11. Cancelaciones

Cancelar una inscripción es dejarla sin efecto. El Reglamento dispone que las cancelaciones se efectúen mediante subinscripciones (**art. 91**), pero debe tenerse presente el **art. 728** del Código: para que cese la posesión inscrita es necesario que la inscripción se cancele por voluntad de las partes, por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, o por sentencia judicial. En el segundo caso, la subinscripción del **art. 91** no es indispensable para la cancelación, sino solo una conveniencia del Registro: si el dueño inscrito vende y el comprador inscribe la venta, esa nueva inscripción ya cancela la anterior.

3.12. Reinscripciones

La práctica ha configurado el mecanismo de las "reinscripciones", que consiste en volver a inscribir inmuebles ya inscritos sin cambiar de titular. Se recurre a ellas, por ejemplo, cuando un heredero enajena un inmueble sin cumplir las inscripciones del **art. 688** del Código y del **art. 55** del Reglamento: el adquirente logra inscribir a su nombre, pero esa inscripción es ineficaz para conferir posesión (**art. 696**); subsanada la situación por el heredero, el adquirente solicita reinscribir el inmueble a su nombre, quedando debidamente encadenado. También opera en los casos de "formación de fundos" o fusión de inmuebles contiguos mediante minuta, y cuando se crean nuevos conservadores y es necesario trasladar las inscripciones.

3.13. Sanción por defectos de la inscripción

La mayoría de las exigencias de una inscripción son requisitos de forma, cuya infracción, según **PEÑAILILLO**, trae la nulidad absoluta, debiendo buscarse la consecuencia de esa nulidad en el rol que en cada caso cumple la inscripción. Según **ROZAS**, si el requisito omitido lo establecen los **arts. 686 a 695** del Código, la sanción es la del **art. 696**: la inscripción no da la posesión efectiva del respectivo derecho, y si se trata de un título traslativo, no transfiere el derecho, sin que la inscripción misma sea nula. Si se trata de otro requisito, su omisión produce nulidad absoluta (**art. 1682**).

3.14. Saneamiento de títulos

Atendido que numerosos inmuebles tienen antecedentes jurídicos poco claros, por defectos en los títulos o en la inscripción, se han dictado leyes de saneamiento, destacando el DL 2.695 sobre saneamiento de títulos de la pequeña propiedad raíz. Conforme a él, quien se considera dueño de un predio de avalúo no superior al máximo indicado, que lo haya poseído material, pacífica e ininterrumpidamente por al menos cinco años y carezca de título inscrito a su nombre, puede solicitar su inscripción al Ministerio de Bienes Nacionales. Se sigue un proceso administrativo en que los interesados pueden oponerse; si no hay oposición, se ordena inscribir el inmueble a nombre del solicitante, que queda como poseedor regular, y al cabo de un año se le tiene por dueño, por un plazo especial de prescripción.

3.15. Problemas del sistema registral chileno

En la práctica se presentan diversos problemas, principalmente las "inscripciones paralelas" y las "inscripciones de papel", que se desarrollan siguiendo un trabajo de **HERNÁNDEZ y PEÑA**.

a) El problema de las inscripciones paralelas

Responden a la distorsión que se produce en la cadena de inscripciones de un predio: por defectos del sistema, nace en cierto momento una cadena paralela, existiendo dos o más inscripciones apa-

rentemente vigentes a nombre de distintos titulares, entre quienes debe resolverse el conflicto posesorio.

a. Dobles inscripciones generadas por el art. 693.

La inscripción de un inmueble ya inscrito, tramitada mediante avisos y cartel como si no lo estuviera, solo genera una inscripción paralela que no cancela la anterior (**arts. 693 y 728**).

b. Dobles inscripciones por omisión de la cancelación.

Se demanda la cancelación de una inscripción y esta se acoge, pero el Conservador no la practica, de modo que tanto los inscritos sin derecho como quienes obtuvieron sentencia favorable terminan con el inmueble inscrito.

c. Dobles inscripciones a partir del art. 14 del Reglamento.

Como esta norma no impide inscribir, sino que ordena esperar hasta que conste que la pretensión del segundo adquirente ha sido puesta judicialmente en noticia de los interesados, es posible que en el intertanto se generen dobles inscripciones.

d. Dobles inscripciones a partir del art. 15 del DL N° 2.695.

Este decreto ley hace primar la posesión material sobre la posesión inscrita, colocando al solicitante como poseedor regular, no como dueño, lo que genera el enfrentamiento entre el "poseedor de papel" y el "poseedor material".

Para resolver estos casos se han propuesto tres criterios: la prevalencia de la primera inscripción en el tiempo, sostenida por autores como **TRUCCO** y que encuentra apoyo normativo en el **art. 1817**; la prevalencia de la inscripción acompañada de posesión material, criterio de mayor acogida en los tribunales por vincular inscripción y posesión (corpus y animus del **art. 700**); y la prevalencia de la inscripción que mejor se concatena con las anteriores, criterio minoritario que prioriza la estricta rectitud del tracto sucesivo por sobre consideraciones de justicia sustantiva.

b) El problema de las inscripciones de papel

Son las que solo representan una anotación en el Registro, sin que su titular tenga la posesión física o material del inmueble. Para **URRUTIA**, se refieren a un inmueble que nunca se ha poseído materialmente y que, por no reunir los requisitos del **art. 700**, no valen contra otra inscripción anterior o posterior, porque la inscripción solemniza un hecho verdadero y no puede solemnizar apoderamientos que no han existido. A diferencia de las inscripciones paralelas, que son un problema interno del sistema registral, las de papel son un problema externo, propio de la filosofía de la posesión inscrita, aunque sus causas coinciden en gran medida con las de las dobles inscripciones.

La doctrina y jurisprudencia siguen, en general, el criterio de que la solemnidad de la inscripción no permite prescindir de la realidad fáctica que constituye la posesión, definida en el **art. 700** inc. 1° como la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño: el corpus y el animus.

4. TRADICIÓN DE DERECHOS REALES SOBRE INMUEBLES

Analizado el sistema registral, la tradición del dominio y demás derechos reales sobre inmuebles se efectúa por la inscripción del título (**art. 686**), con las excepciones ya mencionadas: la inscripción desempeña aquí el rol de tradición. Rigiendo entre nosotros el sistema de la dualidad título y modo, mientras la inscripción de un título traslativo no se efectúa, el dominio no se ha transferido: en la compraventa de inmuebles, perfeccionada la escritura pública, mientras no se inscribe, el vendedor mantiene el dominio y el comprador no lo ha adquirido.

Como la inscripción es una tradición simbólica, a ella debe seguir la entrega material: el vendedor no cumple íntegramente su obligación de entregar la cosa mientras no la entrega materialmente, lo que incide en la procedencia de las acciones de cumplimiento, resolución, posesorias o reivindicatoria según las particularidades de cada caso. Como el dominio se adquiere por un solo modo, cuando opera uno distinto de la tradición, la inscripción es innecesaria para transferirlo, aunque puede ser útil para sus otras funciones: así se ha fallado respecto de la expropiación, en que el dominio lo adquiere el expropiante por el título y modo ley.

En la compraventa y tradición de inmuebles conviene además tener presentes los **arts. 1491 y 1876**, en relación con el **art. 1707**, que explican la forma práctica en que se celebran y ejecutan estos actos. El **art. 1491**, sobre los efectos de la condición resolutoria respecto de terceros adquirentes de un inmueble, dispone que si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena, no podrá resolverse la enajenación sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública; y el **art. 1876** inc. 1º agrega que la resolución por no haberse pagado el precio no da derecho al vendedor contra terceros poseedores sino conforme a los **arts. 1490 y 1491**.

De estas normas, aplicables a toda condición resolutoria, sea expresa o tácita, surge que si en la escritura de compraventa no figura íntegramente pagado el precio, dando cuenta de una condición resolutoria tácita pendiente, todo tercero adquirente queda expuesto a que se resuelva su adquisición, lo que entraría la libre circulación del inmueble. Como el sistema de transferencia se verifica mediante la posterior inscripción del título (**art. 686**), las partes son reacias a pagar de inmediato el precio: el comprador solo querrá entregarlo una vez inscrito el inmueble a su nombre, y el vendedor solo querrá entregar el inmueble una vez pagado el precio.

La práctica salva esta situación mediante una compraventa parcialmente simulada, posible en virtud del **art. 1707**, que resta efectos contra terceros a las escrituras privadas que alteran lo pactado en escritura pública. Se otorga la compraventa señalando que el precio está íntegramente pagado, de modo que en el título no figure una condición pendiente, y las partes suscriben al mismo tiempo una contraescritura privada, conocida como "instrucción al notario", en la que se indica que el precio en realidad queda en poder del notario, quien solo lo entregará al vendedor una vez que el inmueble se inscriba a nombre del comprador. Con ello se cumple una doble finalidad: no figura condición pendiente en el título que se inscribe, protegiendo a los terceros, y el comprador queda tranquilo porque el precio no se libera al vendedor hasta que el inmueble quede inscrito a su nombre.

5. TRADICIÓN DE CUOTAS

Los textos no disponen claramente la forma de efectuar la tradición de la cuota de un objeto.

5.1. Cuota en cosa singular

La doctrina y jurisprudencia entienden que la cuota participa del carácter mueble o inmueble de la cosa: si es de un mueble, su tradición se efectúa por cualquiera de las formas del **art. 684**, y si es de un inmueble, por inscripción, cobrando aplicación el **art. 580**.

Discutida y frecuente es la "enajenación de cuota de una universalidad, referida a un bien determinado": durante la indivisión, el comunero suele disponer de su cuota referida a un bien específico de la comunidad, generalmente un inmueble, usualmente por venta, quedando los efectos definitivos en suspenso hasta el término de la indivisión. Si al partir no se le adjudica al enajenante la cosa cuya cuota vendió, habrá venta de cosa ajena (**art. 1344**), que es válida (**art. 1815**); estos precarios efectos, en suspenso hasta el término de la comunidad, generan dificultades prácticas que no hacen aconsejable la negociación. En teoría, esta figura armoniza mejor con la doctrina que sostiene la comunicación de la cuota con los bienes específicos que con la que la rechaza, y su tradición se efectúa de la misma forma que la de cuota en cosa singular, distinguiendo según la cosa sea mueble o inmueble.

DATO DE GRADO

Por qué la venta de cuota en bien determinado de una comunidad hereditaria es riesgosa

Si se trata de una cosa singular que pertenece a una comunidad hereditaria, el **art. 688** exige posesión efectiva, su inscripción y la inscripción especial de herencia a nombre de todos los herederos antes de poder disponer de la cuota de un inmueble determinado, y la Ley N° 16.271 exige, para los muebles, posesión efectiva e inscripción. El adquirente puede además tener dificultades para ejercer actos de comunero en la cosa y para lograr la inscripción conservatoria, que el Conservador podría objetar.

5.2. Cuota en cosa universal

Aquí la respuesta es controvertida, porque además de la discusión sobre el concepto de universalidad de hecho y de derecho, y sobre si en Chile puede haber comunidad sobre universalidades jurídicas, incide el problema de la comunicación entre la cuota y los bienes que la componen.

Algunos autores, como **SOMARRIVA**, admiten la comunidad sobre universalidad jurídica y, negando la comunicación de la cuota con los bienes, entienden que su tradición se efectúa por cualquiera de las formas simbólicas del **art. 684**, sin requerir inscripción conservatoria aunque haya inmuebles en su contenido, por tratarse de una abstracción que escapa a la clasificación de muebles e

inmuebles. Esta sería la solución para la tradición de una cuota en la comunidad que queda al disolverse una sociedad conyugal.

La postura contraria rechaza que haya comunidad sobre universalidad jurídica, admitiéndola solo sobre universalidades de hecho, y afirmando la comunicación entre la cuota y los bienes, concluye que la tradición sigue la naturaleza de los bienes que la componen: por el **art. 684** para los muebles y por inscripción para los inmuebles. Respecto de universalidades que sin duda son de hecho, como las colecciones o explotaciones, esta última solución cobra fuerza, debiendo recordarse el **art. 580**; el caso del establecimiento de comercio, si se califica de universalidad de hecho, quedaría incluido en esta situación, aunque la naturaleza de algunos de sus elementos incorporeales, como el derecho de llaves o la clientela, puede generar dudas.

6. INSCRIPCIONES A QUE DA LUGAR LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE

6.1. El art. 688 del Código Civil

La inscripción conservatoria cumple básicamente la función de tradición de inmuebles, pero también otras, como mantener la historia de la propiedad raíz y dar publicidad a los actos sobre ella. Para atender a estas otras finalidades se exige también la inscripción en mutaciones de dominio que se producen por otros modos, como la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva. De varios preceptos del Código (**arts. 588, 722, 955, 956 y 1344**) se desprende que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir que opera por el solo fallecimiento del causante.

Si el heredero quiere disponer de un mueble hereditario, debe obtener la posesión efectiva e inscribirla, conforme a la ley de impuesto de herencias (**art. 25**), trámite que el Código de Procedimiento Civil contempla aunque no haya inmuebles (**art. 883**). Para disponer de un inmueble hereditario, debe obtener la posesión efectiva de la herencia (por resolución judicial si es testada, o del Director Regional del Registro Civil si es intestada) y practicar las inscripciones del **art. 688** del Código y **art. 55** del Reglamento:

(i) La inscripción del decreto judicial o de la resolución administrativa que otorga la posesión efectiva.

El decreto judicial se inscribe en el Registro de Propiedad de la comuna del tribunal que lo dictó y en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas; la resolución administrativa se inscribe en este último registro, y el certificado que la acredita debe acompañarse al Conservador del último domicilio del causante para inscribirla también en el Registro de Propiedad. Si la sucesión es testamentaria, se inscribe además el testamento. En virtud de estas inscripciones, los herederos pueden disponer de los bienes muebles.

(ii) La inscripción especial de herencia.

Se practica con el mérito de la anterior: consiste en inscribir los inmuebles de la sucesión a nombre de todos los herederos en comunidad, tantas inscripciones como inmuebles haya, en el Registro del departamento en que se ubiquen. Con ella los herederos pueden disponer de consuno de los inmuebles hereditarios. Si el causante estaba casado en sociedad conyugal y había inmuebles en ella, deben inscribirse a nombre del cónyuge sobreviviente y de los herederos (**art. 30** de la ley de impuesto de herencias).

(iii) La inscripción de la adjudicación.

Al efectuarse la partición de la comunidad hereditaria, se inscribe la adjudicación: cada inmueble, hasta entonces inscrito a nombre de los herederos, queda inscrito a nombre del heredero adjudicatario, quien desde ese momento puede disponer de él por sí solo. Con estas tres inscripciones puede seguirse en el Registro la historia de un inmueble que perteneció primero al causante, luego a sus herederos y finalmente a uno de ellos. Estas exigencias no impiden que los comuneros se adjudiquen entre sí inmuebles en pago de sus cuotas, porque esas adjudicaciones no implican "disposición", sino solo radicación de derechos cuotativos en bienes determinados.

6.2. Sanción por infracción al art. 688 del Código Civil

Conforme al **art. 688**, la posesión legal de la herencia no habilita al heredero para disponer de un inmueble mientras no se practiquen las inscripciones que señala. Se discute cuál es la sanción cuando, sin practicarlas, el heredero dispone de un inmueble. La Corte Suprema ha dado, a lo largo del tiempo, soluciones diversas.

a. Nulidad absoluta del título.

En un primer momento, la Corte resolvió que la sanción recaía sobre el título traslativo otorgado por el heredero, por infringirse normas de orden público sobre la organización del Registro, extendiendo la prohibición incluso a las ventas forzadas en juicio ejecutivo.

b. Inaplicabilidad a las enajenaciones forzadas.

En una segunda etapa, la Corte limitó la prohibición del **art. 688** a los actos voluntarios de los herederos, pues de mantenerse el primer criterio estos podrían paralizar toda ejecución en su contra con solo negarse a inscribir.

c. Validez del contrato, nulidad de la tradición subsecuente.

En una tercera interpretación, la Corte entendió "disponer" en su sentido restringido de enajenar, de modo que la venta, al no transferir el dominio por sí sola, es válida aunque no se hayan practicado las inscripciones; lo nulo sería la tradición subsecuente. Se ha objetado a este fallo que el **art. 1810** prohíbe la venta de las cosas cuya enajenación está prohibida por la ley, pero en su defensa se contra-argumenta que el **art. 688** no es una norma prohibitiva, sino imperativa de requisito.

d. El art. 688 se refiere solo a la tradición, no al título.

Una sentencia posterior precisó que el **art. 688**, por su ubicación en el párrafo de la tradición, no puede referirse al título, como la compraventa, sino al modo de adquirir.

e. La sanción del art. 696: ineficacia transitoria.

Una quinta interpretación, más aceptada por la doctrina, entiende el **art. 688** como norma imperativa de requisitos, no prohibitiva, de modo que su sanción no es la nulidad absoluta sino la del **art. 696**: la inscripción que obtenga el adquirente del heredero no le confiere la posesión mientras no se practiquen las inscripciones omitidas, ineficacia transitoria que se sana, al menos tácitamente, cuando estas se completan.

Se objeta a esta última solución que el **art. 696** se refiere solo a las inscripciones que transfieren el dominio, no a las del **art. 688**, y que deja al tercero adquirente en una posición inestable, obligado a reinscribir su título una vez que el heredero regularice su situación, procedimiento sin base legal que puede originar cadenas paralelas de inscripciones.

Se sostiene, en todo caso, que la inscripción del tercero, aunque no le dé la posesión efectiva del dominio, sí podría conferirle la posesión del inmueble y habilitarlo para adquirir por prescripción, como resolvió una sentencia de la Corte Suprema de 1928. **VIAL** discrepa de esta lectura: el tenor literal del **art. 696**, al señalar que los títulos sujetos a inscripción "no darán ni transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho" mientras no se practique, no distingue entre la posesión efectiva del dominio y la posesión a secas, de modo que mientras subsista la omisión, el adquirente no adquiere posesión alguna, ni siquiera irregular.

Otra solución, fundada en los principios generales, sería la nulidad relativa de la enajenación, saneable con la ratificación del heredero al practicar las inscripciones, aunque se objeta que esta nulidad se sana en 4 años, mientras que la falta de inscripciones hereditarias, según el tenor del **art. 688**, jamás se sana. En la práctica, detectada la infracción, no queda otra vía que resciliar el contrato y celebrar uno nuevo tras practicar las inscripciones hereditarias.

7. LA INSCRIPCIÓN EN LA PRESCRIPCIÓN

Los **arts. 689 y 2513** del Código y el **art. 52** del Reglamento exigen que la sentencia que declara la prescripción adquisitiva de inmuebles se inscriba en el Registro del Conservador. Siendo la prescripción un modo de adquirir originario, la inscripción no desempeña aquí el rol de tradición, sino que sirve para mantener la historia de la propiedad raíz, darle publicidad y hacer oponibles a terceros los efectos del fallo, obteniendo las ventajas de la posesión inscrita.

I. LA TRADICIÓN DEL DERECHO REAL DE HERENCIA Y DE LOS DERECHOS PERSONALES

1. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL ES POSIBLE REALIZAR LA TRADICIÓN DE LA HERENCIA

Una vez fallecido el causante, el heredero puede disponer o enajenar su derecho de herencia. Es imposible enajenarlo antes de su muerte, pues en nuestro Derecho están proscritos los pactos sobre sucesión futura, que adolecen de objeto ilícito y, por ende, de nulidad absoluta (**arts. 1463, 1466, 1204 y 1682**). Una vez que el heredero puede enajenar su derecho, se plantea el problema de la forma en que debe efectuarse la tradición.

2. FORMA DE EFECTUAR LA TRADICIÓN DEL DERECHO DE HERENCIA

El Código, dentro del título "De la cesión de derechos", destina un párrafo a la cesión del derecho de herencia (**arts. 1909 y 1910**), empleando el equívoco término "cesión", que debe entenderse equivalente a tradición. Señala allí algunos efectos de esa cesión, pero no la forma de efectuar la tradición. Como las transferencias por acto entre vivos se rigen por la dualidad título y modo, ambos deben configurarse también aquí: el título más frecuente será la compraventa, que para una sucesión hereditaria requiere escritura pública (**art. 1801**). El problema de cómo efectuar la tradición del derecho real de herencia, no resuelto por el Código, es uno de los clásicos en materia de derechos reales, con dos alternativas conocidas.

a. Doctrina de GUTIÉRREZ: la herencia sigue la naturaleza de sus bienes.

Fundada principalmente en el **art. 580**, sostiene que la herencia es mueble o inmueble según los bienes que la integran: si se compone solo de muebles, su tradición se rige por el **art. 684**; si es mixta o compuesta solo de inmuebles, se rige por las reglas de estos, requiriendo inscripción conservatoria (**art. 686**).

b. Doctrina de URRUTIA: la herencia es una universalidad jurídica.

Fundada en que la herencia es distinta de los bienes específicos que la integran, sostiene que escapa a la clasificación de muebles e inmuebles, y que siendo la inscripción una forma excepcional de tradición, reservada a los inmuebles, la tradición del derecho de herencia no requiere inscripción, bastando cualquier manifestación en que conste la intención de transferir el dominio. Es la misma solución dada para la tradición de cuota de otras universalidades jurídicas.

La jurisprudencia se ha inclinado notoriamente por esta última solución, aunque fallos antiguos se pronunciaron por la contraria. En la práctica, esto se traduce muchas veces en que se entiende efectuada la tradición por una cláusula agregada al final del título en que las partes dejan constancia de que en ese acto transfieren la herencia. La falta de inscripción, existiendo inmuebles, puede

ocasionar inconvenientes en el orden del Registro y sorpresas a terceros, por lo que, siendo posible inscribir, parece útil hacerlo.

3. FORMA DE EFECTUAR LA TRADICIÓN DEL DERECHO A UN LEGADO

Conforme al mismo **art. 1909**, puede transferirse no solo el derecho a una herencia, sino también el derecho a un legado. Según una doctrina jurisprudencial al parecer mayoritaria, el legatario de especie o cuerpo cierto adquiere el dominio de la cosa legada por sucesión por causa de muerte, al fallecer el causante, mientras que el legatario de género adquiere un crédito contra la sucesión.

Tratándose de legado de especie o cuerpo cierto, cuando el legatario transfiere su "derecho al legado" está transfiriendo el dominio de la cosa legada, que ya adquirió, por lo que la tradición no presenta novedad: se efectúa según la naturaleza mueble o inmueble de la cosa (**arts. 684 ó 686**). Si es legatario de género, en cambio, sí tiene un crédito que transferir, y para determinar la forma de la tradición hay que remitirse a las reglas de tradición de los derechos personales.

4. EL ART. 688 Y LA TRADICIÓN DE LOS DERECHOS DE HERENCIA Y LEGADO

Se plantea si, existiendo bienes raíces en la herencia, deben practicarse previamente las inscripciones del **art. 688** cuando el heredero pretende enajenar su herencia, o cuando el legatario de un inmueble pretende enajenar su derecho al legado.

4.1. En cuanto a la herencia

Vuelve a plantearse la controversia sobre la naturaleza de la herencia. Para la tesis de la abstracción, que la ve como una universalidad jurídica distinta de los bienes que la integran, el heredero puede enajenar su herencia o cuota sin esas inscripciones, precisamente porque están exigidas para disponer de un inmueble hereditario, y la herencia no es mueble ni inmueble. Para el otro planteamiento, si en la herencia hay inmuebles, es necesaria la posesión efectiva y su inscripción. La jurisprudencia, al igual que en la forma de efectuar la tradición, se inclina por la primera posición: para enajenar la herencia o cuota hereditaria no exige inscripciones previas.

4.2. En cuanto al legado

Como regla general, el legatario puede disponer de su derecho al legado o de la cosa legada prescindiendo de las inscripciones del **art. 688**, pues están exigidas para que el "heredero" disponga de inmuebles hereditarios. Conviene, con todo, distinguir entre legados de género y de especie.

a) Legado de género

El legatario de género puede disponer de su crédito sin esperar inscripción alguna, aunque lo legado sea un inmueble indeterminado y, según el **art. 580**, sea un crédito inmueble, porque las inscripciones del **art. 688** solo se exigen a los herederos. Una vez determinados los herederos y exigible el crédito, el legatario podrá exigirles la entrega de una cosa del género respectivo: si es un inmueble, los herederos, como dueños obligados a transferirlo, deberán obtener la posesión efectiva, inscribirla y practicar la inscripción especial de herencia, porque esa entrega constituye tradición. El título traslativo que sirve de antecedente al legatario será, en este caso, el acuerdo entre herederos y legatario por el que aquellos proponen la entrega de un inmueble determinado y este acepta, acuerdo que, al conducir a una tradición por inscripción, debe constar por escritura pública.

b) Legado de especie

Si la especie legada es un inmueble, debe distinguirse entre la inscripción a nombre del legatario y la disposición que este haga después a favor de un tercero.

Inscripción a nombre del legatario para adquirir el dominio

El legatario de especie no requiere inscripción para adquirir el dominio, sin perjuicio de su conveniencia. La doctrina está dividida sobre cómo proceder a ella.

a. Basta acreditar el fallecimiento y el testamento reconocido.

Para esta posición, el legatario puede requerir la inscripción comprobando el fallecimiento del testador, acreditando el pago del impuesto que grava su asignación y exhibiendo copia del testamento judicialmente reconocido, sin que sea necesaria escritura pública, aunque es más conforme al espíritu del Registro inscribir primero el testamento y después el inmueble legado.

b. Se requiere escritura pública otorgada por herederos o albacea.

Para otros, no basta el testamento, porque suele señalar el inmueble con designaciones insuficientes, porque el legado está sujeto a contingencias (**arts. 1119 y 1362**) y porque otras normas confirman que no es inmediatamente exigible (**arts. 1374, 959, 1290 y 1292**, y el **art. 54** de la Ley de Impuesto a las Herencias). Procedería entonces otorgar escritura pública por los herederos o el albacea que acredite el carácter definitivo del derecho del legatario, sin necesidad de practicar la inscripción especial de herencia, porque el bien legado como especie no pertenece a los herederos. Esta tesis, a la que se inclina la jurisprudencia, basta que se inscriba el auto de posesión efectiva.

Disposición del inmueble legado por el legatario

También hay discrepancias sobre si el legatario necesita inscribir antes de disponer del inmueble legado.

a. La inscripción del legado es requisito previo para disponer.

Se sostiene que el título del legado es el testamento y que la obligación de inscribirlo es un requisito previo para disponer de la especie, implícito en la relación entre los **arts. 688** del Código y **55** del Reglamento (que exigen inscribir la posesión efectiva y el testamento) y los **arts. 691** del Código y **79** del Reglamento (que exigen que la inscripción del testamento individualice a herederos o legatarios y sus cuotas o legados).

b. No es necesaria la inscripción previa.

Se estima que no la exige el **art. 688**, que se refiere solo al heredero, ni ningún otro precepto, y que el **art. 691** solo señala las menciones de la inscripción testamentaria sin exigir que el legatario inscriba para disponer.

En la práctica, cuando el legatario de un inmueble quiere enajenarlo, deberá inscribirlo previamente a su nombre, porque el Conservador puede negarse a inscribir a nombre de quien adquirió del legatario, amparándose en el **art. 14** del Reglamento, al tratarse de un título que no emana de quien aparece en el Registro como dueño o poseedor. Aunque el legatario ya es dueño por sucesión por causa de muerte, registralmente no aparece como tal: la inscripción previa no se justifica en el Derecho sustantivo, pero sí en el aspecto formal de la organización del Registro.

5. TRADICIÓN DE CRÉDITOS PERSONALES

En la sistemática del Código, los derechos personales o créditos son bienes incorpóreos que, como tales, pueden transferirse por actos entre vivos, requiriendo también aquí de título y modo. Para su tradición, el Código reservó el **art. 699**, especial: se efectúa por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario, entendiéndose por título el instrumento en que el crédito consta. Los **arts. 1901** y siguientes señalan los efectos de esa "cesión", término que, como con el derecho de herencia, la jurisprudencia ha precisado que equivale a la tradición y no a un contrato. Para que la transferencia produzca efectos respecto del deudor y de terceros, es necesario notificarle el traspaso o que él lo acepte (**arts. 1902** y siguientes); antes de eso, le es inoponible, y el deudor que paga al primitivo acreedor paga bien.

La jurisprudencia ha resuelto que la entrega del título puede ser real o simbólica, como en las cosas corporales muebles: así, la tradición de un crédito que consta en escritura pública de mutuo puede efectuarse por otra escritura en que el dueño del crédito expresa su voluntad de transferirlo y el cesionario acepta, sin ser necesaria la entrega de una copia de la escritura de mutuo. En cuanto a los créditos que no constan por escrito, aunque en rigor no podría cumplirse la exigencia del **art. 1901**, jurisprudencia y doctrina han estimado posible transferirlos, entendiendo su tradición efectuada por una declaración especial de transferir el dominio del crédito, lo que en la práctica confiere un efecto real al contrato.

6. TRADICIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS

El Código destina también un párrafo especial a la cesión de los derechos litigiosos (**arts. 1911 a 1914**), sin precisar tampoco allí la forma de efectuar la tradición. Declara que se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente (**art. 1911**). El traspaso del derecho litigioso no escapa a la regla de la dualidad título y modo, lo que confirma también el **art. 1912**.

a. Según la naturaleza del derecho cedido (RIOSECO).

El carácter litigioso del derecho no impide calificarlo de real o personal: si es real, se aplican sus reglas (el **art. 684** si es mueble, inscripción si es inmueble); si es personal, se aplican las reglas de tradición de los derechos personales, entendiéndose que la actuación del cesionario en el litigio, en reemplazo del cedente y con su consentimiento, equivale a las formas simbólicas del **art. 684**.

b. Según el objeto único de la cesión: el evento incierto de la litis (SILVA BASCUÑÁN).

Se objeta que la tradición sería difícil de efectuar si el cedente no tiene la cosa mueble en su poder ni el inmueble inscrito a su nombre. Como lo cedido, en términos inmediatos, es siempre "el evento incierto de la litis" (**art. 1911**), la forma de la tradición debe ser también una sola: una actuación realizada en el litigio por el cesionario, con consentimiento expreso o tácito del cedente y conocimiento de las demás partes, por la que sustituye al cedente en su posición dentro de la controversia.

J. LA POSESIÓN: ASPECTOS GENERALES

1. INTRODUCCIÓN

La posesión es una de las materias del Derecho civil patrimonial que más controversias doctrinarias ha suscitado, con implicancias que llegan hasta la esencia misma del concepto y trascienden lo jurídico hacia lo económico, sociológico y político. Entre los temas de discordia pueden mencionarse: (a) la concepción de la posesión como fundamentalmente objetiva o subjetiva; (b) su autonomía o dependencia respecto de la propiedad; (c) su naturaleza jurídica como un hecho o un derecho; y (d) el fundamento de la protección posesoria.

En el desarrollo doctrinal, los aportes de **SAVIGNY** y de **IHERING** han llegado a constituir lo clásico, aunque las contribuciones han sido innumerables, con **POTHIER** antes y, después, **OLIVART**, **SALEILLES** y **PEROZZI**, entre otros. En el Derecho chileno, a esta complejidad doctrinaria se agrega una reglamentación intrincada, tanto en la posesión propiamente tal como en sus relaciones con la prescripción adquisitiva y con el funcionamiento del sistema registral, en el que consta la llamada posesión inscrita de inmuebles. Así, la posesión se ha erigido como uno de los símbolos de complejidad jurídica en la teoría, y como una fuente importante de litigios en la práctica.

DATO DE GRADO

El Mensaje del Código Civil sobre la posesión

Acerca de la posesión, se ha creído conveniente adoptar una nomenclatura menos embarazosa y ambigua que la que al presente existe. Toda posesión es esencialmente caracterizada por la realidad o la apariencia del dominio; no es poseedor de una finca sino el que la tiene como suya, sea que se halle materialmente en su poder, o en poder de otro que le reconoce como dueño de ella. El arrendatario de una finca nada posee, no goza más que de una acción personal para la conservación de los derechos que le ha conferido el contrato. El que a nombre ajeno posee, no es más que un representante del verdadero poseedor, ni inviste más que la simple tenencia.

Así los términos posesión civil, posesión natural, son desconocidos en el proyecto: las palabras posesión y tenencia contrastan siempre en él, la posesión es a nombre propio, la tenencia a nombre ajeno. Pero la posesión puede ser regular o irregular: aquella adquirida sin violencia ni clandestinidad, con justo título y buena fe; la segunda, sin alguno de estos requisitos. Toda posesión es amparada por la ley, pero solo la posesión regular pone al poseedor en el camino de la prescripción adquisitiva.

El Código reglamenta la posesión fundamentalmente en los **arts. 700** y siguientes. Se inspira de manera especial en el "Tratado de la posesión" de **POTHIER**, y en menor medida en las Partidas y aun en normas justinianeas.

2. DEFINICIÓN Y ELEMENTOS

El Código define la posesión en el inciso primero del **art. 700**: *"La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él"*.

De la propia definición se desprende que en el Derecho chileno la posesión está constituida por dos elementos, que deben concurrir copulativamente: la tenencia de la cosa y el ánimo de dueño. Ello, salvo la particular regla del **art. 722** relativa a la posesión de la herencia, la cual se adquiere desde el momento en que esta es deferida, aunque el heredero lo ignore.

(i) La tenencia (corpus).

Es la aprehensión o contacto físico con la cosa, en cuya virtud se dispone materialmente de ella. La naturaleza de ciertos bienes, en especial los inmuebles, ha conducido a estimar esta aprehensión en términos no muy materializados, admitiéndose que puede consistir en la sola posibilidad de disponer de la cosa aunque no haya contacto directo, lo que se relaciona con las formas simbólicas de tradición de cosa corporal mueble (**art. 684**). **IHERING** sostiene que el corpus es la exteriorización del derecho de propiedad, el hecho de conducirse respecto de la cosa como lo haría el propietario.

(ii) El ánimo de dueño (animus).

Es un elemento intelectual, síquico, que consiste en tener la cosa como dueño, sintiéndose propietario de ella. La preeminencia de uno u otro elemento constituye uno de los aspectos centrales de la discusión doctrinaria sobre la concepción objetiva o subjetiva de la posesión. La mayoría de los autores entiende que en Chile se sigue una concepción subjetiva, la de **SAVIGNY**; pero otros, como **PESCIO**, estiman que el sistema chileno es ajeno a esa controversia, en cuanto no habría influido en la estructuración ideada por **BELLO**.

3. NATURALEZA JURÍDICA

Entre las discusiones que suscita la posesión está la de si ella es un hecho o un derecho. **SAVIGNY** sostiene que, considerada en sí misma, la posesión es originariamente un mero hecho, porque se funda en circunstancias materiales (el corpus); pero agrega que es a la vez un derecho, por las consecuencias jurídicas atribuidas a ese hecho, que son la prescripción y las acciones posesorias. **IHERING**, en cambio, afirma que la posesión es un derecho, porque es un interés jurídicamente protegido.

Las disposiciones del Código Civil chileno se orientan a concebir la posesión como un hecho, partiendo de la propia definición: cada vez que el Código define un derecho dice que es una "facultad" o un "derecho" (**art. 582**), mientras que al definir la posesión dice que es la "tenencia", que constituye un hecho. Hoy la doctrina considera infecunda esta disputa y resuelve la cuestión diciendo que la posesión es un estado de hecho protegido por el derecho.

VIAL, siguiendo a **POTHIER**, propone un matiz a esta posición mayoritaria: más que concebir la posesión misma como un derecho, existiría un derecho a la posesión, esto es, a tener la cosa en calidad de poseedor, del que son titulares el dueño, porque la tenencia de la cosa es normalmente la que le permite ejercer sus facultades de usar, gozar y disponer, y la parte de un título traslativo a quien la otra se obligó a dar y entregar la cosa, pues es la entrega la que le permitirá adquirir su posesión material.

4. LA POSESIÓN EN SU RELACIÓN CON EL DOMINIO

El dominio otorga al propietario un conjunto de facultades sobre la cosa, y para hacerlas efectivas necesitará tenerla a su disposición. De este modo, el dominio trae como consecuencia el "derecho a poseer" (jus possidendi), que es el ejercicio mismo del dominio. Pero también es frecuente que una persona detente una cosa con ánimo de señor sin ser su verdadero dueño; aquí la posesión aparece como una figura autónoma, independiente de la propiedad, a la que la ley atribuye un conjunto de ventajas, el llamado jus possessionis.

En el primer caso hay un poseedor con derecho a poseer, y en el segundo, un poseedor sin derecho a poseer, que generalmente estará en vías de ganar el dominio mediante la prescripción, lo que implica admitir la existencia de dueños que no tienen la posesión. Lo normal, sin embargo, es que ambos derechos vayan unidos: el que tiene derecho a poseer, posee. De ahí lo justificado de la presunción de que el poseedor se reputa dueño (**art. 700, inc. 2º**).

5. MERA TENENCIA

Constituye la última de las tres situaciones en que puede encontrarse un sujeto ante la cosa: es dueño, poseedor (no dueño) o mero tenedor. La define el **art. 714** como aquella que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño; el acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario y el que tiene el derecho de habitación son meros tenedores de la cosa. Su inciso segundo agrega que lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. Sus fuentes, características y relación con la posesión se examinan con mayor detalle más adelante, a propósito de la mera tenencia como institución propia.

6. VENTAJAS DE LA POSESIÓN

Aparte del provecho material que el poseedor obtiene de la cosa poseída, en Derecho la posesión confiere varias ventajas:

- a) Habilita para llegar a adquirir el dominio de la cosa por prescripción, luego de cierto tiempo (arts. 683, 2498 y siguientes).
- b) Otorga una presunción legal de dominio (art. 700, inc. 2°).
- c) Está protegida con las acciones posesorias (arts. 916 y siguientes) y, en ciertas situaciones, con la reivindicatoria, llamada aquí "acción publiciana" (art. 894).
- d) En ciertos casos permite hacer suyos los frutos de la cosa poseída (art. 907, inc. 3°).

7. COSAS SUSCEPTIBLES DE POSESIÓN

Del propio art. 700 queda claro que la posesión ha de recaer sobre cosas determinadas, lo que deriva de su propia naturaleza, como ocurre igualmente con el dominio: no es posible concebir la posesión sobre cosas inciertas o indicadas solo por su género (RDJ, t. 16, p. 593). Ello no impide que dos o más personas posean en común una cosa singular, caso en el cual cada comunero tiene la posesión de su cuota (RDJ, t. 52, p. 311).

Particular interés reviste el problema de la posesión respecto del carácter corporal de las cosas, dado que el Código chileno califica de bienes, cosas incorpóreas, a los derechos. La posesión parece haber tenido su origen en relación con las cosas corporales, propiamente aprehensibles, pero ya los romanos aplicaban la posesión a los derechos mediante la llamada cuasiposesión. No es unánime, sin embargo, la aceptación por la doctrina de la posesión sobre bienes incorpóreas, y sobre todo entre estos, de la posesión sobre derechos personales. En el Código chileno, por los arts. 700 y 715 queda claro que se comprende a los bienes corporales como a los incorpóreas, aunque no se precisó en qué consiste esa posesión sobre las cosas incorpóreas; la doctrina entiende que consiste en el goce o disfrute del derecho respectivo.

8. COSAS NO SUSCEPTIBLES DE POSESIÓN

a) Cosas corporales no susceptibles de posesión.

Son aquellas que no pueden apropiarse, como las cosas comunes a todos los hombres y los bienes nacionales de uso público. Con todo, respecto de estos últimos los arts. 948 y 949 otorgan a la municipalidad y a cualquier persona del pueblo una suerte de protección posesoria, mediante una acción popular destinada a resguardar la seguridad en el tránsito por caminos, plazas y otros lugares de uso público.

b) Cosas incorpóreas.

Los términos amplios del **art. 715**, que alude expresamente a la posesión de las cosas incorpóreas, inducen a concluir que pueden poseerse tanto los derechos reales como los personales, pues ambos son cosas incorpóreas en la nomenclatura del Código (**arts. 565 y 576**). En cuanto a los derechos reales, se discute si puede haber posesión sobre todos ellos: el **art. 882** impide ganar por prescripción las servidumbres discontinuas y las continuas inaparentes, lo que sugiere que no pueden poseerse, y el **art. 917** excluye de la protección posesoria a las mismas que excluye el art. 882, en tanto el **art. 922** parece limitar esa protección al usufructuario, al usuario y al habitador.

NO CONFUNDIR

Poseedor del derecho real vs. mero tenedor de la cosa

Como puntualiza el Mensaje, no debe confundirse la dualidad de situaciones que pueden producirse respecto de los derechos reales: se es poseedor del derecho real, pero mero tenedor de la cosa sobre la que se ejerce. Así, se posee el derecho de usufructo, pero se es mero tenedor de la cosa fructuaria.

9. ¿PUEDEN POSEERSE LOS DERECHOS PERSONALES?

En doctrina se ha debatido arduamente si los derechos personales o créditos pueden ser poseídos, tema trascendente por las ventajas que otorga la posesión, principalmente la posibilidad de adquirir el dominio por prescripción.

Se ha sostenido, en la doctrina nacional (**PESCIO**) y extranjera (**DE RUGGIERO**), que no es posible extender la posesión a los derechos personales, básicamente porque: (i) más allá de los amplios términos del art. 715, los derechos personales no permiten un ejercicio continuado, pues se agotan al ejercerlos, esto es, al cobrar el crédito; (ii) el Mensaje, en el pasaje ya citado, alude única y exclusivamente a la posesión de los derechos reales; y (iii) si bien el **art. 1576** alude a la "posesión del crédito", con ello se refiere no propiamente al "poseedor" sino a un "titular" aparente del crédito, cuestión distinta.

Otros autores (**BARROS ERRÁZURIZ** y **ROSENDE**) han afirmado que sí es posible poseer un derecho personal: (i) existen sólidos argumentos de texto, en especial el art. 715, que se refiere expresa y omnicomprensivamente a la posesión de las cosas incorpóreas, lo que ratifican el **art. 1576**, que alude a "la persona que estaba entonces en posesión del crédito", y el **art. 2456**, que se refiere al "poseedor aparente de un derecho"; (ii) en cuanto al argumento de que los derechos personales no admiten ejercicio continuado, se observa que en los créditos de dinero pueden ejercerse actos de poseedor sin agotarse, como el cobro de intereses, y que la extinción por el ejercicio del crédito tampoco es razón suficiente, pues también acontece con las cosas corporales consumibles, cuya posesión nadie discute.

(iii) Si bien el Mensaje solo alude a la posesión de los derechos reales, lo hace a modo meramente ilustrativo, sin dar a entender que se excluye la posesión de los derechos personales, tratándose de una materia no mencionada en el Mensaje pero sí regulada en el Código; y (iv) los **arts. 699 y 1901** y siguientes regulan la tradición de los derechos personales, y siendo el efecto principal de la tradición dejar al adquirente como poseedor, tal regulación reconoce la posesión sobre créditos.

K. CLASES DE POSESIÓN

1. GENERALIDADES

Siguiendo la nomenclatura más difundida, se distinguen la posesión regular y la irregular, y la posesión viciosa y la no viciosa, que algunos denominan también inútil y útil. Muy en síntesis, la posesión regular es la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, siendo también necesaria la tradición si el título es traslativo de dominio (**art. 702**); posesión irregular es la que carece de uno o más de esos requisitos (**art. 708**). Ambas conducen al dominio, aunque en distintos tiempos, cuando el poseedor carece de él, mediante la prescripción.

Por su parte, posesión viciosa es la que adolece de un vicio de violencia o clandestinidad, y posesión no viciosa la exenta de tales defectos. El Código conoce esta clasificación, aunque no define cada categoría: simplemente prescribe que son posesiones viciosas la violenta y la clandestina (**art. 709**), y define cada una (**arts. 710 y 713**). Con frecuencia se ha llamado posesión útil a la no viciosa y posesión inútil a la viciosa, para significar que la primera presta la utilidad de conducir a la prescripción y la segunda no.

2. POSESIÓN REGULAR

2.1. Concepto

La posesión regular se encuentra definida en el **art. 702**: *"Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe; aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser por consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Si el título es traslativo de dominio, es también necesaria la tradición"*.

Esta posesión constituye, según la expresión de un autor, la síntesis del elemento técnico, el título, con el elemento ético, la buena fe. De su texto queda claro que sus elementos son: (i) el justo título, (ii) la buena fe, y (iii) la tradición, cuando el título es traslativo de dominio.

2.2. Primer elemento: el justo título

El Código no define lo que es título justo, ni siquiera lo que es título. En materia posesoria, **VERDUGO** afirma que puede entenderse por título el hecho o acto en el que se funda la posesión, el antecedente justificante de ella; es la respuesta que ha de dar el poseedor cuando se le pregunta por qué afirma ser dueño. Atendidos los textos del Código, puede entenderse por título justo el que por su naturaleza es apto para atribuir el dominio, siendo auténtico, real y válido; es justo cuando es auténtico, real y válido, lo que se explica porque el Código considera injustos, en el **art. 704**, a los falsificados, los nulos y otros semejantes.

Títulos constitutivos de dominio

El Código llama así a los modos originarios de adquirir el dominio, y los enumera: ocupación, accesión y prescripción (**art. 703**). Normalmente, cuando operan, permiten adquirir el dominio y, por lo mismo, la posesión, pero puede ocurrir que no otorguen el dominio, en cuyo caso solo actuarán como título constitutivo de posesión, como cuando se ocupa un bien que tiene dueño. Respecto a la ocupación como título posesorio hay confirmación en el **art. 726**; esta decisión legal provoca reflexiones, porque admitir a la ocupación como título equivale, en el fondo, a admitir prescindir de título, lo que está reconocido en los **arts. 726 y 729**.

Buena parte de los autores, entre ellos **CLARO SOLAR**, objetan que se incluya a la prescripción dentro de los títulos constitutivos, puesto que ella misma supone posesión, de modo que lo que es efecto no puede constituir causa; aunque otros, como **PESCIO**, han intentado justificar su inclusión en cuanto legitima la situación futura del poseedor irregular que ganó el dominio por prescripción. En lo que respecta a la accesión, la posesión de lo principal se extiende a las accesiones de ella, con particularidades en el **art. 652** y en la accesión de mueble a mueble.

Títulos traslaticios de dominio

Son "los que por su naturaleza sirven para transferirlo" (**art. 703, inc. 3º**), como la venta, la permuta, la donación entre vivos y el aporte en propiedad a una sociedad; el inciso sexto precisa que la transacción es también de esta clase cuando se refiere a un objeto no discutido. Estos títulos, al mismo tiempo que inician el proceso de transferencia del dominio, son títulos para poseer.

El título es traslativo de dominio cuando sirve para transferirlo atendida su naturaleza, examinada en abstracto, aun cuando en el caso concreto de hecho no lo transfiera porque quien aparece transfiriéndolo carece de él. Así, la compraventa es título traslativo aun cuando el vendedor no sea el dueño: el comprador que recibe en tradición quedará como poseedor. Recuérdese que la venta de cosa ajena es válida (**art. 1815**), de modo que esa venta no queda incluida en el **art. 704 N° 3**, como pudiera pensarse, y será título justo si no presenta ninguno de los defectos del art. 704.

Títulos declarativos de dominio

Es una tercera clase de títulos que la doctrina reconoce y distingue de los anteriores. El Código no le dedica una reglamentación especial, pero el **art. 703** y otros preceptos demuestran que están contemplados. Son los que se limitan a reconocer, declarar o aclarar, una situación de dominio preexistente; no forman nuevo título para justificar posesión, de modo que para averiguar cuán legítima es la situación del poseedor es necesario retroceder hasta el hecho o acto con el cual entró a poseer. Como solo declaran lo existente, esta característica puede favorecer al titular, pues nada interrumpe o inicia y tendrá la posesión en todo el tiempo intermedio con la calidad originaria, o perjudicarlo, si el derecho pertenecía a un tercero, caso en que nada obtiene con este título.

(i) Las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición.

El Código chileno, apartándose de la doctrina romana que consideraba a la adjudicación un título traslativo, le atribuyó un efecto declarativo respecto del dominio (**arts. 1344 y 718**): el adjudicatario es considerado dueño de lo que recibe desde el día en que se originó la comunidad, no desde el día de la adjudicación. Respecto de la posesión, en cambio, el problema subsiste, porque el **art. 703, inc. 4°** los incluye entre los traslativos. **STITCHKIN** ha sostenido que respecto de la posesión se les considera título traslativo por el tenor del 703, entendiendo que el 718 se refiere, igual que el 1344, solo al efecto declarativo respecto del dominio.

EJEMPLO

Adjudicación: traslativa o declarativa

La disyuntiva tiene consecuencias prácticas. En 1980, A, B y C compran un mueble en común y lo reciben en tradición; en 1983 parten la comunidad y A se adjudica el bien; en 1984 el verdadero dueño lo reivindica. El resultado depende de si la adjudicación es traslativa, caso en que A solo posee desde 1983, con un año de posesión, o declarativa, caso en que A posee exclusivamente desde 1980 y ya habría ganado la cosa por prescripción ordinaria de dos años, cumplida en 1982.

(ii) Las sentencias judiciales sobre derechos litigiosos.

Son sentencias que resuelven un conflicto entre partes que disputan sobre la existencia de un derecho. Son, sin duda, títulos declarativos: lo expresa el **art. 703, inc. 5°**, al señalar que no forman nuevo título para legitimar posesión, pues se limitan a establecer que una situación discutida existe en ciertos términos desde antes, desde que se originó.

EJEMPLO

Sentencia sobre derechos litigiosos: efecto relativo

En 1990, A vende un predio a B y también a C; en 1993, B y C litigan y la sentencia favorece a C; en 1999, X entabla acción reivindicatoria contra C sosteniendo que A vendió cosa ajena. X responderá, primero, que ese fallo no le empece por el efecto relativo de las sentencias (**art. 3**) y, segundo, que las sentencias sobre derechos litigiosos no forman nuevo título. C debe entonces retroceder hasta su compra a A: si reúne los requisitos de la posesión regular, habrá ganado por prescripción ordinaria de 5 años contados desde 1990, rechazándose la reivindicatoria; si su posesión fue irregular, solo puede pretender la prescripción extraordinaria de 10 años, que en 1999 aún no se cumplen.

(iii) La transacción.

Está definida en el **art. 2446** como el contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven uno eventual. Para calificarla como título posesorio debe distinguirse, como lo hace el **art. 703, inc. final**, entre el acuerdo que decide la suerte de lo disputado, que es título declarativo, y el que crea efectos sobre cosas no disputadas, que es título traslativo. Así, si A y B disputan un predio y transigen quedando este para A porque a cambio A dio a B un camión, respecto del predio la transacción es declarativa, de modo que si aparece un tercero que demuestra ser el verdadero dueño, A nada logra aduciendo la transacción; en cambio, respecto del camión, que no estaba en disputa, la transacción es título traslativo y justifica la posesión de B.

La sucesión por causa de muerte como título

La clasificación del **art. 703** se refiere al justo título que procede de actos entre vivos, pero el legislador ha considerado la sucesión por causa de muerte como justo título de posesión regular, según se desprende de los **arts. 688, 704 y 722**. No es un título traslativo, porque los muertos no transfieren sus bienes, los transmiten; cabe dentro de lo que la doctrina llama títulos derivativos. En todo caso, es justo título, que traspa al heredero la propiedad de las cosas de que el difunto era realmente propietario y que, cuando no lo era, habilita al heredero para la posesión regular de los bienes hereditarios de que el difunto era poseedor con justo título.

La herencia está establecida tanto como derecho real (**art. 577**) como modo de adquirir el dominio de los bienes específicos que pertenecían al causante (**art. 588**).

NO CONFUNDIR

Posesión legal, efectiva y real de la herencia

Se distinguen tres clases de posesión de la herencia: (i) posesión legal, que se tiene por el solo hecho de ser heredero, aunque se ignore la calidad de tal (**arts. 688 y 722**); (ii) posesión efectiva, declaración judicial o resolución administrativa que tiene por herederos a determinadas personas; y (iii) posesión real, la de quien detenta efectivamente la herencia en calidad de heredero, pudiendo o no serlo. El legislador, erróneamente, asimiló la posesión legal a la efectiva, conforme a la modificación del inciso 1º del art. 688 por la Ley 19.903, porque la posesión efectiva debe otorgarse por resolución mientras que la legal se entiende conferida por el solo ministerio de la ley.

Tratándose de la herencia como universalidad, el verdadero heredero puede tener las tres clases de posesión, situación normal; pero si un falso heredero entra a poseerla en posesión real, el verdadero heredero puede intentar la acción de petición de herencia (**arts. 1264 y siguientes**), y si no lo hace, el falso heredero puede ganarla por prescripción en 10 años, o en 5 si obtuvo la posesión efectiva, caso en que el Código lo llama heredero "putativo" y se presumirá que está de buena fe (**art. 704 N° 4**). Tratándose de los bienes específicos, si el pretendido heredero lo es verdaderamente y el causante era dueño o poseedor, entrará también él en posesión, pudiendo agregar la de

su antecesor; si no es heredero, la posesión carecerá de título en estricto rigor, aplicándose igualmente el art. 704 N° 4.

Títulos injustos

El Código no ha definido el título justo ni el injusto; se ha limitado a enumerar taxativamente los títulos que no son justos (**art. 704**). La jurisprudencia ha resuelto que calificar un título de justo o injusto es una cuestión de derecho, no de hecho (RDJ, t. 51, p. 325).

a) El falsificado, esto es, no otorgado realmente por la persona que se pretende (**art. 17** del Código Civil y arts. 193 y siguientes del Código Penal). No se comprende aquí la falta de veracidad: si el título fue realmente otorgado por quienes aparecen, aunque sus declaraciones no sean verdaderas, es siempre justo (RDJ, t. 24, p. 188). La adulteración puede referirse a las personas que intervienen, al funcionario autorizante o a la substancia del acto: aunque la norma limita literalmente la falsificación a los sujetos, parece más armónico con el art. 17 entenderla con esa amplitud.

b) El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo. El título es injusto sea que quien pasa por representante sepa que no lo es o crea serlo; en cambio, si alguien vende una cosa ajena pero como propia, actuando por sí, el título es justo, pues la venta de cosa ajena es válida (**art. 1815**).

c) El que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación que debiendo ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial no lo ha sido. Es injusto tanto si la nulidad es absoluta como relativa, aunque si es relativa puede tener aplicación la confirmación (**art. 705**). Se discute si es necesaria la declaración judicial de nulidad para tener el título por injusto, atendido el principio del **art. 1687** de que la nulidad solo produce efectos una vez declarada.

d) El meramente putativo, como el del heredero aparente que no es en realidad heredero, o el del legatario cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior. Sin embargo, al heredero putativo a quien por decreto judicial o resolución administrativa se le haya dado la posesión efectiva, servirá de justo título el decreto o resolución; como al legatario putativo, el acto testamentario legalmente ejecutado.

2.3. Segundo elemento: la buena fe

Puede entenderse por buena fe la convicción íntima de actuar lícitamente, noción aceptada por el Derecho en una acepción subjetiva, que se examina "en concreto" en cada caso particular; paralelamente se ha desarrollado una noción objetiva, examinada "en abstracto", que ha cobrado desarrollo principalmente en materia contractual. Con fundamento subjetivo, el Código establece lo que en materia posesoria significa la buena fe (**art. 706**), estimando compatible con ella un error de hecho que sea justo o excusable, en tanto que obsta a la buena fe un error de Derecho, como si el título emana de un menor y se pretende ignorar su incapacidad (**arts. 8 y 1459**).

En cuanto a la época en que la buena o mala fe tiene influencia, el Código consagró la regla del **art. 702, inc. 2º**, apartándose de la tradición canónica que exigía buena fe durante todo el curso de la posesión: entre nosotros, la pérdida posterior de la buena fe mantiene al poseedor como regular, aunque trae consecuencias en materia de prestaciones mutuas (**arts. 906, inc. 2º; 907, inc. 2º; y 913**). En cuanto a su prueba, se ha establecido una presunción simplemente legal de buena fe (**art. 707**), de aplicación general, aunque hay también presunciones contrarias (**arts. 94 N° 6; 706, inc. final; y 2510 N° 3**).

2.4. Tercer elemento: la tradición

Si se invoca un título constitutivo no se exige tradición, porque tales títulos colocan de inmediato al sujeto en posesión de la cosa. Si se invoca título traslativo de dominio, la exigencia se explica porque el solo título concede un derecho personal para exigir la entrega, y entregada la cosa se empieza a poseer (**art. 702, inc. 2º**). Existiendo distintas maneras de efectuar la tradición de los muebles, a menudo de difícil prueba, se ha establecido una presunción de tradición (**art. 702, inc. 4º**), inaplicable a los casos en que la tradición se efectúa por inscripción y a la tradición del derecho de servidumbre, que por ser también solemne solo puede probarse por escritura pública (**art. 698**).

2.5. Ventajas de la posesión regular

Es conveniente para el poseedor la situación de ser poseedor regular: arribará al dominio mediante la prescripción ordinaria, de plazo más breve (**arts. 2507 y 2508**), y dispone de la acción reivindicatoria, denominada aquí "acción publiciana" (**art. 894**).

3. POSESIÓN IRREGULAR

3.1. Concepto

Es la que carece de uno o más de los requisitos de la posesión regular (**art. 708**). El texto del precepto parece excesivamente generoso, y no puede extremarse su tenor: podrá faltar uno o más requisitos, pero han de concurrir los elementos indispensables que signifiquen tenencia y ánimo de señor, pues de no ser así simplemente no hay posesión.

3.2. Paralelo entre la posesión regular e irregular

a) Ambas habilitan para adquirir el dominio por prescripción, pero al poseedor regular le basta la prescripción ordinaria (**art. 2508**), mientras que el irregular necesita la extraordinaria (**art. 2511**).

b) El poseedor regular puede entablar la acción publiciana, que no procede contra el verdadero dueño ni contra quien posea con igual o mejor derecho (**art. 894**); el irregular no puede valerse de ella.

c) La presunción de que el poseedor es reputado dueño (art. 700, inc. final) favorece a ambos.

d) Ambos pueden entablar los interdictos posesorios.

e) Solo el poseedor regular vencido, de buena fe hasta la notificación de la demanda, se hace dueño de los frutos percibidos antes de la contestación; el irregular de mala fe debe restituirlos (art. 907).

4. POSESIONES VICIOSAS

4.1. Clases

El art. 709 señala que son posesiones viciosas la violenta y la clandestina. Los arts. 710 a 712 se refieren a la violenta: es la que se adquiere por la fuerza, actual o inminente (art. 710), siendo actual cuando alguien se apodera de la cosa arrebatándola mediante medios compulsivos, e inminente cuando se apodera de ella amenazando con un mal susceptible de producir temor. También es poseedor violento el que, en ausencia del dueño, se apodera de la cosa y repele a este cuando vuelve (art. 711). Es indiferente que la fuerza se ejerza contra el verdadero dueño, el poseedor no dueño o el mero tenedor, y que se ejerza personalmente o por agentes, con o sin ratificación (art. 712).

La posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella (art. 713), y es clandestina aunque sea pública respecto de la generalidad si se oculta al interesado.

NO CONFUNDIR

Violenta (permanente) vs. clandestina (relativa y temporal)

La ley atiende a momentos distintos para calificar uno y otro vicio: el de la adquisición de la posesión en la violenta, y el del ejercicio de actos posesorios en la clandestina. Por ello, el vicio de violencia es permanente, en cuanto contamina la posesión para siempre, mientras que la clandestinidad es un vicio relativo, pues se puede ser poseedor clandestino respecto de un interesado y no de otro, y temporal, pues cesa cuando se deja de ocultar la posesión a quienes tienen derecho a oponerse.

4.2. Utilidad de la posesión viciosa

Procede analizar si las posesiones viciosas son siempre irregulares y si habilitan para adquirir el dominio por prescripción. En cuanto a lo primero, el poseedor violento siempre será irregular, pues adquirió de mala fe y carece de justo título, en atención a que el único antecedente de su posesión es la violencia; en cambio, el poseedor clandestino no necesariamente es irregular, pues pudo ha-

ber adquirido de buena fe y con justo título, y solo con posterioridad ejercer la posesión ocultándola.

En cuanto a si habilitan para prescribir, la doctrina está dividida. La mayoría de los autores estima que todo poseedor, aun vicioso, puede adquirir por prescripción, pues no existe disposición que señale lo contrario. **RODRÍGUEZ GREZ**, en cambio, afirma que la prescripción exige, además de posesión y transcurso del tiempo, "los demás requisitos legales", entre ellos la falta de vicios, por lo que las posesiones viciosas serían inútiles para adquirir el dominio.

VIAL arriba a una conclusión similar por otros motivos: para prescribir se requiere el ejercicio de actos posesorios que exterioricen el ánimo de dueño de manera perceptible, de modo que el dueño pueda advertir la situación y reaccionar. Así, la posesión clandestina es inútil para prescribir porque el ocultamiento impide esa reacción, y la posesión violenta también lo es, pero por otro motivo: quien la ejerce carece de título posesorio y, por ende, no es realmente poseedor, sino que de facto tiene la tenencia de la cosa sin justificación lícita.

L. LA MERA TENENCIA; TRANSMISIBILIDAD, AGREGACIÓN E INTERVERSIÓN DE LA POSESIÓN

1. LA MERA TENENCIA

1.1. Concepto

Son tres las situaciones en que es posible encontrarse frente a una cosa: dueño, poseedor o mero tenedor. El **art. 714** define a este último como quien detenta la cosa, teniendo el corpus, pero reconociendo dominio ajeno, lo que la separa nítidamente de la posesión: el mero tenedor solo tiene el corpus, mas no el animus. Posesión y mera tenencia son conceptos excluyentes, y la mera tenencia nunca conduce a la prescripción, porque para prescribir es necesario poseer y el que tiene la mera tenencia no posee. El art. 714 proporciona ejemplos: el acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario y el que tiene el derecho de habitación.

1.2. Fuentes de la mera tenencia

El mero tenedor puede encontrarse en dos situaciones diversas: puede tener la mera tenencia en virtud de un derecho real sobre la cosa, como el usufructuario, el que tiene uso o habitación, o el acreedor prendario, casos en los cuales se es mero tenedor de la cosa pero poseedor del respectivo derecho real; o puede tenerla en virtud de un título del cual emana un derecho personal que lo vincula con el dueño, como el comodatario, el depositario o el arrendatario, casos en los que sobre la cosa no existe ningún derecho de carácter real.

1.3. Características

Es absoluta. Se es mero tenedor tanto respecto del dueño de la cosa como ante terceros. Por ello, si el mero tenedor pierde la tenencia, por regla general no podrá entablar acciones posesorias, salvo que sea despojado violentamente, caso en el que podrá interponer la querella de restablecimiento dentro de 6 meses (**art. 928**).

Es inmutable o indeleble. La mera tenencia no puede transformarse en posesión, puesto que nadie puede mejorar su propio título (**arts. 716 y 719, inc. 2º**; la expresión "poseer a nombre ajeno" que usa esta última norma es incorrecta, porque siempre se posee a nombre propio). Esta característica tiene dos excepciones aparentes: la del **art. 716**, que se remite a la regla 3ª del **art. 2510**, y la del **art. 730**, que se examinan más adelante, al tratar la interversión y la prescripción extraordinaria.

2. ¿ES LA POSESIÓN TRANSMISIBLE Y/O TRANSFERIBLE?

2.1. En cuanto a la transmisión

Hay acuerdo mayoritario en la doctrina nacional en que la posesión no se transmite, primeramente porque se trata de un hecho que, en cuanto tal, no es susceptible de transmisión, pues solo se transmiten los derechos. Esta conclusión encuentra consagración positiva en el **art. 717**, conforme al cual, sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya, caso en el cual se la apropia con sus calidades y vicios. Reafirman lo anterior los **arts. 688, inc. 1º, y 722**, relativos a la posesión legal de la herencia, en cuanto dan cuenta de que el heredero obtiene la posesión no del causante sino por gracia de la ley.

Sin embargo, el tenor de dos disposiciones pareciera pugnar, al menos en apariencia, con esta intransmisibilidad. La primera es el **art. 919**, conforme al cual el heredero tiene y está sujeto a las mismas acciones posesorias que tendría y a que está sujeto su autor, si viviese; al respecto existen tres posiciones: unos ven una clara contradicción con el art. 717, que se explicaría por ser un resabio del Proyecto de 1853, dando primacía al 717; otros salvan la contradicción limitando el 919 al caso en que el heredero opta por agregar la posesión de su causante; y otros no ven contradicción alguna, pues el 919 no se referiría a la transmisión de la posesión como hecho, sino a la de los derechos que de ella emanan, como las acciones protectoras.

La otra norma es el **art. 2500, inc. 2º**, según el cual la posesión principiada por una persona difunta continúa en la herencia yacente, que se entiende poseer a nombre del heredero. Esta redacción ha sido criticada por dar a entender que la herencia yacente sería una persona jurídica, lo que rechaza la doctrina, entre otras razones porque el **art. 481** la define como los bienes de un difunto cuya herencia no ha sido aceptada. Se suele afirmar que, más allá del tenor literal, el sentido de la norma es claro: la herencia no queda sin posesión al morir el causante, pues terminada la de este empieza inmediatamente la del heredero, por disponerlo los arts. 717 y 722.

2.2. En cuanto a la transferencia

Siendo la posesión un hecho y no un derecho, tampoco puede ser transferida. Un argumento de texto se encuentra, además de en el art. 717, en el **art. 2500, inc. 1º**, que dispone que si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, el tiempo de su antecesor puede o no agregarse al tiempo de su sucesor, según lo dispuesto en el art. 717. La negación de la transferencia contribuye al mejoramiento de los títulos de dominio, en cuanto evita que un sucesor vea enturbiada su posesión con los vicios de la de su antecesor; los beneficios de sumar a la suya la posesión exenta de vicios de este último se logran, en cambio, con la facultativa agregación de posesiones.

3. AGREGACIÓN DE LA POSESIÓN

3.1. Concepto

El **art. 717** permite al poseedor agregar a la suya la posesión de su antecesor o antecesores, posibilidad que la doctrina conoce con distintas denominaciones (unión, accesión, adjunción o conjunción de posesiones), y a la que también se refieren los **arts. 920 y 2500**. La agregación contribuye eficazmente a una mayor aplicación de la prescripción para los poseedores que carecen del dominio, y al ejercicio de las acciones posesorias, que exigen un plazo mínimo de posesión (**art. 920, inc. 4º**). Como está establecida tanto para el sucesor a título singular como para el sucesor a título universal, el tema se vincula también con la transferencia y la transmisión mortis causa de la posesión.

3.2. Posesiones contiguas

Para que proceda la agregación es necesario que la posesión del que agrega sea contigua con la anterior, y si son varias, todas ellas deben serlo, sin solución de continuidad. Si una cosa ha sido poseída sucesivamente por A, B, C y D, este no podrá agregar a la suya la posesión de C y de A excluyendo la de B. Tampoco procede si en la cadena hubo una interrupción, natural o civil. La interrupción natural puede ocurrir por imposibilidad de ejecutar actos posesorios (**art. 2502 N° 1**) o por haber pasado la posesión a otras manos (**art. 2502 N° 2**), caso este último en que podrá haber agregación si la posesión se recuperó por los medios legales (**arts. 2502, inc. final, y 731**). Tratándose de la interrupción civil, solo puede oponerse a la agregación quien procedió a interrumpirla (**art. 2503**).

La agregación se efectúa con las calidades y vicios: si a una posesión de buena calidad se agrega una defectuosa, esta inficiona a aquella, y a la inversa, agregar una posesión exenta de defectos no purifica la del poseedor que la agrega. Se ha sostenido, sin embargo, que si alguien tiene una posesión defectuosa y observa que la de su antecesor era regular y había completado el plazo de prescripción ordinaria, podría disociar su posesión de la del antecesor y alegar prescripción ordinaria basado únicamente en esta última.

4. LA INTERVERSIÓN DE LA POSESIÓN

4.1. Concepto

Es la transformación de la posesión en mera tenencia, o de esta en aquella. Por las importantes consecuencias jurídicas que implica, es sorprendente la insuficiencia de los textos que le dedica el Código: para la transformación de la posesión en mera tenencia, los **arts. 684 N° 5 y 2494**, y para la de la mera tenencia en posesión, los **arts. 716; 2510, regla 3ª; 730; y 719, inc. 2º**. La interversión encuentra su fundamento en los cambios que se ocasionan en la causa o título por el cual el

sujeto posee o detenta la cosa, por lo que bien podría hablarse, en lugar de transformaciones, simplemente de cambios en el título o causa.

4.2. Mutación de la mera tenencia en posesión

De los preceptos aplicables resulta que el puro lapso de tiempo es insuficiente para transformar la mera tenencia en posesión. Se han señalado como excepciones a esta regla los arts. 730 y 2510 regla 3ª, pero no lo son en sentido estricto: en ambos casos se observa que es necesaria la ocurrencia de otros antecedentes que se suman al transcurso del tiempo. En el primer caso, es el que recibe del tenedor usurpador quien adquiere posesión, siendo necesario el acto de enajenación; en el segundo, las exigencias de la regla tercera demuestran un cambio evidente en la conducta tanto del que era mero tenedor como del propietario.

Puede observarse cierta contradicción entre el **art. 730, inc. 1º**, que impide al mero tenedor transformarse en poseedor en términos absolutos, y el art. 2510, que se lo permite probando las circunstancias de la regla 3ª; **PESCIO** hace prevalecer el art. 730, lo que resulta discutible atendida la conveniencia de consolidar situaciones inciertas. Finalmente, si el tenedor adquiere el dominio de la cosa de parte de quien se la había entregado en mera tenencia, la llamada traditio brevi manu, o de un tercero que era el dueño, más que de interversión se estaría en presencia de una adquisición de posesión por tradición.

4.3. Transformación del poseedor en mero tenedor

Esta posibilidad se contempla señaladamente en el denominado constituto posesorio (**art. 684 N° 5**). La doctrina menciona también el caso en que el poseedor efectúe, expresa o tácitamente, un reconocimiento del verdadero propietario, como cuando toma de él la cosa en arrendamiento; en tal caso se transforma en mero tenedor, y los efectos serán los de una interrupción de la prescripción.

M. ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN DE BIENES MUEBLES

1. OBSERVACIONES GENERALES

1.1. Capacidad para adquirir la posesión

Requiriéndose tan solo la aprehensión de una cosa unida a la voluntad de hacerla suya, las reglas de capacidad en esta materia son menos exigentes que las generales. Del **art. 723** se infiere que la posesión de los muebles puede adquirirla toda persona, con la sola excepción de los dementes y los infantes, que carecen por completo de toda voluntad; pero es notable la limitación que se agrega: los incapaces, si bien pueden adquirir la posesión de los muebles, no pueden ejercer actos de poseedores, como prestar la cosa o darla en arriendo, sino con la correspondiente autorización. La posesión de los inmuebles no está sometida a norma particular, por lo que se regula por las reglas generales de capacidad, reforzadas por el **art. 724**, conforme al cual "nadie" podrá adquirir la posesión de inmuebles sino por medio de la inscripción.

1.2. Adquisición de la posesión por intermedio de otro

Sin darse por satisfecho con el precepto general del **art. 1446**, en materia posesoria el Código consagra normas especiales que permiten la adquisición de la posesión a través de otro (**arts. 720 y 721**), pudiendo tal intermediario ser un representante legal, un mandatario o aun un agente oficioso. Hay ciertos casos en que la posesión solo se puede adquirir a través de otro: así ocurre a los infantes y dementes (**art. 723, inc. 2º**), y a las personas jurídicas, que han de adquirirla a través de quienes las representan. El Código hace una particular referencia a la intervención de un intermediario también a propósito de la incapacidad de infantes y dementes (**art. 723**) y de la violencia en la adquisición de la posesión (**art. 712, inc. 2º**).

Si se adquiere por representante legal o mandatario, el **art. 721, inc. 1º** dispone que si una persona toma la posesión de una cosa en lugar y a nombre de otra de quien es mandatario o representante legal, la posesión del mandante o representado principia en el mismo acto, aun sin su conocimiento. Si ese intermediario actúa fuera de la esfera de sus atribuciones, queda ubicado en el ámbito del agente oficioso: el **art. 721, inc. 2º** dispone que si el que toma la posesión a nombre de otra persona no es su mandatario ni representante, no poseerá esta sino en virtud de su conocimiento y aceptación, pero se retrotraerá su posesión al momento en que fue tomada a su nombre.

2. PRINCIPIO BÁSICO DE LA ADQUISICIÓN DE LA POSESIÓN

Es necesario recordar una regla fundamental: la posesión se adquiere cuando se reúnen sus dos elementos constitutivos, el corpus y el animus, esto es, cuando concurren la aprehensión o tenencia de

la cosa con el ánimo de apropiársela. Debe tenerse presente que si bien el Código señaló reglas para la adquisición de la posesión de las cosas corporales, guardó silencio respecto de las incorpóreas que pueden poseerse, y que por ser tales no pueden aprehenderse; no se dan reglas para la adquisición de la posesión de los derechos reales distintos del dominio, salvo respecto de algunos, como el usufructo, el uso y la habitación cuando recaen sobre inmuebles, el censo y la hipoteca (**arts. 724 y 686**). Debido a las importantes diferencias entre bienes muebles e inmuebles en esta materia, se analiza a continuación en base a dicha clasificación.

3. ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN DE BIENES MUEBLES

3.1. Adquisición

Se adquiere la posesión de estas cosas concurriendo el corpus y el animus. El animus existirá en la medida que exista un título posesorio (**art. 703**) que explique que quien tiene una cosa en su poder tiene la convicción de ser su dueño. El corpus se configurará ya por la aprehensión material, ya por un acto que signifique que de hecho el sujeto queda con la cosa a su disposición, sometida a su potestad; estos últimos actos se han aludido al tratar las formas de tradición de las cosas corporales muebles. De ahí que el art. 723 alude, respecto de los bienes muebles, a la "aprehensión material o legal", lo que debe entenderse como una clara referencia al **art. 684**.

3.2. Conservación

Siendo corpus y animus los elementos constitutivos de la posesión, esta se conserva mientras se mantengan ambos. Pero de los preceptos aplicables se observa que es el animus el elemento fundamental para conservarla, en cuanto puede temporalmente perderse el corpus sin perderse la posesión. El **art. 725** dispone que el poseedor conserva la posesión aunque transfiera la tenencia de la cosa dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usufructo o a cualquier otro título no traslativo de dominio; coherente con ello, el **art. 714** señala que el mero tenedor tiene la cosa "en lugar o a nombre del dueño". Por su lado, el **art. 727** agrega que la posesión de la cosa mueble no se entiende perdida mientras se halla bajo el poder del poseedor, aunque este ignore accidentalmente su paradero.

Coherente con lo anterior, la doctrina sostiene que no es necesaria la vigencia permanente del ánimo para conservar la posesión: por caer el poseedor en demencia o durante su sueño, no se pierde. El ánimo se presume mientras no se manifieste una voluntad contraria, como cuando se vende la cosa y se la mantiene en poder como arrendatario, o se la abandona para desprenderse definitivamente de ella. Siguiendo reglas formuladas por **POTHIER**, si se tiene la posesión por intermedio de otro que será mero tenedor, y este cae en demencia o fallece, el poseedor no pierde su posesión; tampoco se pierde si el mero tenedor tiene la cosa a su vez por otro, como en el subarriendo, aunque este último ignore quién es el poseedor.

Se agrega que igualmente no se pierde si el mero tenedor cambia de propósito y se da por dueño (**art. 730, inc. 1º**). Sin embargo, la misma norma agrega que si el mero tenedor usurpador enajena a un tercero la cosa mueble a su propio nombre, la persona a quien se enajena adquiere la posesión, poniendo fin a la anterior: la pérdida está dada porque se crea un nuevo título posesorio para el tercero, que adquiere la posesión por el principio de la libre circulación de los bienes. Tal enajenación no compromete los derechos del verdadero dueño, en cuanto se trata de una venta de cosa ajena que le será inoponible (**art. 1815**), a lo que se agrega que si se recupera legalmente la posesión perdida, se entiende haberla tenido durante todo el tiempo intermedio (**art. 731**).

3.3. Pérdida

Siendo dos los elementos constitutivos, la posesión se pierde al perderse cualquiera de ellos o ambos, sin perjuicio de lo dicho precedentemente.

- a) Se pierden el corpus y el animus cuando el poseedor abandona la cosa o cuando la enajena.
- b) Se pierde la posesión al perderse el corpus. Ello puede acontecer cuando otro sujeto se apodera de la cosa con ánimo de hacerla suya (**art. 726**), situación con la cual se advierte la íntima relación entre la adquisición, conservación y pérdida de la posesión, que resultan correlativas; igual cosa acontece en el caso del art. 730. Ocurre también cuando, sin entrar otro a poseer, se hace imposible la ejecución de actos posesorios, como en los casos de los **arts. 619 y 608, inc. 2º** sobre animales bravíos, o cuando la cosa cae a un lago o al mar; casos que reciben consagración legal para los muebles, no directamente, sino a contrario sensu, pues se entienden perdidos al dejar de hallarse en poder del poseedor (**art. 727**).
- c) Se pierde al perderse el animus, lo que no será de ordinaria ocurrencia, pero tiene lugar señaladamente en el llamado constituto posesorio (**art. 684 N° 5**).

N. LA POSESIÓN INSCRITA: ASPECTOS GENERALES Y RÉGIMEN DE LOS INMUEBLES NO INSCRITOS

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. La posesión de inmuebles en el Mensaje del Código Civil

Esta materia fue abordada por el Código con un criterio diferente al de la legislación antigua, lo que indujo al legislador a profundas innovaciones; las disposiciones sobre ella son quizás las más trascendentales de las novedades que introduce el Código. Como ya se vio a propósito del sistema registral, el Mensaje explica que se descartó obligar a todos los titulares de un derecho real sobre inmuebles a inscribirlo dentro de cierto plazo, por temor a que la comprobación del derecho fuera fuente de litigios prolongados y costosos.

Se optó, en cambio, por hacer obligatoria la inscripción solo hacia el futuro, para las transferencias de dominio o constitución de derechos reales, salvo la servidumbre, y para las transmisiones hereditarias que comprendan inmuebles. El legislador estimó que, siendo lo normal en la historia de un bien raíz que se enajene o que su propietario muera, en un tiempo razonable todos los inmuebles se encontrarían inscritos y la posesión sería, así, manifiesta e indisputable.

Estas consideraciones del Mensaje son de gran relevancia para interpretar las normas sobre posesión de inmuebles. El legislador promueve, además, que los interesados se acojan voluntariamente al sistema de la propiedad inscrita, como lo revelan varias disposiciones: el **art. 729** dispone que si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera violenta o clandestinamente de un inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde, mientras que el **art. 728, inc. 2º** establece que, mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito no adquiere posesión de ella ni pone fin a la existente.

El **art. 924** hace que la posesión de los derechos inscritos se pruebe por la sola inscripción, con un año de duración; y el **art. 2505** exige, para prescribir contra un título inscrito, tener a su vez título inscrito, lo que constituye un fuerte incentivo a inscribir voluntariamente.

1.2. Diferencias con la posesión de bienes muebles

En los inmuebles esta materia presenta diferencias respecto de su aplicación a los muebles, por obra de al menos dos factores: primero, porque por su naturaleza el corpus en los inmuebles se torna más ficticio o simbólico que en los muebles, en muchos de los cuales la aprehensión es factible en términos reales; y segundo, porque en Chile, como en la generalidad de los países, la titularidad de los inmuebles se incorpora a un registro que se vincula tanto con el dominio, mediante la tradición por inscripción (**art. 686**), como con la posesión, en disposiciones como los **arts. 702, 724, 728, 730 y 924**.

1.3. Problemas que presenta la materia

En Chile esta materia es particularmente conflictiva, lo que se debe fundamentalmente a dos factores: la oscuridad y, a veces, aparente contradicción de los textos legales; y las características del Registro Conservatorio, que posibilitan errores en las inscripciones, inscripciones paralelas, inscripciones de papel y falta de congruencia entre los deslindes descritos y los reales, defectos que influyen tanto en la titularidad del dominio como en la posesión de los inmuebles, al estar la inscripción vinculada a ambas materias.

1.4. Doctrinas antagónicas sobre la posesión de los inmuebles

Los artículos que tratan la materia (entre otros, los **arts. 702, 708, 718, 724, 726, 728, 730, 924, 1815, 2505 y 2510**) han dado lugar a diferentes corrientes doctrinarias. Conviene analizar las dos posiciones antagónicas, sin perjuicio de la existencia de doctrinas intermedias: por un lado, la teoría de la posesión inscrita, conforme a la cual la inscripción es requisito necesario de toda posesión, regular e irregular; y por el otro, la doctrina de la inscripción como requisito solo de la posesión regular, pudiendo existir posesión sin inscripción, que en tal caso será irregular.

Teoría de la posesión inscrita

Esta doctrina clásica, sustentada por **TRUCCO, LIRA** y **ALESSANDRI**, entre otros, y conocida también como teoría de la inscripción-ficción, afirma que las disposiciones del Código forman un sistema amplio y armónico que hace de la inscripción prueba, requisito y garantía de la posesión, descansando en la ficción legal de que el poseedor inscrito, con título anotado por más de un año, tiene en su favor, por el hecho de la inscripción, los dos elementos constitutivos de la posesión: la tenencia y el ánimo de dueño.

Se afirma, primero, que la inscripción es requisito de la posesión a la luz del **art. 724**, que dispone que si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción, nadie podrá adquirir su posesión sino por ese medio; leído junto al **art. 686**, que rige la tradición de inmuebles, y al **art. 696**, según el cual los títulos cuya inscripción se prescribe no darán ni transferirán la posesión mientras no se efectúe, se concluye que sin inscripción no hay posesión. Esta exigencia sería doblemente amplia: se aplicaría tanto a la posesión regular como a la irregular, pues el art. 724 dice que "nadie" puede adquirir la posesión sin inscripción, y se aplicaría tanto a inmuebles inscritos como no inscritos, pues todo el sistema fue ideado para que todos los inmuebles llegaran a formar parte del Registro.

Se afirma, segundo, que la inscripción es prueba de la posesión, fundado en el **art. 924**, de modo que el **art. 925**, que alude a la prueba de la posesión del suelo por hechos positivos, resultaría aplicable únicamente a los inmuebles no inscritos.

Y se afirma, tercero, que la inscripción es garantía de la posesión, a la luz del **art. 728, inc. 2º**, en oposición al **art. 729**: quien posee sin inscripción está expuesto a perder su posesión ante un apo-

deramiento ilícito, mientras que, subsistiendo la inscripción, la posesión se conserva.

De acuerdo a esta doctrina, el antiguo poseedor puede hacer valer sus derechos en cualquier momento mientras su inscripción no sea legítimamente cancelada, lo que exige que las inscripciones formen una verdadera cadena de eslabones estrechamente engarzados, reforzando esto el **art. 2505**. A esta teoría se le reconoce ser la más acorde al sentido que tuvo **BELLO** al instaurar el sistema registral, aunque se le critica que, aplicada en extremo, da a la inscripción una superioridad absoluta aun sin correlato con la realidad, como en las llamadas inscripciones de papel, lo que puede producir situaciones injustas respecto de quienes poseen tranquila y pacíficamente por plazos superiores al de la prescripción extraordinaria.

Doctrina de la inscripción solo como requisito de la posesión regular

En el extremo opuesto, autores como **ÁLVAREZ, URRUTIA y CLARO SOLAR**, cuya posición se conoce también como teoría de la inscripción-garantía, afirman que las normas en que se sustenta la teoría de la posesión inscrita solo se aplican a la posesión regular y, consecuentemente, a la prescripción ordinaria, siendo perfectamente factible adquirir la posesión irregular de un inmueble, esté o no inscrito, sin inscripción, habilitando esta para adquirir mediante prescripción extraordinaria.

Esta doctrina se construye sobre los **arts. 702 y 708**: siendo uno de los requisitos de la posesión regular la tradición, es decir, la inscripción, es posible concluir que puede adquirirse una posesión irregular de un inmueble sin ella. En cuanto a la prescripción, estima que el **art. 2505** es exclusivamente para la ordinaria, rigiendo para la extraordinaria solo el **art. 2510**, cuya regla primera no exige título alguno.

Esta posición tiene la virtud de dar una solución más equitativa a quien trabaja un predio careciendo de inscripción, pero se le critican, entre otras cosas: que desatiende el sistema ideado por el Código, cuya ratio legis indica que jamás se podría entrar en posesión, regular ni irregular, sin inscripción; que se construye sobre una distinción artificiosa, atendido que normas como el art. 724 exigen la inscripción tanto para la regular como para la irregular; y que su lectura del art. 708 es objetable, porque el requisito que jamás puede faltar es la tradición, pues sin ella no es que la posesión sea irregular, sino que derechamente no hay posesión.

Doctrinas intermedias

Para salvar las críticas hechas a una y otra tesis han surgido doctrinas intermedias, conforme a las cuales la inscripción, aun cuando sea meramente formal y desvinculada del poseedor inscrito, es un requisito adicional al corpus y al animus que exige el **art. 700**, de modo que para poseer un inmueble se exigen los tres presupuestos.

Se afirma que el **art. 728, inc. 2º** se refiere solamente al apoderamiento material sin inscripción, y no al caso de quien, tomando la cosa con ánimo de dueño, solemniza el apoderamiento con una inscripción; ello se apoyaría en el **art. 730, inc. 2º**, que permite adquirir la posesión mediante la

"competente inscripción", entendida por esta doctrina como la que se practica por el Conservador respectivo, en el registro y forma que la ley ordena, aunque no cancele la inscripción anterior. Bajo estas premisas, si quien toma un inmueble con ánimo de señor solemniza el hecho con una inscripción a su favor, el antiguo poseedor, que queda con una inscripción vacía y sin correlato en la tenencia material, pierde la posesión que tenía, porque no puede haber dos posesiones simultáneas sobre una misma cosa.

DATO DE GRADO

Las tres doctrinas sobre la posesión de inmuebles, en síntesis

Teoría de la posesión inscrita (o de la inscripción-ficción, Trucco/Lira/Alessandri): la inscripción es requisito, prueba y garantía de toda posesión, regular e irregular, inscrita o no inscrita (arts. 724, 924, 728 inc. 2º). Doctrina de la inscripción como requisito solo de la posesión regular (o de la inscripción-garantía, Álvarez/Urrutia/Claro Solar): sin inscripción puede haber posesión irregular, que habilita para la prescripción extraordinaria (arts. 702, 708, 2510). Doctrinas intermedias: la inscripción, aunque sea meramente formal, es un tercer requisito junto al corpus y al animus, de modo que quien solemniza su apoderamiento con una inscripción propia hace perder la posesión al antiguo poseedor inscrito.

1.5. Jurisprudencia

Del examen de las distintas discusiones se observan dos tendencias centrales: conceder preponderancia fundamental a la inscripción, o atenerse más bien a la posesión material. Los fallos de los tribunales han oscilado entre ambas posiciones, sin que sea fácil constatar un estado actual: si bien se otorga protección al poseedor inscrito, una posesión material muy prolongada ha llegado a prevalecer, desconociéndose en general valor al llamado poseedor de papel, en que injustificadamente no hay indicios de posesión material. Cuando se trata de un inmueble no inscrito, poseído por más de diez años, la tesis que privilegia la posesión material se encuentra en su mejor situación; cuando se trata de un inmueble inscrito, cuyo título traslativo se aduce para posesión regular, la tesis que privilegia la inscripción se encuentra en la suya.

2. ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN DE INMUEBLES NO INSCRITOS

2.1. Adquisición

Para adquirir la posesión de los bienes raíces es necesario un título posesorio, que puede ser constitutivo de dominio, como la ocupación, la accesión y la prescripción (**art. 703**), o derivativo, como

la tradición y la sucesión por causa de muerte. Por lo general, los mismos títulos que fundamentan la posesión de los muebles pueden invocarse para la de los inmuebles.

a) Ocupación o simple apoderamiento material. La ocupación nunca puede operar como modo de adquirir el dominio de un inmueble, porque de conformidad al **art. 590** son bienes del Estado las tierras que carezcan de otro dueño, pero sí puede servir como título para adquirir la posesión de un inmueble no inscrito. El **art. 729** dispone que si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera violenta o clandestinamente de un inmueble no inscrito, el que tenía la posesión la pierde; no distinguiendo la norma respecto del apoderamiento pacífico, se concluye que el apoderamiento, en cualquiera de sus formas, hace perder la posesión anterior. Buena parte de la doctrina estima que el apoderamiento pacífico constituye, además, título posesorio suficiente para que el que se apodera adquiera la posesión sin necesidad de inscripción, que será irregular, pues el nuevo poseedor está de mala fe al presumirse que conoce el art. 590. Si el apoderamiento es violento o clandestino, discutir si el que se apodera es poseedor o mero tenedor carece de importancia práctica, porque aun considerándosele poseedor, esa posesión viciosa es inútil para prescribir.

b) Accesión. La mayoría de los autores afirma que la posesión adquirida por accesión no requiere inscripción, pues si se reconoce la posesión de lo principal sin ella, no podría exigirse para lo accesorio, que sigue la suerte de aquello, aunque los actos posesorios deben ejercerse también sobre lo accedido (por ejemplo, sobre lo que llega por avulsión, **art. 652**).

c) Prescripción. Es descartada por la doctrina nacional como título posesorio, porque no podría invocarse como antecedente de una posesión a la que precisamente se llega en virtud de ella.

d) Sucesión por causa de muerte. No es necesaria la inscripción, pues los **arts. 688 y 722** confieren la posesión por el solo ministerio de la ley; las inscripciones del art. 688 habilitan al heredero para disponer de los inmuebles, pero no son las que le confieren la posesión.

e) Tradición. Se ha discutido si se requiere inscripción conservatoria para adquirir la posesión de inmuebles no inscritos invocando la tradición como título posesorio, controversia centrada en la interpretación del **art. 724**.

Ciertos autores, como **FABRES**, sostienen que no se requiere inscripción, porque el art. 724 solo puede referirse a la posesión regular, en la que sí se requiere esencialmente la tradición, mientras que la irregular, la violenta y la clandestina pueden existir sin inscripción, según se deduce de los **arts. 702, 708, 729 y 730**. Otros autores matizan esta opinión, entendiendo que el art. 724 se aplica solo a los inmuebles inscritos, de modo que si se enajena uno no inscrito y no se practica la inscripción, ello no obsta a que se adquiera la posesión irregular, pues falta solo el requisito de la tradición que exige la posesión regular.

Por el contrario, otros autores, entre quienes se cuenta el propio apunte, afirman que a la luz de los **arts. 702, 686, 696 y 724** la inscripción es indispensable, y que cuando se invoca la tradición como título posesorio sin inscripción no hay posesión, sea regular o irregular, de inmuebles: sin inscripción no hay tradición, y sin tradición no hay título posesorio. En apoyo de esta postura se señala que el art. 724 no distingue entre inmuebles inscritos y no inscritos, empleando el término "nadie"

en forma comprensiva de todo poseedor; que el Mensaje ratifica que se buscaba que todos los inmuebles llegaran a estar inscritos, sin restringir esa obligación a los que ya lo estuvieran; y que, no obstante los amplios términos del art. 708, el requisito que jamás puede faltar es la tradición, pues sin ella no hay posesión de ninguna especie.

2.2. Conservación y pérdida

Se ha estimado que la situación de los inmuebles no inscritos es similar a la de los muebles: se pierde la posesión desde que falta el corpus, el animus, o ambos, siendo aplicables los **arts. 726 y 729**. Pero no puede olvidarse la posición de quienes sostienen que para adquirir la posesión de todo inmueble, incluso no inscrito, es necesaria la inscripción. En síntesis, el poseedor no inscrito puede perder su posesión: cuando la abandona; cuando enajena el inmueble; cuando alguien le usurpa el inmueble, disponiendo entonces de un año para las acciones posesorias, entendiéndose que nunca la perdió si la recupera legalmente (**arts. 729 y 731**); y cuando el mero tenedor del inmueble lo usurpa, se da por dueño y lo enajena, caso en el que el adquirente entra en posesión y termina la anterior, aunque si solo se da por dueño sin enajenar, el poseedor no la pierde (**art. 730, inc. 1º**).

O. ADQUISICIÓN, CONSERVACIÓN Y PÉRDIDA DE LA POSESIÓN DE INMUEBLES INSCRITOS

1. ADQUISICIÓN

Hay que distinguir si para adquirir la posesión de un inmueble inscrito se invoca un título no traslativo de dominio o uno que sí lo es.

a) Ocupación. Ciertos autores estiman posible adquirir por apoderamiento la posesión de un inmueble inscrito, porque el **art. 724** no regiría esta situación, al referirse solo a los casos en que se aduce título traslativo, y porque los **arts. 925, 926 y 2502** permitirían esta posibilidad; sus sostenedores están estimulados por una concepción realista u objetiva de la posesión, en la que el elemento fundamental es la tenencia material y el aprovechamiento económico del bien. Sin embargo, el claro tenor del Código permite arribar a la conclusión inversa: no es posible adquirir por ocupación, aun pacífica, la posesión de bienes inscritos, porque el **art. 728, inc. 2º** dispone que, mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título inscrito no adquiere la posesión de ella ni pone fin a la existente. Esta norma constituye un poderoso incentivo para que el poseedor acoja su inmueble al sistema registral, pues la inscripción lo protege frente al apoderamiento de cualquier clase.

b) Accesión. La doctrina está dividida: unos afirman que la ley no requiere inscripción alguna para adquirir por accesión, esté o no inscrito el inmueble al que se accede; otros sostienen que, tratándose de un inmueble principal inscrito, rige con toda su fuerza el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, por lo que también tendría que inscribirse la accesión.

c) Prescripción. Al igual que respecto de los inmuebles no inscritos, nunca puede constituir un título posesorio, pues mal puede servir como título a una posesión que necesariamente debió adquirirse con anterioridad a que la prescripción opere.

d) Sucesión por causa de muerte. No es necesaria la inscripción, aun tratándose de inmuebles inscritos, ya que los **arts. 688 y 722** confieren la posesión por el solo ministerio de la ley.

1.1. Tradición

Para adquirir la posesión regular del inmueble inscrito por tradición, la necesidad de inscripción conservatoria es evidente, por cuanto el **art. 702** exige tradición cuando el título es traslativo de dominio, el **art. 686** establece que esa tradición se efectúa por la inscripción, y el **art. 724** establece que nadie puede adquirir la posesión sin ella.

Se discute, en cambio, si es posible adquirir posesión irregular sin inscripción. Ciertos autores, entre ellos **FABRES**, sostienen que sí, porque el art. 708 señala que la posesión irregular es la que carece de uno o más de los requisitos del art. 702, entre ellos la tradición, siendo posible entonces ser poseedor irregular sin ella; para estos autores, el art. 724 solo se refiere a la posesión regular.

Buena parte de la doctrina, en cambio, sostiene que la inscripción es necesaria para adquirir toda clase de posesión, sea regular o irregular, porque el art. 724 no distingue entre inmuebles inscritos y no inscritos ni entre clases de posesión, porque el Mensaje ratifica que se buscaba que todos los inmuebles llegaran a estar inscritos, y porque, no obstante los amplios términos del art. 708, el requisito que jamás puede faltar es la tradición, sin la cual no habrá posesión de ninguna especie.

2. CONSERVACIÓN Y PÉRDIDA

Debe tenerse presente, una vez más, la correlación entre adquisición, conservación y pérdida. Aquí debe mencionarse destacadamente el **art. 728**, que dispone que para que cese la posesión inscrita es necesario que la inscripción se cancele, sea por voluntad de las partes, por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho a otro, o por decreto judicial.

2.1. Por voluntad de las partes

Atendido que la ley habla de la voluntad "de las partes", no se refiere a una declaración unilateral, sino al acuerdo de dos partes con el propósito de cancelar la inscripción practicada a nombre de una de ellas. Las principales hipótesis son la resciliación, que conforme al **art. 1567, inc. 1º** es la convención por la cual las partes acuerdan dejar sin efecto el contrato que las vincula, exhibiéndose al Conservador un instrumento auténtico que conste esa voluntad, bastando una subinscripción al margen que indique la cancelación (art. 91 del Reglamento), con lo que cobrará vigencia la inscripción precedente; y la transacción celebrada con el fin de poner término a un juicio o precaver un litigio eventual.

2.2. Por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho

Es el caso de más frecuente aplicación: quien tiene inscrito el inmueble a su nombre lo vende, y el comprador exhibe el título al Conservador, que inscribe el inmueble ahora a su nombre. La sola inscripción cancela automáticamente la anterior, lo que se ha denominado "cancelación virtual", sin que sea necesaria una subinscripción; en la nueva inscripción debe hacerse referencia a la anterior, para reconstituir la historia de las mutaciones (**art. 692** del Código y art. 80 del Reglamento). Como el art. 728 exige que la nueva inscripción provenga del "poseedor inscrito", se desprende que debe tener una relación directa con la persona a cuyo nombre estaba inscrito el derecho que transfiere.

Cabe preguntarse qué ocurre si, en verdad, quien celebró el contrato traslativo del que resulta la nueva inscripción no era el poseedor inscrito, sino una persona sin poder para representarlo; aunque el Conservador debe rechazar tal inscripción (art. 14 del Reglamento), puede practicarse por error. Se ha discutido si esa nueva inscripción cancela la anterior: en un extremo, se sostiene que no proviene del poseedor inscrito y por ende no cancela la anterior, existiendo dos inscripciones paralelas, una ineficaz y otra eficaz; pero esta conclusión descarta que se cancele la inscripción por un título injusto, como el falsificado, siendo que el art. 728 no distingue justicia o injusticia del tí-

tulo, y el art. 730 da por cancelada la inscripción basada en un título particularmente injusto, el del usurpador.

La jurisprudencia se ha ido uniformando en que, para que la nueva inscripción cancele la anterior, debe provenir, al menos aparentemente, del poseedor a cuyo nombre figura esta última; esa apariencia se da tanto en el título falsificado como en el otorgado por quien se atribuye una representación de la que carece.

DATO DE GRADO

La "posesión de papel" no habilita para prescribir

Consciente de que exigir al poseedor inscrito revisar periódicamente su inscripción sería excesivo, la jurisprudencia se ha uniformado en que la llamada "posesión de papel", sustentada solo en la inscripción y sin correlato en la realidad, no habilita para prescribir: además de la inscripción es necesario realizar actos posesorios, que son los que permiten enterarse de la posesión a quien tiene derecho a oponerse a ella.

2.3. Cancelación por una nueva inscripción desconectada de la anterior: el art. 730

Conforme al **art. 730**, si el mero tenedor de una cosa simplemente se da por dueño, no adquiere posesión ni cesa la anterior; pero si, dándose por dueño, la enajena, cesa aquella y el adquirente entra en posesión (inc. 1º). Con todo, si el que tiene una cosa en lugar y a nombre de otro se da por dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra sin la "competente inscripción" (inc. 2º). Considerando que este inciso segundo regula la situación del poseedor inscrito, la doctrina mayoritaria afirma que el inciso primero se aplica a los muebles y a los inmuebles no inscritos, y el segundo, exclusivamente a los inscritos.

Se ha discutido, primero, si para los inmuebles no inscritos resultaría necesaria una inscripción: algunos sostienen que basta la sola enajenación del mero tenedor, pues el inciso primero no exige inscripción, a diferencia del segundo, que sí exige la "competente inscripción"; otros sostienen que sería ajeno al espíritu de la legislación que el art. 730 exceptuara el principio de que toda enajenación de inmuebles debe hacerse por inscripción, que fluye de los **arts. 686 y 724**, y que "enajenación" en el inciso primero equivale a tradición, que necesariamente supone inscripción.

Se ha discutido, segundo, qué debe entenderse por "competente inscripción". Una primera doctrina afirma que es aquella que, aunque sea aparente, se relaciona con la anterior, de modo que del contrato traslativo se desprenda al menos la apariencia de consentimiento del poseedor inscrito; se le critica que confunde esta materia con la de los títulos injustos, y que el art. 730 regula precisamente al mero tenedor que enajena a su propio nombre, lo que hace imposible esa apariencia de consentimiento. Una segunda doctrina afirma que es la que se ha practicado observando formalmente la ritualidad de las inscripciones según el Reglamento, constituyendo el inc. 2º del art. 730 una

cuarta forma de cancelación agregada a las tres del art. 728; se le critica que priva de sentido al precepto, pues bastarían para llegar a la misma conclusión los **arts. 686, 702 y 724**.

Una última postura, sostenida por **VIAL**, distingue dos situaciones que sí podrían ocurrir en la práctica: la primera, cuando la compraventa entre el mero tenedor y el tercero adquirente se celebra sobre la base de que el inmueble no está inscrito, pese a estarlo, omitiéndose en la escritura toda referencia a la inscripción del poseedor inscrito, caso en que la "competente inscripción" es la que se efectúa cumpliendo los trámites de los **arts. 693** del Código y 58 del Reglamento, previstos para la primera inscripción de una finca.

La segunda situación se produce cuando el Conservador, ante un inmueble vendido por quien el Registro no muestra como su actual poseedor (art. 14 del Reglamento), rehúsa la inscripción hasta que se acredite que se ha puesto la pretensión en noticia judicial de los interesados a quienes puede perjudicar, caso en que será "competente inscripción" la que se practica tras cumplirse ese trámite.

En ambas situaciones, la competente inscripción supone el cumplimiento de medidas de publicidad que ponen la situación en conocimiento de los interesados, para que puedan ejercer las acciones legales correspondientes.

2.4. Por decreto judicial

Una sentencia puede también disponer la cancelación de una inscripción, cesando así la posesión existente a nombre de una de las partes litigantes, como puede ocurrir en el juicio reivindicatorio, en juicios sobre nulidad o en la acción resolutoria. Exhibiéndose copia del fallo, el Conservador cancelará la inscripción materialmente mediante una subinscripción (art. 91 del Reglamento), cobrando vigencia la precedente si la había, sin perjuicio de que el mismo fallo ordene practicar una nueva inscripción a nombre del otro litigante.

P. PRUEBA DE LA POSESIÓN

La prueba de la posesión es una materia de especial importancia, no solo porque el poseedor es reputado dueño, de modo que basta probar la posesión para que la ley presuma el dominio, sino porque quien alega la prescripción debe probar la posesión en la forma establecida por la ley.

1. PRUEBA DE LA POSESIÓN DE LOS MUEBLES

El Código no reglamenta cómo debe probarse la posesión sobre una cosa mueble, por lo que es necesario recurrir a los principios generales en materia de prueba: tratándose de la prueba de hechos, son idóneos todos los medios de prueba de admisión general (**art. 1698** del Código Civil y art. 341 del Código de Procedimiento Civil).

Como la calidad de poseedor se sustenta en un hecho, la tenencia de una cosa con ánimo de señor y dueño, la prueba de la posesión de muebles consiste en demostrar ambos elementos. Probar el corpus implica demostrar que el objeto se tiene aprehendido físicamente, o al menos que se le gobierna, controla o tiene a disposición. La prueba del animus, por su naturaleza psicológica, es de imposible prueba directa, pero hay hechos que permiten deducirlo: los que conforman la conducta de un dueño, como utilizar la cosa, mantenerla, mejorarla o transformarla sin esperar anuencia de nadie. Para tales efectos, la mejor prueba del animus será la acreditación de un título posesorio que justifique la tenencia material de la cosa.

Si bien el que alega posesión debe probarla, el Código establece algunas presunciones. En particular, el **art. 719** establece tres: si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que la posesión ha continuado hasta el momento en que se alega; si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume igualmente la continuación del mismo orden de cosas; y si alguien prueba haber poseído anteriormente y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio. Incluso, el **art. 731**, en relación con el **art. 2502**, establece una ficción: el que recupera legalmente la posesión perdida se entenderá haberla tenido durante todo el tiempo intermedio.

2. PRUEBA DE LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES

La materia se encuentra regulada en los **arts. 924 y 925**. El primero dispone que la posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción, y mientras esta subsista, con tal que haya durado un año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión con que se pretenda impugnarla. El segundo dispone que se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos, de aquellos a que solo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios o de cerramientos, las plantaciones o sementeras y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión.

Estas disposiciones han dado lugar a un intenso debate. Hay quienes afirman que el art. 924 se aplica a la prueba de la posesión de los inmuebles inscritos, en tanto el art. 925 se aplica a la de los

no inscritos. Para otros, el art. 924 se aplica a la prueba de la posesión de los derechos reales inscritos, con la sola excepción del dominio, en tanto el art. 925 se aplica a la prueba de la posesión del derecho real de dominio sobre un bien raíz, esté o no inscrito.

Una tercera interpretación, sostenida por **VIAL**, distingue: de conformidad a los **arts. 686 y 724** y a la luz del Mensaje, la inscripción es indispensable para adquirir la posesión de un inmueble cuando se invoca como título posesorio la tradición, de modo que en tales casos resulta ineludible acreditar la posesión conforme al art. 924, esto es, mediante la inscripción.

Existen, sin embargo, otros casos en que la inscripción no es indispensable: cuando se adquirió el inmueble por tradición antes de la entrada en vigencia del Código y nunca ha sido enajenado; con las servidumbres, cuya tradición no requiere inscripción sino solo escritura pública; y cuando se adquirió la posesión por un título posesorio distinto a la tradición, como la ocupación, la accesión y la sucesión por causa de muerte. En estos casos la posesión deberá acreditarse conforme al art. 925, esto es, por hechos positivos de aquellos a que solo da derecho el dominio. Finalmente, **VIAL** observa que, si bien la ejecución de actos posesorios no es necesaria para acreditar la posesión, sí lo es para efectos de la prescripción, evento en que deberán emplearse conjuntamente las reglas de los arts. 924 y 925.

Q. LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA: NOCIONES GENERALES, FUNDAMENTO, CARACTERÍSTICAS Y REGLAS COMUNES

1. NOCIONES GENERALES

El **art. 2492** define la prescripción como *"un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción"*.

De la definición legal se desprende que la prescripción puede ser adquisitiva, llamada también usucapión, y extintiva, llamada también liberatoria. La primera produce la adquisición de la propiedad y se incluye entre los modos de adquirir el dominio. La segunda produce la extinción de las acciones y derechos ajenos, y se incluye entre los modos de extinguir las obligaciones, aunque en estricto rigor solo se extinguen por ella las acciones y no los derechos, porque siempre cabe la posibilidad de ejercer estos últimos y retener lo dado o pagado por el deudor, quien habrá cumplido una obligación natural.

La doctrina ha discutido bastante la conveniencia de un tratamiento conjunto o separado de ambas prescripciones: intervienen en la discusión, por una parte, los elementos comunes de lapso de tiempo e inactividad del titular del derecho y ciertas reglas comunes, y por otra, las distintas funciones de cada una. En cuanto a la ubicación del tema al final del Código, los autores nacionales dan como explicación el modelo francés y el carácter consolidador de derechos que exhibe la prescripción, apto para concluir la obra codificadora.

2. FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN

A primera vista la prescripción aparece como un despojo en que se arrebató su derecho al propietario, por lo que es necesario determinar si se trata de una creación arbitraria del Derecho positivo o si tiene fundamento en la equidad. Los autores antiguos la justificaban por necesidades de orden social: **GAIUS**, en Roma, hallaba su justificación en un motivo político, la necesidad de procurar a la propiedad la estabilidad y las garantías que le son necesarias, y excitar a los ciudadanos a cuidar sus negocios como buenos padres de familia.

DATO DE GRADO**LAURENT sobre la certidumbre de los derechos**

"Que uno se represente un instante el estado de una sociedad en que se pudiera hacer valer derechos que dataran de diez mil años. Sería una causal universal de perturbación en el estado de las fortunas; no habría una familia, ni una persona que estuviera al abrigo de una acción por la cual su posición social sería puesta en cuestión. Una incertidumbre permanente y universal tendría como consecuencia una perturbación general e incesante. ¿Cómo podrían subsistir en semejante anarquía los individuos y la sociedad?"

De este modo, la prescripción apunta a la certidumbre de los derechos, a resolver de manera definitiva las relaciones jurídicas. Para beneficio de toda la sociedad, la prescripción consolida situaciones luego de cierto plazo, que no podrían quedar indefinidamente inciertas sin evidente perjuicio para la convivencia de las personas. Adicionalmente, la difícil prueba del dominio se ve facilitada mediante la prescripción adquisitiva.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

3.1. Es un modo de adquirir originario

Aun cuando el objeto tenía un propietario anterior, el prescribiente no lo recibe de aquel; lo adquiere independientemente.

3.2. Permite adquirir el dominio de toda clase de bienes que puedan poseerse

Permite adquirir el dominio y los demás derechos reales, con excepción de las servidumbres discontinuas y continuas inaparentes. En cuanto a la posibilidad de adquirir por prescripción los derechos personales, el tema se inicia con la misma polémica sobre su posesión ya examinada: si se rechaza que exista posesión de derechos personales, habrá que rechazar también su prescripción adquisitiva, y a la inversa. En el Código hay dos preceptos que, en lo concerniente al objeto que se prescribe, aparecen dirigidos solo a los derechos reales (**arts. 2498 y 2512**), lo que constituye un argumento para el rechazo de la prescripción de derechos personales.

Existe, además, una regla según la cual toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho (**art. 2517**), que quienes rechazan esa prescripción entienden reducida a los derechos y acciones reales, y quienes la admiten entienden aplicable a toda clase de derechos y acciones.

3.3. Es un modo de adquirir a título singular

Con la excepción de la posibilidad de ganar por prescripción una herencia.

3.4. Es un modo de adquirir a título gratuito y por acto entre vivos

Para adquirir el dominio por prescripción no se presupone la muerte del titular ni importa una contraprestación pecuniaria para el adquirente.

4. REGLAS COMUNES A TODA PRESCRIPCIÓN

Es tradicional hacer mención a tres reglas que, por ser aplicables tanto a la prescripción adquisitiva como a la extintiva, se denominan reglas comunes a toda prescripción.

4.1. Debe ser alegada

De conformidad al **art. 2493**, el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio. Siendo la prescripción un beneficio que podría renunciarse, es justificado que se exija su alegación; además, es necesario que se hagan constar los antecedentes que configuren la pretensión de que ha operado, y que se plantee en juicio contra legítimo contradictor, el dueño contra quien se prescribe. Excepcionalmente no es necesario alegarla, debiendo el tribunal declararla de oficio, en la prescripción de la acción ejecutiva, pues el **art. 441** del Código de Procedimiento Civil obliga al tribunal a examinar el título ejecutivo, y en la de la acción penal y de la pena (**art. 102** del Código Penal); tratándose solo de casos de prescripción extintiva, la usucapión siempre deberá ser alegada.

Sustantivamente, no existen términos sacramentales para alegarla, pero no basta una vaga referencia, sino que debe alegarse en términos concretos, indicando al juez los elementos esenciales que la configuran, como el plazo. En el ámbito procesal se ha discutido la forma de alegarla: se ha sostenido que solo procede como acción, porque es necesario obtener una declaración positiva del tribunal, y que el **art. 310** del Código de Procedimiento Civil, al hablar de "excepción de prescripción" oponible en cualquier estado del juicio, sería solo aplicable a la extintiva, dado que la adquisitiva exige un juicio de lato conocimiento.

Otros niegan que exista una "acción de prescripción", por ser esta solo un modo de adquirir un derecho, de modo que el prescribiente debe ejercer una acción que derive de su dominio, como la reivindicatoria, señalando la prescripción como causa de pedir; y si se le demanda, puede excepcionarse mediante ella. Por último, se ha sostenido que puede alegarse tanto como acción como excepción. La jurisprudencia no ha sido uniforme, aunque parece inclinarse por la necesidad de accionar de prescripción.

4.2. No puede renunciarse anticipadamente

El **art. 2494, inc. 1º** señala que la prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Siendo la prescripción un beneficio, puede renunciarse una vez cumplidas las exigencias para que opere, conforme al **art. 12**; pero como hay un interés general comprometido, se impide renunciar a ella anticipadamente, porque de permitirse se intentaría la renuncia frecuentemente al celebrarse actos o contratos. La estipulación de renuncia anticipada es nula absolutamente, por infringir una ley prohibitiva y adolecer de objeto ilícito (**arts. 10, 1466 y 1682**).

Se ha discutido cuándo debe estimarse cumplida la prescripción para estos efectos. Algunos piensan que solo una vez dictada la sentencia que la declara. Con mejor fundamento, otros consideran que se encuentra cumplida cuando se ha poseído la cosa por el lapso legal, lo que naturalmente ocurre con anterioridad a la sentencia.

El poseedor adquiere el dominio por el hecho de haber poseído durante cierto tiempo, aunque para que ese dominio sea reconocido por todos sea indispensable que el poseedor alegue la prescripción y el juez la declare, y que, tratándose de inmuebles, la sentencia se inscriba, pues sin inscripción no valdrá contra terceros (**art. 2513**). La renuncia expresa se produce cuando el poseedor declara en términos explícitos su intención de no aprovecharse de la prescripción cumplida; la tácita, cuando ejecuta un hecho del que se deduce esa intención, como cuando toma en arriendo la cosa que ya poseía como dueño. Para renunciar se exige poder de disposición del derecho de que se trata (**art. 2495**) y plena capacidad de ejercicio.

4.3. Las reglas son iguales para todas las personas

El **art. 2497** dispone que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales, y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo. Esta norma tiene una explicación histórica: antiguamente se establecían plazos distintos para prescribir, privilegiando a ciertas personas, como el Fisco y la Iglesia, y **BELLO** quiso innovar estableciendo la igualdad. Con todo, sí existe el beneficio de la suspensión de la prescripción a favor de ciertas personas (**art. 2509**), que se examina más adelante, al tratar los elementos de la prescripción adquisitiva.

R. ELEMENTOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA: COSA SUSCEPTIBLE DE PRESCRIPCIÓN Y LA POSESIÓN

De la propia definición (**art. 2492**) puede observarse que la prescripción adquisitiva consiste, fundamentalmente, en posesión de una cosa por cierto tiempo mínimo. Entonces, los elementos básicos son la posesión y el transcurso de un plazo. A ellos se suele agregar, para mayor claridad en el análisis, el que se trate de una cosa susceptible de prescripción, y que el plazo no se encuentre interrumpido ni suspendido.

1. PRIMER ELEMENTO: COSA SUSCEPTIBLE DE PRESCRIPCIÓN

1.1. Regla general

La regla general es que las cosas sean susceptibles de prescripción: a través de ella se puede adquirir el dominio de las cosas corporales muebles o inmuebles, siempre que sean comerciables, así como los derechos reales.

1.2. Excepciones: cosas no susceptibles de ser adquiridas por prescripción

Las cosas imprescriptibles, o como señala el **art. 917**, las "cosas que no pueden ganarse por prescripción", constituyen la excepción. La doctrina suele indicar que no se pueden adquirir por prescripción:

- a) Los derechos de la personalidad, esto es, el conjunto de derechos inherentes al individuo, como el derecho a la honra, a la imagen o a la privacidad, que por su carácter extrapatrimonial no admiten prescripción.
- b) Las cosas inmerciables o fuera del comercio humano, pues sobre ellas los particulares no pueden tener dominio ni posesión: tienen esta calidad las cosas comunes a todos los hombres (**art. 585**) y los bienes nacionales de uso público (**art. 589**). En cambio, sí pueden adquirirse por prescripción los bienes fiscales.
- c) Las servidumbres discontinuas de cualquier clase y las continuas inaparentes, por así disponerlo expresamente el **art. 882**, conforme al cual no se pueden adquirir ni aun por su goce inmemorial, lo que reitera el art. 917.
- d) Las cosas indeterminadas, porque el fundamento de la prescripción es la posesión, y esta necesariamente debe recaer sobre una cosa determinada, como enfatiza el art. 700 al definir la posesión.
- e) Las cosas propias, porque una cosa solo puede adquirirse por un modo.

f) Según la mayoría de la doctrina, tampoco se pueden adquirir por prescripción los derechos personales, esto es, la calidad de acreedor en una relación de obligación, cuestión que se vincula a la ya examinada discusión sobre las cosas no susceptibles de posesión.

1.3. ¿Puede haber posesión sin prescripción?

Si la cosa no es susceptible de posesión, no podrá adquirirse por prescripción, y la regla general es que todas las cosas que pueden poseerse pueden ganarse por prescripción. La duda surge si se pretende tener esta como regla absoluta: ¿es concebible la posesión con la imposibilidad de ganar por prescripción? Lógicamente, no se ve obstáculo, y una ley puede disponer que cierto objeto pueda poseerse pero sea imprescriptible.

Hay autores que ven esta situación en varias materias del Código: en la posesión viciosa, violenta y clandestina, que sería para un sector de la doctrina una posesión "inútil" que imposibilita adquirir por prescripción, fuente de imprescriptibilidad que estaría dada, entre otras cosas, por la regla 3ª del **art. 2510**; y en la posesión irregular de inmuebles inscritos, que podría poseerse sin inscripción pero no adquirirse por prescripción sin inscribirse, debido al **art. 2505**.

También se cita el caso de las servidumbres discontinuas y continuas inaparentes, que no pueden adquirirse por prescripción conforme al art. 882, no obstante lo cual la misma norma reconoce que se pueden "gozar", lo que para algunos sería sinónimo de poseer; y, finalmente, el de los derechos personales, que ciertos autores admiten poseer, fundamentalmente por los **arts. 715 y 1576**, agregando sin embargo que no serían susceptibles de adquirirse por prescripción.

1.4. Prescripción entre comuneros

Tanto en la doctrina universal como entre nosotros es antigua la discusión de si es posible la prescripción entre comuneros; los textos chilenos no solucionan la cuestión expresamente.

NO CONFUNDIR

Comprar la cuota a un comunero, versus prescribir entre comuneros originarios

Conviene aislar la situación de quien adquiere la cosa común de manos de un solo comunero, que la vende dándose por dueño exclusivo: el adquirente no adquiere más derechos que los que tenía su causante, por lo que se hace dueño solo de su cuota, pasando a ser comunero con los demás; pero la venta de cosa ajena es válida, y él, ignorando la existencia de la comunidad, posee toda la cosa exclusivamente, pudiendo llegar a adquirir el dominio exclusivo por prescripción, incluso ordinaria. Esta situación no es discutida por la doctrina ni la jurisprudencia. El problema, en cambio, es más agudo tratándose de quienes son comuneros originarios entre sí.

Para algunos autores, un comunero no puede adquirir por prescripción la cuota de otro, aunque haya gozado de ella como único dueño: (i) por la imprescriptibilidad de la acción de partición (**art. 1317**), relacionada con el **art. 2517**; (ii) por la exclusividad de la posesión que supone la prescripción, que no existiría en la coposesión de los comuneros (**art. 718**), pues cada uno posee la totalidad de la cosa común sin posesión exclusiva sobre una cuota determinada; (iii) por la naturaleza incorpórea de la cuota, que no constituiría una cosa corporal susceptible de posesión material; (iv) por antecedentes históricos, pues **BELLO** permitía expresamente la figura en algunos proyectos, lo que en definitiva no quedó; y (v) porque el principio que fluye del art. 730 sería contrario, en cuanto el comunero que pretende el dominio exclusivo tendría siempre la calidad de usurpador.

Otros autores, en cambio, aceptan que un comunero pueda prescribir la cuota de otro: (i) la acción de partición es imprescriptible solo mientras se mantienen los fundamentos de la comunidad, y si un comunero posee con ánimo de dueño exclusivo durante el plazo legal sin que los demás hagan valer la partición, la comunidad desaparece; (ii) la coposesión se desvanece desde que uno de los comuneros se desvincula, no reconociendo el derecho de los otros y pasando a gozar de la cosa a título privativo; (iii) intelectualmente la cuota de cada comunero aparece delimitada, y sobre ella tiene dominio y posesión exclusiva, lo que confirma la posesión de las cosas incorporales que admite el art. 715.

Además, (iv) si se puede ganar por prescripción la totalidad del dominio de una cosa, no hay razón para negar la adquisición por prescripción de una cuota; y (v) no hay por qué rechazar que un comunero, con un cambio de actitud, empiece a poseer exclusivamente, principio que fluye de la regla 3ª del art. 2510, debiéndose proteger a quien efectivamente labora la cosa común por largo tiempo mientras los demás se desentienden de ella.

La jurisprudencia nacional se ha inclinado ostensiblemente por negar lugar a la prescripción entre comuneros. De aceptarse, generalmente se requerirá prescripción extraordinaria, ya que el comunero estará por lo común de mala fe y su posesión será, por tanto, irregular.

2. SEGUNDO ELEMENTO: LA POSESIÓN

El art. 2492, al definir la prescripción como modo de adquirir las cosas ajenas, exige que se hayan "poseído las cosas", lo que deja de manifiesto que la posesión es un requisito de la prescripción; al respecto, corresponde remitirse a todo lo ya expuesto sobre la materia. Solo resta mencionar la regla del **art. 2499**, relativa a los llamados actos de mera facultad y actos de mera tolerancia.

Se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar en lo suyo sin necesidad del consentimiento de otro; el no ejecutar un acto al que faculta el propio derecho nada puede envolver a favor de un extraño. El inciso segundo del art. 2499 da un ejemplo: el que durante muchos años dejó de edificar en un terreno suyo no por eso confiere a su vecino el derecho de impedirle que edifique.

Los actos de mera tolerancia no están definidos por la ley, pero puede decirse que, desde el punto de vista de quien los tolera, son aquellos que entrañan el ejercicio de un derecho, como permitirlos o no, a cuya ejecución no se opone por benevolencia; y desde el punto de vista del tercero, son los que este realiza sin intención de ejercitar un derecho propio, basándose en la condescendencia del titular del derecho ejercitado. Por ejemplo, el que tolera que el ganado de su vecino transite por sus tierras eriales o paste en ellas no por eso se impone la servidumbre de tránsito o pasto.

Puede resultar dudosa en ciertos casos la calificación de un acto como de mera facultad o tolerancia, en lugar de acto posesorio propiamente tal; es una cuestión de hecho que habrá de analizarse considerando la conducta del dueño y de su contrincante, la magnitud objetiva de tales actos, su frecuencia, exclusividad y publicidad.

S. TERCER ELEMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA: EL TRANCURSO DEL TIEMPO

Para llegar a ganar por prescripción debe poseerse durante un determinado lapso, que depende de la naturaleza de la cosa y de la clase de prescripción de que se trate. Debe tenerse presente lo ya dicho sobre la agregación de posesiones, y las normas sobre cómputo de los plazos (**arts. 48** y siguientes).

1. ADQUISICIÓN POR PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO REAL DE DOMINIO

Con base en las características de la posesión, el **art. 2506** distingue entre prescripción adquisitiva ordinaria y extraordinaria. Con posesión regular se llega al dominio por la prescripción ordinaria, que impone al prescribiente un plazo inferior al necesario si se tiene posesión irregular.

1.1. Prescripción adquisitiva ordinaria

El **art. 2507** dispone que para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular no interrumpida durante el tiempo que las leyes requieren. De conformidad al **art. 2508**, ese tiempo es de dos años para los bienes muebles y de cinco años para los bienes raíces. La Ley 16.952, de 1968, derogó la regla por la cual, si la persona contra la cual se prescribía residía en el extranjero, cada dos días se contaban por uno.

1.2. Prescripción adquisitiva extraordinaria

Basta para ella la posesión irregular, y se exige posesión por diez años (**arts. 2510 y 2511**). El lapso era primitivamente de treinta años; se abrevió a quince por la Ley 6.162 y, posteriormente, a diez, por la Ley 16.952; corre contra toda persona y no se suspende a favor de las personas enumeradas en el art. 2509 (art. 2511).

DATO DE GRADO**Texto completo del art. 2510**

"El dominio de cosas comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse: 1ª Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno. 2ª Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de la falta de un título adquisitivo de dominio. 3ª Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe, y no dará lugar a la prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias: 1ª Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos diez años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción; 2ª Que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo."

A primera vista, y de una lectura aislada de este precepto, pareciera que se aparta de todos los principios que informan al Código en materia posesoria, por cuanto admitiría adquirir por prescripción sin título alguno, que respecto del poseedor irregular se presumiría de derecho la buena fe, y que la mera tenencia puede mudar sin más en posesión. Ello impone interpretar la norma conforme a su verdadero sentido, en forma armónica con el resto del ordenamiento; siguiendo en varios aspectos a **VIAL**, resulta indispensable tener en cuenta las consideraciones que siguen.

Una primera cuestión que no puede soslayarse es que el art. 2510 regula, fundamentalmente, aspectos probatorios relativos a una controversia judicial sobre si operó o no una prescripción extraordinaria: por ello establece una presunción legal, una presunción de derecho, y dispone que se deben probar ciertos hechos, y que no se pueden probar otros, para que la prescripción opere en ciertos casos. Que el Código regule estos aspectos es armónico con la regla común de que la prescripción debe ser alegada (**art. 2493**) para ser declarada por sentencia judicial (**art. 2513**).

Es relevante, además, considerar que el art. 2510 establece reglas probatorias para una situación extraordinaria, como es que el verdadero dueño haya dejado que otro posea por diez o más años, plazo que para el Código es el periodo máximo de consolidación de las situaciones jurídicas irregulares, al punto que en ese mismo plazo se "sanea" incluso la nulidad absoluta (**art. 1683**), la sanción de ineficacia más grave de un acto jurídico.

Teniendo esto presente, resultan lógicos los términos del art. 2510 si se recuerda que la prescripción ordinaria se vincula con la posesión regular, la que conforme al **art. 702** procede de justo título y buena fe, mientras que la extraordinaria se vincula con la irregular, que conforme al **art. 708** carece de uno o más de esos requisitos. Así, en la controversia sobre prescripción ordinaria será relevante discutir y probar el título posesorio y la buena fe, pero en la extraordinaria esa discusión es irrelevante, pues basta la posesión irregular.

Así, cuando la regla 1ª señala que para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno, lo que expresa es que en el juicio no es necesario demostrar qué título posesorio justifica la pose-

sión, no que el Código permita poseer sin título. **VIAL** agrega que todo poseedor, incluso el irregular, necesita de un título posesorio, aunque sea injusto: el título no justo del que procede la posesión irregular no tiene, en estricto rigor, existencia jurídica, pues es solamente un título aparente y no verdadero, lo que justifica que la disposición señale que no se necesita título alguno, aunque siempre existe un título posesorio putativo o aparente.

Por su lado, la regla 2ª dispone que se presume de derecho la buena fe en la prescripción extraordinaria, presunción que conforme al **art. 47, inc. final** es inadmisibile de prueba contraria. En consecuencia, en un juicio sobre prescripción extraordinaria no se considerarán para ningún efecto las pruebas que demuestren la mala fe del poseedor, ya que la buena fe en la adquisición de la posesión solo tiene relevancia jurídica para la prescripción ordinaria; la presunción es, así, lógica, pues descarta una prueba inconducente.

La primera parte de la regla 3ª dispone que la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe y no dará lugar a la prescripción, lo que es concordante con el **art. 730**, conforme al cual el mero tenedor no adquiere la posesión de la cosa si la usurpa dándose por dueño de ella. Resulta obvio que si el mero tenedor no puede convertirse en poseedor, menos podrá llegar a convertirse en dueño por prescripción, que presupone la posesión: para prescribir hay que poseer, y el mero tenedor no posee.

La mayor controversia ha surgido respecto de la segunda parte de la regla 3ª, que da lugar a la prescripción aun existiendo un título de mera tenencia si concurren las dos circunstancias que señala. Resulta ineludible coordinar esta disposición con el **art. 716**, que señala que el simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesión, salvo el caso del art. 2510 regla 3ª. Si bien ciertos autores han afirmado que en este caso la mera tenencia se transformaría en posesión sin más, ello no es así.

NO CONFUNDIR

La regla 3ª no transforma al mero tenedor "en cuanto tal"

El art. 2510 no habilita al mero tenedor a prescribir en su calidad de tal, sino que permite que quien inicialmente era mero tenedor pase a ser poseedor en circunstancias especialísimas, lo que lo habilita para adquirir por prescripción. Esto se confirma con el art. 716: el mero transcurso del tiempo, por largo que sea, jamás transforma por sí solo a un mero tenedor en poseedor.

La mera tenencia se muda en posesión cuando concurren dos requisitos: que el mero tenedor deje de reconocer dominio ajeno y de tener la cosa a nombre del dueño, ejerciendo actos posesorios de aquellos a que solo da derecho el dominio; y que el dueño, en pleno conocimiento de lo anterior, manifieste con su inacción o indiferencia la intención de desprenderse de la cosa, aceptando tácitamente que el mero tenedor asuma esa calidad.

En otras palabras, el abandono de la cosa no solo hace perder la posesión al dueño, sino que pasa a ser el título posesorio en virtud del cual el mero tenedor con ánimo de dueño pasa a ser un poseedor habilitado para prescribir; no se trata de una mera tolerancia del verdadero dueño, sino de algo más, el desasimiento o abandono de la cosa. Este título posesorio, el abandono, es presumido por el legislador cuando concurren las dos circunstancias de la regla 3ª: que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos diez años se haya reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción, y que este último pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni interrupción por el mismo espacio de tiempo.

Finalmente, buena parte de la doctrina entiende que para que opere la prescripción, sea ordinaria o extraordinaria, de un inmueble inscrito, siempre resulta indispensable que el poseedor cuente a su turno con un título inscrito, por disponerlo el **art. 2505**. Los amplios términos de la norma, que no distingue, permiten concluir que es aplicable a ambas clases de prescripción, lo que corrobora su ubicación: precede al art. 2506, que distingue entre prescripción ordinaria y extraordinaria, y a los artículos siguientes que regulan una y otra, por lo que las normas que la anteceden, entre ellas el art. 2505, resultan aplicables a las dos.

1.3. Adquisición por prescripción de los otros derechos reales

Para los demás derechos reales, que es posible igualmente ganar por prescripción (**art. 2498, inc. 2º**), como la hipoteca o el usufructo, se siguen las reglas del dominio. El mismo **art. 2512** señala tres excepciones: el derecho de censo, que rige por la prescripción extraordinaria de diez años; el derecho de herencia, que puede adquirirse por la prescripción extraordinaria de diez años, o de acuerdo a los **arts. 704 y 1269**, por la ordinaria de cinco años tratándose del heredero putativo a quien por decreto judicial o resolución administrativa se haya dado la posesión efectiva, que servirá de justo título, sin perjuicio de que también debe concurrir la buena fe.

Y el derecho de servidumbre, respecto del cual el **art. 882** distingue entre las discontinuas de toda clase y las continuas inaparentes, que solo pueden adquirirse por un título, ni aun por el goce inmemorial, y las continuas y aparentes, que se adquieren por prescripción de cinco años, haya posesión regular o irregular.

Un punto útil de referir aquí, por su vinculación con el art. 2517, es que la prescripción posible respecto del derecho de herencia es la adquisitiva. Los términos del **art. 1269**, cuando expresa que la acción de petición de herencia "expira" en diez años, han conducido a algunos a hablar de prescripción extintiva, pero la precisión técnica obliga a calificar esa expresión solo como una redacción que pudo ser más clara: tratándose de un derecho real (**art. 577**), la acción participa de la vocación de eternidad del dominio y no se extingue por su no uso, sino solo cuando alguien posee la herencia hasta ganarla por prescripción adquisitiva, en aplicación del art. 2517. El tema se trata con la debida extensión en Derecho Sucesorio.

T. INTERRUPCIÓN, SUSPENSIÓN Y EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

1. CUARTO ELEMENTO: LA PRESCRIPCIÓN NO DEBE ENCONTRARSE INTERRUPTIDA

1.1. Conceptos generales

La prescripción se funda en dos hechos que deben concurrir para que opere: uno positivo, la actividad del prescribiente al ejecutar actos posesorios que revelan su ánimo de señor y dueño; y otro negativo, la inactividad del dueño, quien encontrándose en situación de advertir que otro posee, nada hace para oponerse. Antes de que el lapso se cumpla pueden acaecer circunstancias que impiden actos posesorios, o que den cuenta de que el dueño ha salido de su inacción; una y otra se denominan interrupción. Su efecto inmediato es detener la prescripción que corría y, por lo general, hacer perder el tiempo ya transcurrido. Por lo mismo, posesión no interrumpida es la que no ha sufrido ninguna interrupción, natural o civil (**art. 2501**).

1.2. Interrupción natural

Se encuentra regulada en el **art. 2502**, conforme al cual es natural cuando, sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como una heredad permanentemente inundada; y cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona.

La interrupción natural por un hecho de la naturaleza (**art. 2502 N° 1**) no produce otro efecto que el de descontarse su duración: mientras dure la imposibilidad de ejercer actos posesorios no se computa el plazo, pero cesada esta, se recomienza el cómputo, sin perderse el tiempo anterior (así, de acuerdo al **art. 653**, si la heredad inundada deja de estarlo antes de 5 años, vuelve a sus antiguos dueños, pero si la inundación permanente dura más de 5 años, al cesar no solo se pierde la posesión, sino también el dominio, que accede a los propietarios riberaños conforme a las reglas de la accesión).

Se ha discutido si esta clase de interrupción se aplica a los inmuebles inscritos: algunos opinan que no, porque la inscripción representaría por sí misma el corpus y el animus, de modo que la posesión jamás se perdería mientras subsista; otros, como **SOMARRIVA**, creen que sí se aplica, porque la norma no distingue entre inmuebles inscritos y no inscritos y su tenor exige solo que se haga imposible el ejercicio de actos posesorios materiales.

La interrupción natural por un hecho del hombre (**art. 2502 N° 2**) sí produce el efecto propio de la interrupción, esto es, hacer perder todo el tiempo de la posesión anterior. Al efecto son pertinentes el art. 726, aplicable a muebles; el art. 729, aplicable a inmuebles no inscritos; y el art. 728, inc. 2°,

aplicable a inmuebles inscritos. La ley deja, sin embargo, una salida al antiguo poseedor: si recupera legalmente la posesión, se entenderá que nunca hubo interrupción, en concordancia con la ficción del **art. 731**. Si, en cambio, recupera la cosa por vías de hecho, la interrupción producirá todos sus efectos, con el agravante de que la nueva posesión será violenta y, por ende, inútil para prescribir.

1.3. Interrupción civil

De conformidad al **art. 2503**, interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa contra el poseedor, expresión que se entiende referida a la interposición de cualquier acción, fundamentalmente la reivindicatoria. Los tribunales han precisado que se trata del ejercicio de una acción y no de una gestión no contenciosa; que ninguna demanda interrumpe si se intenta después de cumplido el plazo; que si los demandados son varios debe notificarse a todos; y que interrumpe incluso la demanda intentada ante tribunal incompetente.

Se ha discutido si para interrumpir basta presentar la demanda dentro del plazo, o si también debe notificarse dentro de él. Una primera postura exige que la notificación se practique dentro del plazo, apoyándose en que las resoluciones judiciales solo producen efecto una vez notificadas. Otra postura sostiene que basta con que el recurso judicial se haya "intentado" dentro del plazo, idea que reafirmaría la exigencia paralela de "demanda judicial" para la interrupción de la prescripción extintiva (**art. 2518**), pues exigir también la notificación dejaría en desigualdad a quien deba interrumpir contra un demandado de difícil ubicación.

JURISPRUDENCIA

CORTE SUPREMA, 31 DE MAYO DE 2016, ROL N° 6900-2015

Los tribunales, y sobre todo la Corte Suprema, se habían inclinado decididamente por exigir que la notificación se produjera antes de vencer el plazo. Sin embargo, en este fallo la cuarta sala sostuvo que "es tiempo de cambiar el criterio" y decidió que basta que la demanda haya sido presentada dentro del plazo de prescripción para que se entienda interrumpida, aunque haya sido notificada con posterioridad. El caso versaba sobre una reivindicación contra un poseedor que había regularizado un inmueble conforme al D.L. N° 2.695, cuyo art. 15 exige un año de posesión inscrita no interrumpida; la demanda se presentó a tiempo pero se notificó tres días después de vencido ese plazo.

La Corte distinguió entre los efectos procesales y los efectos sustantivos de la notificación, concluyendo que "la mera presentación de la demanda interrumpe la prescripción, siendo la notificación de la misma una condición para alegarla, debiendo circunscribir su efecto al ámbito procesal, pero no como un elemento constitutivo de la interrupción de la prescripción".

El **art. 2503, inc. 2°** dispone que solo el que ha intentado el recurso judicial puede alegar la interrupción, y ni aun él en ciertos casos: si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma le-

gal, si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia, o si el demandado obtuvo sentencia de absolución; en estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción.

Según lo dicho, por la interrupción se pierde todo el tiempo que se llevaba poseyendo, salvo la excepción del art. 2502 N° 1 y la posibilidad de recuperar legalmente la posesión del art. 2502 N° 2. Debe tenerse presente además la regla especial del **art. 2504**: si la propiedad pertenece en común a varias personas, todo lo que interrumpe la prescripción respecto de una de ellas la interrumpe también respecto de las otras. La interrupción tiene vigencia tanto para la prescripción ordinaria como para la extraordinaria, lo que comprueba la ubicación de estas reglas, antes de la distinción entre ambas enunciada en el **art. 2506**, y el que la regla 3ª del art. 2510 exija, precisamente, posesión sin interrupción.

2. QUINTO ELEMENTO: LA PRESCRIPCIÓN NO DEBE ENCONTRARSE SUSPENDIDA

2.1. Concepto y fundamento

La suspensión es un beneficio que la ley establece a favor de determinadas personas y de la herencia yacente, consistente en la detención del cómputo del plazo para ganarles una cosa por prescripción. Su fundamento está en que no todos los dueños se encuentran en condiciones de reaccionar oportunamente cuando otra persona los priva de la posesión, presumiendo la ley que en esa situación se encuentran los incapaces, tengan o no representante legal diligente. La razón de ser de la suspensión es, así, la injusticia que supondría dejar correr la prescripción contra quienes están imposibilitados de defender por sí mismos sus derechos.

2.2. Aspectos generales

La suspensión se encuentra regulada en el **art. 2509**, que permite formular varios comentarios. La suspensión se aplica solo a la prescripción ordinaria, que supone posesión regular; el **art. 2511** señala que la extraordinaria corre contra toda persona y no se suspende a favor de las enumeradas en el art. 2509. No opera solamente en beneficio de "personas", pues se establece también a favor de la herencia yacente, que no tiene esa calidad. Tampoco todas las personas beneficiadas son incapaces, pues no lo es la mujer casada en sociedad conyugal. Su efecto es que, en contra de quienes aparecen mencionados en la disposición, no corre la prescripción ordinaria.

2.3. Causales de suspensión

El art. 2509 enumera las causales de suspensión de la prescripción ordinaria: los menores, los dementes, los sordos o sordomudos que no puedan darse a entender claramente y, en general, todos los que estén bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría, sin que importe que el menor esté

emancipado ni que se exija declaración de interdicción para dementes y sordomudos; la mujer casada en sociedad conyugal, mientras dure esta, pues aunque plenamente capaz no administra sus bienes propios, que administra el marido; y la herencia yacente, que no tiene la calidad de persona (**art. 2346**) pero es la denominación que reciben los bienes de un difunto cuya herencia no ha sido aceptada y a los que el juez designa un curador, beneficiándose en último término el heredero que acepta.

2.4. Suspensión entre cónyuges

El **art. 2509, inc. final** dispone que la prescripción se suspende siempre entre cónyuges. El mantenimiento de la armonía matrimonial y el evitar donaciones irrevocables encubiertas entre ellos explican esta regla.

Es clásica la polémica sobre si esta suspensión opera solo en la prescripción ordinaria o también en la extraordinaria. A favor de restringirla a la ordinaria se invoca su ubicación en el Código, tratando esa clase de prescripción, y que la expresión "enumeradas" del art. 2511 comprendería a todas las mencionadas en el art. 2509. A favor de extenderla a ambas se invoca que las razones de la suspensión se presentan en las dos situaciones, y que la expresión "siempre" del art. 2509 se refiere precisamente a que rige sea ordinaria o extraordinaria la prescripción. Esta última alternativa, sustentada en la razón de fondo de la institución matrimonial, parece ser la mayormente seguida.

3. PRESCRIPCIÓN CONTRA TÍTULO INSCRITO

El tema está regulado en el **art. 2505**: contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en estos, sino en virtud de otro título inscrito, ni empezará a correr sino desde la inscripción del segundo. Esta disposición da lugar a dos problemas ya examinados: si el título inscrito del prescribiente debe estar vinculado al del poseedor inscrito anterior, cuestión que se analizó al tratar la cancelación de la posesión inscrita y la "competente inscripción" de los **arts. 728 y 730**; y si el precepto se aplica a toda prescripción o solo a la ordinaria, cuestión que depende de la posición que se adopte sobre la posibilidad de adquirir posesión irregular de inmuebles inscritos sin inscripción.

En ambos problemas vale, una vez más, la posición básica que se adopte, ya en favor de la inscripción registral, ya de la posesión material. Los tribunales se inclinan mayormente por proteger la inscripción, de modo que resulta difícil lograr prescripción contra un título inscrito, aunque frecuentemente restan mérito a las inscripciones "de papel" que no exhiben un antecedente de posesión material. Cabe recordar que, por la legislación de saneamiento de títulos, el D.L. 2.695, es posible inscribir inmuebles antes inscritos, con consecuencias muy controvertidas.

El D.L. N° 2.695, de 1979, sobre regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, altera frontalmente el sistema de la posesión inscrita del Código: su **art. 2** permite solicitar la regularización al poseedor material sin título inscrito que acredite posesión continua, exclusiva, sin violencia

ni clandestinidad, por cinco años a lo menos, advirtiendo expresamente que no será obstáculo para ejercer este derecho la circunstancia de que existan inscripciones de dominio anteriores sobre el mismo inmueble.

Esta regla colisiona de manera directa con el **art. 2505** del Código, que exige un título inscrito para prescribir contra otro título inscrito, y con el **art. 924**, que hace de la inscripción prueba exclusiva de la posesión mientras dure un año completo; por esta razón, un sector de la doctrina ha criticado el decreto ley como un retroceso en la protección jurídica de los inmuebles y en la certeza que la inscripción brinda a los terceros, y la jurisprudencia llegó incluso a declararlo contrario a la Constitución, aunque en años recientes ha tendido a aceptar su constitucionalidad.

4. LA ADQUISICIÓN DEL DOMINIO POR LA PRESCRIPCIÓN

Por la prescripción adquisitiva se adquiere el dominio y otros derechos reales. Esta adquisición opera, no desde que se cumple el plazo necesario, sino retroactivamente, desde que se inició la posesión, de ahí preceptos como el **art. 1736**. La doctrina da distintos fundamentos a esta retroactividad, como la presunción de que el anterior propietario abdicó de su dominio antes de iniciarse la posesión, o la protección de terceros que ya contrataban con el poseedor teniéndolo por dueño.

Varias consecuencias origina esta retroactividad: el poseedor queda dueño de los frutos producidos durante la posesión, aunque haya estado de mala fe; quedan firmes los gravámenes o cargas que haya constituido en ese tiempo; y le son, en cambio, inoponibles los que haya constituido el propietario en la misma época, aunque en la práctica es difícil que se den relaciones jurídicas entre el dueño y terceros mientras exista un poseedor de la cosa.

5. EFECTO LIBERATORIO DE LA PRESCRIPCIÓN

La prescripción adquisitiva lleva consigo un efecto extintivo respecto del derecho del dueño contra el que se ganó por prescripción, de ahí los **arts. 2517 y 1815**.

Se ha planteado también que provoca un efecto extintivo de las cargas o derechos reales constituidos sobre la cosa por el anterior dueño antes de entrar a poseerla el que ahora la adquirió: al poseer la cosa se poseían también esos derechos reales, de modo que al adquirirla se adquirieron y, simultáneamente, se extinguieron por confundirse con el dominio en un solo titular, pues los derechos reales limitados solo se conciben en cosa ajena. A este efecto suele llamársele "usucapión liberatoria", denominación que parece preferible reemplazar por la de "efecto liberatorio de la usucapión".

El D.L. 2.695, sobre saneamiento de títulos de la pequeña propiedad raíz, contiene una regla que evoca este efecto: transcurridos dos años desde la inscripción que otorga al poseedor material regularizado (**art. 15**, plazo aumentado de uno a dos años por la Ley N° 21.108 de 2018), prescriben las acciones emanadas de los derechos reales de dominio y demás derechos reales limitados relati-

vos al inmueble, y las inscripciones anteriores que lo afectaban se entienden canceladas por el solo ministerio de la ley (**art. 16**).

6. LA FUNCIÓN DE LA SENTENCIA EN MATERIA DE PRESCRIPCIÓN

Se atribuye a la sentencia que declara la prescripción adquisitiva la calidad de requisito de eficacia, sobre todo por lo dispuesto en el **art. 2513**: la sentencia judicial que declara una prescripción hará las veces de escritura pública para la propiedad de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos, pero no valdrá contra terceros sin la competente inscripción. En contrario se ha sostenido que basta con que se cumplan las exigencias legales para que la prescripción produzca sus efectos, y que si después se celebran actos de dueño, serán eficaces; pero puede replicarse que esa eficacia la tendrán siempre que, de objetarse, un fallo posterior declare la prescripción, operando retroactivamente y justificando la validez de esos actos, y quedando sin efecto si el fallo es adverso.

La sentencia debe inscribirse (**arts. 689 y 2513**, y art. 52 N° 1 del Reglamento). Como el modo de adquirir es la prescripción, esta inscripción no constituye tradición; se establece solo para mantener la historia de la propiedad inmueble y como medida de publicidad.

U. LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE COMO MODO DE ADQUIRIR

El estudio acabado de la sucesión por causa de muerte corresponde al curso de Derecho Sucesorio. En Bienes se analizan solo los principales aspectos de la materia en lo que toca a su calidad de modo de adquirir el dominio.

1. IDEAS GENERALES

En Derecho, la expresión sucesión designa la transmisión de todo o parte del patrimonio de una persona fallecida a una o más personas vivas, señaladas por el difunto o la ley. Su justificación está en que, de extinguirse con la muerte del titular las relaciones jurídicas que afectan su patrimonio, se crearían fuertes perturbaciones en el tráfico jurídico. La sucesión por causa de muerte se constituye así en una verdadera subrogación personal, en cuya virtud los herederos pasan a ocupar la misma posición que el causante.

Es uno de los modos de adquirir el dominio que señala el **art. 588**, y considerando lo dispuesto en el **art. 951**, puede decirse que es un modo de adquirir el dominio del patrimonio de una persona difunta, o de una cuota de él, o de especies o cuerpos ciertos o cosas indeterminadas de un género determinado. Es un modo de adquirir derivativo, porque el derecho del sucesor emana del que tenía su antecesor, de manera que si el causante no era dueño, el sucesor no adquiere el dominio, sino solo los derechos transmisibles que aquel tenía; gratuito, porque el asignatario no realiza ningún sacrificio económico, sin perjuicio de la obligación de solventar las deudas hereditarias; por causa de muerte, porque es el fallecimiento el hecho que trae consigo la transmisión; y tanto a título universal como a título singular (**arts. 951, 1907 y 1104**).

La sucesión por causa de muerte sirve para adquirir tanto derechos reales como personales, salvo los que la ley declara intransmisibles por su carácter personalísimo, como el usufructo (**art. 773, inc. 2º**), el uso y la habitación (**art. 819**), las expectativas del fideicomisario o del asignatario condicional que fallecen antes de la restitución o pendiente la condición, el derecho de alimentos (**art. 334**) y el mandato (**art. 2163 N° 5**), entre otros; de modo semejante, tampoco se transmiten ciertas obligaciones que suponen aptitudes especiales del deudor.

Como modo derivativo, la sucesión requiere de un título: el testamento o la ley. Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si en virtud de la ley, intestada o abintestato (**art. 952**), pudiendo la sucesión de una persona ser parte testamentaria y parte intestada. Las disposiciones de bienes que hace el testador o la ley reciben la denominación genérica de asignaciones (**art. 953**), y la sucesión puede ser a título universal, cuando comprende la totalidad de los bienes del difunto o una cuota de ellos, o a título singular, cuando comprende bienes determinados; las asignaciones a título universal se llaman herencias, y las a título singular, legados (**art. 954**). El asignatario de herencia se denomina heredero, y el de legado, legatario; las asigna-

ciones que hace la ley son siempre a título universal, de modo que no existen legatarios abintestato.

NO CONFUNDIR

Herederos versus legatarios

Difieren en el objeto de la asignación (universalidad versus especies o géneros determinados); el heredero representa al causante y sus patrimonios se confunden, salvo beneficio de inventario o separación, lo que no ocurre con el legatario; el heredero responde de las deudas hereditarias incluso ultra vires hereditatis, mientras el legatario solo responde excepcionalmente y hasta el monto del legado; el heredero adquiere el dominio desde el fallecimiento del causante, mientras el legatario de especie lo adquiere en el mismo momento, pero el de género solo adquiere entonces un crédito; el heredero adquiere junto con el dominio la posesión legal de la herencia (**arts. 688 y 722**), mientras el legatario, aunque sea de especie, no adquiere la posesión de la cosa legada sino con su entrega; y la posesión efectiva es típica del heredero, no del legatario.

2. APERTURA DE LA SUCESIÓN Y DELACIÓN DE LAS ASIGNACIONES

La adquisición de una asignación no se produce en un solo instante, sino que importa un proceso que empieza con la apertura de la sucesión, continúa con la delación de la asignación y culmina con su aceptación, o se frustra con la repudiación. La apertura de la sucesión es el hecho jurídico, consecuencial de la muerte de una persona, en cuya virtud los bienes del difunto pasan a sus sucesores, y se abre con la muerte natural o con la muerte presunta. El problema de los comurientes, quienes fallecen conjuntamente sin poder determinarse quién murió primero, está resuelto expresamente: se entiende que ambos murieron al mismo tiempo, y por ende ninguno sucede al otro (**arts. 79 y 958**). El **art. 955** dispone que la sucesión se abre al momento de la muerte.

Abierta la sucesión tiene lugar, regularmente, la delación, que el **art. 956, inc. 1º** define como el actual llamamiento de la ley a aceptar o repudiar la asignación, naciendo así un derecho potestativo de opción, el *jus delationis*, que forma parte del patrimonio del llamado y puede transmitirse. Por regla general, la delación coincide con la apertura de la sucesión, ambas al momento de la muerte del causante; pero si la asignación es condicional, se defiere en el momento de cumplirse la condición (**art. 956, inc. 2º**), salvo que se trate de una condición suspensiva negativa y meramente potestativa del asignatario, esto es, de no hacer algo que dependa de su sola voluntad, caso en el cual la asignación se defiere igualmente desde la muerte del causante, debiendo el asignatario rendir caución de restituir si la condición se contraviene (**art. 956, inc. 3º**).

3. EL DERECHO DE HERENCIA

Desde un punto de vista objetivo, la herencia es todo el patrimonio del difunto, una universalidad jurídica que comprende derechos y deudas. Desde un punto de vista subjetivo, es un derecho real que consiste en la facultad o aptitud de una persona para suceder en el patrimonio del causante o en una cuota de él.

Su calidad de derecho real distinto del dominio no es dudosa en la legislación chilena, porque el Código lo menciona expresamente (**art. 577**); es un derecho absoluto que genera la acción de petición de herencia, oponible a cualquier poseedor de la herencia. No debe confundirse el dominio sobre los bienes que la componen con el derecho de herencia, que tiene por objeto la universalidad y no los bienes que la forman; y por lo mismo, el derecho de herencia tiene una vida transitoria, pues una vez practicadas las adjudicaciones de la partición, pasa a confundirse con el derecho de dominio.

Existe controversia en la doctrina nacional sobre si el Código siguió, para la adquisición de la herencia, el sistema romano, en que el heredero la adquiere por su aceptación, o el germánico, en que la adquisición se produce de pleno derecho y la aceptación solo consolida esa adquisición ya verificada. A favor del sistema romano se invoca que fue el escogido por el Código francés que sirvió de modelo; a favor del germánico, que los **arts. 688 y 722** confieren a los herederos la posesión legal de la herencia por el solo ministerio de la ley, que el **art. 1233** entiende repudiada la asignación del asignatario en mora de pronunciarse, que el **art. 1239** da efecto retroactivo a la aceptación o repudiación hasta el momento de la delación, que el **art. 1240** reconoce la herencia yacente, y que el **art. 957** consagra el derecho de transmisión.

En cuanto a la posesión de la herencia, es menester distinguir tres clases. La posesión legal es la que el heredero adquiere por el solo ministerio de la ley desde el momento en que la herencia le es deferida, aunque lo ignore; el que válidamente la repudia se entiende no haberla poseído jamás (**art. 722**). Es una posesión singularísima, porque el legislador presume en ella la concurrencia de corpus y animus, aunque el heredero, ignorando la delación, pueda carecer de ambos. La posesión real o material, en cambio, exige efectivamente corpus y animus conforme al art. 700, y puede radicarse tanto en el verdadero heredero como en un falso heredero que se comporte como tal, siendo esta posesión la que habilita para adquirir la herencia por prescripción.

La posesión efectiva, por último, es una institución procesal propia del Derecho chileno: aquella que se otorga por resolución judicial, si la sucesión es testada, o por resolución de la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, si es intestada, conforme a la Ley 19.903, y que sirve para conservar la historia de la propiedad raíz, dar origen a una prescripción más breve de la herencia, y determinar tributariamente a los herederos.

El derecho de herencia puede adquirirse, además de por la sucesión misma, por tradición y por prescripción, materias ya examinadas al tratar esos modos de adquirir. Basta recordar que la tradición del derecho de herencia presupone el fallecimiento del causante, pues el derecho de suceder a una persona viva es intransmisible y los pactos sobre sucesión futura adolecen de nulidad absoluta

por ilicitud del objeto (**art. 1463**); y que, al recaer sobre una universalidad jurídica y no sobre bienes determinados, no requiere inscripción aunque existan inmuebles entre los bienes hereditarios, bastando las reglas de tradición de los muebles; y que, tratándose de la prescripción, la regla general es de diez años (**art. 2512, N° 1**), reducida a cinco para el heredero putativo a quien se ha concedido la posesión efectiva, que le sirve de justo título (**art. 1269**).

V. LA PROPIEDAD FIDUCIARIA

El más completo de los derechos reales es el dominio, pues comprende las facultades de usar, gozar y disponer. Hay derechos reales menos completos, limitados en relación a aquel: el dominio se encuentra limitado cada vez que le falte alguna de sus características esenciales, o cuando se constituye sobre una cosa un derecho real a favor de una persona que no es el dueño. Estas limitaciones pueden ser legales o voluntarias, y el **art. 732** alude a los modos en que puede ser limitado el dominio. Se habla de derechos reales limitados por dos razones: porque limitan el dominio, y porque, considerados en sí mismos, confieren sobre la cosa facultades más reducidas que las del dominio. Son derechos reales limitados, según se desprende del art. 732, la propiedad fiduciaria, el usufructo, el uso o la habitación y las servidumbres.

1. DEFINICIÓN Y ORIGEN

El **art. 733** dispone que se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta al gravamen de pasar a otra persona por el hecho de verificarse una condición. La misma disposición fija la terminología: la constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso, nombre que se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria, y la traslación de la propiedad a la persona en cuyo favor se ha constituido se llama restitución.

La institución nace en el Derecho romano, como consecuencia de que los peregrinos no podían suceder por causa de muerte a un ciudadano romano, quien, si quería dejarles sus bienes, se los dejaba a otro ciudadano, el fiduciario, para que este se los entregara al peregrino, el fideicomisario. En la Edad Media se utilizó para la conservación de las fortunas, mediante fideicomisos perpetuos y sucesivos. Los postulados liberales de fines del siglo XVIII modificaron su orientación para impedir que entrabara la libre circulación de la riqueza, y **BELLO** recogió esta tendencia: pasado cierto plazo la condición se reputa fallida (**art. 739**, cinco años); se prohíben los fideicomisos sucesivos (**art. 745**); y se prohíben los mayorazgos, vinculaciones o fideicomisos perpetuos (**art. 747**, a contrario sensu).

NO CONFUNDIR

Fideicomiso y usufructo son ambos derechos reales limitados que desmiembran el dominio, pero se distinguen en lo esencial. En el fideicomiso la incertidumbre recae sobre si habrá restitución: mientras la condición esté pendiente, el fiduciario puede llegar a consolidar el dominio si ella falla. En el usufructo, en cambio, no hay incertidumbre sobre la restitución, que necesariamente ocurrirá; lo único incierto puede ser cuándo, si el plazo se fija por la vida del usufructuario. Además, el fiduciario tiene la facultad de disposición sobre la cosa (salvo pacto en contrario), mientras que el usufructuario carece de ella y solo tiene uso y goce.

2. CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO

La constitución del fideicomiso es solemne: si se constituye por acto entre vivos requiere instrumento público, y si por testamento, queda incluido en la solemnidad del acto testamentario (**art. 735, inc. 1º**). Además, todo fideicomiso que afecte inmuebles debe inscribirse en el competente registro, el de hipotecas y gravámenes (**art. 735** del Código y art. 52 N° 2 del Reglamento).

El rol de esta inscripción es discutido. Cuando se constituye por testamento, la inscripción no es tradición, porque el modo de adquirir es la sucesión por causa de muerte; para algunos es solemnidad de la constitución, y para otros solo tiene por finalidad mantener la continuidad de las inscripciones y dar publicidad a las mutaciones de dominio.

Cuando se constituye por acto entre vivos, la inscripción cumple el rol de tradición de la propiedad fiduciaria; para algunos es este su único papel, mientras que para otros es, además, solemnidad del acto constitutivo, de modo que mientras no se inscriba no podría exigirse el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto, como la entrega del inmueble. La posibilidad de adquirir la propiedad fiduciaria por prescripción es igualmente discutida: se rechaza por algunos, porque la prescripción no se menciona entre las formas de constitución del art. 735, y se acepta por otros, apoyados en que los **arts. 2498 y 2512** no la excluyen.

3. ELEMENTOS

La propiedad fiduciaria requiere de tres elementos: una cosa susceptible de darse en fideicomiso, la concurrencia de tres personas (constituyente, propietario fiduciario y fideicomisario), y la existencia de una condición en virtud de la cual ha de pasar la propiedad del fiduciario al fideicomisario.

3.1. Una cosa susceptible de darse en fideicomiso

El **art. 734** es amplio y permite constituir el fideicomiso tanto sobre muebles como sobre inmuebles. Como el fiduciario debe restituir la cosa misma, quedan excluidos los bienes consumibles; pero si el fideicomiso se constituye sobre una herencia o una cuota de ella, no hay inconveniente en que algunas de las cosas que la integran sean consumibles.

3.2. Concurrencia de tres personas

El constituyente es el propietario del bien que, por testamento o por acto entre vivos, declara transferirlo a otro bajo una condición, elemento de la esencia del fideicomiso. El propietario fiduciario es quien recibe el bien, sujeto al gravamen de traspasarlo si se verifica la condición; puede haber varios, de llamado simultáneo o como sustitutos (**art. 742**). Si el constituyente no lo designó, gozará fiduciariamente de la propiedad el mismo constituyente, si viviere, o sus herederos (**art. 748**); y

si el propietario fiduciario falta después de deferido el fideicomiso, la propiedad fiduciaria se transmite a sus herederos, con el gravamen de restituir (**art. 751**).

El fideicomisario es quien tiene la expectativa de ser dueño absoluto del bien si se cumple la condición, un acreedor condicional bajo condición suspensiva. No es necesario que exista al tiempo de constituirse el fideicomiso, bastando que se espere que exista (**art. 737**), pero se requiere que exista al momento de la restitución, condición que siempre se entiende incorporada al fideicomiso (**art. 738**). Pueden nombrarse varios fideicomisarios, simultáneos o sustitutos, sin perjuicio de la prohibición de los fideicomisos sucesivos, que entraban la libre circulación de la riqueza. Si el fideicomisario falta antes de cumplirse la condición y no hay sustituto, se consolida la propiedad en el fiduciario, sin que aquel transmita nada a sus herederos (**art. 762**); si falta después de cumplida la condición pero antes de la tradición, transmite a sus herederos su derecho a exigir la entrega.

3.3. Existencia de una condición

Es el elemento característico de la institución (**arts. 733 y 738**): la incertidumbre de si el fiduciario restituirá o no la cosa al fideicomisario es lo que distingue al fideicomiso del usufructo, en el que el goce del usufructuario tiene necesariamente un fin. La condición es resolutoria para el fiduciario y suspensiva para el fideicomisario: de cumplirse, se resuelve el derecho de aquel y nace el de este; de fallar, se consolida el dominio en el fiduciario. En cuanto al tiempo, el **art. 739** fija un máximo de cinco años de pendencia, transcurridos los cuales la condición se entiende fallida de pleno derecho, prevaleciendo esta norma especial sobre el art. 962; se exceptúa la muerte del fiduciario, que siendo un plazo cierto e indeterminado, se convierte en condición al exigirse que a esa época exista el fideicomisario.

4. EFECTOS DEL FIDEICOMISO

4.1. Derechos y obligaciones del fiduciario

El fiduciario es un propietario sujeto a la posibilidad de restituir, y en tal calidad tiene sobre la cosa una serie de derechos: enajenarla por acto entre vivos y transmitirla por causa de muerte, manteniéndose siempre indivisa y con el gravamen de eventual restitución, salvo que el constituyente haya prohibido la enajenación (**art. 751, inc. 2º**), y sin perjuicio de que si la restitución está fijada para el día de la muerte del fiduciario, el adquirente de una enajenación en vida deberá igualmente restituir al fideicomisario; gravar la propiedad con hipoteca, servidumbre u otras cargas, cumpliendo los requisitos del **art. 757** para que sean oponibles al fideicomisario; administrar el bien, respondiendo de culpa leve, premunido de la acción reivindicatoria (**art. 893**) y con el bien inembargable (**art. 1618 N° 8**), aunque no sus frutos; y gozar de los frutos de la propiedad fiduciaria.

Como contrapartida, se le imponen las cargas del usufructuario, con modificaciones (**art. 754**): debe confeccionar inventario solemne, sin estar obligado a rendir caución salvo que las personas

indicadas en el art. 761 lo exijan y el juez acceda (**art. 755**); y debe conservar la cosa para restituirla, respondiendo de culpa leve, con derecho de retención y a que se le abonen las mejoras según las reglas del usufructo.

Cumplida la condición, debe restituir al fideicomisario mediante la tradición de la cosa. Hacen excepción a estas obligaciones el llamado tenedor fiduciario, que solo tiene las facultades de los curadores de bienes cuando se reservan los frutos para quien adquiera la propiedad absoluta (**art. 749**); la posibilidad de liberar al fiduciario de responsabilidad por deterioros si se le concede gozar de la propiedad a su arbitrio; y el llamado fideicomiso de residuo, en que si además se le concede la libre disposición, el fideicomisario solo tendrá derecho a lo que exista al tiempo de la restitución (**art. 760**).

4.2. Derechos y obligaciones del fideicomisario

Con la constitución del fideicomiso, el fideicomisario adquiere la simple expectativa de llegar a obtener la cosa (**art. 761**), de la que derivan sus derechos: solicitar medidas conservativas, incluida caución de conservación y restitución; transferir su expectativa, por ejemplo venderla (**art. 1813**); solicitar indemnización al fiduciario por los perjuicios derivados de su hecho o culpa; y, cumplida la condición, exigir la entrega. Si la condición se cumple, puede verse obligado a reembolsar al fiduciario las mejoras de su cargo y a reintegrarle los pagos que hubiere hecho por deudas y cargas hereditarias y testamentarias que pesaban sobre la cosa, materia regulada por el **art. 1372**.

5. EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO

Las causales de extinción están indicadas en el **art. 763**:

- a) Por la restitución, cuando cumplida la condición se extingue el dominio del fiduciario y nace el del fideicomisario.
- b) Por la resolución del derecho del constituyente, pues resuelto el derecho del causante se resuelve también el del causahabiente.
- c) Por la destrucción total de la cosa (**art. 807**); si la destrucción es solo parcial, el fideicomiso subsiste sobre el resto.
- d) Por renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución, sin perjuicio de los derechos de los sustitutos.
- e) Por fallar la condición o no cumplirse en tiempo hábil, esto es, dentro de cinco años, incluyendo el fallecimiento del fideicomisario antes de cumplida la condición; en este caso se consolida el dominio en el fiduciario.
- f) Por confundirse la calidad de único fiduciario con la de único fideicomisario.

W. EL USUFRUCTO, EL USO Y LA HABITACIÓN

Junto con la propiedad fiduciaria, el usufructo es el segundo gran derecho real de goce sobre cosa ajena que limita el dominio (**art. 732**). El derecho de uso y el de habitación, por su parte, se rigen en lo fundamental por las reglas del usufructo, con las particularidades que se estudian al final de este eje.

1. CONCEPTO

El **art. 764** define el usufructo como el derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y substancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si la cosa es fungible.

Pese al tenor literal, un sector de la doctrina sostiene que el Código emplea aquí "fungible" en el sentido de consumible, siguiendo la concepción romana: hay usufructo propiamente tal si la cosa es no consumible, y cuasiusufructo si es consumible.

2. CARACTERÍSTICAS

2.1. Es un derecho real

Está enumerado en el **art. 577**, y le da contenido, de uso y goce, el **art. 764**. Es un derecho real de goce, a diferencia de los llamados derechos reales de garantía, como la hipoteca y la prenda. Siendo propietario de su derecho (**art. 583**), el titular está premunido, para protegerlo, de la acción reivindicatoria y, si recae sobre inmuebles, de las acciones posesorias que correspondan. Es además un derecho real principal, a diferencia de la prenda y la hipoteca, que son accesorios y sirven para asegurar el cumplimiento de una obligación principal.

En el usufructo coexisten dos derechos reales: el del nudo propietario, titular del dominio, y el del usufructuario, titular del uso y goce. En esto se distingue del fideicomiso, en que solo existe un derecho, radicado primero en el fiduciario y luego en el fideicomisario. El derecho real de usufructo puede ser mueble o inmueble, según lo sea el bien sobre que recae (**art. 580**).

2.2. Es un derecho real sobre cosa ajena

El **art. 732** señala que el dominio puede limitarse "por el gravamen de un usufructo": se trata de una limitación al dominio, que impide a su titular el ejercicio del uso y el goce. Ambos derechos coexisten, pero el dominio queda reducido a la facultad de disposición (**art. 765**).

2.3. Confiere la mera tenencia de la cosa fructuaria

El usufructuario es mero tenedor de la cosa fructuaria, pues reconoce dominio ajeno (**art. 714**), aunque es propietario de su derecho de usufructo (**art. 583**).

2.4. Es temporal

El usufructo tiene una duración limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad. Su duración la fija generalmente un plazo, aunque también puede fijarse mediante una condición, y en todo caso dura, a lo más, por toda la vida del usufructuario (**arts. 765, 770, 771 y 804**).

2.5. Es intransmisible por causa de muerte

El **art. 773** dispone que el usufructo es intransmisible por testamento o abintestato. Es, sin embargo, negociable por acto entre vivos, salvo que el constituyente lo prohíba.

2.6. En principio, es divisible

La división puede concebirse referida a partes de la cosa o a partes de su utilidad, aunque en definitiva la divisibilidad queda determinada por la naturaleza de cada cosa y la utilidad que provea.

3. ELEMENTOS

3.1. Bien susceptible de usufructo

El Código no ha establecido normas restrictivas al respecto, de manera que se admite una amplia posibilidad de constituir usufructo: sobre una universalidad, como la herencia, o una cuota de ella; sobre una especie o cuerpo cierto o una cuota de él; sobre bienes muebles e inmuebles, fungibles o no fungibles; y sobre derechos personales.

Usufructo y cuasiusufructo

Al definir el usufructo, el Código permite al usufructuario restituir, según la naturaleza de la cosa fructuaria, la misma cosa o igual cantidad y calidad del mismo género, o su valor. Sin nombrarlas, contempla así las figuras del usufructo propiamente tal, en el primer caso, y del cuasiusufructo, en el segundo. Las diferencias entre ambas son las siguientes.

a) El usufructo es un título de mera tenencia, pues el usufructuario reconoce dominio ajeno (**art. 714**); el cuasiusufructo, en cambio, es un título traslativo de dominio, y el cuasiusufructuario se hace dueño del bien que recibe (**art. 789**).

b) Llegada la época de la restitución, el nudo propietario dispone de la acción reivindicatoria para obtener la cosa dada en usufructo; en el cuasiusufructo, en cambio, quien tiene derecho a la restitución solo cuenta con un crédito, es decir, una acción personal contra el cuasiusufructuario, para exigir la entrega de la cantidad debida o de su valor.

c) El usufructuario es deudor de especie o cuerpo cierto, y el cuasiusufructuario es deudor de género. Si la cosa se pierde o destruye por caso fortuito, los riesgos los soporta el nudo propietario en el usufructo, pues las cosas perecen para su dueño; y siempre el cuasiusufructuario en el cuasiusufructo, pues el género no perece.

NO CONFUNDIR

El usufructo es título de mera tenencia y recae sobre cosa no fungible: el usufructuario debe restituir la misma cosa. El cuasiusufructo es título traslativo de dominio y recae sobre cosa fungible, es decir, consumible: el cuasiusufructuario se hace dueño y solo debe restituir otro tanto del mismo género, o su valor. Por eso el propietario originario conserva, en el usufructo, la acción reivindicatoria; y solo un crédito, en el cuasiusufructo.

Cuasiusufructo y mutuo

Conviene también comparar el cuasiusufructo con el mutuo, figuras similares pero no idénticas: en ambas se entregan especies con cargo de restituir otras tantas de igual cantidad y calidad, y ambas son títulos traslativos de dominio. Se diferencian, sin embargo, en que el cuasiusufructo puede tener su origen en la ley, lo que nunca ocurre con el mutuo, siempre contractual; en que el mutuo es un contrato real, mientras el cuasiusufructo constituido por acto entre vivos es consensual; en que la caución y el inventario se exigen en el cuasiusufructo y no en el mutuo; y en que ambas figuras tienen distintas causales de extinción.

3.2. Concurrencia de tres sujetos

Intervienen en el usufructo tres categorías de sujetos.

a) Constituyente: quien crea el derecho de usufructo, sea porque se despoja solo del uso y goce conservando la nuda propiedad, sea porque enajena o transmite el usufructo a una persona y la nuda propiedad a otra.

b) Nudo propietario: quien tiene la propiedad de la cosa fructuaria, despojada del uso y goce. Puede ser el mismo constituyente, que conserva la propiedad nuda, o un tercero a quien se le atribuye.

c) Usufructuario: el titular del derecho real de usufructo.

No hay inconveniente para que exista pluralidad en cada categoría: el constituyente pueden ser dos o más copropietarios, la nuda propiedad puede atribuirse a dos o más personas en común, y puede

haber dos o más usufructuarios (**art. 772**). En este último caso, todos deben ser llamados simultáneamente o como sustitutos, pues al igual que en el fideicomiso y por la misma razón, el principio de la libre circulación de la riqueza, están prohibidos los usufructos sucesivos o alternativos (**art. 769**).

Los sucesivos consisten en el traspaso del derecho de un usufructuario a otro al cabo de un tiempo, y luego a otro, sucesivamente; el alternativo consiste en la adquisición del derecho por un usufructuario que lo traspasa a otro al cabo de un tiempo, volviendo al primero al final del plazo de este, y así de manera alterna e infinita. Si de hecho se constituyeren, el **art. 769** dispone que los usufructuarios posteriores se considerarán sustitutos para el caso de faltar los anteriores antes de deferirse el primer usufructo, y que el primer usufructo que tenga efecto hará caducar los otros, sin durar sino por el tiempo que le estuviere designado.

Entre el usufructuario y el nudo propietario no existe comunidad, pues aunque los derechos de ambos recaen sobre el mismo objeto, son de distinta naturaleza.

3.3. El plazo

El usufructo tiene una duración limitada, al cabo de la cual pasa al nudo propietario y se consolida con la propiedad (**art. 765**, inc. 2º). Genera cierta confusión que el Código permita también establecer una condición de cuyo evento dependa la extinción del usufructo; los **arts. 770, 771, 773 y 804** han de entenderse conforme a las siguientes reglas.

a) El constituyente puede fijar la duración por un tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario, y si omite fijar plazo se entiende constituido por toda la vida de este. Si el usufructuario es una corporación o fundación, el plazo no puede exceder de 30 años (**art. 770**).

b) Si el usufructo es por tiempo determinado y el usufructuario muere antes, sus herederos no le suceden en el goce hasta la expiración del plazo, porque el usufructo es intransmisible (**art. 773**, inc. 2º); la muerte del usufructuario pone siempre fin al usufructo.

c) Se prohíbe constituir usufructo bajo una condición o a un plazo que suspenda su ejercicio; si de hecho se constituyere, no tiene valor alguno (**art. 768**, inc. 1º), salvo la excepción de su inciso 2º. La prohibición busca impedir la existencia disimulada de usufructos sucesivos.

d) El término del usufructo puede someterse a una condición, cuyo único efecto posible es anticipar la extinción, jamás retardarla más allá del plazo. Si la condición se cumple antes del plazo, el usufructo termina y se consolida con la propiedad; si no se cumple antes del plazo o de la muerte del usufructuario, se mira como no escrita (**art. 771**), y el usufructo terminará entonces con el plazo o con la muerte del usufructuario.

4. CONSTITUCIÓN

El **art. 766** señala varias fuentes del usufructo; agrupando sus numerales y agregando la sentencia judicial, puede decirse que se constituye por ley, por voluntad del propietario, por prescripción, o por sentencia judicial.

4.1. Por ley

El **art. 810** se refiere a dos usufructos legales o derechos legales de goce: el del padre o madre sobre ciertos bienes del hijo no emancipado, de los que el **art. 250** excluye ciertos bienes, y el del marido, como administrador de la sociedad conyugal, sobre los bienes de la mujer. Aunque se les llama usufructos, difieren bastante de la institución general; la Ley de Filiación N° 19.585 prefiere hablar de "derechos legales de goce" (**art. 252**, inc. final). También se ha sostenido que los poseedores provisorios de los bienes del desaparecido tendrían un usufructo de origen legal (**art. 89**), aunque puede entenderse más bien que tienen la propiedad sujeta a condición resolutoria.

4.2. Por voluntad del propietario

El propietario puede constituir el usufructo por testamento, sujeto a sus formalidades, o por acto entre vivos con un cocontratante. En este último caso, la formalidad depende de la naturaleza de la cosa: si recae sobre muebles es consensual; si recae sobre inmuebles requiere instrumento público inscrito (**art. 767**). Se discute el rol de la inscripción: para algunos cumple el doble papel de solemnidad del acto constitutivo y de tradición del derecho real; para otros, solo el segundo, quedando perfecto el acto constitutivo con el solo otorgamiento del instrumento público. La inscripción debe efectuarse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del conservador del lugar donde se ubique el inmueble (**arts. 686** del Código y 52 N° 2 del Reglamento).

Dentro de esta forma de constitución, el dueño puede reservarse el usufructo dando a otro la nuda propiedad, por retención; mantener la nuda propiedad concediendo a otro el usufructo, por vía directa; o dispersar los derechos concediendo a un sujeto el usufructo y a otro la nuda propiedad, por desprendimiento. Si por testamento se concede el usufructo sin designar nudo propietario, esta corresponderá a los herederos del testador.

4.3. Por prescripción

No es sino una confirmación de la regla general conforme a la cual se ganan por prescripción los derechos reales que no estén especialmente exceptuados (**art. 2498**, inc. 2°), posibilidad contemplada expresamente en el **art. 766** N° 4. No será frecuente, pues por lo general quien posee una cosa lo hace con ánimo de señor sobre su integridad; pero puede darse, por ejemplo, cuando se constituye usufructo sobre cosa ajena: la tradición del derecho no producirá su efecto normal por faltarle el derecho al tradente, pero dejará al adquirente en posesión de él, que terminará ganando por prescripción según las reglas y plazos del dominio (**art. 2512**).

4.4. Por sentencia judicial

Suele citarse como ejemplo el **art. 1337** N° 6, sobre la partición de bienes, aunque el precepto exige el consentimiento de los interesados, por lo que se trataría más bien de un usufructo de origen convencional que solo formalmente se consigna en el fallo arbitral. Más preciso es el ejemplo de la Ley N° 14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, que permite al juez fijar como pensión alimenticia un derecho de usufructo, uso o habitación sobre bienes del alimentante, quien no podrá enajenarlos sin autorización judicial; si se trata de un inmueble, la prohibición debe inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces (**art. 11**, inc. 1°, de dicha ley).

EJEMPLO

El juez de familia, al fijar alimentos, constituye a favor del alimentario un derecho de usufructo sobre la casa del alimentante y le prohíbe enajenarla mientras dure. Esa prohibición debe inscribirse en el Conservador de Bienes Raíces para ser oponible a terceros. Es el ejemplo más citado de usufructo constituido por sentencia judicial.

5. EFECTOS

El usufructo genera derechos y obligaciones tanto para el usufructuario, los más numerosos y de mayor contenido, como para el nudo propietario.

5.1. Derechos del usufructuario

i) **Derecho a usar la cosa fructuaria.** Aunque el **art. 764** no alude expresamente a la facultad de uso al definir el usufructo, esta se entiende comprendida en la expresión "facultad de gozar de una cosa". Usar significa aplicar la cosa a los servicios que es capaz de proporcionar, sin tocar sus productos ni destruirla; son manifestación de esta facultad los **arts. 782, 785 y 787**.

ii) **Derecho a gozar la cosa fructuaria,** esto es, a apropiarse de los frutos naturales y civiles que produzca, según lo desarrollan los **arts. 781, 790, 792, 793 y 794**. Por regla general el usufructuario no tiene derecho a los productos, salvo las excepciones de los **arts. 783, 784 y 788**; la extensión de sus facultades se determina primero por el acto constitutivo (**art. 791**), y responde de culpa leve como buen padre de familia.

iii) **Derecho a administrar la cosa fructuaria,** conforme al **art. 777**, previo cumplimiento de las obligaciones de inventario y caución.

iv) **Derecho a hipotecar el usufructo.** El **art. 2418** permite hipotecar inmuebles que se posean en usufructo; en rigor, lo hipotecable es el derecho real de usufructo, pues el usufructuario es

solo mero tenedor del inmueble.

v) Derecho a arrendar y ceder el usufructo, a título oneroso o gratuito, incluso al propio nudo propietario sin que ello importe consolidación (**art. 793**). Si el constituyente prohibió arrendarlo o cederlo, la infracción hace perder el derecho; se discute si ello importa nulidad absoluta por objeto ilícito (**arts. 1464 N° 2, 1466 y 1682**) o solo habilita a pedir la declaración de término del usufructo, postura esta última más plausible por no estar la nulidad establecida expresamente.

vi) Si se trata de un cuasiusufructo, el cuasiusufructuario puede disponer de la cosa fructuaria, pues se hace dueño de las cosas consumibles que recibe.

vii) Derecho a ejercitar las acciones destinadas a proteger su derecho: la reivindicatoria (**art. 891**) y, si recae sobre inmuebles, las acciones posesorias (**arts. 916 y 922**); se ha resuelto incluso que puede entablar la acción de precario del **art. 2195** contra el propio nudo propietario. Sus acreedores pueden embargar su derecho, salvo que se trate de un usufructo legal (**arts. 803 y 2466**).

viii) Derecho a ser indemnizado por los deterioros que sufra la cosa por culpa o dolo del propietario, desde que se produjo la delación del usufructo (**art. 774**).

ix) Derecho legal de retención de la cosa fructuaria, aunque haya expirado el usufructo, hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones que la ley prevé (**art. 800**).

5.2. Obligaciones del usufructuario

Se distingue entre las obligaciones previas al usufructo, las que surgen al entrar en el goce, las que rigen durante su vigencia y las posteriores a su extinción.

Obligaciones previas: inventario y caución

Antes de entrar en el goce, el usufructuario debe practicar inventario solemne (**art. 858** del Código de Procedimiento Civil) y rendir caución de conservación y restitución (**art. 775**). El inventario no se exige en los usufructos legales, y se discute si el constituyente puede liberar de esta obligación; predomina la opinión de que sí, por autonomía de la voluntad, salvo casos excepcionales como el **art. 1407**, sobre donación, o el **art. 379**, sobre guarda testamentaria.

La caución, cuya naturaleza y monto la ley no precisa, se conviene generalmente entre las partes o la regula el juez en su desacuerdo. Están liberados de rendirla los usufructos legales, los constituidos por donación con reserva de uso del donante (**art. 775**, inc. 3°), aquellos en que el constituyente o el nudo propietario exoneraron al usufructuario (**art. 775**, inc. 2°), y los casos que la ley señala, como el de los bancos que administran bienes gravados con usufructo (**arts. 86 N° 9 y 87** de la Ley General de Bancos). Su objeto difiere según se trate de usufructo, en que garantiza una obligación de especie o cuerpo cierto, o de cuasiusufructo, en que garantiza una obligación de género.

La omisión de inventario y caución no acarrea la pérdida del derecho, sino los efectos de los **arts. 776 y 777**: el usufructuario no podrá entrar en la administración, que corresponderá provisionalmente al propietario, obligado a entregarle el valor líquido de los frutos; fijado un plazo por el juez sin que se rinda caución, la administración se adjudica definitivamente al nudo propietario, quien podrá deducir del valor de los frutos una suma proporcional al trabajo de administrar.

Los muebles necesarios para el uso personal del usufructuario y su familia le serán entregados, con todo, bajo la llamada caución juratoria, y su derecho a reclamar la administración cumpliendo con la caución es imprescriptible.

Obligaciones al entrar en vigencia el usufructo

El usufructuario debe respetar los arrendamientos de la cosa fructuaria contratados por el propietario antes de constituirse el usufructo, y las demás cargas reales o personales impuestas con anterioridad (**arts. 792 y 796**); estos arrendamientos le son oponibles aunque consten en instrumento privado, pues el art. 792 prevalece sobre el **art. 1962**. Como contrapartida, le pertenecen desde que principia el usufructo las rentas de esos arrendamientos.

Debe además recibir la cosa en el estado en que se encuentre a la delación de su derecho (**art. 774**), sin perjuicio de su derecho a ser indemnizado por los deterioros anteriores imputables al propietario.

Obligaciones durante la vigencia del usufructo

Debe mantener la cosa fructuaria, conservando su forma y substancia (**art. 764**), obligación de la esencia del usufructo cuyo alcance exacto se determina caso a caso, atendiendo a la estructura física, el aspecto externo y el destino de la cosa, y a las facultades que confirió el título constitutivo.

Debe también pagar las expensas y mejoras necesarias para la conservación de la cosa: las expensas ordinarias de conservación y cultivo (**art. 795**); las pensiones, cánones y demás cargas periódicas que graven la cosa y se devenguen durante el usufructo (**art. 796**); los impuestos periódicos, fiscales y municipales, cualquiera sea su fecha de establecimiento, pero no los extraordinarios (**art. 796**); y las deudas hereditarias y testamentarias, en la proporción del **art. 1368**, si el usufructo se constituyó por testamento.

Obligaciones una vez extinguido el usufructo

Debe restituir la cosa fructuaria (**arts. 764 y 787**); si no lo hace, el propietario puede reivindicarla (**art. 915**). En el cuasiusufructo debe restituirse otro tanto de igual cantidad y calidad, o su valor, a elección del cuasiusufructuario (**arts. 764 y 789**). Excepcionalmente puede negarse a restituir invocando el derecho legal de retención del **art. 800**.

5.3. Derechos del nudo propietario

- a) Derecho de dominio sobre la cosa fructuaria: puede enajenarla (art. 773), hipotecarla (art. 2416) y transmitirla, respetando en todos los casos el adquirente, acreedor hipotecario o heredero el usufructo vigente. Dispone también de la acción reivindicatoria (art. 893) y, si recae en inmuebles, de las acciones posesorias (art. 916), ejercibles contra cualquiera y, al término del usufructo, contra el propio usufructuario.
- b) Derecho a los frutos pendientes al momento de la restitución (art. 781).
- c) Derecho a ser indemnizado por la pérdida o el deterioro de la cosa fructuaria imputable a dolo o culpa del usufructuario, incluidos los hechos ajenos que su negligencia haya permitido (arts. 787, 788 y 802).
- d) Derecho a percibir los intereses legales de los dineros que hubiere invertido en obras o refacciones mayores necesarias para la conservación de la cosa, mientras dure el usufructo (art. 797).
- e) Derecho al tesoro que se descubra en el suelo dado en usufructo, del que el usufructuario nada participa (art. 786).
- f) Derecho a pedir anticipadamente el término del usufructo, por haber faltado el usufructuario gravemente a sus obligaciones o haber causado daños considerables a la cosa (art. 809); el juez podrá ordenar que cese el usufructo o que la cosa vuelva al propietario con cargo de pagar al usufructuario una pensión anual hasta su terminación.
- g) Derecho de reclamación de la cosa fructuaria: se reconoce al nudo propietario, además de la reivindicatoria, una acción personal de restitución fundada en el acto constitutivo, dirigida contra el usufructuario al extinguirse el usufructo, cuya ventaja es que basta acreditar dicho acto sin necesidad de probar el dominio.

5.4. Obligaciones del nudo propietario

Se reducen al pago de las expensas extraordinarias mayores que se hayan ejecutado (arts. 797, 798 y 801). Se entiende por tales las que reúnen dos requisitos copulativos: ocurren por una vez o a largos intervalos de tiempo, y conciernen a la conservación y permanente utilidad de la cosa fructuaria (art. 798). Las expensas ordinarias de conservación y cultivo, en cambio, son siempre de cargo del usufructuario, sin derecho a reembolso.

DATO DE GRADO

La distribución de expensas entre usufructuario y nudo propietario es un clásico tema de examen: las expensas ordinarias de conservación y cultivo (**art. 795**) y las cargas periódicas e impuestos (**art. 796**) son siempre de cargo del usufructuario, sin derecho a reembolso; solo las expensas extraordinarias mayores, esto es, las que ocurren por una vez o a largos intervalos y conciernen a la conservación y permanente utilidad de la cosa (**art. 798**), son de cargo del nudo propietario, quien además debe al usufructuario los intereses legales de lo invertido mientras dure el usufructo (**art. 797**). A estas mismas reglas remitió el eje anterior el abono de mejoras entre fiduciario y fideicomisario.

6. EXTINCIÓN

El usufructo se extingue por las siguientes causales.

- a) Por la llegada del día o el cumplimiento de la condición establecidos (**art. 804**); cualquiera sea el plazo o condición, el usufructo no puede continuar después de la muerte del usufructuario (**arts. 804 y 805**).
- b) Por muerte del usufructuario (**arts. 806 y 773**, inc. 2º), atendida la intransmisibilidad del derecho.
- c) Por resolución del derecho del constituyente (**art. 806**), causal aplicable a una causa de resolución preexistente a la constitución del usufructo, como cuando este se constituyó sobre una propiedad fiduciaria y llega el caso de la restitución; si el nudo propietario simplemente enajena la cosa, el usufructo persiste por tratarse de un derecho real.
- d) Por consolidación del usufructo con la nuda propiedad (**art. 806**), esto es, por reunirse en una sola persona ambas calidades, como si el usufructuario hereda al nudo propietario.
- e) Por prescripción (**art. 806**): el usufructo se extingue para un usufructuario determinado cuando otra persona gana por prescripción adquisitiva el derecho de usufructo, o la propiedad plena de la cosa (**arts. 2498**, inc. 2º, y **art. 2512**). Se discute si además cabe la prescripción extintiva por el simple no ejercicio; se ha negado esta posibilidad razonando que la acción para reclamar un derecho solo se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho (**art. 2517**), y que el usufructuario tiene dominio sobre su derecho, el cual no se extingue por el solo no ejercicio.
- f) Por renuncia del usufructuario (**arts. 806 y 12**); si recae sobre un inmueble, debe constar en escritura pública y anotarse al margen de la inscripción, para su cancelación (**art. 52** N° 3 del Reglamento Conservatorio).

g) Por destrucción completa de la cosa fructuaria (arts. 807 y 808); si la destrucción es solo parcial, el usufructo subsiste sobre el resto. Si recae sobre un edificio que pertenece a una heredad, su destrucción no extingue el usufructo sobre el resto de ella; y si una heredad fructuaria es inundada, el usufructo revive por el tiempo que faltaba para su terminación al retirarse las aguas.

h) Por sentencia judicial (art. 809), a instancia del propietario, por haber faltado el usufructuario gravemente a sus obligaciones o causado daños o deterioros considerables a la cosa.

i) Por expropiación, en cuanto la propiedad plena pasa al Fisco conforme a la Constitución y a la Ley de Expropiaciones.

7. EL USO Y LA HABITACIÓN

7.1. Concepto

El **art. 811** define el derecho de uso como el derecho real que consiste, generalmente, en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa; si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación.

Aunque el **art. 819** parece aludir a dos derechos distintos, en rigor se trata de un solo derecho, el de uso, que al recaer sobre una casa toma el nombre de habitación. Ello no impide que el derecho de uso recaiga sobre un inmueble, como un predio agrícola, sin relación con el habitar una casa que en él pueda encontrarse.

NO CONFUNDIR

Uso y habitación no son dos derechos reales distintos, sino un mismo derecho con dos nombres según su objeto: se llama uso cuando recae sobre cosas en general, y habitación cuando recae específicamente sobre una casa y consiste en la utilidad de morar en ella.

7.2. Principales aspectos

a) Es un derecho personalísimo: son intransmisibles a los herederos y no pueden cederse, prestarse ni arrendarse (art. 819). Están, sin embargo, en el comercio humano y pueden adquirirse por prescripción (art. 2498); son, en suma, comerciables pero inalienables.

b) Son inembargables (arts. 2466 y 1618 del Código Civil, y art. 445 N° 15 del Código de Procedimiento Civil).

c) Se constituyen y extinguen según las reglas del usufructo (art. 812), salvo los usufructos legales, que quedan excluidos de esta asimilación. La Ley 14.908 permite también al juez constituirlos

en la sentencia de alimentos.

d) Por regla general no exigen inventario ni caución, salvo dos casos que sí lo requieren: el habitador, siempre; y el usuario, cuando el uso se constituye sobre cosas que deban restituirse en especie (art. 813).

e) Se limitan a las necesidades personales del usuario o habitador, comprendiendo las de su familia (art. 815); su extensión se determina en primer lugar por el título constitutivo (art. 814).

f) El usuario o habitador deben ejercer su derecho con la moderación y cuidado de un buen padre de familia (art. 818).

X. LAS SERVIDUMBRES

1. CONCEPTO

La servidumbre es otro derecho real limitado, enumerado en el **art. 577**, desde el punto de vista del predio dominante; y es una limitación al dominio, desde el punto de vista del predio sirviente. Esta doble faceta origina las servidumbres activas y pasivas.

El **art. 820** contiene la definición legal: servidumbre predial, o simplemente servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño.

2. ELEMENTOS

2.1. Dos predios de distinto dueño

Se ha discutido la clase de inmuebles que pueden quedar comprendidos en el concepto de "predios". La jurisprudencia no es uniforme: se ha sostenido que se trata no solo de inmuebles por naturaleza, sino también por adherencia o por destinación; en otra oportunidad se ha resuelto que solo es posible constituir servidumbre respecto de los inmuebles por naturaleza, pues el **art. 568** llama "predios" a las casas y heredades.

La diferencia de dueño es una característica fundamental de la institución, porque, como ha dicho la jurisprudencia, no se puede ser a la vez sujeto activo y pasivo de una misma relación jurídica.

2.2. Un gravamen

El gravamen debe pesar sobre uno de los predios, para favorecer al otro, y que origina en el uno la denominación de predio sirviente y en el otro la de predio dominante. El gravamen y la utilidad han de ser, pues, para el predio.

3. CARACTERÍSTICAS

Para el predio sirviente, la servidumbre significa un gravamen de carácter real, porque tal naturaleza tiene el derecho que es su extremo opuesto; las mutaciones de propietario no alteran dicha carga. Para el predio en cuyo beneficio se establece, en cambio, es una utilidad que constituye un derecho del dueño del fundo dominante, con los siguientes caracteres.

a) Es un derecho real, porque se tiene sobre una cosa, el predio sirviente, sin respecto a determinada persona (**art. 577**). Aunque cambie el dueño del fundo sirviente, el gravamen sigue vigente y no podrá ser alzado por el nuevo dueño sin el consentimiento del dueño del fundo dominante.

- b) Es un derecho inmueble, porque se ejerce sobre una cosa de esta naturaleza (art. 580).
- c) Es un derecho accesorio, característica que deriva directamente de la predialidad de la servidumbre: no puede subsistir sin los predios sobre los cuales recae (art. 825). A diferencia de otros derechos reales, como el usufructo o el uso, no se tiene el derecho de servidumbre directamente, sino como consecuencia de ser propietario del predio dominante. Por ello no puede ser cedido, embargado ni hipotecado independientemente del predio dominante, y, en cambio, integra el goce de la propiedad a que accede (arts. 782, 1120 y 1125).
- d) Es un derecho perpetuo, en el sentido de que subsiste mientras objetivamente existan los predios a que se refiere y la necesidad o justificación del gravamen. Con todo, nada impide que se establezcan por las partes con duración limitada (art. 885 N° 2), y pueden extinguirse por el no uso (art. 885 N° 5).
- e) Es un derecho indivisible: la servidumbre no puede adquirirse, ejercerse ni extinguirse parcialmente por las partes, lo que cobra especial importancia en caso de pluralidad de propietarios (arts. 826, 827 y 886).

4. CLASIFICACIÓN

4.1. Según su origen

Pueden ser naturales, legales y voluntarias (art. 831), clasificación que se desarrolla en el número 6 de este eje.

4.2. Según sus señales de existencia

Pueden ser aparentes e inaparentes (art. 824). Se suele objetar a esta clasificación su débil consistencia, pues depende de circunstancias materiales más o menos accidentales: hay servidumbres que pueden ser aparentes o inaparentes, como las de tránsito o acueducto; y otras que siempre serán inaparentes, como aquellas que consisten en un no hacer en el predio sirviente.

4.3. Según su ejercicio

Pueden ser continuas o discontinuas (art. 822). Para esta calificación se atiende a la forma natural como se ejerce, apreciada de manera objetiva y universal, y no al hecho de que se ejerza continuamente y sin intermitencia. Así, una servidumbre continua puede ejercerse con intermitencia, como la de acueducto por la que el agua pasa de tiempo en tiempo, y será siempre continua porque siempre estará allí el canal apto para el paso del agua; en cambio, una servidumbre de tránsito será discontinua aunque se esté transitando continuamente por el predio sirviente, pues requiere de un hecho actual del hombre.

4.4. Según su objeto o carácter

Pueden ser positivas o negativas (**art. 823**). En las positivas, la servidumbre impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer, por regla general, como la de acueducto o de tránsito; en las negativas, impone la prohibición de hacer algo, como elevar las paredes hasta cierta altura. En ningún caso la servidumbre puede imponer la obligación de hacer: el que la sufre debe dejar hacer o abstenerse de hacer, pero nada está obligado a hacer en razón del gravamen; la actividad la despliega el dueño del predio dominante.

Una servidumbre determinada puede quedar comprendida al mismo tiempo en cada una de estas clasificaciones. Así, una servidumbre de tránsito convenida entre los propietarios A y B, que corre por una senda visible, es voluntaria, aparente, discontinua y positiva.

DATO DE GRADO

La distinción entre servidumbres continuas/discontinuas y aparentes/inaparentes tiene tres consecuencias prácticas de examen. En materia de prescripción adquisitiva, solo pueden adquirirse por este medio las servidumbres continuas y aparentes; las discontinuas de toda clase y las continuas inaparentes solo pueden adquirirse por un título, y ni siquiera el goce inmemorial basta para constituir las (**art. 882**). En materia de extinción por el no uso, el plazo de tres años (**art. 885** N° 5) se cuenta distinto según el tipo: en las continuas, desde que se realiza un acto contrario a la servidumbre; en las discontinuas, desde el último acto que supone gozarla. Y en materia de constitución por destinación del padre de familia, solo procede en las servidumbres continuas y aparentes (**art. 881**).

5. EJERCICIO DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE

Para determinar los derechos del dueño del predio dominante y del predio sirviente hay que atenderse a la fuente originaria de la servidumbre (**art. 884**). En todo caso, deben tenerse presentes los **arts. 828, 829 y 830**, este último, junto con otras disposiciones como el **art. 833**, inspirado en el principio romano del comportamiento civiliter: en el ejercicio del derecho, el dueño del predio dominante debe procurar el mínimo perjuicio, evitando toda molestia o embarazo innecesario en el predio sirviente. Es la contrapartida de la conducta que se exige al dueño del predio sirviente, quien debe abstenerse de efectuar obras o actos que perturben el ejercicio de la servidumbre.

6. CLASES DE SERVIDUMBRES SEGÚN SU ORIGEN

6.1. Servidumbres naturales

Son las que provienen de la natural situación de los lugares (**arts. 831 y 833**). Actualmente el Código contempla solo una, la de libre descenso y escurrimiento de las aguas: proviniendo de la natural situación de los predios, el dueño del predio sirviente no tiene derecho a indemnización alguna y deberá siempre soportarla.

6.2. Servidumbres legales

Según el **art. 831**, son las impuestas por la ley, y el **art. 839** las subclasifica en servidumbres de utilidad pública y de interés privado.

a) Servidumbre de utilidad pública

El **art. 839** hace referencia especial a la del uso de riberas para menesteres de navegación o flote, remitiéndose en su regulación al Código de Aguas, y agrega que existen otras cuya reglamentación se remite a los respectivos reglamentos u ordenanzas. Sus características más importantes son que generalmente carecen de un predio dominante, lo que hace discutible su carácter de servidumbre; que están fuera del comercio, lo que excluiría su extinción por prescripción; y que no conceden indemnización al dueño del predio gravado, salvo disposición expresa.

b) Servidumbre de utilidad privada

El gravamen reporta utilidad solo al propietario particular del predio dominante. El **art. 841** dispone que estas servidumbres también se determinan por las ordenanzas de policía rural, y el Código se limita a regular las de demarcación, cerramiento, medianería, tránsito, acueducto, luz y vista, precisadas con detalle entre los **arts. 842 y 878**, muchas de cuyas reglas provienen del derecho romano. Que la ley las califique de "legales" significa que, cumplidos sus supuestos, pueden imponerse aun contra la voluntad del dueño del predio sirviente, pero no que operen de pleno derecho: será necesario, según el caso, acudir al juez para que constate los supuestos y, a falta de acuerdo, fije las características del sendero o determine la indemnización.

Demarcación. Es la operación que tiene por objeto fijar la línea que separa dos predios colindantes de distintos dueños, señalándola por medio de signos materiales. Como no se exige prueba del dominio, puede entablar la acción todo poseedor regular o irregular, el nudo propietario, el propietario fiduciario, el usufructuario, el cesionario y, en general, todo el que tenga la posesión de un derecho real sobre la cosa; se ha resuelto que cualquier comunero puede demandarla sin que sea necesario que concurren todos, aplicando la doctrina del mandato tácito y recíproco entre comuneros. Como sujeto pasivo, en cambio, si el predio vecino pertenece a una comunidad, deben ser incluidos todos los comuneros en la demanda para que el fallo los afecte.

Se trata de una servidumbre positiva que constituye una excepción a las de su especie, pues impone una obligación de hacer (**art. 823**, inc. 2º); en doctrina se discute que sea en rigor una servidumbre, por faltar predio dominante, predio sirviente y gravamen propiamente tales, tratándose más bien de una facultad derivada del dominio. La acción, tramitada en juicio sumario, es imprescriptible por emanar del dominio.

Cerramiento. Consiste en el derecho de todo propietario a cerrar su predio y obtener que contribuyan a esa actividad los dueños de los predios colindantes. Al igual que la demarcación, emana del dominio, por lo que la acción es real e imprescriptible y, por la misma razón, tampoco es propiamente una servidumbre; con frecuencia queda involucrado en la demarcación, a la que sigue.

Medianería. Regulada en los **arts. 851 a 859**, tampoco presenta los elementos propios de una servidumbre: en doctrina se explica como un caso de comunidad forzosa y perpetua, consecuencia de la copropiedad de la pared divisoria. No toda pared divisoria es medianera (**art. 846**): lo es cuando el cerramiento se ha hecho a expensas comunes, aunque el **art. 854** da derecho al dueño que no construyó el cerco a hacerse medianero pagando los gastos correspondientes. Se prueba por título, por señales exteriores o por presunciones (**arts. 852 y 853**), y sus efectos comprenden el derecho a edificar y a elevar la pared medianera (**art. 857**), y los derechos recíprocos de los colindantes (**art. 858**), en armonía con el **art. 2309** sobre la comunidad.

Servidumbre de tránsito. Es la que tiene derecho a imponer un predio cuando está desprovisto de toda comunicación con un camino público. Es una verdadera servidumbre, positiva, discontinua, y aparente o inaparente. Para establecerse se requiere que el predio esté desprovisto de toda comunicación con el camino público, que esta comunicación sea indispensable para su uso y beneficio, y que se indemnice previamente al propietario del predio sirviente; a falta de acuerdo, el conflicto se resuelve por informe de peritos, que determinan tanto la indemnización como la forma de ejercicio (**arts. 847 y 848**). Puede pedirse que cese cuando deje de ser indispensable y se restituya lo pagado (**art. 849**).

El **art. 850** contempla el caso especial de constitución sin indemnización cuando el adquirente o adjudicatario era comunero con el tradente o con los demás partícipes de la partición, norma orientada a proteger a los demás propietarios vecinos frente a quien, sin ella, podría verse obligado a soportar la servidumbre.

Servidumbre de acueducto. Es el medio del que disponen los propietarios no ribereños para servirse de las aguas corrientes, conduciéndolas por la heredad sirviente a expensas del interesado (**art. 861**). Es continua y positiva, y puede ser aparente o inaparente, generalmente lo primero. El predio dominante puede ser una heredad que carezca de aguas para el cultivo, un pueblo que las requiera para el servicio doméstico, o un establecimiento industrial que las necesite para sus máquinas.

Servidumbre de luz. Su objeto es dar luz a un espacio cerrado y techado, sin darle vista sobre el predio vecino (**art. 873**). Es continua, aparente y positiva. El Código regula cuándo existe

(**art. 874**, incs. 1º y 2º), las condiciones de la servidumbre legal de luz (**art. 875**) y cuándo se destruye en el hecho (**art. 876**).

Servidumbre de vista. Tiene por finalidad prohibir que se vea lo que ocurre en el predio vecino. Es negativa, continua y aparente, pues se manifiesta por la ausencia de balcones, azoteas y ventanas orientados hacia el predio sirviente.

6.3. Servidumbres voluntarias

El **art. 880** da margen a la voluntad para pactar cualquier gravamen, con las limitaciones del orden público y la ley; pueden constituirse como voluntarias, incluso, las servidumbres denominadas legales, cuando no se cumplen todos los requisitos que la ley exige para imponerlas como tales. Se constituyen por título, por sentencia judicial, por prescripción o por destinación del padre de familia.

a) Por título: cuando la ley se refiere a la constitución por título (**arts. 882, 883 y 884**), no debe entenderse el término como instrumento material, sino como el acto jurídico que da origen a la servidumbre; puede ser un acto entre vivos o un testamento, gratuito u oneroso, y por título puede constituirse toda clase de servidumbres (**art. 882**, inc. 1º). El título puede suplirse por un reconocimiento expreso del dueño del predio sirviente, que importa una verdadera constitución de la servidumbre y debe contener las precisiones necesarias para su ejercicio (**art. 883**). La tradición del derecho real de servidumbre se efectúa, excepcionalmente al **art. 686**, por escritura pública, que puede ser la misma del acto o contrato constitutivo (**art. 698**); consecuentemente, el Reglamento del Conservador incluye su constitución entre los títulos que pueden, y no que deben, inscribirse (**art. 53** N° 2).

b) Por sentencia judicial (**art. 880**): la ley, en general, no contempla casos de servidumbre a establecerse por sentencia, pues estas son declarativas de derechos y no atributivas, y en tal caso tampoco podría hablarse de servidumbre voluntaria. El Código contempla un caso, en el fallo que recae en la partición de bienes (**art. 1337**, regla 5ª).

c) Por prescripción: solo pueden adquirirse así las servidumbres continuas y aparentes; las discontinuas y las continuas inaparentes no pueden adquirirse por este medio, ni siquiera mediante el goce inmemorial, referencia de la antigua legislación española que el Código consignó justamente para desterrarla (**art. 882**). Se justifica la imposibilidad tratándose de las discontinuas en que sus actos pueden considerarse de simple tolerancia del propietario del predio sirviente (**art. 2499**), y tratándose de las inaparentes, en la falta de posesión pública. El plazo de posesión para prescribir es de cinco años (**art. 882**); el **art. 2512** señala esta prescripción como una excepción a sus reglas generales, en cuanto no distingue entre posesión regular e irregular: con cualquiera de ellas se adquiere a los cinco años.

d) Por destinación del padre de familia: es el acto por el cual el dueño de dos predios establece un gravamen sobre uno en beneficio del otro, originándose la servidumbre posteriormente y de pleno derecho al enajenarse uno de ellos, o ambos, a propietarios distintos (**art. 881**); en otras palabras,

el "servicio" se transforma en "servidumbre". Se exige que los predios hoy separados hayan pertenecido a un mismo dueño, que el servicio se hubiere constituido por ese mismo dueño, que el servicio sea continuo y aparente, y que en el acto de enajenación o partición no se haya establecido expresamente otra cosa.

EJEMPLO

El dueño de dos predios contiguos abre, mientras ambos son suyos, un canal que conduce agua desde uno hacia el otro. Ese canal es solo un servicio interno de su propiedad, no una servidumbre, porque falta la diferencia de dueños. Si luego vende uno de los predios sin decir nada sobre el canal, la servidumbre de acueducto nace de pleno derecho por destinación del padre de familia, precisamente al momento en que aparecen dos dueños distintos.

7. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS DUEÑOS DE LOS PREDIOS

Para determinar los derechos y obligaciones del dueño del predio dominante y del dueño del predio sirviente hay que remitirse al origen de la servidumbre: al título, a la forma en que se poseyó si se adquirió por prescripción, o a la forma en que se usó el servicio en el caso de la destinación del padre de familia (**art. 884**).

8. EXTINCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES

En principio, las servidumbres, por constituir servicios de predio a predio, son perpetuas; con todo, existen factores que pueden producir su extinción, señalados en los **arts. 885, 886 y 887**, a los que debe agregarse la extinción por expropiación.

a) Por resolución del derecho del que las ha constituido (**art. 1491**): se aplica solo a las servidumbres voluntarias, pues las demás están impuestas por la naturaleza o por la ley.

b) Por la llegada del plazo fijado o el cumplimiento de la condición pactada, con la misma observación que la causal anterior.

c) Por confusión, es decir, la reunión perfecta e irrevocable de ambos predios en manos de un mismo dueño.

d) Por renuncia del dueño del predio dominante.

e) Por el no uso durante tres años, cualquiera sea su causa, pues la ley no distingue. Si el predio dominante pertenece a una comunidad, el goce de uno de los comuneros interrumpe la prescripción respecto de todos, y la suspensión que beneficia a uno beneficia a todos (**art. 886**), consecuencia del carácter indivisible de las servidumbres.

f) Por imposibilidad de ejercicio (art. 887), que debe mantenerse por tres años; si cesa antes, revive la servidumbre.

9. EXCURSO: EL DERECHO REAL DE CONSERVACIÓN

Fuera de las servidumbres tradicionales, la Ley N° 20.930 incorporó el derecho real de conservación, una de las adiciones más recientes al catálogo de derechos reales fuera del **art. 577**. Consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio determinado, y se distingue de las servidumbres en dos aspectos centrales: no requiere de un predio dominante, pudiendo constituirse en favor de una persona natural o jurídica sin que esta sea dueña de un predio vecino; y es de carácter enteramente voluntario, constituyéndose por contrato entre el dueño del predio gravado y el titular del derecho.

Al igual que las servidumbres voluntarias, se inscribe en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces respectivo, publicidad que le confiere oponibilidad frente a terceros.

Y. LAS ACCIONES PROTECTORAS: FORMAS DE PROTECCIÓN Y ACCIÓN REIVINDICATORIA

El dominio y los demás derechos reales necesitan protección jurídica cuando un tercero pretende vulnerarlos o efectivamente los vulnera. El ordenamiento consulta varios instrumentos de los que dispone el titular para preservar su derecho.

1. DIVERSAS FORMAS DE PROTECCIÓN

1.1. Medidas generales de protección del dominio

a) La legítima defensa, que opera en el Derecho Penal y cubre no solo a la persona, sino también a los bienes (art. 10 N° 4 del Código Penal).

b) La garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad privada, cuya excepción es la expropiación por causa de utilidad pública (art. 19 N° 24 de la Constitución); en su marco, la Constitución otorga a los afectados el recurso de protección (art. 20 de la Constitución).

c) Los delitos contra la propiedad, cuya tipificación constituye otra forma de protección del dominio (art. 432 y ss. del Código Penal).

1.2. Medidas de protección en el derecho privado

Se han configurado ciertas acciones tendientes a la protección del dominio y de los demás derechos reales, denominadas genéricamente acciones protectoras. En el ámbito de las acciones reales es posible observar dos grupos.

Un primer grupo lo constituyen las acciones del dominio propiamente tales, que lo protegen en forma directa. Algunas están destinadas a eliminar perturbaciones ya consumadas, como la acción reivindicatoria; otras buscan prevenir un daño que se teme, evitando que se consume, como las acciones posesorias de obra nueva y obra ruinosas, las acciones de demarcación y cerramiento, y la tercería de dominio (art. 518 y ss. del Código de Procedimiento Civil).

Un segundo grupo protege el dominio solo indirectamente, pues normalmente persigue otros objetivos: las acciones posesorias, la acción publiciana y la tercería de posesión. Como el poseedor lo es generalmente por ser dueño, al protegerse la posesión se termina protegiendo el dominio.

También hay acciones personales que protegen en definitiva el dominio, cuando la perturbación deriva de una relación contractual: así, si al terminar el comodato el comodatario no restituye la cosa, el comodante dispone de la acción personal para lograr judicialmente la restitución, lo mismo que en el arrendamiento o en el derecho de reclamación de la cosa fructuaria del nudo propietario. Este camino puede resultar más expedito, pues la prueba del contrato suele ser menos dificultosa que la prueba del dominio que exige la reivindicación.

2. CONCEPTO DE LA ACCIÓN REIVINDICATORIA

Reglamentada en los **arts. 889 a 915**, la primera de estas normas la define: la reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela.

3. REQUISITOS

Son requisitos de la reivindicatoria que se trate de una cosa susceptible de reivindicarse, que el reivindicante sea dueño de ella, y que esté privado de su posesión.

3.1. Que se trate de una cosa susceptible de reivindicarse

Cosas susceptibles de reivindicarse

a) La cosa debe ser singular. Es condición esencial que se determine y especifique de tal manera la cosa reivindicada que no pueda caber duda en su individualización, para que la discusión recaiga sobre algo concreto. No pueden reivindicarse las universalidades; el **art. 891** anuncia para la herencia una acción especial, la de petición de herencia, regulada en los **arts. 1264** y siguientes.

b) Pueden reivindicarse todas las cosas corporales, muebles o inmuebles, con limitaciones consagradas en protección de la buena fe y la seguridad del tráfico: las cosas muebles compradas en una feria, tienda, almacén u otro establecimiento en que se vendan cosas de la misma clase obligan solo a reembolsar al poseedor su valor, incluido lo pagado por ella y lo gastado en repararla y mejorarla (**art. 890**, inc. 2°); otra excepción similar la consagra el **art. 2303**, a propósito del pago de lo no debido.

c) Pueden reivindicarse también los derechos reales (**art. 891**), no así, en principio, los derechos personales, aunque sobre las cosas incorporales exista también una especie de propiedad (**art. 583**); ello se explica porque estos derechos no recaen directamente sobre cosas, sin perjuicio de que el título o instrumento en que consta un derecho personal sea perfectamente reivindicable.

d) Puede reivindicarse una cuota determinada proindiviso de una cosa singular (**art. 892**). El problema surge cuando la cosa común es una universalidad jurídica: la respuesta depende de la naturaleza de la comunidad, según si los derechos de cada comunero se comunican cuotativamente a cada objeto o permanecen como cuota abstracta; la jurisprudencia se ha pronunciado en ambos sentidos, y el **art. 1268**, al conceder al heredero acción reivindicatoria para perseguir un objeto de la herencia, no resuelve si puede reivindicar una cuota de él.

Cosas no susceptibles de reivindicarse

a) El derecho de herencia, amparado por la acción de petición de herencia y no por la reivindicatoria, que exige una cosa singular; el heredero sí puede reivindicar cosas singulares dentro de la uni-

versalidad (art. 1268).

b) Discutiblemente, los derechos personales, sin perjuicio de que pueda reivindicarse el documento en que consta el crédito.

c) Las cosas muebles compradas por su poseedor en feria, tienda, almacén u otro establecimiento en que se vendan cosas muebles de la misma clase (art. 890, incs. 2º y 3º), disposición que se ha aplicado también a establecimientos no mencionados expresamente, por ser su texto ejemplificativo.

d) En el pago de lo no debido, cuando el supuesto acreedor enajena la cosa recibida: hay acción contra el tercero adquirente de mala fe o a título gratuito, pero no contra el de buena fe que adquirió a título oneroso (arts. 2302 y 2303).

e) Cuando el tercero adquirió la cosa por prescripción.

f) Cuando se ha declarado resuelto un contrato, no hay acción reivindicatoria contra terceros poseedores de buena fe (arts. 1490 y 1491).

g) Cuando el heredero o legatario indigno transfirió los bienes hereditarios o legados a un tercero de buena fe (art. 976).

3.2. Que el reivindicante sea dueño de la cosa

En principio solo puede reivindicar el dueño, pleno o nudo, absoluto o fiduciario (art. 893), quien debe acreditar su calidad de tal, pues al reivindicar reconoce en el demandado la calidad de poseedor, que se apoya en la presunción de dominio del art. 700, la cual el reivindicante queda obligado a destruir.

Aquí aparece la principal dificultad de la acción, la prueba del dominio, conocida como probatio diabólica. Si el reivindicante adquirió por un modo originario, basta probar los hechos que lo constituyeron; si adquirió por un modo derivativo, como la tradición, no basta probar que ese modo se configuró a su favor, porque queda la interrogante de si el antecesor tenía o no el dominio, atendido que nadie puede transferir más derechos que los que tiene. Para sortear esta dificultad se acude a la prescripción adquisitiva, con mayor seguridad la extraordinaria, pudiendo servirse además de la agregación de posesiones.

El art. 894 consagra lo que el Derecho romano llamó acción publiciana, que permite reivindicar a quien, sin ser dueño, poseía regularmente y estaba en vías de ganar la cosa por prescripción, aunque no puede ejercerse ni contra el verdadero dueño ni contra quien posea con igual o mejor derecho. Se discute si para ejercitarla es necesario tener cumplido el plazo de prescripción ordinaria o basta algún tiempo de posesión: para ALESSANDRI, es necesario haberlo completado, porque el apoderamiento de un tercero produce una interrupción natural que hace perder todo el tiempo anterior, dejando de estar el primer poseedor "en vías de ganar por prescripción".

Para **ROZAS VIAL**, en cambio, no se exige el cumplimiento del plazo, pues si ya estuviera cumplido bastaría alegar la prescripción para reivindicar como dueño, sin necesidad de esta acción especial; añade que la prescripción operaría de pleno derecho, sin necesidad de sentencia judicial, razón por la cual el art. 894 dispone que la acción publiciana no puede deducirse contra el dueño, calidad que ya tendría quien enteró el plazo. Se ha resuelto, en todo caso, que cuando el reivindicante no logra probar el dominio pero sí un mejor derecho que el demandado, la demanda puede acogerse entendiendo ejercida implícitamente la acción publiciana.

3.3. Que el reivindicante esté privado de su posesión de la cosa

Siendo el fin de la reivindicación obtener la posesión, mal puede reclamarse si se tiene y conserva. Respecto de los inmuebles surge el problema de si corresponde acción reivindicatoria al propietario con inscripción a su nombre a quien se arrebató materialmente el inmueble; la solución depende del valor que se atribuya a la inscripción conservatoria. Si se le atribuye un valor absoluto y excluyente como prueba de posesión, no habría pérdida de la posesión y, por tanto, no competiría la reivindicatoria, quedando al dueño solo la acción de precario del **art. 2195**, inc. 2º, y las acciones criminales de usurpación.

Pero también puede sostenerse que, al privarse al dueño de la tenencia material, se le priva de una parte integrante de la posesión, su fase material, pudiendo entonces reivindicar por no ser integralmente poseedor, entendimiento con el que también tendría acción posesoria de amparo o de restitución.

4. CONTRA QUIÉN SE DIRIGE LA ACCIÓN

4.1. Contra el actual poseedor

Por regla general la acción se dirige contra el actual poseedor, sea regular o irregular (**art. 895**). Si quien tiene la cosa es un mero tenedor y el dueño ignora quién es el poseedor, el **art. 896** lo obliga a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene, gestión que se lleva a cabo mediante la medida prejudicial del **art. 282** del Código de Procedimiento Civil, cuya negativa se sanciona con multa o arresto en la forma del **art. 274** del mismo Código.

El **art. 897** sanciona además al poseedor ficto, esto es, quien de mala fe se da por poseedor sin serlo, condenándolo a indemnizar todo perjuicio causado por el engaño; se trata en rigor de una acción indemnizatoria personal. Si el poseedor fallece, el **art. 899** distingue entre la acción para obtener la entrega de la cosa, indivisible, y la de indemnizar, perfectamente divisible entre los herederos a prorrata de sus cuotas (**arts. 1526** N° 2 y 1354).

4.2. Contra el poseedor que dejó de poseer

También puede dirigirse contra quien dejó de poseer, distinguiendo entre el de buena y el de mala fe.

Conforme al **art. 898**, contra el poseedor de buena fe que, antes de trabada la litis, enajena la cosa creyéndola suya, haciendo imposible o difícil su persecución, procede la acción de dominio contra quien enajenó, para la restitución de lo que haya recibido por ella; si la enajenación no fue onerosa, nada hay que restituir por esta vía. Se exigen tres supuestos: pérdida de la posesión a consecuencia de la enajenación y no de otra causa; dificultad o imposibilidad de perseguir la cosa en otras manos; y que esa dificultad provenga precisamente de la enajenación.

El reivindicador que recibe del enajenador lo pagado por la cosa confirma con ello la enajenación (**art. 898**, inc. 2º), entendiéndose el dominio transferido al adquirente desde la tradición (**arts. 682**, inc. 2º, y 1819); además, cuando el tercero adeuda al poseedor enajenante todo o parte del precio, el reivindicador puede pedir su retención o embargo, extensión de la acción reivindicatoria que el **art. 903** concede en garantía de sus derechos.

Contra el poseedor de mala fe, en cambio, la acción de dominio procede siempre que haya dejado de poseer por culpa o hecho suyo, sin importar la existencia de obstáculos para la persecución, y se dirige como si actualmente poseyese (**art. 900**, inc. 1º): se le demanda la restitución de la cosa misma, con sus accesorios, frutos y demás prestaciones. Si el poseedor de mala fe paga el valor de la cosa y el reivindicador lo acepta, aquel le sucede en los derechos sobre ella, sin que el reivindicador quede obligado al saneamiento (**art. 900**, incs. 3º y final); y respecto del tiempo en que tuvo la cosa en su poder, tiene las obligaciones y derechos de los poseedores de mala fe en materia de frutos, deterioros y expensas (**art. 900**, inc. 2º).

Estas mismas reglas del poseedor de mala fe se aplican al de buena fe que, durante el juicio, se pone por su culpa en la imposibilidad de restituir, pues desde que se le discuten sus derechos deja de estar de buena fe (**art. 900**, inc. 4º).

NO CONFUNDIR

Contra el poseedor de buena fe que enajenó la cosa antes de la litis, la acción solo persigue lo que recibió por ella; contra el poseedor de mala fe, la acción se dirige como si actualmente poseyese, exigiéndole la cosa misma con todas sus prestaciones. La diferencia no está en si conservan o no la cosa, sino en la buena o mala fe con que dejaron de poseerla.

4.3. Contra el injusto detentador

El **art. 915** extiende las reglas del título de la reivindicación contra quien, poseyendo a nombre ajeno, retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque sin ánimo de señor. Se han propuesto

tres lecturas de esta norma. La primera, hoy mayoritaria en la jurisprudencia, admite excepcionalmente la propia acción reivindicatoria contra el injusto detentador entendido en sentido amplio, esto es, contra cualquier mero tenedor que retenga indebidamente la cosa; así lo resolvió la Corte Suprema en fallo de 23 de abril de 2007, razonando que la ley confiere la acción de dominio también a quien no ha perdido el ánimo de poseedor aunque sí la tenencia material.

La segunda lectura, sostenida por **CLARO SOLAR** y **ROZAS VIAL**, niega que el art. 915 otorgue acción reivindicatoria contra el mero tenedor, y le atribuye solo el efecto de hacer aplicables en su contra las reglas sobre prestaciones mutuas, dentro de la acción personal o restitutoria que corresponda según el caso, como la restitutoria que emana de un comodato expirado. La tercera, de lectura más restrictiva, limita la aplicación del artículo a quienes comenzaron a poseer a nombre ajeno como mandatarios, representantes legales o agentes oficiosos (**arts. 719**, inc. 2º, 720 y 721).

JURISPRUDENCIA

El propio alcance del art. 915 dividió a la Corte Suprema en el fallo rol N° 26.927-2015, de 7 de septiembre de 2016: por tres votos contra dos, la mayoría acogió la segunda teoría, negando que la norma consagre una acción reivindicatoria contra el mero tenedor y limitando su efecto a hacer aplicables las prestaciones mutuas dentro de la acción restitutoria que corresponda; el voto de minoría, invocando el rol N° 6.905-2015, sostuvo que la tendencia mayoritaria de la jurisprudencia sí reconoce en el art. 915 una verdadera acción reivindicatoria contra el simple detentador.

La doctrina ha insinuado la conveniencia de una acción general restitutoria para los casos en que no procede la reivindicatoria, las acciones posesorias ni las personales de restitución contractual, necesidad que se agudiza porque el mero tenedor puede alegar la prescripción del **art. 2510**, regla tercera. Se ha acudido para llenar este vacío a la acción de precario del **art. 2195**, aunque para **PEÑAILILLO** resulta más adecuado fundarla en una lectura extensiva del propio **art. 915**.

5. EXTINCIÓN POR PRESCRIPCIÓN

Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho (**art. 2517**). Si un propietario ve que un tercero comienza a poseer su bien, puede reivindicarlo, pero debe hacerlo antes de que ese poseedor lo gane por prescripción adquisitiva.

6. MEDIDAS PRECAUTORIAS

La acción reivindicatoria se tramita en juicio ordinario. Mientras tanto, el poseedor demandado está protegido por la presunción de dominio del **art. 700**, y el **art. 902**, inc. 1º, le permite seguir

gozando del bien hasta la sentencia ejecutoriada, pudiendo incluso enajenarlo; para evitarlo, los **arts. 901 y 902** autorizan al reivindicante a solicitar medidas precautorias.

Tratándose de cosas muebles, si hay motivo de temer que se pierdan o deterioren en poder del poseedor, el actor puede pedir su secuestro, esto es, su depósito en manos de un tercero que debe restituirla a quien obtenga sentencia favorable (**arts. 901 y 2249**). Tratándose de inmuebles, el poseedor sigue gozando de ellos hasta la sentencia firme, pero el actor tiene derecho a provocar las providencias necesarias para evitar su deterioro y el de los muebles y semovientes anexos, si hubiere justo motivo de temerlo o el demandado no ofreciere garantía suficiente (**art. 902**): son las medidas precautorias del Código de Procedimiento Civil, como la prohibición de celebrar actos o contratos, medidas para evitar el deterioro o el nombramiento de interventor.

7. PRESTACIONES MUTUAS

Terminado el juicio reivindicatorio y vencido el demandado, tienen lugar las prestaciones mutuas, esto es, los hechos y pagos que recíprocamente se deben el reivindicante y el poseedor vencido, reguladas en los **arts. 904** y siguientes como manifestación del principio de la reparación del enriquecimiento sin causa. Se aplican también a otras restituciones, como la acción de petición de herencia (**art. 1266**) y la de nulidad (**art. 1687**).

7.1. Prestaciones del poseedor vencido al reivindicante

El poseedor vencido debe restituir la cosa en el plazo que señale el juez, caso excepcional de plazo judicial (**arts. 904 y 1494**, inc. 2º). En la restitución de una heredad se comprenden las cosas que forman parte de ella o se reputan inmuebles por su conexión con ella; las demás solo si lo fueron en la demanda y sentencia, sin perjuicio de reivindicarse separadamente; en la de un edificio se comprenden sus llaves, y en la de toda cosa, los títulos que la conciernen, si están en poder del poseedor (**art. 905**). Los actos de administración que hubiere ejecutado el poseedor vencido, como los arrendamientos, caducan.

En materia de deterioros, el **art. 906** distingue: el poseedor de mala fe responde de los que provengan de su hecho o culpa, no de los debidos a caso fortuito; el de buena fe solo responde si se aprovechó de ellos. En ambos casos, la buena o mala fe se aprecia al momento en que se produjeron los deterioros (**art. 913**, aplicado por analogía).

En materia de frutos, el **art. 907** obliga al poseedor de mala fe a restituir los naturales y civiles, incluidos los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, o su valor si no existen; el de buena fe no debe restituir los percibidos antes de la contestación de la demanda, pero sí los posteriores, respecto de los cuales responde como el de mala fe, distinción que también se rige por el tiempo de percepción de los frutos (**art. 913**). Los gastos de custodia y conservación de la cosa durante el juicio solo los indemniza el poseedor de mala fe (**art. 904**).

7.2. Prestaciones del reivindicante al poseedor vencido

Por el principio de proscripción del enriquecimiento sin causa, el reivindicante debe abonar al poseedor vencido los gastos ordinarios invertidos en la producción de frutos, sin distinción entre poseedor de buena o mala fe (**art. 907**, inc. final), y las mejoras o expensas introducidas en la cosa, esto es, toda obra ejecutada para su conservación, para aumentar su valor, o con fines de ornato o recreo, que se clasifican en necesarias, útiles y voluptuarias.

a) Mejoras necesarias: aseguran la conservación de la cosa, evitando su deterioro, menoscabo o pérdida. Todo poseedor, de buena o mala fe, tiene derecho a que se le abonen. Tratándose de obras materiales, como levantar una cerca o reparar un edificio arruinado, se abonan reducidas a lo que valgan al tiempo de la restitución (**art. 908**, inc. 2°); tratándose de obras inmateriales, como la defensa judicial de la finca, se abonan si aprovecharon al reivindicador y se ejecutaron con mediana inteligencia y economía (**art. 908**, inc. 3°).

b) Mejoras útiles: aumentan el valor venal de la cosa sin ser necesarias (**art. 909**, inc. 2°). Al poseedor de buena fe se le reembolsan las que ejecutó estando de buena fe, pudiendo el reivindicante optar entre pagar su valor a la época de la restitución o el mayor valor que la cosa experimentó (**art. 909**). El de mala fe no tiene derecho a que se le restituyan, pero puede llevarse los materiales invertidos si pueden separarse sin detrimento de la cosa y el reivindicante se niega a pagar su valor (**arts. 910 y 912**).

c) Mejoras voluptuarias: consisten solo en objetos de lujo y recreo, como jardines, miradores o fuentes, y generalmente no aumentan el valor venal de la cosa, o lo hacen de forma insignificante (**art. 911**, inc. 2°). El reivindicante no está obligado a pagarlas a ningún poseedor, pero ambos pueden llevarse los materiales si el reivindicante no se allana a pagar su valor (**art. 911**).

7.3. Liquidación de las prestaciones

Efectuadas las compensaciones entre reivindicante y poseedor vencido, una de las partes resultará con un saldo en contra, única suma que en definitiva deberá pagar. Esta liquidación puede ventilarse en el mismo juicio reivindicatorio, en la ejecución del fallo o en un juicio diverso (**art. 173** del Código de Procedimiento Civil).

7.4. Derecho legal de retención

El poseedor vencido tiene un derecho legal de retención mientras el reivindicante no le pague o le asegure el pago de lo que le adeuda a su satisfacción (**art. 914**).

Z. LAS ACCIONES POSESORIAS

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. Concepto

Conforme al **art. 916**, las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos. Estas acciones también se llaman interdictos, y la demanda con que se interponen recibe el nombre específico de querella. El Código las regula en los **arts. 916 a 950**, complementados por los **arts. 549** y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

1.2. Características

i) Son acciones inmuebles (**arts. 916 y 580**), en cuanto resguardan la posesión de bienes de esta clase o de derechos reales constituidos en ellos. Se discute la razón de no extenderlas a los muebles: para algunos, por ser más fácil en ellos la prueba de dominio; para otros, por no ameritar, dada su menor importancia, una protección adicional a la reivindicatoria. No existe, en rigor, una justificación jurídica para la distinción, que atiende a razones históricas.

ii) Son acciones reales, calificación controvertida por la discusión sobre si la posesión es un derecho o un hecho; se les considera generalmente reales por ejercerse contra cualquier persona que turbe o arrebate la posesión, sin que importe un vínculo preestablecido con ella (**art. 927**).

iii) Su ejercicio generalmente deja a salvo el derecho de discutir después el dominio entre las mismas partes (**arts. 563 y 576** del Código de Procedimiento Civil); en la querella de restablecimiento, cuyo carácter de acción posesoria se discute, quedan a salvo incluso las acciones posesorias comunes (**art. 928** del Código Civil y **art. 564** del Código de Procedimiento Civil).

1.3. Diferencias con la acción reivindicatoria

a) La reivindicatoria ampara el dominio, un derecho; las acciones posesorias amparan la posesión, un hecho.

b) El titular de la reivindicatoria es el dueño y, excepcionalmente, el poseedor regular en vías de ganar por prescripción, mediante la acción publiciana. Las acciones posesorias, en cambio, pueden ejercerlas el poseedor y hasta el mero tenedor, en la querella de restablecimiento.

1.4. Requisitos

Quien entabla una acción posesoria debe reunir tres exigencias: ser poseedor, que el objeto sea susceptible de acción posesoria, y que se interponga en tiempo oportuno.

Ser poseedor

No se exige poseedor regular; la protección alcanza tanto a la posesión regular como a la irregular, siempre que reúna ciertas condiciones (**art. 918**): ser tranquila, no interrumpida, y de un año a lo menos, contado en la forma del **art. 920**, siendo posible la agregación de posesiones (**arts. 717, 2500 y 920**). Exigir posesión tranquila niega protección a la violenta; aunque no se exige expresamente que sea pública, con lo que quedaría desprotegida la clandestina, la jurisprudencia lo ha impuesto igualmente.

El **art. 922** consagra la acción en favor del usufructuario, el usuario y el habitador, quienes, aunque son meros tenedores de la cosa, son poseedores de sus respectivos derechos. Se sostiene, además, que entre comuneros no puede entablarse acción posesoria, pues entre ellos, para parte importante de la doctrina y la jurisprudencia, no corre la prescripción.

Objeto susceptible de acción posesoria

Lo son los bienes raíces y los derechos reales constituidos en ellos (**art. 916**), teniendo en cuenta la regla del **art. 922** y la exclusión de las servidumbres discontinuas y de las continuas inaparentes (**arts. 917 y 882**). El derecho real de herencia no puede ampararse por esta vía, por ser una universalidad jurídica, aunque sí puede ampararse un inmueble determinado de la sucesión. Respecto de los bienes nacionales de uso público, como no pueden ganarse por prescripción ni siquiera poseerse, se ha concluido que no procede acción posesoria; pero si un particular adquiere de la autoridad un derecho de uso y goce sobre ellos, puede proteger ese derecho con la acción posesoria correspondiente, según la teoría de los derechos reales administrativos.

Debe interponerse en tiempo oportuno

Al exigirse un año de posesión para tener acción posesoria, se concede el mismo plazo para ejercitarla. La ley distingue, para el cómputo, entre las acciones que buscan conservar y las que buscan recuperar la posesión: las primeras prescriben al cabo de un año contado desde el acto de molestia o embarazo; las segundas, al cabo de un año contado desde que el poseedor anterior perdió la posesión. En caso de posesión violenta, el año se cuenta desde el último acto de violencia; en caso de clandestina, desde que esta cesa. Por tratarse de un plazo especial, esta prescripción no se suspende en favor de las personas del **art. 2509 (art. 2524)**. Cuando hay actos de turbación reiterados de distinta naturaleza, el plazo se cuenta individualmente para cada uno; si son reiterados de una misma turbación, se discute si debe contarse desde el primero o desde el último.

1.5. Prueba

Quien entabla una acción posesoria debe probar, fundamentalmente, que es poseedor tranquilo y no interrumpido por un año a lo menos, y que se le ha turbado o arrebatado la posesión.

Prueba de la posesión

El contenido aparentemente contrapuesto de los **arts. 924 y 925** plantea el problema de cómo se prueba la posesión: mientras el primero dispone que la posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción, el segundo establece que la posesión del suelo se prueba por hechos posesorios positivos. Para algunos autores, como **BAHAMONDES** y **MONTERO**, el art. 924 se aplica a la prueba de todos los derechos reales salvo el dominio, que debe probarse conforme al art. 925 por confundirse, en el lenguaje del Código, con la cosa misma (posición que apoyan preceptos como los **arts. 700, 715 y 916**).

Incluso quienes rechazan esta tesis y prefieren aplicar el art. 924 a los derechos inscritos y el art. 925 a los no inscritos, admiten la prueba de hechos posesorios cuando el poseedor inscrito tiene menos de un año de inscripción, cuando hay dos inscripciones paralelas, cuando los deslindes de la inscripción son inexactos y se discuten, o cuando ninguna de las partes tiene inscrito el predio.

Para otros, que rechazan esa confusión entre el derecho y la cosa y asignan a la inscripción un valor categórico como símbolo de posesión, el art. 924 se refiere a los derechos inscritos y el art. 925 a los no inscritos, es decir, a los que aún no se incorporan al régimen registral, apoyándose en los **arts. 686, 724, 728 y 729**. La jurisprudencia se ha inclinado mayoritariamente por esta segunda alternativa; a ella se agrega la interpretación de **VIAL**, ya tratada a propósito de la prueba de la posesión en general.

Prueba de la turbación o privación de la posesión

Deben probarse también los hechos en que consiste la molestia o privación, y su fecha, para acreditar que la acción se interpuso en tiempo oportuno (**art. 551** del Código de Procedimiento Civil).

2. ANÁLISIS PARTICULAR DE LAS DIVERSAS ACCIONES POSESORIAS

El Código de Procedimiento Civil denomina a los procedimientos de estas acciones "querellas" o "interdictos" (**art. 549**): querella de amparo, querella de restitución, querella de restablecimiento, denuncia de obra nueva, denuncia de obra ruinosa e interdictos especiales. El Código Civil trata las tres primeras en el Título XIII del Libro II, bajo el nombre de "acciones posesorias", y las siguientes en el Título XIV, bajo la denominación genérica de "acciones posesorias especiales".

2.1. Querella de amparo

Tiene por objeto conservar la posesión de bienes raíces y derechos reales constituidos en ellos (**arts. 916 y 921** del Código Civil y **art. 549** del Código de Procedimiento Civil). El querellante aún no ha perdido la posesión; se querella para impedir o poner término a la turbación o embarazo que, de continuar, pudiere concluir en una privación o despojo, pudiendo pedir conjuntamente indemnización del daño causado y seguridades contra quien fundadamente teme (**art. 921**). Turbación, embarazo o molestia es todo acto o hecho voluntario, de buena o mala fe, que sin despojar de la posesión disputa o cuestiona el derecho que pretende ejercer el poseedor; la acción puede intentarse tanto cuando se ha tratado de turbar la posesión como cuando ya se ha turbado en el hecho (**art. 551** N° 2 del Código de Procedimiento Civil), y se ha resuelto que la turbación puede ser de hecho o de derecho.

2.2. Querella de restitución

Tiene por objeto recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos (**arts. 916 y 926** del Código Civil y **art. 549** del Código de Procedimiento Civil). El querellante ha sido despojado de su posesión y pide que le sea restituida, pudiendo pedir además indemnización de los daños causados (**art. 926**); previendo la posibilidad de traspasos, se permite dirigir la acción contra todo el que derive su posesión de quien efectuó el despojo (**art. 927**), sea este total o parcial.

La situación del poseedor inscrito despojado materialmente de su finca presenta la dificultad de determinar si perdió o no la posesión, lo que depende de la concepción que se tenga de la inscripción conservatoria. Si se le concibe como símbolo de posesión absoluto y excluyente, no habría privación ni siquiera turbación, y el afectado debería recurrir a la querella de restablecimiento si el despojo fue violento y actúa dentro de seis meses, a la acción de precario del **art. 2195**, a alguna acción ordinaria innominada en que se discutan dominio y posesión, o a la acción criminal de usurpación; solo habría turbación si un tercero pretende inscribir el mismo inmueble a su nombre, y privación si efectivamente lo inscribe.

Si se concibe la inscripción solo como garantía de una posesión que siempre es tenencia con ánimo de dueño, habría en el caso propuesto turbación de la posesión, fundando la acción de amparo. Y puede entenderse, por último, que incluso en los bienes inscritos la posesión material es un elemento fundamental, de modo que privarla de ella importaría al menos un despojo parcial.

2.3. Querella de restablecimiento

Se concede a quien ha sido despojado violentamente de la posesión o mera tenencia de un inmueble, para que le sea restituido en el estado existente antes del acto de violencia (**arts. 928** del Código Civil y **art. 549** del Código de Procedimiento Civil). Llamada también querella de despojo violento, tiende a evitar que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Se discute su naturaleza, como acción posesoria propiamente tal o como acción personal de carácter delictual, calificación a

la que inducen tanto el hecho de concederse también al mero tenedor como los textos de los **arts. 928** del Código Civil y **564** del Código de Procedimiento Civil. Prescribe en seis meses contados desde el acto de despojo, plazo que no se suspende (**art. 2524**).

2.4. Otras acciones

Las restantes acciones posesorias están reguladas en los **arts. 930 a 950** del Código Civil y **arts. 565 a 583** del Código de Procedimiento Civil: la denuncia de obra nueva, la denuncia de obra ruinosa y otras acciones posesorias especiales, con sus requisitos, plazos de prescripción y la concesión de acción popular en ciertos casos.

Reglas comunes

La jurisprudencia ha resuelto que a estas acciones especiales no se aplica el **art. 918**, que exige un año completo de posesión tranquila, por estar comprometido el interés público. El **art. 946** contempla el caso de pluralidad de querellados o querellantes: habiendo pluralidad de sujetos activos, cada uno puede pedir la prohibición, destrucción o enmienda de la cosa, y cada uno puede pedir indemnización, pero solo por el daño que haya sufrido. Estas acciones, además, no proceden contra el ejercicio de una servidumbre legítimamente constituida (**art. 947**).

Denuncia de obra nueva

Su objeto es que se prohíba toda obra nueva sobre el suelo del que se está en posesión, así como la que embarace el goce de una servidumbre legítimamente constituida sobre el predio sirviente (**arts. 930**, inc. 1º, y **931**, inc. 1º). El **art. 930**, incs. 2º y 3º, se refiere a las obras nuevas no denunciabiles.

Denuncia de obra ruinosa

Tiene por objeto evitar que el mal estado de edificios o construcciones entorpezca el ejercicio de la posesión, siendo denunciabiles las obras ruinosas de los **arts. 932 y 935**. Persigue obtener la destrucción del edificio ruinoso, su reparación si es posible, o, si el daño temido no es grave, que el dueño rinda caución de resarcir todo perjuicio; las reparaciones deben ser hechas por el querellado, y si no las hace, por el querellante en la forma del **art. 933**.

El **art. 934** se pone en el caso de que el edificio se derrumbe: si fue antes de notificarse la demanda, no hay derecho a indemnización, como sanción al querellante negligente, pudiendo accionar no solo el vecino colindante sino cualquier persona (**art. 149** de la Ley General de Urbanismo y Construcciones); si fue después de notificada, se distingue: si se debió a caso fortuito, no hay indemnización, salvo que se pruebe que el mal estado del edificio, y no el caso fortuito, lo habría derribado; si hubo dolo o culpa, se indemniza todo perjuicio a los vecinos. La acción para pedir la destrucción de la obra ruinosa no prescribe mientras haya justo temor de que el edificio pueda de-

rumbarse (**art. 950**); los **arts. 2323** y siguientes regulan, por su parte, la responsabilidad extracontractual por la ruina de un edificio.

Acción popular

La municipalidad y cualquier particular tienen, en favor de los caminos, plazas y demás lugares de uso público, y para la seguridad de quienes transitan por ellos, los derechos que la ley concede a los dueños de heredades o edificios privados (**arts. 948 a 950**). Si a consecuencia de una acción popular debe demolerse o enmendarse una construcción, o resarcirse un daño, se recompensará al actor, a costa del querellado, con una suma entre la décima parte y un tercio del costo de la demolición, enmienda o resarcimiento; si además se castiga el delito o la negligencia con una pena pecuniaria, se adjudicará al actor la mitad de ella.

DATO DE GRADO

La prescripción de las acciones posesorias especiales del **art. 950** distingue tres reglas: las que indemnizan un daño prescriben para siempre en un año completo; las que buscan prevenir un daño no prescriben mientras haya justo motivo de temerlo, como la denuncia de obra ruinosa o la acción del **art. 937** contra obras que corrompan el aire; y la denuncia de obra nueva prescribe en un año, quedando a salvo la acción reivindicatoria, salvo que la obra se haya construido en virtud de una servidumbre legítimamente constituida.